

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ



БИЛТЕН



Ниш, 2017. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

Ниш, 2017. године

БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ПРИРЕЂИВАЧ: Апелациони суд Ниш

За приређивача: Драган Јоцић, председник суда

ИЗДАВАЧ: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

За издавача:

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР: Драган Јоцић, председник суда,
Зоран Поповић, Снежана Милошевић,
Гордана Павловић, Данијела Николић,
Марина Милановић, Ружица Јовановић,
судије Апелационог суда

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

У приређивању Билтена учествовали су судије и судијски помоћници Апелационог суда у Нишу.

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА И ДИЗАЈН: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОМОТА: Наталија Стојановић

ШТАМПАРИЈА: Београф, Нова Пазова

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.11)

БИЛТЕН / Апелациони суд у Нишу ; главни и одговорни уредник Драган Јоцић. - 2010, бр. 1- . - Нови Сад : Paragraf Lex, 2010- (Нова Пазова : Београф). - 21 cm

Два до четири пута годишње.

ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу
COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202.

Садржај

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ	9
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2017. ГОДИНЕ	
Упоредни приказ података за апелационе судове	19

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА23

ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА КАО ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК	25
EXTRAORDINARY LEGAL REMEDY TO REOPEN OF CRIMINAL PROCEEDINGS	46
СТРУЧНИ САВЕТНИК КАО СУБЈЕКТ ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ВЕШТАЧЕЊА -ПРОЦЕСНИ ПОЛОЖАЈ И ДОПРИНОС ВЕШТАЧЕЊУ	47
EXPERT ADVISOR AS THE SUBJECT OF THE PSYCHIATRIC EXPERTISE -PROCEDURAL POSITION AND CONTRIBUTION TO THE EXPERTISE	68
ФЕТУС КАО ОБЈЕКТ РАДЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА НЕСАВЕСНО	69

ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ

И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА.....87

ПРЕГЛЕД УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА	89
-----------------------------------	----

СТАВОВИ

Кривичног одељења Врховног касационог суда око спорних правних питања у вези којих није постигнута сагласност представника апелационих судова (Нови Сад - 31.03.2017. године).....	93
--	----

СТАВОВИ

Кривичног одељења Врховног касационог суда око спорних правних питања у вези којих није постигнута сагласност представника апелационих судова (Петроварадин - 25.03.2016. године, Београд- 30.06.2016. године, Ниш- 30.09.2016. године и Топола, Опленец -02.12.2016. године) Петроварадин - 25.03.2016. године.....	95
--	----

КРИВИЧНО ПРАВО
СУДСКА ПРАКСА101

КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 112

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 128

ГРАЂАНСКО ПРАВО
ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА129

ЗАЈЕДНИЧКА ИМОВИНА СУПРУЖНИКА
О појму и настанку заједничке имовине супружника 131

ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА 150

ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ
И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА163

ОДГОВОРИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА НА ПИТАЊА ПОДРУЧНИХ СУДОВА 174

ГРАЂАНСКО ПРАВО
СУДСКА ПРАКСА181

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 183

СТВАРНО ПРАВО 191

ПОРОДИЧНО ПРАВО 197

НАКНАДА ШТЕТЕ 218

РАДНО ПРАВО 228

ПРОЦЕСНО ПРАВО 245

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ

МОДЕЛ ОКВИРА КОМПЕТЕНЦИЈА - СУДИЈА

I ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ

- Обезбеђује ефикасан тимски рад у пријатној радној атмосфери.
- Ефикасно управља предметима: делотворно утврђује приоритете, избегава непотребна одлагања у поступку
- Ангажује се на професионалном развоју и усавршавању других : активно учествује у развијању компетенција сарадника, помоћника и особља
- Конструктивно сарађује са другима, нарочито са припадницима других професија, подстичући сарадњу и заједнички рад

ЛИЧНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

- Сагледава разноликост друштвеног окружења у којем суд функционише
- Поступа са другима са поштовањем и обзиром, правично и без предрасуда и дискриминације по било ком основу
- Поступа у складу са Етичким кодексом
- Поступа у складу са начелима независности и интегритета
- Показује смиреност и ауторитет у захтевним и непријатним ситуацијама
- Саопштава материјалноправне и процесне информације на одговарајући начин, једноставно и лако разумљивим језиком

ПРАВНОТЕХНИЧКЕ

- Суди ефикасно и делотворно
- Управља поступком на непристрасан и објективан начин
- Предузима неопходне припремне радње у поступку и сагледава различита процесна решења
- У стању је да ради брзо и под притиском
- У стању је да брзо и делотворно усвоји и анализира велики број информација, чињеница и правних аргумената
- Доноси јасно образложене одлук

П ЗНАЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА

- Поседује висок ниво познавања материјалног и процесног права и начелима на којима оно почива
- Стално тежи да ажурира, унапреди и прошири своје знање, у контексту друштвених и економских промена
- Редовно прати развој у судској пракси релевантних судова, као што су Врховни касациони суд, Уставни суд, Европски суд за људска права, Европски суд правде и слично

ПОЗНАВАЊЕ ВАНПРАВНИХ ОБЛАСТИ

- Поседује способност да делотворно користи различите изворе информација, укључујући и електронске базе података
- Користи информационе и комуникационе технологије у свакодневном раду
- Активно тежи стицању, развијању и унапређењу знања из ванправних области као што су медицина, економија, форензика, информационо-комуникационе технологије и слично

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Служба председника Апелационог суда у Нишу сачинила је пречишћени текст распореда послова судија и судијских помоћника за 2017. годину.

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

СУ I -2-22/16

13.12.2016. године

Н и ш

ИЗВОД ИЗ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2017.ГОДИНУ

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. ст. 1. Закона о уређењу судова и члана 46 - 48 Судског пословника, донео је Годишњи распоред послова за 2017. годину.

I СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи **Драган Јоцић**, председник суда.

За заменик председника суда одређују се судија: **Снежана Милошевић**

Председника суда замењиваће судија Снежана Милошевић, којој се повећавају и посебне обавезе за информисање и контакте са јавношћу и медијима (портпарол).

За руководиоца службе председника суда одређује се Јелена Јанчетовић, секретар суда.

У њеном одсуству замењиваће је Сања Антић Милановић, судијски помоћник.

II СУДСКА ОДЕЉЕЊА

У суду постоје следећа одељења:

Кривично одељење

Грађанско одељење

Одељење за радне спорове

Одељење судске праксе

ПРЕДСЕДНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА СУ:

- 1. У Кривичном одељењу:** председник одељења је судија Зоран Поповић, а његов заменик судија Слободан Стојилковић.
- 2. У Грађанском одељењу:** председник одељења је судија Данијела Николић.
- 3. У Одељењу радних спорова:** председник одељења је судија Ивана Рађеновић, а њен заменик судија Тања Ристић.

За уређивање Веб сајта суда задужује се судија Соња Симоновић Стојановић.

За праћење и евиденцију одлука Европског суда за људска права, Уставног суда, стручних реферата и судске праксе других судова у штампаним публикацијама које суд прима у недовољном броју примерака за све судије задужују се судије Весна Стевановић, Јасмина Јововић, Добрила Здравковић и Тања Ристић.

III КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I - ВЕЋЕ

1. Љиљана Миљковић, председник већа
 2. Весна Стевановић, члан
- Судијски помоћници: Никола Насковић и Ивана Лазовић.

II - ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан
- Судијски помоћници: Марија Петровић и Милан Жижић.

III - ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Ранко Банковић, члан
 3. Јасмина Јововић, члан
- Судијски помоћници: Иван Калезић и Миљана Радовановић

IV - ВЕЋЕ

1. Гордана Павловић, председник већа,
 2. Горана Митић, члан
 3. Иван Булатовић, члан
- Судијски помоћници: Милица Алексић и Миодраг Перуновић

V - ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Саша Бошковић, члан
- Судијски помоћници: Зоран Ђурђевић и Јелена Додић

III-a

Одређују се већа која ће поступати по жалбама изјављеним против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима).

I- Веће

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Горана Митић, члан
3. Мирјана Ђорђевић, члан

II- Веће

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Драгана Живадиновић, члан
3. Гордана Павловић, члан

III-6

За поступање у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица одређују се III и V веће.

За предмете у којима већа поступају у петорном саставу, веће које је задужено предметима ће се допунити члановима првог наредног већа, до потребног броја.

Председника већа замењује први члан већа.

Дежурна већа за време годишњих одмора у кривичном одељењу су:

- у јулу месецу **IV** веће,
- у августу **V** веће.

Одређује се и посебно веће за поступање искључиво у старим предметима према Програму решавања старих предмета овог суда.

1. Драган Јоцић, председник већа
2. Снежана Милошевић, члан
3. Слободан Стојилковић, члан

4. Данијела Николић, члан

5. Ивана Рађеновић, члан

с тим што ће члана овог већа чинити и судија који реферише старе предмете. Ово веће се не задужује новим предметима.

IV

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I - ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа

2. Невена Благојевић, члан

3. Оливера Јовановић, члан

Судијски помоћници: Милена Миловановић и Јасмина Кузмановић

II - ВЕЋЕ

1. Данијела Николић, председник већа

2. Добрила Здравковић, члан

3. Снежана Лазић, члан

4. Зоран Стаменковић, члан

Судијски помоћници: Бети Лазаревић, Сања Антић Милановић и Марија Фехир

III - ВЕЋЕ

1. Марина Милановић, председник већа

2. Стојанка Вујошевић, члан

3. Никола Пржић, члан

Судијски помоћници: Сандра Стефановић, Слађана Љубеновић и Тијана Митровић.

IV-ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић Стојановић, председник већа

2. Зорица Стошић, члан

3. Јадранка Митровски, члан
Судијски помоћници: Мирјана Милутиновић, Иван Васиљковић,
Оливера Алексић Цветковић и Ивана Стевановић

Председника већа замењује први члан већа.

Све судије Грађанског одељења поступаће у предметима породичних и статусних спорова с обзиром да све судије овог одељења имају потребне сертификате за поступање у овим предметима.

V

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I - ВЕЋЕ

1. Јелена Јовановић, председник већа
2. Ружица Јовановић, члан
3. Зорица Цветковић, члан
Судијски помоћници: Слађанка Тасић, Наташа Митковић и Горан Драгомански.

II - ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа
2. Љубиша Милојевић, члан
3. Данијела Божовић, члан
Судијски помоћници: Ивана Д. Младеновић и Дамјан Мирчић.

III - ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан
3. Лидија Стошић, члан
Судијски помоћници: Весна Јовановић Јанковић, Драгана Вељковић, Ивана Г. Младеновић.
Председника већа замењује први члан већа.

V-a

У предметима рехабилитације поступаће судије :

1. Иван Булатовић
2. Саша Бошковић
3. Соња Симоновић Стојановић
4. Никола Пржић
5. Зорица Стошић

У саставу овог већа, без обзира ко је судија известилац, члан већа биће судија који поступа у Кривичном одељењу.

VI

**ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВИМА
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ**

На основу чл. 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, за поступање у предметима заштитите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

Марина Милановић
Стојанка Вујошевић
Никола Пржић

У предметима из области Радних спорова

Јелена Јовановић
Ружица Јовановић
Зорица Цветковић

У предметима из области Кривичне материје

Снежана Милошевић
Слободан Стојилковић
Дијана Јанковић

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списка предмета у којем је ово право повређено.

Поступци у предметима по приговорима и по жалбама се међусобно изједначавају приликом завођења и расподеле предмета.

Судијама које буду задужене предметима ове материје, рачунаће се као редован прилив предмета у материјама у којима поступају.

VII

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

I- ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан

II-ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа
 2. Данијела Николић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан
- Председника већа замењује први члан већа.

За поступање у предметима унутрашњег узбуњивања поступаће судија Добрила Здравковић.

Предмети примљени у овој материји рачунаће се судијама који су њима задужени у редован прилив предмета.

VIII

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

1. **Драган Јоцић**, председник суда, руководиоца судске праксе суда.
2. **Зоран Поповић**, његов заменик
3. **Снежана Милошевић**, заменик председника суда
4. **Данијела Николић**, председник Грађанског одељења
5. **Ружица Јовановић**, руководиоца судске праксе у Одељењу радних спорова
6. **Гордана Павловић**, руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу
7. **Марина Милановић**, руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу.
8. Судијски помоћник, **Милан Ђорђевић** у Кривичном одељењу, кога мења судијски помоћник **Миљана Радовановић**.
9. Судијски помоћници **Златица Петровић** и **Миљана Поповић Ђурић** у Грађанском одељењу.
10. Судијски помоћник **Ивана Ђурђић - Митровић** у Одељењу радних спорова.

Редакцију Билтена судске праксе суда чине судије овог одељења с тим да је главни и одговорни уредник Билтена председник суда Драган Јоцић, а његов заменик судија Зоран Поповић.

IX

Непотпуна већа биће допуњена, до пуног састава, судијама других већа из исте материје према месечном распореду који сачињава Судска управа и благовремено уручује судијама на које се допуна већа односи.

Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у целини и појединачно судија и судијских помоћни

Шестомесечни извештај 2017. године

Упоредни приказ података за апелационе судове

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БРСУДИЛА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	14	167	761	928	734	8.74	194	23
НОВИ САД	13	160	731	891	742	9.51	149	6
КРАГУЈЕВАЦ	15	95	850	945	797	8.86	148	5
БЕОГРАД	27	198	771	969	726	4.48	243	20

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БРСУДИЛА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	14	3	351	354	342	4.07	12	0
НОВИ САД	13	17	735	752	727	9.32	25	0
КРАГУЈЕВАЦ	15		410	410	404	4.49	6	0
БЕОГРАД	27	23	979	1.002	974	6.01	28	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	11	638	3.495	4.133	2.945	44.62	1.188	1
НОВИ САД	24	1.018	2.190	3.208	2.390	16.6	818	18
КРАГУЈЕВАЦ	16	1.904	2.472	4.376	2.354	24.52	2.022	193
БЕОГРАД	38	3.971	3.965	7.936	4.339	19.03	3.597	885

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	7	874	2.597	3.471	1.939	46.17	1.532	131
НОВИ САД	10	390	1.720	2.110	1.795	29.92	315	1
КРАГУЈЕВАЦ	12	1.546	2.127	3.673	2.038	28.31	1.635	47
БЕОГРАД	16	2.766	2.765	5.531	2.496	26.00	3.035	826

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ2”

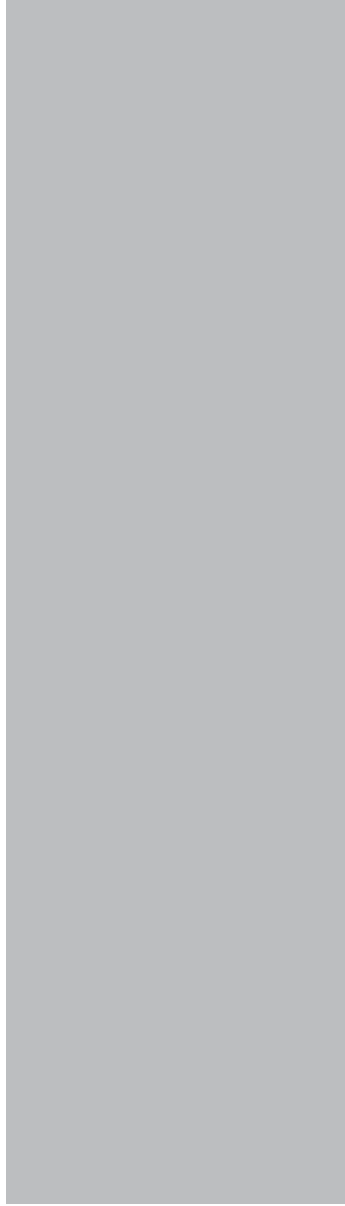
АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	11	18	291	309	261	3.95	48	0
НОВИ САД	13	41	338	379	342	4.38	37	0
КРАГУЈЕВАЦ	16	22	340	362	318	3.31	44	0
БЕОГРАД	38	77	432	509	428	1.88	81	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У СУДУ	РЕ- ШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМ ЉЕНО	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕ- ШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА	просечно предмета остало у раду по судији	старих према датуму пријема у суд просечно по судији
НИШ	32	1.713	8.367	10.070	7.013	36.53	3.057	156	95.53	4.87
НОВИ САД	47	1.691	6.381	8.072	6.310	23.68	1.395	25	29.68	0.53
КРАГУЈЕВАЦ	44	3.674	6.881	10.555	6.547	24.8	4.008	247	91.09	5.61
БЕОГРАД	82	7.649	10.385	18.034	10.598	21.54	7.438	1.770	90.70	21.58

АПЕЛАЦИОНИ СУД	процент решених предмета у суду	саклапавање прилива	АЖУРНОСТ	УКУПАН КВАЛИТЕТ
НИШ	69,64	83.81738	2.19	99.62
НОВИ САД	82,72	98.88732	1.31	99.16
КРАГУЈЕВАЦ	62,03	95.14605	3.49	99.24
БЕОГРАД	58,76	102.051	4.30	98.88

КРИВИЧНО ПРАВО
ТЕОРИЈСКО ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА



Драган Јоцић

Судија Врховног касационог суда
и Председник Апелационог суда у Нишу

Др Дијана Јанковић,

Судија Апелационог суда у Нишу

ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА КАО ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК

Апстракт: У раду се разматра понављање кривичног поступка и то у погледу услова, чињеница и околности који су подобни да се на основу њих дозволи понављање правноснажно окончаног поступка. Понављање кривичног поступка, као ванредни правни лек, се разликује од поступка по редовним правним лековима по томе што се за разлику од жалбеног поступка у овом поступку разматра правноснажна пресуда. Опште је правило да се понављање кривичног поступка може дозволити само у корист окривљеног, што је засновано на принципу забране *“reformatio in peius”*. Захтев за понављање кривичног поступка може поднети окривљени, његов бранилац или законом одређени круг лица, а може и јавни тужилац али само у корист окривљеног. Прва фаза у поступању по захтеву за понављање кривичног поступка је разматрање да ли су испуњене формалне претпоставке за усвајање захтева, уколико захтев буде одбачен не могу се предузимати даљи кораци у том правцу. Такође је у раду указано на судску праксу домаћих судова и извршен је критички осврт на поједине законске одредбе.

Кључне речи: ванредни правни лек, понављање кривичног поступка, кривични поступак.¹

¹ Рад је изложен на Регионалној конференцији у Београду у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу, која је одржана 10. јуна 2016. године на тему „Правни лекови у кривичном поступку“ и публикован у ширем обиму у Зборнику радова изложених на Конференцији.

Уводна разматрања

Опсежна реформа домаћег кривичнопроцесног законодавства окончана је доношењем новог Законика о кривичном поступку (ЗКП) (“Службени гласник РС”, бр.72/11, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) - у даљем тексту Законик., који је ступио на снагу у октобру 2013. године, а који се до тада примењивао само у поступцима који су се односили на ратне злочине, организовани криминал и високотехнолошки криминал. Тим је законом створена правна основа и нормативни оквир за нови кривични поступак у Републици Србији, битно другачији од модела уређеног Закоником о кривичном поступку из 2001. године са изменама и допунама (“Службени лист СРЈ”, бр.70/01, 68/02 и “Службени гласник РС”, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 20/09 - др. закон и 72/09, 76/10) - у даљем тексту ЗКП/2001), који је до тада био у примени.

Савремено кривично процесно право се иначе карактерише постепеним приближавањем елемената из два велика кривичнопроцесна система - континентално-европског и англосаксонског, што је последица како општих глобалистичких тенденција, тако и свести о потреби уграђивања у поједине правне системе оних елемената који су потенцијално ефикасни и корисни, независно од тога да ли потичу из једног или другог великог кривичнопроцесног система. У тражењу оптималних решења, у последњих неколико деценија јасно су изражена два настојања. Прво, које иде за приближавањем националних система и друго, које усмерава ка њиховом међусобном усклађивању и превазилажењу супротности. Оваква конвергенција, иако свакако оправдана, ипак има своје границе, које се у битној мери морају заснивати и на присутној правној традицији одређене државе.²

Сваки кривични поступак одсликава системе репресивних мера формалне друштвене реакције у борби против криминалитета. Кривично процесно право, којим се тај поступак уређује, изразито је конзервативна грана права, те јој нису својствене честе промене. Међутим, како је ступањем на снагу новог Законика о кривичном поступку у великој мери промењен традиционални кривичнопроцесни систем, то су се у судској пракси у скоро свим областима кривичнопроцесног права, отворила бројна питања. Тежиште реформе домаћег кривичнопроцесног права било је на увођењу јавнотужилачке ис-

² Милан Шкулић, „Доминантне карактеристике основних великих кривичнопроцесних система и њихов утицај на реформу српског кривичног поступка“, *Crimen (IV)*, Правни факултет, Универзитет у Београду, 176-234, 2013, стр.178.

траге и адверзијално уређење главног претреса, иако су значајне промене обухватиле и поступак по правним лековима, укључујући и поступак по ванредним правним лековима.

Проблематика правних лекова у кривичном поступку сложено је правно подручје у теорији кривичнопроцесног права о чему говоре бројни разлози. Пре свега, право на правни лек је истовремено уставно, законско али и основно људско право окривљеног. Наиме легитимно је право окривљеног да захтева преиспитивање неправилне или незаконите судске одлуке којом се угрожавају или повређују његова основна људска права и слободе, те с тим у вези може тражити уклањање оних штетних последица из пресуде које на било који начин погоршавају његов правни положај. Према једној од дефиниција, правни лекови су законом уређене радње странака и других овлашћених субјеката у кривичном поступку, којима побијају неправилну и незакониту судску одлуку и истовремено захтевају да суд више инстанце у прописаном поступку исправи постојеће неправилности и незаконитости, тако што ће побијану одлуку укинути или преиначити новом одлуком.

Ванредни правни лекови се заснивају на истим основама на којима се заснивају и редовни правни лекови, али ипак не на свим већ само на неким тачно законом прописаним и могу се користити под одређеним условима у погледу субјекта и других питања. Они нису дозвољени за сваку повреду закона, сваку нетачност у утврђивању чињеничног стања, односно сваку неправилно изречену казну, већ само за оне одређеног значаја, стављајући у осталим случајевима стабилност стања утврђеног правноснажном пресудом изнад правилности одлучивања. У том контексту посебан значај има ванредни правни лек понављање кривичног поступка и то у погледу услова, чињеница и околности који су подобни да се на основу њих дозволи понављање правноснажно окончаног поступка. Од свих ванредних правних лекова једино се понављањем поступка може исправити чињенична основица пресуде. Понављање кривичног поступка може бити само у корист окривљеног, што је засновано на принципу забране *“reformatio in peius”*, и може бити само изузетно дозвољено под законом строго прописаним условима, а што је последица примене начела *ne bis in idem* тј. забране поновног суђења у правноснажној пресуђеној ствари (члан 4. став 1 ЗКП).

Тренутно су, према Законику о кривичном поступку у примени два ванредна правна лека: понављање кривичног поступка и захтев за заштиту законитости. До 2009. године постојала су још два ванредна правна лека: захтев

окривљеног за испитивање законитости правноснажне пресуде и захтев за ванредно ублажавање казне. Први је у садашњем Законнику о кривичном поступку, спојен са захтевом за заштиту законитости (члан 485. став 4. ЗКП), а други са понављањем поступка (члан 473. став. 1. тачка 6 ЗКП), оба у ограниченом обиму. Понављање кривичног поступка као правни лек у целини има својих варијација, што доводи до више врста ове установе, о чему се изјашњава како законодавац приликом законског регулисања тако и кривичноправна теорија. Најчешћа теоријска и практична подела је на право и неправом понављање кривичног поступка.

Право понављање кривичног поступка се заснива на томе да је кривична ствар окончана правноснажном судском одлуком у меритуму и да су се након њене правноснажности појавиле нове чињенице и нови докази, који сами за себе или у склопу са ранијим доказима указују да је утврђено чињенично стање погрешно и да је потребно у новом поступку поново оценити доказе ради правилног утврђивања чињеничног стања.

Осим правог понављања кривичног поступка (члан 473. ЗКП) као ванредног правног лека, постоје и случајеви слични понављању кривичног поступка који по својој правној природи не спадају у ванредне правне лекове него им само личе, јер као и правни лекови, омогућавају промену правноснажне пресуде. То су случајеви кад се у пресуди уопште не показује погрешно утврђено чињенично стање већ се ради: 1) о процесној техници усклађивања више пресуда изречених према истом окривљеном, са одредбама за изрицање јединствене казне за кривична дела у стицају (члан 552-556. ЗКП) и 2) о случајевима настављања поступка, у свим фазама чим престану узроци који су изазвали обуставу (члан 417. ЗКП). У овим случајевима суд не утврђује ново чињенично стање, већ се одређеним процесним техникама усклађују процесне форме које већ почивају на утврђеној чињеничној основици или се наставља поступак коме неке сметње нису дозвољавале да се оконча, без обзира на чињеничну основицу. Зато се и каже да то није право понављање кривичног поступка већ случајеви слични понављању поступка.

Карактеристично је, да је новом законском регулативом први пут у домаћем кривичнопроцесном праву раздвојено тзв. право од неправог понављања поступка и као ванредни правни лек задржано је само право понављање кривичног поступка, у коме, ако захтев буде усвојен, следи главни претрес. Одредбе досадашњег неправог понављања кривичног поступка су, према новом Законнику о кривичном поступку из одељка о ванредним прав-

ним лековима, премештене у главу XXIII “Поступци за преиначење правноснажне пресуде”, тако да је законодавац и формално оваквом систематиком указао да се у случају неправог понављања кривичног поступка, не ради о ванредном правном леку, већ о посебном процесном поступању којим се преиначује правноснажна пресуда под законом прописаним условима. Поред наведеног, као посебан облик понављања кривичног поступка издваја се и понављање у случају када је поступак окончан осуђујућом пресудом донетом у одсуству оптуженог, а настане могућност да се суди у његовом присуству (чл. 479 ЗКП). У том случају се, такође по поднетом захтеву за понављање кривичног поступка, суди поново, да би се доследним спровођењем начела усмености, непосредности и контрадикторности, расветлило чињенично стање и дала могућност оптуженом да пред судом изнесе своју одбрану.

Захтев за понављање кривичног поступка, као сви ванредни правни лекови због тога што њихова могућност коришћења зависи од околности, временски неодређених и независних од воље странака, није везан за рок (осим захтева из члана 473 став 1 тачка 7 ЗКП - ако се изнесу нове чињенице или поднесу нови докази да окривљеном није уредно достављен позив за претрес који је одржан у његовом одсуству - који у ствари и није право понављање поступка). Циљ захтева за понављање кривичног поступка је да правноснажно осуђено лице буде ослобођено или осуђено по блажем закону, при чему је нормативна основа један од веома важних фактора ефикасности кривичног поступка као целине.

Најновије законске одредбе су у знатној мери измениле систематику ванредних правних лекова и унеле нека потпуно нова законска решења, те су се у вези њихове примене, отворила нова питања у кривичноправној теорији и судској пракси, на која ће бити указано у даљем току излагања.

Формалне претпоставке за понављање кривичног поступка

Када су у питању формалне претпоставке за понављање кривичног поступка, потребно је пре свега да постоји правноснажна пресуда и да је поднет захтев овлашћеног лица. Процесна иницијатива, која је усмерена на поступање суда по захтеву за понављање поступка, не може у начелу потицати ни од суда који је донео одлуку, нити од тела које за то нема ту надлежност. Процедура понављања поступка се дели на два дела: поступак о дозволи понављања и само понављање. Поступак о дозволи понављања тече следећим редом: оцена да ли према наводима самог захтева постоје услови за понављање, и одба-

цивање захтева ако ти услови не постоје и одлучивање суда на основу приложеног новог доказног материјала. Постојање формалних претпоставки за понављање кривичног поступка, суд проверава у фази испитивања захтева (члан 475. тачка 1. - 6 ЗКП), где се поред наведене две основне претпоставке испитује и постојање других формалних услова, без чијег се постојања суд неће упустити у мериторно одлучивање о постављеном захтеву.

Захтев за понављање поступка одбацује се решењем у случајевима када: захтев није поднео осуђени или његов бранилац у његово име или јавни тужилац (или лица наведена у члану 433. став 2 ЗКП (У корист оптуженог жалбу могу изјавити и његов брачни друг, лице са којим живи у ванбрачној или другој трајној заједници живота, сродници по крви у правој линији, законски заступник, усвојитељ, усвојеник, брат, сестра и хранитељ... - члан 433. став 2 ЗКП) или када у односу на истог осуђеног не постоји једна или више правноснажних осуђујућих пресуда на казну чија се измена тражи, или када захтев не садржи све оно што је потребно да би се по њему могло поступити (Саветовање кривичних одељења Савезног суда, Врховних судова и Врховног војног суда од 23.11.1990. године), као и из осталих разлога наведених у члану 475. ЗКП. Разлози за одбацивање захтева за понављање поступка су процесне природе. Решењем о одбацивању захтева за понављање кривичног поступка решава се о самом праву странке да тражи измену правноснажне пресуде, али се не решава о пресуђеном праву. Приватни тужилац и оштећени као тужилац, иако имају положај странке у кривичном поступку, не могу бити подносиоци захтева за понављање кривичног поступка, јер им недостаје правни интерес да улажу правне лекове у корист осуђеног, док јавни тужилац такав интерес има.

Лица овлашћена на подношење захтева за понављање кривичног поступка, њиме се могу користити само у оквиру свог непосредног правног интереса. Правни интерес увек постоји ако осуђени у случају да његов захтев буде усвојен, може очекивати побољшање свог правног положаја, односно постизање одређене правне користи у вези са конкретним случајем. Природа правног интереса проистиче из природе непосредне правне погођености осуђеног.

Поднети захтев за понављање мора испуњавати и одређене услове у погледу садржаја (члан 472. ЗКП), те је потребно да лице које тражи понављање кривичног поступка, уз податке формалног карактера, потребне за идентификацију случаја (име или назив подносиоца, назив суда, ознака предмета, подаци о правноснажној пресуди) наведе и којим доказима поткрепљује чињенице на које се позива. Међутим, према већ устаљеној судској

пракси, захтев странке, неће бити одмах одбачен само због тога што не испуњава прописану садржинску форму или због тога што странка није приложила доказе, а још мање због тога што докази нису у форми прописаној кривичним поступком за прибављање те врсте доказа. Дакле, ако захтев не садржи основ по којем се тражи понављање поступка, него само предлоге за саслушање нових сведока и тврдње да је пресуда заснована на лажним исказима и неоввереним копијама исправа, суд неће такав захтев одмах одбацили, него је дужан да најпре позове подносиоца да захтев допуни и означи законски основ (Решење Апелационог суда у Београду, Кж2. бр. 933/11 од 05.04. 2011. године³). Захтев се одбацује ако по наредби суда у остављеном року није допуњен у смислу члана 472. став 1. и 2. ЗКП.

Кривични поступак се може поновити само уколико је завршен правноснажном пресудом. Како је понављање кривичног поступка могуће само у корист окривљеног, то се оно не односи на све врсте пресуда, већ само на пресуде којима се оптужени оглашава кривим (не и на ослобађајуће пресуде, пресуде којима се оптужба одбија и решења о одбачају оптужбе када се не тражи понављање већ настављање поступка). Понављање поступка је могуће и против оних пресуда против којих редовни правни лекови нису дозвољени, односно против којих редовни правни лекови, иако дозвољени нису били коришћени. Захтев за понављање кривичног поступка је могућ и када је осуда брисана по члану 97 КЗ, или ако је изречен престанак правних последица осуде по члану 96. став 2 КЗ, јер после ових мера лице се и даље сматра осуђиваним, а подаци о осуди могу се и после тога давати одређеним државним органима. Осим, тога, одређене обавезе из брисане осуде и даље терете окривљеног (намирење трошкова и имовинскоправних захтева) без обзира на брисање осуде и правних последица.

Испитивање формалних претпоставки за понављање кривичног поступка, а што се односи уопште и на упуштање суда у поступање у свакој од фаза кривичног поступка, је у уској вези са испуњењем захтева за ефикасношћу кривичног поступка. Захтев за ефикасношћу кривичног поступка је, слободно се може рећи, постао и једна од важнијих особености савремене науке кривичнопроцесног права³ а тиме и савременог кривичнопроцесног законодавства, при чему наведене законске одредбе и основна структура

3 Claus Roxin, *Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band 1, Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4. Auflage, München 2006, s. 256.

понављања кривичног поступка у фази испитивања формалне исправности поднетог захтева, нису претрпеле веће измене у односу на раније законске одредбе о понављању кривичног поступка. Значајно са аспекта судске праксе је да се практична реализација принципа ефикасности усагласи са још једним неизоставним захтевом, а то је да ефикасност кривичног поступка не сме ићи на штету законитости решења конкретне кривичне ствари и угрожавања загарантованих права и слобода учесника кривичног поступка. Сагледавајући целину кривичног поступка а у оквиру њега и понављање кривичног поступка, као факултативни сегмент који зависи од диспозиције странка, под ефикасношћу кривичног поступка се подразумева како његова квалитативна компонента (законитост вођења кривичног поступка и доношење правилне и законите судске одлуке) тако и његова квантитативна компонента (временски размак од покретања кривичног поступка па до његовог окончања и то како у фази главног претреса тако и у фази редовних и ванредних правних лекова).

Понављање кривичног поступка и “решење које одговара пресуди”

За разлику од ранијег Законика о кривичном поступку (ЗКП/2001), важећи Законик прописује да се кривични поступак може поновити само ако је завршен правноснажном пресудом (члан 470. ЗКП), не и ако је довршен правноснажним решењем. Међутим, Законик о кривичном поступку на многим местима говори о “решењу које одговара пресуди” (члан 16. став 4 и 5, члан 226. тачка 1, члан 227. став 2 и 3, и др.), односно ради се о решењу којим се правноснажно окончава кривични поступак а није донето у форми пресуде.

Такво решење у ужем смислу суд доноси у поступку за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или обавезног психијатријског лечења на слободи, када утврди да је окривљени учинио противправно дело које је у закону одређено као кривично дело и да је у време извршења дела био неурачунљив (члан 526. став 4. ЗКП). Решењем које одговара пресуди по Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (“Службени гласник РС”, бр. 85/05 - у даљем тексту ЗМУ) изриче се васпитна мера и обуставља поступак, у случају када се по Законику о кривичном поступку доноси ослобађајућа или одбијајућа пресуда, или када суд нађе да малолетнику није целисходно изрећи ни казну ни васпитну меру (члан 78. ЗМ). У ширем смислу то се односи и на друге одлуке којима суд решава кривичноправни случај,

на начин који подлеже начелу *ne bis in idem*. На пример, у случају обуставе поступка услед смрти окривљеног (чл. 20. ЗКП), затим када веће из чл. 21. ст. 4. ЗКП испитујући оптужницу одлучи решењем да нема места оптужби и да се кривични поступак обуставља - чл. 338. ЗКП, или када председник већа из законом прописаних разлога решењем обустави кривични поступак (чл. 352. ЗКП) односно у скраћеном поступку судија решењем одбије оптужени предлог, односно приватну тужбу ако утврди да нема места оптужби због постојања разлога из чл. 338. ст. 1. ЗКП (чл. 503. ЗКП).

Са аспекта понављања кривичног поступка значајно је питање, да ли се с обзиром на важећу законску регулативу, када је донето решење којим се изриче мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или обавезног психијатријског лечења на слободи, може дозволити понављање кривичног поступка, имајући у виду да је судска одлука донета у форми решења. Можемо рећи да је досадашња судска пракса става да је могуће понављање кривичног поступка завршеног решењем о примени мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или обавезног психијатријског лечења на слободи, јер се ова решења с обзиром на члан 526. ст. 4. ЗКП, суштински појављују као мериторна одлука у вези са извршеним кривичним делом, због чега се у погледу члана 470. ЗКП и члана 473. ЗКП, морају изједначити са пресудом.

Овакво становиште, може подржати и одредба члана 2. став 2 ЗКП, према којој појам “осуђеног” обухвата лице које је правноснажном пресудом оглашено кривим али исто тако и лице коме је изречена мера безбедности обавезног лечења и чувања у здравственој установи, односно лице за које је правноснажном судском одлуком суда утврђено да је учинилац противправног дела одређеног као у закону кривично дело.

Такође је и став судске праксе да је положај окривљеног у поступку за изрицање мере безбедности као самосталне кривичне санкције, изједначен са положајем окривљеног у редовног кривичном поступку (Одлука Савезног суда, Кзс. 55/78 од 29.09.1978. године).

Поред тога, напоменули бисмо да је и ранији Законик о кривичном поступку само у општој одредби (члан 404. ЗКП /2001.) прописивао да се може поновити кривични поступак завршен правноснажном пресудом и правноснажним решењем, а да је одредба чл. 407 ЗКП/2001. године, говорила само о понављању кривичног поступка завршеног правноснажном пресудом, али да је и тада судска пракса била тако рећи јединственог става да се може понови-

ти кривични поступак који је завршен решењем о примени мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или обавезног психијатријског лечења на слободи, управо из разлога које смо напред навели (Пресуда Врховног суда Србије Кж. бр. 673/67 од 08.09.1967. године).

Према Закључку председника кривичних одељења Савезног суда и Врховних судова од 05.03.1084. године: “Кривични поступак који је завршен решењем о изрицању мере безбедности из члана 63. КЗ СФРЈ (сада чл. 81. КЗ) може се поновити сходном применом одредаба које се односе на понављање поступка, на основу члана 508 ЗКП (Законик о кривичном поступку, “Службени лист СФРЈ” број 4/77, у даљем тексту ЗКП/1977). При томе, скоро исте садржине као чл. 508 ЗКП/1977 је и члан 520. ЗКП/2001 (Члан 520. ЗКП/2001 и члан 508. ЗКП/1977 су исте садржине и гласе: Ако у одредбама ове главе није шта друго предвиђено у погледу поступка за примену мера безбедности или одузимање исте користи, примењиваће се сходно остале одредбе овог законика”), као и члан 521. ЗКП који је сада у примени, који сви чланови упућују на сходну примену осталих одредаба ЗКП, у поступцима за примену мера безбедности, уколико није нешто посебно прописано.

Резимирајући наведено, сматрамо да не би било оправдано не разматрати захтев за понављање кривичног поступка и исти одбацити, само због тога што се формално ради о “решењу које одговара пресуди” а не о пресуди. Међутим, важно је при томе увек имати у виду да се кривични поступак може поновити само у корист окривљеног, те и са те стране сагледати природу и садржину судске одлуке и поднетог захтева, приликом доношења одлуке о захтеву за понављање кривичног поступка.

Нове чињенице и нови докази као основ за понављање кривичног поступка

Да би могли да представљају основ за право понављање кривичног поступка, нове чињенице и докази морају бити одређеног квалитета. Квалитет нових чињеница и доказа одређује се законом. Ово је разумљиво када се има у виду правна природа установе понављања кривичног поступка и њен циљ, јер би се у супротном дешавало да се једна правноснажна пресуда напада овим ванредним правним леком по било ком основу и било којим чињеницама и доказима. То би значило да се једна кривична ствар не би могла никада окончати. Оваква ситуација би утицала, с једне стране на ауторитет суда као

установе, а с друге би угрожавала личну безбедност грађана. Такође, чињенице чији ће се квалитет испитивати по захтеву за понављање кривичног поступка, зависе од иницијативе странка. Дакле, испитивање се само чињенице које су предложене и наведене у захтеву за понављање кривичног поступка. Ако такве иницијативе нема, неће се све чињенице и утврђено чињенично стање испитивати по службеној дужности.

Захтев за понављање кривичног поступка се не може заснивати на томе да је суд погрешно применио закон (повреде закона у правноснажној пресуди исправљају се захтевом за заштиту законитости), нити да је суд у ранијем поступку погрешно оценио доказе: понављање се не може тражити ради поновне оцене старог доказног материјала, јер би нова оцена старог доказног материјала, била у ствари поступање по редовном правном леку. Дакле, грешка у ранијем поступку чије се понављање тражи, не сме бити у погрешној оцени доказног материјала, већ у погрешном материјалу који је суд ценио што показује новоприбављени материјал.

Имајући у виду све ове околности Законик о кривичном поступку је стриктно одредио квалитет нових чињеница и доказа који су подобни да послуже као основ за понављање кривичног поступка окончаног правноснажном пресудом. Законодавац је то учинио тако што је члану 473. став 1. тачка 1-7. ЗКП лимитативно прописао основе за право понављање кривичног поступка окончаног правноснажном пресудом, без могућности било каквог проширивања. У судској пракси је често танка линија разграничења чињеница и доказа који очигледно нису подобни да се на основу њих дозволи понављање кривичног поступка, а што представља основ за одбацивање захтева из формалних разлога, сходно одредби члана 475. тач 6. ЗКП, од чињеница и доказа који су подобни да буду предмет разматрања суда по поднетом захтеву, али за које се након тога процени да нису таквог квалитета да би се на основу њих дозволило понављање кривичног поступка, односно да нису испуњени услови за понављање кривичног поступка, те захтев буде одбијен.

О томе постоји веома разнолика судска пракса. При оцени да ли су чињенице и докази очигледно неподобни да се на основу њих дозволи понављање, суд у тој фази оцењује само да ли су поднети докази такви да могу довести у сумњу правилност чињеничног стања утврђеног у ранијем поступку, односно веродостојност тамо изведених доказа, те захтев може одбацити само ако нађе да поднети докази очигледно нису подобни за то, али не може улазити

у коначну оцену њихове веродостојности (Пресуда Врховног суда Србије, Кж.бр.833/66. од 02.06.1966. године).

Међутим у случају да подносилац захтева указује да би се новим доказима потврдила истинитост нпр. раније одбране окривљеног, да није извршио кривично дело, онда се такав захтев не може одбацити са образложењем да су докази очигледно неподобни да се на основу њих дозволи понављање кривичног поступка.

Тако, када осуђени за дрску крађу, уз захтев за понављање поступка, поднесе оверену изјаву лица у којој признаје да је он, а не осуђени извршио крађу за коју је овај осуђен, суд ће тек након спроведених провера (члан 476. ЗКП) донети одлуку. Према заузетом ставу Врховног суда Србије (Пресуда Врховног суда Србије КжП.бр. 1745/04 од 23.11.2004. године¹ у том случају се ради о новом доказу који сам за себе, а у вези са ранијим доказима може да доведе до ослобођења оптуженог од оптужбе, те је неопходно да суд спроведе неопходне провере (према ранијем ЗКП/2001 године, користио се термин “извиђаји”). У судској пракси могу се најчешће срести захтеви за понављање кривичног поступка по основу из члана 473. став 1. тачка 3 ЗКП. Да би дошло до понављања поступка по наведеном основу потребно је да се у захтеву изнесу нове чињенице или поднесу нови докази који су сами за себе или у вези са ранијим чињеницама и доказима подобни да проузрокују ослобођење лица које је било осуђено, одбијање оптужбе или осуду по блажем кривичном закону.

Ово је један од основа који није строго лимитиран од стране законодавца, већ је дат у једној уопштеној форми. Међутим, и ту постоји посредна одређеност која се огледа у томе да наведене чињенице и докази морају бити релевантни и нови. На пример, чињеница да је поднет доказ да је извештај поште о уручењу преписа пресуде нетачан или да је одбацивање жалбе странка као неблаговремене, неоправдано, не може бити основ за понављање поступка, јер нема никаквог утицаја на чињенично стање утврђено у пресуди, а у обзир би могао доћи захтев за заштиту законитости (Пресуда Врховног суда Србије Кж П. бр. 39/72 од 03.02.1972. године).

Релевантност ових чињеница и доказа огледа се у томе што је потребно да буду таквог квалитета и квантитета који може да произведе последице које закон тражи, тј. да се на основу њих самих или у вези са ранијим чињеницама и доказима може донети садржајно и формално другачија пресуда

у корист окривљеног. То значи да код нових чињеница и доказа не постоји релевантност ако се на основу њих може постићи изрицање блаже односно строже казне без промене чињеничног стања у погледу кривице учиниоца и правне квалификације кривичног дела.

Шта се сматра новим чињеницама и доказима у поступку по захтеву за понављање кривичног поступка?

Нове чињенице и нови докази у поступку по захтеву за понављање кривичног поступка, треба да буду такви да утичу на чињенично стање утврђено у пресуди, да га приказују другачијим. Није спорно да докази које су странке у току поступка предлагале, а чије извођење је суд одбио не представљају нове доказе који би могли бити основ за понављање кривичног поступка (Решење Окружног суда у Београду Кж. 2916/03 од 14.10.2003. године).

Међутим, у вези са наведеним се поставило питање у ком смислу чињенице и докази треба да буду нови: 1) да ли нови у том смислу што се у захтеву за понављање кривичног поступка први пут износе или подносе суду (*noviter produkta*), односно ти докази нису раније предлагани суду да буду изведени, иако су странке за те чињенице и доказе знале и пре правноснажности пресуде, тј. током трајања редовног поступка, па их свесно нису употребиле, или 2) чињенице и докази треба да буду нови у том смислу што су се накнадно појавили, тј. да је странка за њих сазнала тек после правноснажности пресуде, а пре тога или они нису постојали или су постојали, али странка за њих није знала (*noviter repeta*). Кратко речено, питање је да ли нове чињенице и нови докази могу бити “новоподнети” или “новопојављени”.

Према раније заступљеним становиштима, да би се се чињенице и докази сматрали новим било је довољно да су “новоподнети” односно први пут изнети пред суд у захтеву за понављање кривичног поступка, без обзира када је подносилац захтева за исте сазнао.

Наведено је било у складу са начелом материјалне истине, које је било једно од руководећих начела у тадашњем кривичном поступку и захтевало је слободну употребу свих доказа, без икаквог ограничења у погледу времена изношења истих.

Овакво становиште је било у складу и са законским решењем садржаним у ЗКП/2001, које није постављало никаква ограничења у вези са могућношћу

странака и оштећеног да предложи нове доказе и након заказивања главног претреса, без потребе да образложе због чега то раније није урађено и без икаквих штетних последица.

Према сада важећем Законику о кривичном поступку, предлагање доказа је регулисано одредбом члана 350. ЗКП. Нови Законик у складу са расправним моделом кривичног поступка, ставља у први план доказну активност странка, које су дужне да се пре почетка главног претреса изјасне о чињеницама које оспоравају и образложе предложене доказе које намеравају да изведу на главном претресу, при чему је председник већа дужан да их упозори да се неће изводити они докази који су им били познати, али који без оправданог разлога на припремном рочишту нису предложени (члан 350. став 1 ЗКП). Такође је одредбом члана 395. став 4. тачка 1 ЗКП предвиђено да председник већа на главном претресу може одбити доказни предлог ако оцени да је реч о доказу за који су странке, бранилац и оштећени знали у току припремног рочишта или након одређивања главног претреса, али га без оправданог разлога нису предложили. *Ratio legis* оваквог законског решења заснован је на адверзијалној конструкцији главног претреса и циљ му је да се странке што је могуће раније у процесно-стадијумском смислу, изјасне у погледу својих “доказних интенција” и да се на тај начин омогући суду пред којим ће се главни претрес одвијати, да на одговарајући начин, планира време одржавања, трајање и ток главног претреса, а што укључује и поступање по ванредним правним лековима.

Дакле, доказни предлог може бити одбијен ако је неоправдано неблаговремен, односно уколико су предлагачи знали за њега у току припремног рочишта или након одређивања главног претреса ако припремно рочиште није одржано, али га без оправданог разлога нису предложили. Тако је прихваћено у судској пракси да уколико се нове чињенице појаве или се за њих сазна после објављивања пресуде, па исте буду изложене у жалби, па самим тим буду и предмет разматрања пред другостепеним судом, на њима се не може заснивати захтев за понављање кривичног поступка. Међутим, ако су изнете у неблаговременој допуни жалбе, која буде одбачена, у том случају могу бити основ за понављање поступка.

Имајући у виду наведене законске одредбе као и ограничења која Законик о кривичном поступку поставља у вези са предлагањем нових доказа, сматрамо да иако из формулације члана 473. став 1. тачка 3 ЗКП произилази да

Законик у начелу и уопштено прописује да је потребно да се нове чињенице накнадно изнесу, односно да се нови докази накнадно поднесу, и не одређује ближе шта се има сматрати новим доказом, да се сходно одредбама члана 350. и члана 395. ЗКП, новим доказима у поступку за понављање кривичног поступка, могу сматрати само докази који су се накнадно појавили, односно они докази за које странка накнадно сазнала.

Подобне и неподобне чињенице и докази за понављање кривичног поступка

Једно од најважнијих питања у поступку по захтеву за понављање кривичног поступка је оцена подобности нових доказа да се на основу њих дозволи понављање кривичног поступка. Од доказа се тражи да су сами за себе или у вези са ранијим доказима подобни да проузрокују промене у стању утврђеном правноснажном пресудом. Квалитет новоподнетих доказа и изнетих чињеница, суд оцењује у сваком поједином случају, при чему чему се од доказа тражи да се таква последица може претпоставити. При томе и према међународним стандардима, када домаће законодавство прописује редован или ванредни правни лек против осуде или против казне, због одређених чињеничних или правних недостатка, тај поступак се мора третирати као продужетак првостепеног поступка. Захтев за понављање кривичног поступка суд може уважити на основу нових чињеница и доказа одређеног квалитета, али не и на основу новог тумачења ранијих доказа, нити понављање може ићи на исправку раније заузетог становишта.

Према решењу Врховног суда Србије од 22.01.2002. године, приложени налаз и мишљење лекара неуропсихијатра, уз захтев за понављање кривичног поступка, о постојању битно смањене урачунљивости осуђеног у време извршења кривичног дела не представља нови доказ на основу којег се може дозволити понављање кривичног поступка. У наведеној одлуци Врховног суда Србије, заузето је становиште да налаз и мишљење лекара неуропсихијатра о постојању битно смањене урачунљивости осуђеног у време извршења кривичног дела (који налаз је прибављен на захтев осуђеног након правноснажности пресуде) није подобан да сам за себе, ни у вези са другим доказима, проузрокује другачију одлуку суда, повољнију за осуђеног. Ово због тога што евентуална примена члана 23. став 3 Кривичног законика (дакле у случају да је урачунљивост осуђеног у време извршења кривичног

дела била битно смањена) не значи обавезно осуду по блажем закону, пошто наведена законска одредба не представља облигаторан, већ факултативни основ за блаже кажњавање. Следствено томе, околност да је окривљени у време извршења кривичног дела био потпуно неурачунљив може довести до понављања поступка на основу чл. 473. ст. 1. тач. 3. ЗКП, јер постоји могућност изрицања ослобађајуће пресуде.

Међутим, треба имати у виду да је поменута одлука Врховног суда Србије донета у време важења ранијег Законика о кривичном поступку - ЗКП/2001, када је био у примени захтев за ванредно ублажавање казне, као посебан ванредни правни лек.

У вези са наведеним, а имајући у виду одредбе садашњег Законика о кривичном поступку, можемо се сложити са наведеним становиштем Врховног суда Србије да битно смањена урачунљивост у време извршења дела, која је утврђена након правноснажности пресуде, не би могла бити разлог за понављање кривичног поступка на основу одредбе чл. 473.ст. 1.тач.3. ЗКП, али сматрамо да би евентуално могла бити разлог за понављање кривичног поступка сходно одредби чл. 473. ст. 1. тач. 6. ЗКП, и да би то суд морао размотрити у сваком конкретном случају.

Суд може *ex officio* одредити извођење доказа и у поступку који се води по захтеву за понављање кривичног поступка. Такво становиште је заузео Апелациони суд у Београду, који је у својој одлуци навео да је првостепени суд је био у обавези, а имајући у виду околности на које је бранилац осуђеног указао у поднетом захтеву за понављање кривичног поступка, да одреди судско-медицинско вештачење од стране вештака одговарајуће струке, како би се утврдила тежина наступелог облика нарушавања здравља код осуђеног, његова укупна радна и животна способност и његове потребе за даљим лечењем, као и да се вештак изјасни о условима у којима је потребно наставити даље лечење осуђеног, односно да ли се лечење осуђеног може успешно спровести и у затворским условима (Решење Апелационог суда у Београду Кж.2 По1 бр. 417/12 од 16. 10. 2012. године и решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1 бр. 66/10 - Кв.По1 бр. 430/12 од 18.09.2012.године).

Међутим када су у питању нова вештачења и експертска мишљења, обављена ван суда и приложена уз захтев за понављање кривичног поступка, иста по правилу нису прихватана као нов доказ у судској пракси. Врховни суд Србије је у више одлука заузимао став да вештачење које је извршено

ван суда не представља такав доказ који би сам за себе или у вези са другим раније изведеним доказима био подобан да се дозволи понављање кривичног поступка (Решење Врховног суда Србије, Кж. 280/02 од 23.4.2002. године). Такође, осуђеном јер је кривичном делом причинио знатну штету, неће се дозволити понављање кривичног поступка само на основу тога што има доказа да је штета проузрокована кривичним делом мања од оне утврђене правноснажном пресудом. Потребно је да је стварни износ штете мањи у тој мери да би могао проузроковати осуду за блаже кривично дело тј. измену правне квалификације.

Доказ у виду новог налаза и мишљења вештака из правноснажно завршеног поступка, представља само другачији приступ истим чињеницама, па сам за себе није подобан да доведе до другачијег чињеничног стања, нити да послужи као основ за понављање кривичног поступка (Врховни суд Србије, Кзз бр. 49/05 од 02.11.2015. године).

Међутим, у судској пракси, а посебно у пракси старијег датума, је било ставова да налаз и мишљење стручне установе прибављен и без наредбе суда, на личну иницијативу осуђеног, може бити основ за покретање поступка за понављање кривичног поступка (Саветовање кривичних одељења Савезног суда и Врховних судова од 27.12.1991. године). Сматрамо да би налаз и мишљење стручне установе који је одбрана прибавила након правноснажности пресуде, а који се не слаже са раније обављеним вештачењем, требао бити предмет провере у поступку за понављање поступка (члан 476. став 2 ЗКП), а како би се утврдило да ли се нови налаз односи на нове чињенице или само на другачије тумачење ранијим вештачењем утврђених чињеница. Уколико би се нови налаз односио на нове чињенице он би могао бити основ за понављање поступка.

Дакле у сваком случају приликом оцене подобности нових доказа за понављање кривичног поступка, је значајно да суд разграничи да ли се у конкретном случају ради о новом доказу или чињеници или се подношењем доказа и изношењем одређених чињеница у захтеву за понављање кривичног поступка, у ствари тражи нова оцена ранијих доказа, а што не може бити основ понављања поступка.

Осуда по блажем кривичном закону у поступку за понављање кривичног поступка

Понављање кривичног поступка је апстрактно дозвољено чим је могућа осуда по блажем кривичном закону, те се поставља питање шта се има сматрати “осудом по блажем кривичном закону” и да ли се у том случају примењују одредбе о временском важењу кривичног законодавства из члана 5. став 1. и 2. Кривичног законика. Одговор је негативан.

Када је реч о осуди по блажем закону, из нових чињеница или доказа таква осуда треба нужно да следи из правне квалификације кривичног дела, а не само да представља једну од околности које утичу на врсту и меру кривичне санкције.⁴ Нове чињенице које се односе само на ублажавајуће околности могу представљати евентуално разлог за понављање поступка из члана 473. став 1. тачка 6. ЗКП (раније ванредни правни лек ванредно ублажавање казне).

Под “осудом по блажем кривичном закону” сматра се осуда по кривичној одредби која за кривично дело прописује блажу казну него што је прописана у кривичној одредби по којој је окривљени правноснажно осуђен, а никако не применом појединих одредби општег дела Кривичног законика, које предвиђају блаже одмеравање казне у границама исте квалификације кривичног дела.

Такође осуда по блажем кривичном закону се односи увек на закон који је био на снази у време изрицања правноснажне пресуде (Пресуда Савезног суда, Кз 30/90 од 4.12.1990. године).

Када се новом пресудом донетом по захтеву за понављање кривичног поступка оставља у целини на снази ранија правноснажна пресуда не долази у обзир примена блажег закона, који је донесен по правноснажности пресуде поводом које је дозвољено понављање кривичног поступка, јер обавезна примена члана 5. став 2 Кривичног законика важи само до наступања правноснажности судске одлуке. У својој одлуци Врховни суд Србије наводи да ако је чињенично стање остало неизмењено суд у новом поступку није овлашћен да примени блажи закон који је ступио на снагу после доношења раније пресуде (Врховни суд Србије, Кж. I 800/00 од 08.09.2000. године). Уколико ранија правноснажна пресуда остане на снази у целини, првостепени суд не може да мења ранију пресуду ни у погледу правне оцене дела,

⁴ Горан Илић, Миодраг Мајић, Слободан Бељански, Александар Трешњев, *Коментар Законика о кривичном поступку*, Службени гласник, 2013, стр.942.

квалификујући дело по блажем закону, ни у односу на казну, јер дозвола понављања поступка сама по себи не утиче на ранију правноснажност пресуде, уколико се у новом поступку не утврде нове релевантне чињенице.

Сходно томе, и чињеница да је након правноснажности пресуде којом је донета осуђујућа пресуда дошло до измене казни у кривичном закону, не представља законом предвиђен случај за понављање кривичног поступка (Решење Окружног суда у Београду, Кв. 1238/02 од 20.6.2002).

Понављање кривичног поступка ради изрицања блаже кривичне санкције

Поступак се, сходно одредби члана 473. став 1. тачка 6 ЗКП, може поновити ако се у захтеву изнесу нове чињенице или поднесу нови докази којих није било када је изрицана казна или суд за њих није знао иако су постојали, а они би очигледно довели до блаже кривичне санкције, а ставом 2. исте одредбе прописано је да се понављање поступка по овом основу може тражити док казна затвора не буде извршена. Дакле, законодавац допушта понављање кривичног поступка по овом основу само када је осуђеном изречена затворска казна.

То актуелизује питање са почетка реферата, да ли се по овом основу (члан 473. став 1. тачка 6. ЗКП) може тражити понављање кривичног поступка у случају када је изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи или обавезно психијатријско лечење на слободи.

Уколико прихватимо судску праксу засновану на ранијем захтеву за ванредно ублажавање казне, понављање кривичног поступка по овом основу није могуће, осим ограничења у претходном ставу, ни после смрти осуђеног, као ни по опроштеној или застарелој казни. Накнадно смањење или ублажавање казне може имати основа, у случају када се може очекивати да се и смањеном или ублаженом казном може остварити сврха кажњавања а о таквој сврси може бити речи само када предстоји извршење казне или се казна делом још извршава (Врховни суд Србије, Кж. II 66/84).

Суд је овлашћен да у поновљеном поступку не само ублажи изречену казну, већ и да је замени блажом санкцијом-да уместо казне затвора изрекне условну осуду или судску опомену. Поступак се по овом основу може поновити и изрећи блажа казна и у случају када је осуђеном суђено у одсуству и то независно, као и пре евентуалног понављања кривичног поступка на основу члана 479. ЗКП.

Уколико се поступак понови и усвоји захтев а осуђени је оглашен кривим за дела у стицају и осуђен на јединствену казну, новом пресудом ублажава се само јединствена казна. Међутим, могуће је да ублажавање јединствене казне није допуштено ако би се тиме повредила одредба члана 60. КЗ. На пример, уколико су осуђеном утврђене казне затвора у трајању од 5 - година и у трајању од 2 месеца, па је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5-година и 1-месец, ублажавањем јединствене казне суд би повредио одредбу члана 60. став 2. тачка 2. КЗ. Суд ће, у том случају, ублажити појединачно утврђене казне (или неку од њих) а затим изрећи нову јединствену казну. Другим речима, у поновљеном поступку по овом основу суд поступа на исти начин као и кад се у другостепеном поступку преиначава одлука о казни у корист окривљеног (Заједничка седница кривичних одељења Савезног суда, Врховних судова и Врховног војног суда од 29.11.1990. године).

У случају када се разлози због којих је дозвољено понављање кривичног поступка не односе на сва, већ само на нека од кривичних дела обухваћених продуженим кривичним делом, спорно је, јер ЗКП то не одређује, да ли је веће пред којим се држи поновљени главни претрес везано решењем већа (члан 21. став 4. ЗКП) којим је уважен захтев за понављање кривичног поступка не за сва већ само за нека од кривичних дела обухваћених продуженим кривичним делом. Уколико су докази који су прикупљени током поновљеног кривичног поступка од битног утицаја и на остала кривична дела из продуженог кривичног дела иако нису обухваћена решењем којим је уважен захтев, судеће веће је овлашћено да поступак прошири и на та дела с обзиром да је у питању јединствено кривично дело, наравно уколико је то у корист осуђеног.

Оваква становишта подржавала је судска пракса пре усвајања важећег Законика о кривичном поступку, али сматрамо да се наведени ставови могу применити и у садашњој судској пракси и нису у колизији са кривичнопроцесним одредбама које су у примени.

Закључак

Сумирајући претходна излагања, може се закључити да су ступањем на снагу Законика о кривичном поступку 2013. године, отворена нека нова питања у судској пракси која се тичу поступања по захтеву за понављање кри-

вичног поступка, а што је последица нових законских решења и начела, на којима је сада постављено домаће кривичнопроцесно право. Судска пракса се суочава са новим изазовима и у појединим случајевима не може да настави са устаљеном традицијом у поступању у одређеним случајевима, али се исто тако у свим случајевима у којима је то могуће и није у супротности са важећим законским решењима, надограђује своју мисао и одлуке кроз већ дате закључке и ставове Врховног суда, који и представљају у ширем смислу њен главни оријентир. Коначно, можемо рећи да се у поновљеном поступку ранија пресуда ставља се ван снаге само у оном делу у којем је чињенично стање измењено. Тако, ако је у поновљеном поступку утврђено да осуђени није крив за неко од кривичних дела, суд ће новом пресудом ставити ван снаге ранију правноснажну пресуду у том делу. Ако се с обзиром на новоутврђено чињенично стање мења правна квалификација дела, новом пресудом биће стављена ван снаге одлука која се односи на правну квалификацију, у сваком случају треба ставити ван снаге ранију одлуку о казни и заменити новом. Важно је да из пресуде донете у поступку за понављање поступка мора бити јасно видљиво да та пресуда заједно са раније донетом пресудом у делу којем раније донета пресуда није стављена ван снаге, чини целину.

Dragan Jovic

President of the Appellate Court in Nis

Dijana Jankovic

PhD, judge at the Appellate Court in Nis

Extraordinary Legal Remedy to Reopen of Criminal Proceedings

Abstract: This paper provides an overview of the right to the extraordinary legal remedy to reopen criminal proceedings, according to the new Criminal Procedure Act. The paper stresses in particular the persons who may exercise this right, the right to challenge the final judgment and the manner of examining these decisions. The general rule is that the extraordinary legal remedy to reopen criminal proceedings should be allowed only for the benefit of the accused. This prohibition is based on the principle of “prohibition of *reformatio in peius*”. An appeal involves the appeals court examining a judgment that is not yet final and extraordinary legal remedy, on the other hand, it involves the reopening of final proceedings, whether those proceedings became final after trial (where no appeal was filed by the parties) or after appeal. The accused or the representative of the accused will normally bring such proceedings, although the prosecutor can petition the court to reopen the proceedings as well, only if he or she was acting for the benefit of the accused. The first stage in dealing with an application for the reopening of criminal proceedings is the competent examination of the appeal by the court in order to determine if it raises sufficient issues to merit a new proceeding. The paper analyses the basic principles of the domestic law in the area of the reopening of criminal proceedings and the actual judicial practice in this area as well as the circumstances that the court takes as relevant. A critical review is provided for particular legal solutions.

Key words: extraordinary legal remedy, reopen criminal proceedings, criminal proceedings.

Драган Јоцић

Судија Врховног Касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

Др Дијана Јанковић

Судија Апелационог суда у Нишу

СТРУЧНИ САВЕТНИК КАО СУБЈЕКТ ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ВЕШТАЧЕЊА -ПРОЦЕСНИ ПОЛОЖАЈ И ДОПРИНОС ВЕШТАЧЕЊУ

Апстракт

Једна од најзначајнијих новина у домаћем кривичнопроцесном праву је увођење стручног саветника у кривични поступак, као лица које располаже стручним знањем из области у којој је одређено вештачење. Област психијатријског вештачења представља веома комплексну и сложену проблематику. Имајући у виду практичну вредност резултата психијатријског вештачења као и чињеницу да налаз и мишљење вештака психијатра има значајно место у доказном поступку, то ће предмет излагања бити проблематика која се односи на кривичнопроцесни положај стручног саветника као субјекта психијатријског вештачења. Како је по свом законском одређењу поступање стручног саветника везано за вештачење, посебно ће бити размотрена овлашћења стручног саветника у случају када је одређено психијатријско вештачење, а у вези са тим и кривичнопроцесни однос вештака и стручног саветника, као и доказна снага њихових стручних мишљења.

Кључне речи: стручни саветник, психијатријско вештачење, вештак, стручно лице.⁵

⁵ Реферат је изложен на Регионалној конференцији у Београду која је одржана 2. јуна 2017. године, у организацији мисије ОЕБС у Србији у сарадњи са Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу на тему “Мере безбедности медицинског карактера” и публикован у ширем обиму у Зборнику радова изложених на Конференцији.

Увод

Расветљење и решење кривичне ствари одвија се у законом покренутом и спроведеном поступку. За успешно расветљење и решење кривичне ствари потребна је, у првом реду активност кривичнопроцесних странака, с тим што остварењу овог задатка доприносе и други како главни, тако и споредни кривичнопроцесни субјекти.

Предмет кривичнопроцесног права као гране законодавства је кривична ствар - *causa criminalis*, а задатак расветљење и решење кривичне ствари, тј. њено чињенично и правно оформљење. Кривична ствар представља реалан догађај који се одиграо у прошлости и друштву и који у себи садржи кривично дело и учиниоца. По својој садржини кривична ствар може бити веома разноврсна и сложена. На сложеност кривичне ствари, поред осталог утиче и развој науке и технике и осложњавање кривичне ствари.

Активност кривичног суда и других кривичнопроцесних субјеката нарочито се манифестује на плану доказивања, тј. откривања и извођења доказа, ради утврђивања правно-релевантних и других чињеница које чине садржинну кривичне ствари. Законик о кривичном поступку, који је за судове опште надлежности ступио на снагу 1. октобра 2013. године ("Службени гласник Републике Србије", 72/11, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014), је проширио круг кривичнопроцесних субјекта уводећи у кривични поступак стручног саветника, као лице које располаже стручним знањем из области у којој је одређено вештачење и које може бити ангажовано од стране странка у кривичном поступку ради пружања стручне помоћи у области у којој је одређено вештачење. Закоником је одређен положај стручног саветника, као и његова овлашћења и обавезе.

Као кривичнопроцесне субјекте, које орган поступка поступка може одредити када је за оцену неке чињенице у поступку потребно стручно знање, Законик о кривичном поступку је, пре доношења новог Законика, предвиђао вештака и стручно лице, као лица са посебним стручним знањем, која могу бити постављена од стране органа поступка.

Међутим, иако ранији Законик о кривичном поступку није изричито прописивао могућност ангажовања стручног лица или вештака од стране одбране, судска пракса је познавала њихово ангажовање у току кривичног поступка, посебно у кривичним предметима у којима је поступак вођен због

кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја, али веома често и код кривичних дела против живота и тела, кривичних дела против службене дужности и других кривичних дела. Наиме, није био неуобичајено у судској пракси да од стране одбране буде приложено као доказ вештачење које је обављено без наредбе суда, на захтев одбране (нпр. саобраћајно вештачење, медицинско вештачење, психијатријско вештачење, финансијско вештачење и др.). Такође није било процесних сметњи да тај вештак који је на захтев окривљеног обавио вештачење буде саслушан пред судом, с тим што су такви налази и мишљења према ставу судске праксе, били третирани као примедбе одбране на већ дати налаз и мишљење, с обзиром да то ново вештачење није обављено по наредби суда, већ на захтев одбране (Решење Врховног суда Србије Кж. 2253/05 од 30. јануара 2006). “Налаз и мишљење дипломираног инжењера, које је доставила одбрана у току поступка, не сматра се налазом вештака, јер није наложен од стране суда, већ стручним мишљењем које је одбрана доставила суду у смислу примедби на налаз судског вештака,” (Пресуда Окружног суда у Краљеву Кж. 41/07 од 14.2.2007. године).

Новим Законом је практично законски уведен стручни саветник, као кривичнопроцесни субјект у кривични поступак, иако је он већ у одређеним сегментима постојао и био прихваћен у судској пракси. За разлику од вештака и стручног лица које одређује орган поступка, под законом прописаним условима, када се у кривичном поступку укаже потреба за одређеним стручним знањем у некој области, стручни саветник се ангажује у кривичном поступку искључиво на основу диспозиције странка, дакле по захтеву странка. Међутим уколико постане субјект кривичног поступка, стручни саветник има законом прописана права и обавезе и подлеже одређеним правилима поступка као и остали учесници кривичног поступка. Имајући у виду да је по свом законском одређењу поступање стручног саветника везано за вештачење и може бити само у области у којој је вештачење одређено, посебно је значајно размотрити положај и овлашћења стручног саветника у случају када је одређено психијатријско вештачење, а у вези са тим испитати и однос у процесном поступању између вештака, стручног саветника и стручног лица и доказну снагу њихових стручних налаза приликом утврђивања чињеничног стања.

Психијатријско вештачење одликује низ специфичности, почев од чињенице да вештак може бити појединац - лекар психијатар али и чињенице да је веома често психијатријско вештачење поверено некој специјализованој установи или психијатријској болници, у коју се смешта лице које се вешта-

чи и практично му се тиме ограничава слобода у одређеној мери. Наиме, орган поступка може одредити да лице које се вештачи мора провести неко време у таквој установи на психијатријском посматрању, ради потпунијег сагледавања његове личности и душевног стања од стране вештака. Такође се ради о специфичном предмету психијатријског вештачења, јер су то лица за која постоји сумња у њихову урачунљивост, због постојања душевних болести, душевних поремећаја, зависности од употребе дрога, алкохола и сл. или због сумње у њихову способност да учествују у кривичном поступку. Улога стручног саветника у таквим вештачењима, свакако има одређене специфичности и посебан значај и отвара бројна питања. Ово посебно у односу на околности у којој мери и на који начин стручни саветник може да присуствује психијатријском вештачењу и у коликој мери може да му допринесе, а нарочито су значајна питања у области процесног положаја вештака психијатра и стручног саветника, што се рефлектује и на однос њихових стручних мишљења у доказном поступку.

Однос психијатријског вештачења и искаса стручног саветника у кривичном поступку

Да би орган кривичног поступка, могао што успешније да расветли и реши кривичну ствар, потребна му је све више помоћ других кривичнопроцесних субјеката, односно кривичнопроцесних странака и других учесника у кривичном поступку. Међу овим учесницима као што је поменуто посебно место све више има стручни саветник, као лице које располаже стручним знањем из области у којој је одређено вештачење. Стручни саветник је лице - стручњак, специјалиста, које пружа стручну помоћ странци која га је ангажовала у области у којој је одређено вештачење, на плану расветљавања оних правно-релевантних и других чињеница за чије је утврђивање потребна примена посебног стручног знања. Наиме, како развој науке и технике непосредно утиче на осложавање кривичне ствари, али исто тако и на савремене технике вештачења, то странкама може бити потребна помоћ стручног саветника ради провере и контроле вештачења у циљу остваривања процесних права у току кривичног поступка, што представља суштину процесне улоге стручног саветника.

Дакле, поред права да предложи вештачење и вештака, странке (јавни тужилац, оштећени као тужилац или приватни тужилац и окривљени) према

новом Законику, имају право и да изаберу себи стручног саветника увек када орган поступка одреди вештачење. Сходно члану 125. став 2. ЗКП, странка пуномоћјем овлашћује одређено лице као свог стручног саветника у поступку. Најранији процесни тренутак од којег она то може учинити је одређивање вештачења од стране органа поступка.⁶

С обзиром да је Законик о кривичном поступку дао могућност и јавном тужиоцу да ангажује стручног саветника, може се поставити питање у којим ће случајевима јавни тужилац ангажовати стручног саветника и на који начин? Неспорно је да јавни тужилац у претходном поступку као орган поступка наредбом може одредити вештачење уколико сматра да је неопходно одредити лице које располаже потребним стручним знањем за утврђивање или оцену неких чињеница у поступку. Такође, ако јавни тужилац има неке предлоге и дилеме у односу на налаз и мишљење вештака, одредиће допуну вештачења, односно ако постоје недостаци у датом налази и мишљењу јавни тужилац треба да их “расчисти” пре него што подигне оптужницу. Након подизања оптужног акта, може се поставити питање, зашто би јавни тужилац ангажовао стручног саветника на главном претресу, када је вештачење обављено по његовој наредби у претходном поступку, јер уколико јавном тужиоцу евентуално дати налаз и мишљење вештака није био довољно јасан у претходном поступку, он не би могао да подигне оптужницу. Уколико се размотри и могућност да је вештачење први пут одређено на главном претресу наредбом суда, те да би евентуално јавни тужилац ангажовао стручног саветника, опет се може поставити питање, на који начин ће јавни тужилац то практично урадити, односно ко ће конкретно дати пуномоћје стручном саветнику имајући у виду одредбу чл. 125. ст. 2. ЗКП, јер судска пракса до сада није познавала ситуацију да јавни тужилац или јавно тужилаштво, дају пуномоћје неком кривично-процесном субјекту. У свом поступању јавни тужилац издаје наредбе, налоге, захтева обавештења и сл. Сходно наведеном, произилази да ће стручни саветник, бити по правилу ангажован од стране одбране и скоро да нема процесне ситуације у којој би јавни тужилац ангажовао стручног саветника.

Психијатријско вештачење, као и друге врсте вештачења, одређује орган поступка по службеној дужности или на предлог странке и браниоца, који

⁶ Горан П. Илић, Миодраг Мајић, Слободан Бељански, Александар Трешњев, *Коментар Законика о кривичном поступку*, ЈП Службени гласник, Београд 2012, стр. 326

могу предложити и вештака коме треба поверити вештачење и формулисати питања која вештаку треба поставити (члан 117. став 1. и став 2. ЗКП). Према одредбама члана 131. ЗКП, психијатријско вештачење је обавезно ако се појави сумња да је искључена или смањена урачунљивост окривљеног, као и у случају сумње да је услед зависности од употребе алкохола или опојних дрога учинио кривично дело или да је због душевних сметњи неспособан да учествује у кривичном поступку. Стање душевне болести или душевне поремећености учиниоца посматра се пре свега са аспекта начина процесног понашања окривљеног у кривичном поступку, односно правца у којем окривљени развија своју процесну активност. Такође, окривљени се може бранити, и тако што ће изјавити да у време извршења кривичног дела, услед душевне болести или душевног поремећаја, није располагао интелектуалним или волунтативним капацитетом, услед чега не сноси кривицу, односно да због тога не постоји урачунљивост као елемент кривичног дела.

Осим тога, новину у Законнику о кривичном поступку, у области психијатријског вештачења, представља и могућност да орган поступка може одредити психијатријско вештачење сведока, ако се појави сумња у способност сведока да пренесе своја сазнања или опажања у вези са предметом сведочења (члан 131. став 2. ЗКП). Реч је о сумњи у општу способност да се буде сведок, која се може јавити у току кривичног поступка. Наведено је у вези са одредбом члана 92. став 1. ЗКП којом је прописано да “свако лице које може да пренесе своја сазнања и опажања у вези са предметом сведочења има способност сведочења”. Дакле, поменутом одредбом је уређено питање опште способности да се буде сведок. Она подразумева могућност одређеног лица да пренесе своја сазнања или опажања у вези са предметом сведочења. Такође, нема сметњи да се као сведок испита лице које има одређене физичке или душевне недостатке, дете, стар човек, болесник итд. под условом да орган поступка оцени да то лице може да пренесе обавештења о чињеницама које се утврђују у поступку. У складу са тим, исказ малолетног оштећеног, који је ментално недовољно развијен и смањеног степена развијености, може представљати доказ у поступку, ако је саслушан под одређеним условима (Пресуда Врховног суда Србије, Кж1.бр. 285/06 од 27.02.2006. године).

Такође судска пракса познаје и прихвата вештачење сведока или оштећених лица у погледу утврђивања да ли код тих лица постоји склоност да се служе лажима, преувеличавањем и сл. а с обзиром на структуру њихове личности. Тако је у пресуди Врховног суда Србије Кж 1.бр.2300/05 од 23.02.2006.

године наведено да је “искказ оштећене првостепени суд правилно прихватио као истинит и због тога што се из налаза и мишљења вештака неуропсихијатра, као и из налаза и мишљења вештака клиничког психолога утврђује да се оштећена при давању својих исказа не служи лажима и конфабулацијама”. Новина је само у том правцу, што орган поступка приликом оцене да ли одређено лице поседује опште способности да буде сведок, може да одреди и психијатријско вештачење тог лица. Битно је указати и на то, да је у случају сумње у урачунљивост окривљеног и при постојању услова прописаних одредбом члана 131. став 1. ЗКП, орган поступка “обавезан” да одреди психијатријско вештачење, дакле вештачење је у том случају “обавезно”, док када се ради о психијатријском вештачењу сведока из члана 131. став 2. ЗКП, постојање сумње у способност сведока да сведочи даје “могућност” органу поступка да одреди ово вештачење, али исто није обавезно.

Стручни саветник мора имати исте квалификације као и вештак и уколико је постављен по одредбама члана 125. став 2. ЗКП, односно уколико га поставља орган поступка мора бити са списка сталних судских вештака (Правна схватања Посебних одељења Вишег суда у Београду - Нови Законик о кривичном поступку), а мимо тог списка само ако сталних судских вештака нема или су спречени (члан 114. став 3. ЗКП се сходно примењује и на стручне саветнике).

Имајући у виду напредак науке, технике и велики број еминентних стручњака у различитим научним областима који нису на листи вештака, супротно тренутној законској регулативи и заузетим становиштима, сматрамо да не би требало да буде сметња ангажовање стручног саветника уколико се не налази на листи вештака, и да би у том правцу требало проширити законске одредбе. Свако лице које располаже стручним знањем у некој области у којој је одређено вештачење, и које странка жели да ангажује, би требало да има могућност да поступа као стручни саветник те странке. Међутим, према садашњим законским одредбама стручни саветник може бити само лице које је уписано у Регистар вештака, под условом да у конкретном случају није одређен за вештака, осим изузетка из члана 114. став 3. ЗКП.

Питање утврђивања душевног стања окривљеног или сведока, покрећу одбрана, окривљени и његови сродници, јавни тужилац или сам судија кад примети одступања од уобичајеног у понашању или у догађајима њиховог ранијег живота: раније лечење од душевних болести, епилептични напади

и сл., а када је у питању душевно стање окривљеног, посебно се имају виду дела извршена без мотива, посебне околности извршења кривичног дела и др. У тим случајевима вештак психијатар пружа помоћ органу кривичног поступка у утврђивању оних правно-релевантних и других чињеница које се тичу душевног стања посматраног лица. На који начин ће бити обављено психијатријско вештачење окривљеног, да ли у установи за лечење психијатријских болести посматрањем или прегледом од стране лекара вештака психијатра зависи од сваког конкретног случаја. Према ставу судске праксе ако код учиниоца кривичног дела није утврђена нити индукована ниједна аномалија психичке природе која би захтевала дуже посматрање, довољан је психијатријски преглед учиниоца (Пресуда Врховног суда Србије Кж. 1402/97 од 17. децембра 1997).

Имајући у виду процесну улогу стручног саветника може се поставити питање на који начин и у којој мери стручни саветник може учествовати и дати допринос неком конкретном психијатријском вештачењу, односно да ли може бити присутан приликом обављања психијатријског вештачења?

Према одредби члана 126. став 1. ЗКП стручни саветник има право да буде обавештен о дану, часу и месту вештачења и да присуствује вештачењу којем имају право да присуствују окривљени и његов бранилац, да у току вештачења прегледа списе и предмет вештачења и предлаже вештаку предузимање одређених радњи, као и да даје примедбе на налаз и мишљење вештака, да на главном претресу поставља питања вештаку и да буде испитан о предмету вештачења. Из наведене законске одредбе произилази да стручни саветник може да присуствује вештачењу којем имају право да присуствују окривљени и бранилац. Такође, орган поступка је обавезан да чим буде обавештен о ангажовању стручног саветника, о томе обавести вештака или руководиоца стручне установе или државног органа коме је поверено вештачење.

Сходно одредби члана 300. став 5. ЗКП јавни тужилац је дужан да стручног саветника обавести да може да присуствује вештачењу. Међутим, како стручни саветник може да присуствује само вештачењу којем имају право да присуствују окривљени и бранилац, то се може приметити да је право стручног саветника да присуствује вештачењу, ипак у одређеној мери ограничено и зависи од фазе кривичног поступка, врсте и начина на који се обавља вештачење.

Према члану 300. став 1. ЗКП окривљени и бранилац имају право да у претходном поступку присуствују испитивању вештака, а не и самом вешта-

чењу. Сагледавајући специфичности психијатријског вештачења, ако се вештачење обавља у одсуству органа поступка, а посебно када је за вештачење потребно испитивање и посматрање, нпр. када се вештачење врши у стручној установи ли државном органу (нпр. специјализована психијатријска болница, затворска болница и сл.) таквом вештачењу странке немају право да присуствују”⁷ па сходно томе, таквом вештачењу не може присуствовати ни стручни саветник. Са друге стране, вештачење душевног стања може се извршити и пред самим органом који спроводи кривични поступак, анализом утврђених чињеница, непосредним контактом са окривљеним, разговорима, праћењем поступка окривљеног у току процесних радњи, непосредним увидом у медицинску документацију, испитивањем писаног материјала који потиче од окривљеног (дневници, кореспонденција, рукописи и др.) и током таквог вештачења стручни саветник може присуствовати вештачењу.

Законик примарно упућује, на испитивање окривљеног прегледом, приликом психијатријског вештачења, односно без упућивања на посматрање у здравствену установу, кад год је то без штете за правилност резултата кривичног поступка могуће. Упућивање у здравствену установу за лечење душевних болести врши се тек када вештак на основу прегледа окривљеног нађе да је потребно дуже посматрање. Конкретно, Законик предвиђа испитивање пред самим судом или путем смештаја у здравствену установу за лечење душевних болести, тј. стационарно посматрање (члан 122. ЗКП), те зависно од конкретног случаја и резултата примарног вештачења суд одлучује о даљем току психијатријског вештачења, месту и начину на који ће исто бити обављено.

Поменута законска решења, повлаче границу између процесног положаја вештака и стручног саветника. Иако се стручни саветник поставља из реда вештака, он није вештак у кривичном поступку и стручни саветник не даје налаз и мишљење, он пружа стручну помоћ странкама у области у којој је одређено вештачење, јер располаже потребним стручним знањима. Основна разлика између вештака и стручног саветника је у томе што стручни саветник органима поступка не даје налаз и мишљење о својим стручним закључцима, већ својим исказом само указује на неке недостатке или своја запажања у односу на налаз и мишљењу вештака. Стручни саветник се испитује о предмету вештачења

⁷ Момчило Грубач, Тихомир Васиљевић, *Коментар Законика о кривичном поступку –тринаесто издање* –према Законика из 2011, Пројурис, Београд, 2014, стр.240.

(члан 126. став 1. ЗКП), и тада има прилику да изложи своје стручно мишљење и закључке, али његов исказ ни тада нема процесну форму налаза и мишљења вештака. Наиме, према Законику о кривичном поступку, стручни саветник приликом испитивања пред органом кривичног поступка даје “исказ” о предмету вештачења, јер се тако и заклиње (члан 126. став 2. ЗКП) “да ће дати исказ у складу са правилима науке и вештине”. Дакле, његова улога је превасходно у функцији провере вештачења, обзиром да је, како је наведено “лице које располаже стручним знањем из области у којој је одређено вештачење”.

С обзиром на специфичности психијатријског вештачења, јер се вештачи окривљени и његово душевно стање, требало би размотрити могућности на који начин проширити право стручног саветника да присуствује психијатријском вештачењу, или бар неким његовим фазама, и у случајевима када се вештачење обавља у затвореној установи.

На овом месту бисмо указали на једну дилему коју, са становишта судске праксе, отвара законом прописана заклетва стручног саветника и његов одређен круг права и дужности. Наиме заклетвом се стручни саветник обавезује да исказ да “непристрасно”, а са друге стране је истом одредбом у наредном ставу (чл. 126. ст. 3. ЗКП), обавезан да “странци пружи помоћ, стручно, савесно, благовремено”, те се може поставити питање, уколико стручни саветник уочи чињенице приликом давања стручног исказа које нису у корист странке која га је ангажовала, да ли “непристрасно” треба да их наведе на главном претресу у складу са положеном заклетвом иако су на штету странке која га је ангажовала (по правилу одбране), и да ли би то било у том случају у колизији са његовом обавезом да пружи странци помоћ. Наиме, чланом 72. став 1. тач 3. ЗКП је прописано да је бранилац дужан да пружи окривљеном помоћ у одбрани стручно, савесно и благовремено. Лојалност према кривичном поступку и обавеза на поштен однос према осталим субјектима не значи да је бранилац дужан да суду саопштава и онај процесни материјал који је на штету окривљеног. Међутим, бранилац не полаже заклетву пред судом да ће бити “непристрасан”, као што је законодавац предвидео у случају стручног саветника. Сматрамо да се на овај начин кривичнопроцесни положај стручног саветника законом прописује прилично неодређено, јер ће са једне стране бити ангажован по правилу од стране одбране и обавезује се да странци пружи помоћ, а са друге стране је заклетвом обавезан на “непристрасност” као судски вештак, при чему његов процесни положај не одговара процесном положају вештака.

Уводећи стручног саветника као новог кривичнопроцесног субјекта, било је потребно законом признати му већа овлашћења, и јасније дефинисати његов кривичнопроцесни положај. Неспорно је да јавни тужилац, скоро и да нема практичне могућности, али ни интерес да у кривичном поступку ангажује стручног саветника, јер увек може ангажовати стручно лице или вештака, нити му стручни саветник може бити постављен у смислу одредбе чл. 125. ст. 3. ЗКП као државном органу. Пратећи судску праксу као и законске одредбе, сматрамо да је било целисходније Закоником прописати и јасно одредити стручног саветника као кривичнопроцесни субјект који пружа помоћ само одбрани и у складу са тиме дефинисати његова права и обавезе у кривичном поступку. На тај начин, се не би отварала питања о чињеницама о којима је стручни саветник дужан да се изјасни у складу са положеном заклетвом, и коме је дужан практично да пружи помоћ у кривичном поступку, окривљеном који га најчешће и по правилу ангажује и коме је по закону дужан да пружи помоћ или органу поступка, јер је везан заклетвом да “непристрасно” да исказ.

Према судској пракси уколико се појаве супротности између исказа стручног саветника и налаза и мишљења вештака, укључујући и налаз и мишљење вештака психијатра, према усвојеном схватању Посебног одељења Вишег суда у Београду (Правна схватања Посебних одељења Вишег суда у Београду - Нови Законик о кривичном поступку, са седнице одржане - 31.01.2012. године), не би требало одредити “супер вештачење”, јер не постоји супротност између два вештачења која су у истој равни. Такве супротности, могу се решавати испитивањем вештака и стручног саветника, као и сагледавањем и оценом, изјашњења и стручног мишљења стручног саветника, у светлу других доказа. Дакле, суд се према исказу стручног саветника неће односити као према новом вештачењу, већ ће размотрити примедбе, покушати да отклони нејасноће саслушањем вештака, те ако у томе не успе евентуално може одредити ново вештачење, али не као “супер вештачење”, између мишљења стручног саветника и обављеног вештачења, већ ће наредбом одредити допуну вештачења или ново вештачење.

На основу чл. 124. ЗКП, јасно су прописани услови за понављање вештачења и то ако је налаз вештака нејасан, непотпун, погрешан и у противречности сам са собом или са околностима у којима је вештачено или се појави сумња у његову истинитост и ако је мишљење нејасно и противречно. У том случају уколико се наведени недостаци не могу да отклоне поновним испитивањем вештака или допунским вештачењем тада може да се одреди други

вештак који ће обавити ново вештачење (Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу, одржаној дана 16. и 17.04.2014. године, усаглашени са закључцима Кривичног одељења Врховног касационог суда на састанку Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу дана 01.12.2014. године).

Осим тога, поставило се питање до које фазе кривичног поступка може бити ангажован стручни саветник? Према Закључку који је усвојен на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу (Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу, одржаној дана 16. и 17.04.2014. године, усаглашен и са закључцима Кривичног одељења Врховног касационог суда на састанку Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу дана 01.12.2014. године), фаза поступка до које може бити ангажован стручни саветник ограничена је правилима о трајању доказног поступка на главном претресу и околношћу да ли странке имају процесну могућност предлагања нових доказа на главном претресу. То значи да стручни саветник може бити ангажован уз услове прописане одредбама чл. 350, 356. и 395. ЗКП, до завршетка вештачења и окончања доказног поступка на главном претресу. Саветник може бити ангажован и касније у смислу чл. 410, 411. и 414. ЗКП, у случају измена и проширења оптужнице, и накнадне допуне доказног поступка.

Дужности стручног саветника у кривичном поступку

Уколико странке одлуче да изаберу стручног саветника, поставља се питање његовог увођења у поступак, односно не само његових права, већ и дужности у току кривичног поступка. Странке пуномоћјем овлашћују стручног саветника (члан 125. став 2 ЗКП) и стручни саветник је дужан да органу поступка поднесе пуномоћје, одмах и без одлагања, како би могао да остварује своја права и учествује у поступку.

У вези са наведеним, може се поставити питање, ако је окривљени (постоји основана сумња) душевно болестан, тј. неурачунљив и одређено је психијатријско вештачење, ко може дати валидно пуномоћје стручном саветнику? Стриктним тумачењем члана 125. став 2. ЗКП ова категорија лица је лишена могућности ангажовања стручног саветника, јер није прописана сходна примена неких других одредби ЗКП, нити круг лица и сродника који би у том случају у име тог лица могли дати пуномоћје. У вези са наведеним се одмах

поставља још једно питање, да ли у том случају одредбу члана 125. став 2. ЗКП треба екстензивно тумачити и право на давање пуномоћја дати кругу лица која имају право и да ангажују браниоца у име окривљеног - законском заступнику, брачном другу, сроднику по крви у правој линији итд. (члан 75. став 1. КЗ). Напомињемо да се управо код ове категорије лица (ако се појави сумња да је искључена урачунљивост) обавезно врши психијатријско вештачење, при чему окривљени има интерес да уместо теже (затвореног типа) суд изрекне блажу меру безбедности (на слободи), па самим тим може имати и интерес да ангажује стручног саветника. Сматрамо да је неопходно у овом делу допунити одредбу члана 125. став 2. ЗКП и упутити на сходну примену одредбе чл. 75. ЗКП.

У оквиру дужности стручног саветника, као што је поменуто, Законик прописује и полагање заклетве пре испитивања (чл. 126. став 3. ЗКП). Одбијање стручног саветника да испуни ову своју дужност и положи заклетву (као и у случају одбијања заклетве вештака) не повлачи процесне последице, али се може узети у обзир приликом оцене вредности његовог исказа. Стручни саветник је дужан да странци пружи помоћ стручно, савесно и благовремено, да не злоупотребава своја права и да не одуговлачи кривични поступак. Уколико стручни саветник присуствује главном претресу и нарушава ред тако што не поштује наређења председника већа за одржавање реда или вређа достојанство суда, може бити кажњен новчаном казном у складу са правилима из одредбе члана 370. став 1. ЗКП. Такође, стручни саветник може бити и принудно доведен на главни претрес, ако је уредно позван, а није приступио на главни претрес нити је изостанак оправдао (члан 384. став 1. ЗКП) - Претпоставка за предузимање наведене мере је уредност позива (члан 355. став 3. ЗКП), уручење позива на прописан начин (члан 243.) и неоправданост изостанка.

На главном претресу стручни саветник се испитује уз сходну примену правила о испитивању сведока из чл. 98. КЗ, а питања му непосредно постављају странке и бранилац, председник већа и чланови већа, а стручни саветник може такође непосредно постављати питања уз одобрење председника већа (члан 402. став 1. и 2. ЗКП).

Може се поставити и питање да ли лице које је саслушано као сведок може бити одређено за стручног саветника? Да би се одговорило на наведено питање, може се поћи од тога, да ли лице које је саслушано као сведок може бити одређено за вештака? Иако је функција вештака начелно неспојива

са улогом сведока, постоји изузетна могућност да се за вештака одреди лице које је испитано као сведок. Искључење, по правилу, као вештака лица које је испитано као сведок, је ради избегавања, да вештак, поред правила своје науке и вештине, буде при давању свог налаза и мишљења под утицајем својих непосредних сазнања која су претходила вештачењу. Одређивање за вештака лица које је претходно испитано као сведок носи у себи опасност од пристрасности, а код појединих вештачења, нарочито у одређеним случајевима код психијатријског вештачења, ствара и проблем етичности (нпр. када би се од лекара психијатра тражило да вештачи свог пацијента). Постоје ипак случајеви у којима је за одређену врсту вештачења или за одређени случај могуће одредити за вештака једино лице које је претходно испитано као сведок.

Због тога је у члану 116. став 3. ЗКП предвиђена изузетна могућност “удвајања” процесних улога сведока и вештака. Имајући у виду да је одредбом члана 125. став 3. ЗКП прописано да се и на стручног саветника сходно примењују одредбе члана 116. став 1. до става 3. ЗКП, може се закључити да у изузетним случајевима, лице које је саслушано као сведок може бити и стручни саветник у истом кривичном поступку, односно да закон не искључује ту могућност, при чему суд треба да има у виду све оне околности које се узимају у обзир приликом одлучивања о објективности и подобности вештака у таквом истом случају.

Сходно одредби члана 401. став 1. тачка 1. ЗКП стручни саветник се упозорава да давање лажног исказа представља кривично дело и на основу члана 473. став 1. тачка 1. ЗКП, ако је пресуда заснована на лажном исказу стручног саветника то може бити разлог за понављање кривичног поступка. Према члану 376. став 2. ЗКП, ако се у току главног претреса појаве основи сумње да је стручни саветник (исто се односи и на сведока и вештака) на главном претресу дао лажан исказ, председник већа ће наредити да се о таквом исказу састави посебан записник, који ће након што га потпише стручни саветник, или након што председник већа констатује да је одбијено потписивање тог записника и наведе разлоге одбијања, исти доставити јавном тужиоцу.

Можемо на овом месту да укажемо, да у вези са наведеним постоји одређена колизија између Законика о кривичном поступку и Кривичног законика који и након измена и допуна из 2016. године (Закон о изменама и допунама Кривичног законика, “Службени гласник РС”, број 94/2016. године), није као извр-

шиоца кривичног дела давање лажног исказа из члана 335. став 1. КЗ предвидео стручног саветника, већ се као извршиоци наведеног кривичног дела могу само наћи сведок, вештак, преводилац или тумач.

Поред могућности странке да изабере и пуномоћјем овласти стручног саветника који ће јој пружати стручну помоћ у вези са одређеним вештачењем, Законик је предвидео и право окривљеног и оштећеног као тужиоца да поднесу захтев органу поступка за постављање стручног саветника на терет буџетских средстава (члан 125. став 3. ЗКП). Наведено право није дато и јавном тужиоцу, јер је он, у истрази орган поступка (што значи да одлучује о захтеву окривљеног за постављање стручног саветника), а када по оптужењу дође у примарни положај странке у поступку, уколико сматра да је потребно да ангажује стручног саветника, има могућности да за то обезбеди потребна средства као државни орган. О постављењу стручног саветника одлучује судија за претходни поступак или председник већа за главни претрес, односно судија појединац, а саветника поставља председник суда пред којим се води поступак редоследом са списка сталних судских вештака у том суду.

Место стручног лица у односу на процесни положај стручног саветника и вештака у области психијатријског вештачења

У области психијатријског вештачења, може се поставити и питање, процесног положаја и улоге стручног лица, у односу на процесни положај стручног саветника и вештака, као трећег кривичнопроцесног субјекта, који даје своје стручно мишљење у кривичном поступку. Оно што је заједничко, за сва ова три кривичнопроцесна субјекта је, да пружају стручну помоћ у току кривичног поступка. Према томе, стручно знање је основно обележје које представља сличност између ових кривичнопроцесних субјекта. Са друге стране, основне разлике између вештака, стручног саветника и стручног лица се огледају у: 1. начину пружања стручне помоћи, 2. процесној форми фиксирања резултата њихове делатности и 3. њиховом процесном положају у кривичном поступку.

Ако направимо краћи осврт на место стручног лица у кривичном поступку, може се уочити, да за разлику од стручног саветника, стручно лице, у дужем временском периоду егзистира као кривичнопроцесни субјект. Ранији Законик о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 70/01, 68/02

и “Службени гласник РС”, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 20/09 - др. закон и 72/09, 76/10) - у даљем тексту ЗКП/2001), такође је предвиђао да се под одређеним законским условима може као учесник у кривичном поступку појавити стручно лице. Улога стручног лица у кривичном поступку према ЗКП/2001 и садашњем Законику, није у битном измењена. Она је измењена превасходно у томе што одређене радње у истрази које је раније предузимао истражни судија сада предузима јавни тужилац, тако да ће стручно лице у истрази, према важећим законским одредбама, практично бити ангажовано од стране јавног тужиоца, а не као раније од стране истражног судије.

Помоћ стручног лица користи се углавном у истрази, али се може користити и пре истраге и после завршене истраге. Јавни тужилац, ангажује стручно лице у претходном поступку “ради разјашњења појединих техничких или других стручних питања која се постављају у вези са прибављеним доказима или приликом саслушања осумњиченог или предузимања других доказних радњи” (члан 300. став 9. ЗКП). Наиме, уколико јавни тужилац, саслушавајући окривљеног и сведоке или одлучујући о фиксирању трагова или привременом одузимању предмета, оцени да му је потребно да располаже одређеним стручним сазнањима, да би могао да оцени шта је у датом случају важно за истрагу, о чему и у ком правцу треба поставити питања, на чему заснивати своје примедбе, може затражити потребна обавештења од стручног лица.⁸ Помоћ стручног лица може се користити у свим врстама доказних радњи: при увиђају, претресању стана и лица, привременом одузимању предмета, саслушању окривљеног и испитивању сведока, посебно малолетних. Стручна лица, као што су психолог, педагог, психијатар, могу имати посебан значај приликом испитивања посебно осетљивих сведока (члан 104. ЗКП), као што су малолетна лица, лица са одређеним психичким проблемима, жртве насиља и др., а која у даљем току кривичног поступка, могу бити и предмет психијатријског вештачења. Дужност стручног лица је двострука он на тражење органа поступка даје обавештења и истовремено пружа стручну помоћ. Одредбом члана 133. став 3. ЗКП је прописано да ће “орган поступка приликом предузимања увиђаја по правилу затражити помоћ стручног лица форензичке, саобраћајне, медицинске или друге струке која ће по потреби, предузети и проналажење и обезбеђивање или описивање

⁸ Војислав Ђурђић, „Кривично процесно законодавство као нормативна претпоставка ефикасности поступања у кривичним стварима.“ Збор. Кривично законодавство, организација правосуђа и ефикасност поступања у кривичним стварима, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2008.

трагова, извршити потребна мерења и снимања, сачинити скице, узети потребне узорке ради анализе или прикупити друге податке.” Дакле, као помоћ органу који предузима увиђај могу, по његовој одлуци и под његовим руководством, учествовати стручна лица одговарајуће струке (форензичке, саобраћајне, медицинске и др.) ради обављања појединих криминалистичких стручних или техничких послова.

Иако законодавац и кривичнопроцесна теорија прецизно не одређују појам стручног лица, у великој мери је прихваћено, да стручно лице, поред вештака, који пружа помоћ органу кривичног поступка, на плану утврђивања правно-релевантних и других чињеница, такође пружа помоћ органу кривичног поступка на плану решавања појединих техничких и других стручних питања, као и у извођењу појединих доказних радњи. Стручно лице се помиње и у скраћеном поступку, у коме помоћ стручног лица може користити јавни тужилац коме је судећи судија после пријема оптужног предлога наредио да спроведе поједине доказне радње или допуни спроведене (члан 501. став 5. ЗКП).

Посматрајући стручно лице и вештака, као стручњаке који учествују у кривичном поступку може се уочити да стручно лице пружа помоћ органу кривичног поступка у разјашњавању техничких и других стручних питања (која могу бити и из области психијатрије) и у извођењу појединих доказних радњи. Вештак психијатар пак пружа стручну помоћ органу кривичног поступка, у утврђивању спорних правно-релевантних чињеница које се тичу урачунљивости окривљеног и обавеза је вештака, да у налазу истакне да ли је код окривљеног у време извршења кривичног дела постојала душевна болест, привремена душевна поремећеност, заостали душевни развој или друга тежа душевна поремећеност. У случају да утврди постојање наведене чињенице, вештак ће одредити природу, врсту, степен и трајност поремећености, а ако сматра да теже душевне поремећености није било дужан је да то објасни. Вештак психијатар такође може уколико утврди неки од душевних поремећаја, предложити изрицање неке од мера безбедности психијатријског лечења. Осим у односу на неурачунљива лица код којих су мере психијатријског лечења главни и најважнији одговор друштва на њихову опасност од поновног вршења кривичног дела, те мере имају велики значај и код битно смањено урачунљивих лица. Иако је у односу на њих главна реакција друштва на учињено кривично дело казна (или санкција која је замењује као што је условна осуда), она није увек довољна и у одређеним случајевима постоји оправдање да се уз казну реагује и мером безбедности чија је садржина

психијатријско лечење таквог учиниоца кривичног дела, а у циљу смањивања ризика и вероватноће од поновног вршења кривичног дела.⁹ Стручни саветник, пружа стручну помоћ странци која га је ангажовала у области у којој је одређено вештачење, али у крајњем, својим стручним мишљењем, такође доприноси утврђивању правно-релевантних и других чињеница које су од значаја за решење конкретне кривичне ствари.

Када је у питању форма у којој се у кривичном поступку фиксира резултат делатности вештака, стручног лица и стручног саветника, могу се уочити значајне разлике. Наиме, вештак пружа помоћ органу кривичног поступка у утврђивању оних правно-релевантних и других чињеница за чије је утврђивање потребна односно нужна примена посебног стручног знања. Резултат вештачења се фиксира се у посебном процесном спису, тј. у писаном налазу и мишљењу вештака, односно у записнику о испитивању вештака, који садржи његов налаз и мишљење. Стручно лице - стручњак, специјалиста пружа помоћ органу кривичног поступка у разјашњењу појединих техничких и других стручних питања, односно у извођењу појединих доказних радњи, за чије је извођење потребно посебно стручно знање. Резултат делатности стручног лица манифестује се у јединству са резултатом делатности органа кривичног поступка, тј. овај резултат се фиксира у истом процесном спису у коме се фиксира и резултат изведене процесне радње, нпр. у записнику о увиђају, или записнику о испитивању окривљеног итд. Такође када, јавни тужилац или суд зависно од фазе поступка, именује и позива стручно лице то чини без неког формалног акта, према свом избору. Писмена наредба, као у случају када се одређује вештачење се не доноси, нити се писмено одређују питања на која стручно лице треба да одговори. Стручно лице не полаже заклетву. Резултат делатности стручног саветника је његов исказ, који може бити дат у писаној форми, као и усмено на записнику о његовом испитивању и не подлеже некој посебној процесној форми. Суштина резултата исказа стручног саветника је, да представља одређену врсту примедби на налаз и мишљење вештака, које примедбе износи стручни саветник на стручан начин у име странке (по пуномоћју које му је странка дала).

Можемо такође рећи да је процесни положај вештака у кривичном поступку много повољнији у односу на процесни положај стручног лица и стручног

⁹ Зоран Стојановић, “Мере безбедности психијатријског лечења - Принудно психијатријско лечење као кривична санкција”, *Crimen (V)* 2/2014, 145–172, стр.146.

саветника. Вештак, је један од кључних кривичнопроцесних субјеката при утврђивању чињеничног стања, и има много шира права у својој делатности, много је самосталнији али и много одговорнији за своју делатност од стручног саветника. Конкретно, од датог налаза и мишљења вештака психијатра веома често зависи даљи ток кривичног поступка и кривична санкција која ће се изрећи у посматраном случају. Постојећа решења у Кривичном закону Србије воде рачуна о потреби да се на понашање одређених категорија лица (неурачунљива и битно смањено урачунљива лица) реагује и принудним психијатријским лечењем. Када су у питању одређени учиниоци кривичних дела и одређене ситуације, сама казна не може бити довољан и адекватан начин реаговања на вршење кривичних дела. Штавише, у односу на неурачунљиве учиниоце мера безбедности је основна санкција, која се предлаже управо психијатријским вештачењем. Док је казна, односно претња казном, окренута пре свега потенцијалним учиниоцима, мере безбедности су кривичне санкције предвиђене да буду реакција на индивидуалну опасност одређеног учиниоца. Опасност учиниоца се схвата као опасност за околину, опасност да се врше нова кривична дела. То значи да се примена мера безбедности више не везује за одређене типове деликвената, нити да су прихватљиве биолошке, односно биопсихолошке интерпретације појма опасности учиниоца. То није никаква генерална опасност, или друштвена опасност учиниоца, већ индивидуална, ситуациона опасност од тога да одређени учинилац у одређеној ситуацији понови кривично дело. Избор, врста и трајање мере безбедности одређује се, пре свега, на основу процене опасности учиниоца, а што је у непосредној вези са резултатима психијатријског вештачења.

Са друге стране, стручно лице, према кругу својих процесних овлашћења, није ни сведок, ни вештак, ни стручни саветник, он је нека врста помоћника јавног тужиоца, иако према законским одредбама и судској пракси нема сметњи да се стручно лице саслуша као сведок о ономе што је запазио приликом пружања своје стручне помоћи или да буде касније у току поступка буде одређен као вештак. Међутим, као и у случају када се за вештака или стручног саветника одређује лице које је испитано као сведок, и тада треба водити рачуна и о свим поменутих ограничењима и доказној вредности таквог вештачења. Према ставу Заједничке седнице од 25-26. октобра 1979. године (Заједничка седница Савезног суда, Врховних судова и Врховног војног суда од 25. и 26.X1979. године), стручно лице треба одредити за вештака само изузетно у случају опасности од одлагања или кад нема другог вештака.

Када је у питању однос странка и осталих учесника кривичног поступка, према стручном лицу, оне имају право, уколико присуствују доказној радњи у којој стручно лице даје одређене информације значајне за поступак, да поставе питања и да траже од стручног лица обавештења ради заузимања свог ставе или за потврду својих исказа. У Законнику је предвиђена и могућност изузећа стручног лица као и стручног саветника а у трошкове поступка су убрајани и трошкови стручног лица као и стручног саветника, а што све важи и за вештака. Наведено на извештан начин, додатно приближава ове процесне субјекте, међутим, њихов кривичнопроцесни положај се значајно разликује.

Нови Законик о кривичном поступку је поставио јасну границу између оних доказа које је предложио тужилац, затим оних које је предложила одбрана и најзад, оних чије је извођење одредио суд, и то изузетно, по службеној дужности. Наведено је као што смо видели од значаја и за процесне улоге поменутих кривичнопроцесних субјеката. Када је у питању улога резултата делатности вештачења, исказа стручног саветника и исказа стручног лица у доказном поступку, важно је истаћи да само вештачење представља доказну радњу. Стручно лице има више консултативну улогу приликом обављања тачно одређене доказне радње и представља најчешће део те предузете доказне радње. Исказ стручног саветника има доказну снагу и суд се у образложењу пресуде може на њега позивати, међутим исти не представља самосталну доказну радњу, већ се може ценити само у оквиру предузете доказне радње вештачења.

Закључак

Нови Законик о кривичном поступку је дао одговор на значајно питање које дуги низ година постављала кривичнопроцесна теорија, а судска пракса примењивала, а да није било посебне законске регулативе, да ли се стручна помоћ може пружати и кривичнопроцесним странкама, с обзиром да доприносе утврђивању правно-релевантних и других чињеница у кривичном поступку. Увођење стручног саветника као новог кривичнопроцесног субјекта који располаже стручним знањем и који може пружати стручну помоћ странкама у једној од најзначајнијих доказних радњи у вештачењу, представља једну од битних новина у нашем кривичном поступку. Наиме, кривичнопроцесне странке, тј. овлашћени тужилац и окривљени доприносе утврђивању чињеница првенствено стављањем предлога органу кривичног поступка за

извођење доказа помоћу којих се утврђују чињенице а затим и могућношћу да присуствују извођењу доказа којом приликом имају право да буду активне тј. могу да постављају питања, да траже објашњења да стављају предлоге у извођењу других доказа, при чему јавни тужилац у истрази представља орган поступка и руководи истрагом.

Полазећи од тога да кривичнопроцесне странке доприносећи утврђивању чињеница, истовремено доприносе и успешном расветљењу и решењу кривичне ствари, законске одредбе о стручном саветнику створиле су услове да и кривичнопроцесне странке могу да се користе стручним знањем, ангажовањем стручног саветника, који им може пружити помоћ на плану бољег разумевања стручног налаза и мишљења вештака и допринети остваривању њихових процесних права. Наведено је посебно значајно у области психијатријског вештачења, које може бити од великог утицаја на исход кривичног поступка и директно утицати на врсту кривичне санкције коју суд изриче.

Сматрамо да би стручном саветнику у кривичном поступку требало дати већа права и ослободити га ограничења, која му намеће како закон тако и судска пракса. С обзиром да јавни тужилац, скоро да нема практичне могућности, али ни интерес да у кривичном поступку ангажује стручног саветника, јер увек може ангажовати стручно лице или вештака, нити му стручни саветник може бити постављен у смислу одредбе чл. 125.ст. 3. ЗКП као државном органу, било би једноставније са становишта судске праксе а и законске регулативе, прописати законом стручног саветника, као кривичнопроцесног субјекта који може бити само на страни одбране и у складу са тим одредити његов круг права и дужности.

Dragan Jovic

President of the Appellate Court in Nis

Dijana Jankovic

PhD, judge at the Appellate Court in Nis

EXPERT ADVISOR AS THE SUBJECT OF THE PSYCHIATRIC EXPERTISE -PROCEDURAL POSITION AND CONTRIBUTION TO THE EXPERTISE

Abstract

One of the most important novelties in the domestic criminal procedural law is the introduction of the expert advisor in criminal proceedings, as a qualified in the field in which the expertise is demanded. The field of psychiatric expertise is a very complex issue. The fact that the practical value of the psychiatric expertise results as well as that the finding and the opinion of an expert are of considerable significance in the evidentiary process implies that the subject of the exposure are the issues concerning criminal procedural position of the expert advisor as the subject of the psychiatric expertise. Since the activities of the expert advisor are related to the expertise, special attention will be payed on the authorization of the expert advisor in the case of psychiatric expertize concerning the relation between the expert and the expert advisor in the criminal procedure as well as the evidentiary strength of their opinions.

Key words: expert advisor, psychiatric expertise, expert, professional person.

Др Дијана Јанковић

Судија Апелационог суда у Нишу

СПОРНО ПИТАЊЕ

ФЕТУС КАО ОБЈЕКТ РАДЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА НЕСАВЕСНО ПРУЖАЊЕ ЛЕКАРСKE ПОМОЋИ

У судској пракси поставило се као спорно питање:

Да ли смрт фетуса бремените жене, који је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот, која је наступила услед кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ, представља смртну последицу у смислу кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259 ст. 2. или ст. 4. КЗ?

Повод за наведено питање је био један број предмета у којима су судови одлучивали по оптужницама јавних тужилаца, које су подигнуте против оптужених лекара због кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. ст. 2. (или ст. 4.) у вези чл. 251. ст. 1. (или став 3.) КЗ, јер су према наводима оптужби, оптужени - лекари, очигледно несавесно поступали (неком од алтернативно прописаних радњи из кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ), те да је услед тих њихових радњи наступила квалификована последица у виду смрти фетуса. Дакле, став оптужби је био да смрт фетуса представља квалификовану последицу кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. КЗ. Радило се, по правилу, о случајевима када је смрт фетуса наступила, док је бременита жена била под лекарским надзором, најчешће у болничким условима, где је примљена ради порођаја.

Конкретно, поставило се питање у случају ако би се утврдило да је до смрти фетуса (који је био способан за ванматерични живот), дошло услед пропуста лекара или здравственог радника тј. неком од законом прописаних радњи кривичног дела из чл. 251. ст. 1. или 2. КЗ које представљају очигледно несавесно поступање (нпр. неблаговремени порођај, непружање адекватне

медицинске помоћи и др.), да ли би се у тим случајевима радило кривичном делу тешко дело против здравља људи из чл. 259. ст. 2. или ст. 4. КЗ, где би квалификована последица била смрт фетуса (тј. да ли се фетус у том случају може сматрати “лицем” у смислу наведеног кривичног дела).

Постављено питање је било предмет разматрања кривичних одељења Апелационих судова у Нишу, Београду, Новом Саду и Крагујевцу. **Поводом наведеног питања није постигнута јединствена сагласност кривичних одељења сва четири Апелациона суда.** Питање је такође било разматрано на заједничком састанку представника апелационих судова и Врховног касационог суда, дана 29.09.2017. године у Нишу, међутим није постигнута сагласност свих апелационих судова поводом наведеног питања, тако да ће коначни став у вези са постављеним питањем дати Врховни касациони суд.

1. Кривично одељење Апелационог суда у Нишу је заузело јединствени став да се:

Фетус који је достигао толики степен развоја да је способан за ван-матерични живот, сматра живим бићем, ужива кривичноправну заштиту и може представљати објект радње кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ и смрт фетуса може представљати квалификовану последицу кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. ст. 2. или ст. 4. КЗ.

При одговору на постављено питање се пошло од тога да је потребно претходно одговорити на следећа питања:

- Када плод (фетус) бремените жене постаје објект кривичноправне заштите као живо људско биће?
- Да ли фетус може бити објект радње кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ, па тиме и смртне последице кривичног дела људи тешко дело против здравља људи из чл. 259. ст. 2. или ст. 4. КЗ?
- Односно да ли је објект радње наведеног кривичног дела у конкретном случају само бременита жена или то може бити и плод?

1) Да би уопште могло да се расправља о смртној последици у виду смрти фетуса, неопходно је напре размотрити од ког момента започиње кривичноправна заштита живота човека, у домаћем кривичном праву.

Посматрајући кривично убиство из чл. 113. КЗ, кривично дело тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 8. КЗ где је радња кривичног дела “ко лиши

живота дете или бремениту жену” или кривично дело убиство детета при порођају из чл. 116. КЗ (као и друга дела из групе кривичних дела против живота и тела), неспорно је да је објект радње ових кривичних дела а истовремено и објект кривичноправне заштите живо људско биће.

Од нарочитог је значаја утврђивање времена када плод (фетус) бремените жене може да буде као живо биће објект убиства, односно када је у питању кривично дело тешко дело против здравља људи из чл. 259 ст. 2. или ст. 4. КЗ, квалификована смртна последица?

Из одредбе чл. 116. КЗ, којом је прописано кривично дело убиство детета при порођају, следи да се убиство може извршити већ за време порођаја.

Кривичноправна заштита почиње живота почиње од момента када је живи плод достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот, самим моментом рађања и није неопходно да је плод одвојен од тела мајке. Према прихваћеним становиштима судске праксе, отпочињање рађања представља временско разграничење када плод постаје објект убиства.

За отпочињање рађања, према прихваћеној судској пракси, као што је поменуто, није потребно да је плод одвојен од тела мајке.

Судска пракса је прихватила на пример, да отпочињање рађања у складу медицинским сазнањима настаје наступањем контракција мишића материце (тзв. трудови), које су болне (јер контракција материце постоји већ од десете седмице трудноће и траје све до краја трудноће, али их трудница не осећа као болне), редовите, ритмичне и у правилним временским размацима и трајању које доводе до ширења грла материце. При том, није од значаја да ли је до ових трудова дошло спонтано или уметнуто (нпр. индукцијом, применом лекова и сл.). Почетком порођаја се сматрало и прерано прснуће водењака са отицањем плодове воде иако трудови не постоје, а може да буде и непромењено грло материце. И са медицинског становишта жена са прерано прснутим водењаком сматра се породилцом, а не трудницом. Отпочињањем порођаја се може сматрати и тренутак када је фетус зрео и спреман за редован порођај и ванматерични живот.

Плод може бити предмет кривичноправне заштите и у случају превременог порођаја, уколико наступи смрт плода, с тим што би се морао, у сваком конкретном случају, утврђивати степен развијености плода и његова способ-

ност за ванматерични живот, па би се на основу тога оцењивало да ли постоји кривично дело и о ком би се кривичном делу могло евентуално радити.

Може се закључити: Да фетус почиње да ужива кривично правну заштиту од момента када је живи плод достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот. За моменат отпочињања рађања није неопходно да је плод одвојен од тела мајке и може се налазити и у телу мајке, и моменат отпочињања рађања зависиће од конкретнoг случаја.

- 2) Друго је питање да ли фетус може бити објект радње кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ, па тиме и смртне последице кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. ст. 2. или ст. 4. КЗ и од ког момента?

Дакле, предмет разматрања је кривичноправна заштита живота фетуса у вези са кривичним делом несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. Кривичног законика и квалификоване смртне последице (у виду смрти фетуса) која евентуално може проистећи (кривично дело тешко дело против здравља људи из чл. 259 ст. 2. или ст. 4. КЗ). Карактеристично за наведено дело је: да се о врши при пружању лекарске помоћи, да учинилац може бити само лекар или други здравствени радник (чл. 251. ст. 1. и ст. 2. Кривичног законика), као и да чињење или нечињење лекара или другог здравственог радника треба да се односи на поступак пружања лекарске помоћи, а у конкретном случају на пружање лекарске помоћи бременитој жени и фетусу. Наведене околности разликују предметно кривично дело од других дела, у којима такође услед неке радње учиниоца може да наступи последица у виду смрти фетуса.

Када су у питању кривична дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. ст. 2. у вези чл. 251. ст. 1. и ст. 2. КЗ (постоји умишљај у односу на основно дело) или из чл. 259. ст. 4. у вези чл. 251. ст. 3. КЗ (постоји нехат у односу на основно дело), радњу основног кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. ст. 1. КЗ врши, лекар који при пружању лекарске помоћи примени очигледно неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења, или не примени одговарајуће хигијенске мере или уопште очигледно несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица, казниће се затвором од три месеца до три године.

У судској пракси је прихваћено да су у оквиру појма “средство лечења” обухваћена сва “средства која се уносе у организам или стављају на тело

ради постављања дијагнозе или лечења или из превентивних разлога”. “Начин лечења” представља метод који се примењује у дијагностици и лечењу. Под применом “очигледно неподобног средства” или “очигледно неподобног начина лечења” подразумева се све оно што у делатности лекара очигледно односно у великој мери одступа од важећих, општеприхваћених принципа медицинске науке и праксе, односно оно што представља упадљиву грешку која излази из оквира медицинске толеранције. Медицинском толеранцијом сматра се оно што је обухваћено медицинским схватањем појма лекарске грешке, а што је фактичко питање које се утврђује савком конкретном случају.

Тежа последица из кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. КЗ, било да се ради о тешкој телесној повреди или смрти, је увек обухваћена нехатом.

Одредбом чл. 27. КЗ је прописано када постоји одговорност за тежу последицу. У случају кад је из кривичног дела произашла тежа последица због које закон за то дело прописује тежу казну, та се казна може ако је учинилац у односу на ту последицу поступао из нехата, а са умишљајем ако тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела.

Да би се одговарало за облик кривичног дела који је квалификован тежом последицом потребно је да буду испуњена два услова. Први је да је постојала узрочна веза између извршеног основног кривичног дела и наступања теже последице. Други услов одговорности за дела квалификована тежом последицом јесте да се та последица може “приписати” нехату учиниоца односно да је он у односу на ту последицу поступао из нехата. И виност се у оваквим случајевима утврђује кроз две фазе: у односу на основно кривично дело и у односу на тежу последицу.

Када је у питању објект радње кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ, па тиме и смртне последице кривичног дела људи тешко дело против здравља људи из чл. 259. ст. 2. или ст. 4. КЗ, неопходно је најпре размотрити да ли објект радње основног облика дела, у случају да се пружа медицинска помоћ бременитој жени, може бити само бременита жена или и њен плод.

Кривично дело несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. ст. 1. и ст. 2. КЗ, у оба своја облика је свршено кад је услед несавесног пружања лекарске помоћи од стране лекара или несавесног поступања другог здравственог радника проузроковано погоршање здравственог стања неког лица.

Како је објект радње дела лице, дакле живо биће, сматрамо да се појам фетуса као живог бића и објекта према коме може бити предузета радња извршења кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи, треба схватити управо на напред наведени начин, те да фетус ужива кривичну правну заштиту од момента када је живи плод достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот и да од тог тренутка може бити објект кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи, тако да су објект кривичноправне заштите у том случају и фетус и бременита жена.

Поред тога тога, медицина јасно поима фетус као самосталног пацијента на коме се не само поставља дијагноза, него и практикује фетална терапија. Плод се у утроби труднице може посматрати са великом прецизношћу и јасним уочавањем срчане радње и осталих виталних функција. Фетус се у том смислу сматра пацијентом, при чему лекар обавља дијагностику и прати његов развој. У појединим случајевима, лекари примењују и одређене феталне терапија ради медицинског третирања и правилног развоја плода. Напредак у развоју медицине, укључујући и ултразвучну дијагностику, слушање откуцаја тонова срца плода и др., омогућио је да се утврди да ли је дете живо и одрживо унутар тела мајке. Лекар би у највећем броју случајева био у могућности да у складу са медицинским знањем и искуством предвиди могући ток развоја фетуса и порођаја и да благовремено интервенише, што зависи од случаја до случаја и било би предмет посебног утврђивања суда.

Сходно наведеном сматрамо да плод (фетус) бремените жене, који је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот, може представљати објект радње кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ, па самим тим квалификовану последицу кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. КЗ.

Степен развоја фетуса, његова способност за ванматерични живот и отпочињање рађања, представљају фактичка питања која ће се утврђивати у сваком конкретном случају.

Може се закључити: Плод (фетус) бремените жене, може представљати објект радње кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из чл. 251. КЗ, а може и представљати квалификовану последицу кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259. КЗ, при чему је неопходно да је фетус достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот.

2. Кривично одељење Апелационог суда у Новом Саду је на седници кривичног одељења заузело исти став, као и Апелациони суд у Нишу:

Да се фетус, а у наведеном случају је то нерођено дете које је иначе било способно за ванматерични живот, до чијег рођења, међутим, није дошло због кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 251 КЗ, има сматрати живим бићем односно “лицем” у смислу законског описа кривичних дела у питању.

Смиљка Матковић, судија Апелационог суда у Новом Саду је у свом реферату поводом одговора на наведено питање навела да се према садржини постављеног питања, не показује се спорним утврђење да је смрт фетуса бремените жене (који је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот) наступила услед кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 251. КЗ. Истиче се да оно што се, показује спорним у вези са постављеним питањем, јесте да ли се фетус бремените жене који је достигао толико степен развоја да је способан за ванматерични живот а чија је смрт наступила услед кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 251. КЗ сматра “лицем” у смислу одредаба члана 259. КЗ?

Према наведеном мишљењу, ако би се фетус наведеног степена развоја, дакле да је био способан за ванматерични живот, сматрао “лицем” у напред наведеном смислу, дакле, спрам наведених законских одредаба члана 251. односно члана 259. КЗ, тада би смрт фетуса под датим околностима представљала смртну последицу у смислу члана 259. став 2. или став 4. КЗ односно супротно томе, ако се не би сматрао “лицем” тада се не би могло радити о смртној последици у смислу кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259. став 2. или став 4. КЗ па нити о том кривичном делу. Код таквог стања ствари, у другом случају, не доводи се у питање постојање кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 251. КЗ, услед ког дела је и дошло до смрти фетуса, како би то произилазило из садржине постављеног спорног питања.

Апелациони суд у Новом Саду је прихватио закључак да, без обзира што правна, али ни медицинска струка у Србији, па ни у свету, као ни међународне конвенције не дају јасан одговор на питање да ли је фетус живо биће или није (па самим тим, ни да ли је фетус” лице” или није, о чему је напред било речи), код неспорног са медицинске тачке гледишта да је плод иначе способан за ванматерични живот почев од 28. недеље, а по неким мишљењима

ма већ од 24. недеље, то у конкретном случају, по мом мишљењу, смрт фетуса достигнутог степена развоја да је био способан за ванматерични живот, која смрт је наступила услед кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 251. КЗ, представља смртну последицу у смислу кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259. став 2. или став 4 КЗ.

3. Кривична одељења Апелационог суда у Београду и Апелационог суда у Крагујевцу су на састанцима својих кривичних одељења били супротних мишљења од Апелационог суд у Нишу и Новом Саду. Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу, је на седници 06.09.2017. године, након дискусије, усвојило већином гласова став да:

Фетус, без обзира што би вештачењем био утврђено да је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот, не може се подвести под појам “лице” у смислу одредбе чл. 251. ст. 1. и ст. 1. КЗ, па тиме смрт (угинуће) фетуса не може представљати квалификаторну околност која би основно дело из чл. 251. КЗ чинила квалификованим (тежим) обликом дела из чл. 259. КЗ. Ова околност може бити значајна само код одлуке о кривичној санкцији.

У допису Апелационог суда у Крагујевцу I-Су-7-17/17 од 06.09.2017. године, је наведено да: “Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу сматра да се ово спорно питање не може изоловано посматрати, односно само у погледу кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи (односно тешка дела против здравља људи), јер одговор на ово питање је од значаја и за друга кривична дела, пре свега код кривичног дела убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 11. КЗ (са напоменом да постоји посебан облик дела тач. 9. који се односи на лишење живота бремените жене и не прави се разлика у ком месецу трудноће је била оштећена у тренутку лишења живота односно да ли је фетус “достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот), те код свих кривичних дела код којих се (тежа) последица састоји у наступању смрти оштећеног лица у смислу да ли је смрт наступила код једног или два (више) лица у случају када је смртно страдала бременита жена. Осим тога, ово кривично одељење упућује и на кривично дело недозвољен прекид трудноће из чл. 120. КЗ, које није сврстано у кривична дела убиства односно лишење живота (од чл. 113. до 118. КЗ) без обзира на “степен развоја фетуса”, те упућује на кривично дело убиство детета при порођају из чл. 116. КЗ где се убиство може учинити (па дакле ужива кривичноправну заштиту) само према детету “за време порођаја или непосредно након порођаја”, дакле не пре него што је порођај отпочео”.

Кривично одељење Апелационог суда у Београду већином гласова се сложило са ставом кривичног одељења Апелационог суда у Крагујевцу, који гласи:

Фетус, без обзира што би вештачењем био утврђено да је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот, не може се подвести под појам “лице” у смислу одредбе чл. 251. ст. 1. и 2. КЗ, па тиме смрт (угинуће) фетуса не може ни представљати квалификаторну околност која би основно дело из чл. 251. КЗ чинила квалификованим (тежим обликом дела из чл. 259. КЗ. Ова околност би могла бити значајна само код одлуке о кривичној санкцији.

Дакле као што је поменуто, поводом наведеног питања није заузет јединствен став кривичних одељења апелационих судова, тако да је наведено питање и даље “отворено” као спорно питање, о чему ће свој став дати и Врховни касациони суд.

Осврт на праксу Европског суда за људска права и упоредноправна схватања фетуса у кривичном праву

Пракса Европског суда за људска права. Право на живот основа је сваког система за заштиту људских права. Члан 2 представља једну од основних одредби Европске конвенције о људским правима (“Конвенција”). Основна сврха члана 2 је заштита појединаца од незаконитог одузимања живота. Она проистиче из јуриспруденције Европског суда за људска права (“Суд”) да се дужност државе да штити право на живот, састоји од три главна аспекта:

1. Дужности да се њени службеници уздрже од незаконитог одузимања живота (такозвана негативна обавеза);
2. Дужности да истражује сумњиве смртне случајеве (такозвана процесна обавеза) и
3. Дужности да предузима кораке за заштиту живота, а посебно да спречава губитак живота, који се може избећи (такозване позитивне обавезе).

Упркос важности права из члана 2 његов обим је још увек у много чему нејасан. Конвенција, на пример, ништа не каже о томе када живот почиње или се завршава. То су значајна питања и у односу на права фетуса и бременитих жена.

Питање о томе да ли се право на живот из члана 2 Конвенције протеже на живот фетуса, углавном се постављало у предметима везаним за законе о дозвољеном прекиду трудноће. Европски суд за људска права није директно одговорио на питање да ли се чл. 2 Европске конвенције односи и на фетус и од ког тренутка. Стога изгледа да питања могућности прекида трудноће (абортуса), у односу на право фетуса на живот остају у оквирима процене државе у околностима у којима закони успостављају “правичну равнотежу између потребе да се осигура заштита фетуса и интереса жена”, како је сматрао Суд у предмету *Boso protiv Italije* (2002) [став 1].

У предмету, **X против УК (1980)**, Комисија Европског суда је у свом решењу одбацила (у ставу 19) тврдњу да фетус има апсолутно право на живот на основу члана 2. јер је сматрала:

“Живот фетуса тесно је повезан са животом труднице и не може се посматрати одвојено од њега. Када би се узело да члан 2. обухвата фетус, а његова заштита на основу тог члана у одсуству неког изричитог ограничења била сматрана апсолутном, тада би се морало сматрати да је прекид трудноће забрањен чак и ако наставак трудноће озбиљно угрожава живот труднице. То би значило да се “нерођени живот” фетуса сматра вреднијим од живота труднице...”

У предмету **RH против НОРВЕШКЕ (1992)** (став 1), Комисија је констатовала да би у одређеним околностима члан 2 могао да се примени на фетус:

“Комисија сматра да не мора да решава да ли би фетус могао да ужива заштиту на основу члана 2...али не искључује да под одређеним околностима то може бити случај без обзира што се државе-уговорнице прилично разилазе око тога да ли и у којој мери члан 2 штити нерођен живот.”

Међутим, Суд још није јасно рекао које би те околности могле бити.

У предмету **BOSO против ИТАЛИЈЕ (2002)**, (став 1), Суд сматра да се од њега не тражи да утврђује да ли се фетус може квалификовати за заштиту на основу члана 2. Конвенције. Чак и ако се претпостави да би у одређеним околностима за фетус могло да се сматра да има права заштићена чланом 2. Конвенције, Суд примећује да у датом предмету “иако подносилац представке није навео број недеља које су протекле пре прекида трудноће или тачан основ због којег је извршен, доказни материјал по свему судећи показује да је трудноћа његове жене прекинута у складу са ст. 5. Закона бр. 194 од 1978...”

По мишљењу Суда, такве одредбе успостављају правичну равнотежу између, са једне стране, потребе да се осигура заштита фетуса и с друге, интереса жене. (видети *Н. против Норвешке*, бр.17004/90, Одлука Комисије од 19. маја 1992.г., ДР 73, стр. 155).¹⁰

У предмету *VO против ФРАНЦУСКЕ (представка број 53924/00, 8. јули 2004)*, Суд се селективно позабавио питањем у којој мери члан 2. Конвенције обухвата фетус. (Видети: Људска права у Европи, Правни билтен број 56, 2004) Овај случај се односи на представку коју је поднела француска држављанка, гђа *Thi-Nho Vo*, рођена 1967. године и настањена у Француској. Она је 27. новембра 1991. године дошла у Општу болницу у ради лекарског испитивања заказаног за шести месец трудноће. Истог дана је друга жена, требало да буде подвргнута вађењу спирале. Због забуе која је настала због чињенице да обе жене имају исто презиме, доктор који је прегледао подносиоца представке пробио је плаценту, због чега је било нужно извршити прекид трудноће.

Подносилац представке и њен супруг поднели су кривичну пријаву 1991. године, и доктор је оптужен за нехатно наношење повреде, а затим је оптужба преиначена у убиство без предумишљаја. Кривични суд Француске га је 3. јуна 1996. године ослободио оптужби. Подносилац представке се жалила, и Апелациони суд је 13. марта 1997. године осудио доктора за убиство без предумишљаја и досудио му шест месеци условне казне и новчану казну од 10.000 француских франака. Касациони суд је 30. јуна 1999. године поништио пресуду Апелационог суда, сматрају и да чињенице случаја не указују на кривично дело убиства без предумишљаја; он је стога одбио да фетус сматра људским бићем које има право на заштиту кривичног закона.

Позивајући се на члан 2. Европске конвенције пред Европским судом за људска права, подносилац представке се жалила на одбијање власти да квалификују нехатно убиство њеног нерођеног детета као убиство без предумишљаја. Она је тврдила да Француска има обавезу да донесе закон који ће таква дела сматрати кривичним делима.

Суд је био мишљења да питање када право на живот почиње мора бити решено на домаћем нивоу; прво, зато што ово питање није разрешено у већини земаља које су ратификовале Конвенцију, конкретно у Француској, где је

¹⁰ *Interights*, Приручник за Правнике, члан 2 – Право на живот према Европској конвенцији о људским Правима, Ланцастер Хоусе, Лондон, 2005, стр.50.

предмет јавне расправе; и друго, зато што не постоји европски консензус у погледу научне и правне дефиниције почетка живота. Имајући ово у виду, Суд је био уверен да није ни пожељно нити могуће, како сада ствари стоје, начелно одговорити на питање да ли је нерођено дете особа за потребе члана 2. Конвенције.

У погледу случаја пред њим, Суд је сматрао да није неопходно испитивати да ли нагли прекид трудноће подносиоца представке спада у обухват члана 2., имајући у виду да, чак и под претпоставком да је та одредба применљива, није било пропуста Француске да се придржава захтева у погледу очувања живота у сфери јавног здравства. Нерођено дете није лишено сваке заштите по француском закону. Уз кривични поступак, који је подносилац представке покренула против доктора због нехатног наношења повреде, могла је да поднесе захтев за надокнаду штете у управном поступку који би имао добре изгледе за успех. Такав захтев би јој омогућио да докаже немар лекара, и да добије пуно обештећење за насталу штету. Стога није било потребе за покретањем кривичног поступка. Суд је сходно томе закључио да, чак и под претпоставком да је члан 2. Конвенције применљив на овај случај, није дошло до повреде те одредбе.

Само седам од седамнаест судија које су заседале у овом случају сложило се са образлагањем “већине”, иако се четрнаест сложило са закључком да није дошло до повреде. **Одлуком већине Великог већа избегнуто је одлучивање у погледу осетљивог питања које је постављено, и за које је Веће признало да је “суштинско” за случај (став 74.), наиме да ли фетус има право на заштиту према члану 2. Конвенције.** Суд је приметио да не постоји европски консензус у овом погледу, иако је сматрао да одредбе Европске конвенције о људским правима и биоетици штите зачет људски живот. Он је заобишао питање закључком да, “чак и под претпоставком” да фетус има право на ту заштиту, позитивне обавезе државе не укључују обезбеђивање правног лека у кривичном поступку када је уништење било нехатно.

Пет судија је у заједничком одвојеном мишљењу изнело да није логично рећи да нису обавезни да одлуче да ли је члан 2. Конвенције применљив на фетус, а онда закључити да, ако би био применљив, није повређен. Судије противног мишљења биле су става да би се могла захтевати било пуна кривична казна или бар озбиљна дисциплинска казна (која није досуђена) против немарног доктора. Четири од њих су сматрале да живот шестомесечног фетуса у овом случају спада у обухват члана 2. Конвенције.

Наведена пресуда је изазвала бројне полемике, критике и дискусије, изражено је мишљење да је вероватно очувала неутрални положај Суда који се очекује у погледу фетуса и члана 2. Конвенције, али да је тиме што је подржала приступ који су заузели француски судови (који је подржан од стране већине Европског суда) оставила мајку - чији је губитак последица озбиљног лекарског немара - без икаквог правног лека или правичне надокнаде за њен губитак. Осим тога у наведеној одлуци, Суд није конкретно разматрао питање да ли се члан 2. Европске конвенције, протеже на фетус, при чему је Суд између осталог био мишљења да питање када право на живот почиње мора бити решено на домаћем нивоу.

Упоредно право. У свим јурисдикцијама, како домаћој тако и међународним, правна питања која се односе на права фетуса сматрају се често спорним и предмет су интензивног извештавања медија и подлежу законским изменама. Питања која се налазе на првом месту се тичу права на прекид трудноће, смрти фетуса услед нехатног поступања лекара, дужности бриге о фетусу и сагласности трудне жене за прекид трудноће. Најспорније је питање правног субјективитета фетуса, односно да ли се и од ког тренутка фетус сматра живим људским бићем и да ли може да буде предмет судске заштите.

Пошто су кривична дела убиство и телесне повреде везана за појам “човек”, у теорији постоје различита гледишта о томе у ком тренутку фетус бива човек. Именује се, углавном, седам временских тренутака: 1) кад је трудница приметила прве покрете детета у својој утроби; 2) почетак рођења; 3) тренутак ступања водећег дела фетуса кроз спољашњи порођајни канал; 4) кад је фетус учинио први удисај; 5) кад фетус постане способан за живот изван мајчине утробе; 6) у тренутку зачећа; 7) у тренутку нидације.

Савезни уставни суд Немачке стао је на становиште да се уставна гаранција права на живот односи и на фетус у утроби мајке, па је држава дужна да му пружи ефикасну заштиту. По мишљењу тог суда, живот фетуса започиње 14. дана од зачећа, са тзв. нидацијом, која подразумева коначно учвршћивање плода у материци жене. Од тог тренутка, па све до зрелости плода, прекидање трудноће је, у начелу, забрањено и кажњиво. Та забрана односи се и на трудницу и на трећа лица, па и на лекара¹¹. Ипак, немачки Кривични законик допушта и изузетке од овог правила, слично осталим земљама Европе (V. § 218 новелираног и допуњеног текста Кривичног законика Немачке).

11 Радишић, Ј. (2008). *Медицинско право*, Београд: Номос, стр.113, фн.21 .

Према немачком праву, Кривични законик Немачке не признаје фетусу никаква посебна права до рођења. Међутим, Немачки грађански законик штити интегритет фетуса на исти начин као и интегритет трудне жене. Та заштита тиче се сваког медицинског захвата, како пренаталног тако и приликом рођења и повлачи обавезу накнаде штете. У неким јурисдикцијама, законодавство понекад прописује да фетус има сва права па и право на живот почев од тренутка зачећа. Ова законодавства прописују да је правни статус фетуса као живог бића једнак било ком другом животу рођеног човека.

Америчка конвенција о људским правима из 1978 године (*American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose, Costa Rica", B-32*) у члану 41 прописује да "Свако има право на поштовање права на живот. Ово право је заштићено законом од тренутка зачећа". Од 35 држава чланица Организације америчких држава које су ратификовале конвенцију, она је обавезујућа за 24 државе чланице.

У међународној правној терминологији и судској пракси се користи термин "*feticide*" или "*foeticide*", као назив за радњу којом се изазива незаконита смрт фетуса. Са правног аспекта "убиство фетуса" ("*foetal homicide*") односи се на умишљајно или нехатно убиство фетуса, као што је нпр. ударац у абдомен труднице или услед неадекватног пружања медицинске помоћи. Дакле, "*feticide*" није случај када је дошло до смрти фетуса услед природних узрока или спонтаним побачајем. У многим јурисдикцијама се сматра да је "убиство фетуса" озбиљно кривично дело. На пример у Индији термин "*foeticide*" се односи на чин убијања женских фетуса, како би се обезбедила мушка деца у настојању да се смањи укупан број деце у породици.

У САД, 2004. године, Конгрес је донео Закон о нерођеним жртвама насиља (*Unborn Victims of Violence Act 2004*), који предвиђа фетус ("*child in utero*") као правну жртву, ако је фетус убијен или повређен, приликом извршења неког од 68 кривичних дела, која су федералним законом прописана као злочини насиља. Наведени Закон дефинише фетус ("*child in utero*") као "биће из врсте "*Homo Sapiens*", у било којој фази развоја, које још није рођено и налази се у телу мајке". У САД, 35 држава прихвата "убиство фетуса", а од тога у 25 држава Закон се примењује на фетус од тренутка зачећа, током целог периода развоја плода, док 10 држава успоставља заштиту у каснијој фази развоја плода, што се разликује од државе до државе (*National Right to Life, Key Facts on the Unborn Victims of Violence Act, The National Right to Life Committee, 2004*). На пример, одлука Врховног суда Калифорније је

да се поступа са убиством фетуса, као са убиством, у складу са наведеним Законом, с тим што суд не третира убиство фетуса, од пре око осам недеља, како убиство.¹²

Наведене ситуације се разликују од схватања фетуса у случају остваривања права на прекид трудноће и услова који се траже за дозвољени прекид трудноће.

Питање да ли фетус има права на живот у случају прекида трудноће се разматра на другачији начин него у случају када је неким недозвољеним насилним актом или нехатном лекарском радњом прекинут живот фетуса. Полази се од тога да док фетус не живи независно од мајчиног тела не посматра се као самостална личност. У судском поступку пред Породичним судом у Аустралији (*Family Court of Australia, F v. F (1989) FLC 92-031*), супруг је поднео захтев породичном суду да донесе забрану којом би спречио његову трудну жену да прекине трудноћу. У тужби је тврдио да фетус има право на заштиту од прекида трудноће и да фетус може то право самостално остваривати у своје име. Суд је након разматрања захтева одлучио да: “Суд не може доносити етичке пресуде - јер суд примењује закон. Суд тумачи и примењује закон, а не моралне или етичке норме. Фетус нема лична права док се не роди и не буде егзистенцијално одвојен од мајке”. Суд је разматрао и да ли суд има право да заустави мајку, по захтеву оца, од прекида трудноће, те је суд нашао да: “Давање налога да се жена присили да уради нешто у односу на своје тело што она не жели, то би било мешање у њену слободу да одлучи о својој судбини”.

С друге стране умишљајно усмрћење фетуса (“*killing unborn child*”) је кривично дело које предвиђено у Западној Аустралији. За ово кривично дело прописана је максимална казна доживотног затвора због спречавања живота детета (*Criminal Code of the Northern Territory of Australia, section 170 - Killing unborn child -Criminal Code Act (NT)*).

У Великој Британији усмрћење фетуса, прописано је Кривичним законом из 1958. (*Crimes Act 1958 (UK)*): “Свако лице које са умишљајем уништи живот детета, које је способно да се живо роди, било којим умишљајним делом незаконито узрокују да дете умре пре порођаја, биће криви за уништење детета. Доказ да је жена у било ком тренутку у објективном времену од 28

¹² Sheena Meredith, *Policing Pregnancy: The Law and Ethics of Obstetric Conflict*, Ashgate Publishing, Ltd, 2005, p. 182.

недеља или више била трудна, доказиваће да је у том периоду носила дете способно да се роди”.

У САД, правило “да је дете живо рођено” (“*born alive*”), представљало је правни принцип, на основу кога су се законске одредбе, које се односе на кривично дело убиство и кривична дела са различитим облицима насиља, могле применити само на дете које је “живо рођено” (“*born alive*”). Међутим, савремени напредак медицинске науке, довео је до судских одлука које су укинуле ово правило.

Напредак у развоју медицине, укључујући и ултразвучну дијагностику, слушање откуцаја тонова срца плода и др., омогућио је да се утврди да ли је дете живо и одрживо унутар тела мајке, те су многе јурисдикције, посебно у САД, предузеле кораке да замене и укину овај принцип.

Крајем 2002. године у САД је било 23 држава које су у већој или мањој мери користиле правило “да је дете живо рођено” (“*born alive*”), временом се то правило све мање примењивало и његова примена се изостављала од случаја до случаја.

Један од таквих примера, када је правило изостављено је било у случају *Commonwealth vs. Cass* у држави Масачусетс, САД (*Commonwealth vs. Daniel I. Cass, in the Commonwealth of Massachusetts, 392 Mass. 799 October 5, 1983 - August 16, 1984*), где је суд сматрао да мртворођени осмомесечни фетус, чија је мајка повређена од стране возача, представља смртну последицу у смислу кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја (енг. *vehicular homicide*). Одлуком већине, Врховни суд Масачусетс, је нашао да је фетус “лице” у смислу законске одредбе која се односи на смртну последицу кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја.

Морамо напоменути и да је било и другачијих мишљења и да је неколико судова у САД сматрало да није у њиховој надлежности да ревидирају законодавство укидањем наведеног правила “да је дете живо рођено” (“*born alive*”), и закључило је да такве промене морају бити прописане од стране законодавца. Тако је 1970. године у предмету *Keeler v. Superior Court of Amador County*, Врховни суд Калифорније одбацио оптужницу којом је окривљени био оптужен за убиство јер је узроковао да дете његове жене буде мртворођено. Суд је био става да “Судови не могу ићи толико далеко да стварају кривична дела проширивањем законских одредби, убацивањем или брисањем речи или давањем новог значаја појмовима...”

Неколико јурисдикција САД, је након тога ревидирало своје законодавство, како би експлицитно укључиле у своје законодавство случајеве повреде фетуса пре порођаја.

Може се закључити, да законодавна регулатива и правна схватања у страним законодавствима иду у правцу, да свако ко напада или проузрокује смрт фетуса, сноси и кривичну одговорност због тога и треба да буде кажњен на исти начин као и да је тај напад извршен и према било ком лицу које је нападнуто и које је лишено живота, иако о наведеном питању још увек не постоје уједначена законска решења у законодавствима, а мишљења у судској пракси су веома подељена.

Закони “*born alive*” у САД су закони који права фетуса проширују на различита кривична дела као што су убиство, дела са елементима насиља и др., како би пружили кривично правну заштиту незаконитој смрти или повреди нерођеног фетуса који се још налази у телу мајке. Правни основ наведених закона налази се у напретку медицине која омогућава да се фетус медицински третира и види као живо биће у телу мајке и то омогућава да се социјално и правно прихвати као лице, у неком делу или током целе трудноће.

Поменути закони поништавају традиционални принцип да до физичког рођења фетус нема независно правно постојање од мајке и да стога не може бити жртва кривичног дела. Такви закони често обезбеђују пренесени умишљај (који се у често назива “пренесено кривично дело” - “*transferred malice*”), тако да се незаконито и противправно деловање које утиче на трудницу и на тај начин наноси штету њеном плоду може квалификовати као кривично дело према фетусу као жртви, као и према било ком другом лицу.

Закон о нерођеној жртви насиља, изричито предвиђа да се његове одредбе не односе нити дозвољавају гоњење било ког лица у вези са дозвољеним прекидом трудноће, лечењем мајке или њеног фетуса, нити утичу на став било које жене у односу на њен фетус.

Током последњих неколико деценија, закони о уништењу фетуса, постали су предмет жестоке дебате. Има мишљења да су такви закони неопходни, да би се заштитиле трудне жене од насиља и да би обезбедили накнаду штете у случајевима насиља и радњи који резултирају губитком фетуса. Са друге стране има супротних мишљења, да су наведени закони само средство којим се тежи за обезбеђењу правног субјективитета фетусу и осујећењу права на прекид трудноће.

PRAVNI KOMPLET



PRETPLATOM STIČETE PRAVO NA:

- 24 BROJA ČASOPISA
- SPECIJALIS: PARAGRAFOVU ZBIRKU SUDSKIH ODLUKA
- TELEFONSKE KONSULTACIJE
- ODGOVORE NA PITANJA U PISANOJ FORMI
- BESPLATNA JEDNODNEVNA SAVETOVANJA na temu popisa i godišnjih finansijskih izveštaja
- ZBIRKU PROPISA
- SVE BROJEVE objavljene u godini u kojoj je zaključena pretplata, u pdf formatu, na kraju kalendarske godine
- POPUSTE NA PRETPLATU na ostala izdanja i stručne skupove kompanije Paragraf

KONTAKT TELEFONI

BEOGRAD
Takovska 42

tel: 011/3290-393, 2750-952
fax: 011/2751-723

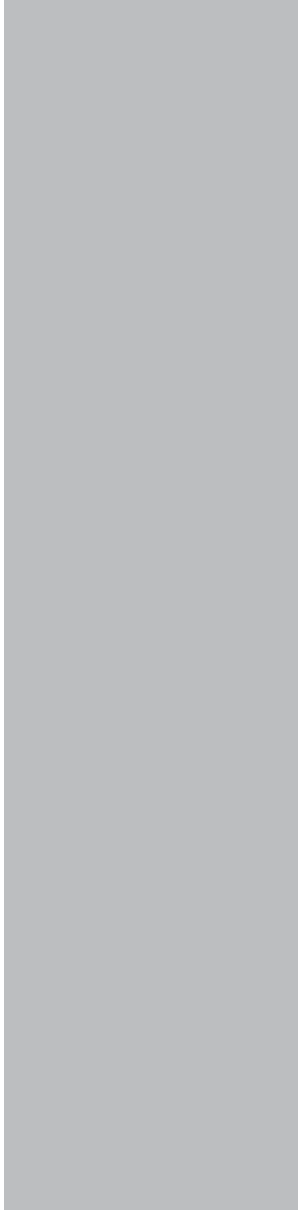
NOVI SAD
Kej žrtava racije 4a/III

tel: 021/557-505, 457-421
fax: 021/456-880

NIŠ
Obrenovićeve 11/I/5

tel: 018/528-808, 4100-030
fax: 018/511-839

ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА



ПРЕГЛЕД УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА

представника кривичних одељења Апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, у присуству представника Кривичног одељења Врховног касационог суда, на заједничким седницама одржаним у току 2016. године, око спорних питања од значаја за функционисање судова у Републици Србији и уједначавање судске праксе (члан 24. став 3. Закона о уређењу судова - “Службени гласник РС” бр. 116/08.....101/13).

Петроварадин - 25.03.2016. године

Услови за пуштање осуђеног на условни отпуст

Да ли су испуњени услови за пуштање осуђеног на условни отпуст (члан 46.КЗ) у ситуацији кад је у писаном извештају Завода у коме осуђени издржава казну затвора наведено да код осуђеног и стичу средњи степен ризика, а истовремено се образлаже да су испуњени законски услови и предлаже да осуђени буде пуштен на условни отпуст тако што се наводи да је сврсисходан условни отпуст и слично или се суду оставља на оцену одлука па се поставља питање на који начин поступити у ситуацији кад се образлаже да су испуњени законски услови и предлаже да буде пуштен на условни отпуст у ситуацији када Завод доставља суду на оцену да ли осуђени треба да буде пуштен и под следеће, када Завод ништа не предлаже или постоје противречности између наведеног утврђеног средњег степена ризика, с једне стране, а са друге стране наводи да су испуњени законски услови и предлаже да се осуђени условно отпусти па на који начин овакав извештај тумачити са становишта Апелационог суда приликом решавања о жалби?

“Уколико завод у писаном предлогу или представник завода на рочишту и даље наводи да код осуђеног постоји средњи степен ризика али истовремено

остаје код предлога да осуђени буде условно отпуштен са издржавања казне и то детаљно и убедљиво образложи, као и када је у извештају у суштини дато позитивно мишљење за условни отпуст али није изричито предложен већ је остављено суду на оцену па и када се завод уопште не изјашњава у том правцу, не искључује се могућност суда да донесе позитивну одлуку ако постоје законски услови за пуштање осуђеног на условни отпуст”.

Недоступност осуђеног који казну затвора треба да издржава у кућним условима- обезбеђење присуства

Да ли се код недоступности осуђеног који казну затвора треба да издржи у просторијама у којима станује имају применити мере за обезбеђење присуства у којима станује или се пак имају применити одредбе члана 29. став 2. и став 3. Закона о извештају ванзаводских санкција и мера и члана 45. став 6. КЗ у смислу доношења решења који се одређује да осуђени остатак казне издржи у заводу за извршење казне затвора?

“Присуство осуђеног који је тренутно недоступан има се обезбедити на исти начин као и када осуђени казну затвора треба да издржи у Заводу за извршење казне затвора па се у таквој ситуацији осуђени који казну затвора треба да издржи у кућним условима има привести на издржавање казне затвора у кућним условима. Одредбе члана 29. став 2. и 3. Закона о извршењу заводских санкција као и одредбе члана 45. став 6. КЗ које прописују замену казне затвора у кућним условима казном у Установи за извршење казне затвора односе само на ситуацију када осуђени након што је већ отпочео са издржавањем казне затвора у просторијама у којима станује, самовољно напусти исте у трајању преко шест часова или два пута у трајању до шест часова”.

Београд - 28.06.2016. године

Изузеће судије који је одлучивао у доношењу одлуке по жалби

1. Да ли је изузет од поступања у другостепеном већу судија који је у већу другостепеног суда претходно већ учествовао у доношењу одлуке по жалби на првостепену пресуду којом је та пресуда укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање? Исто питање се поставља и у односу на првостепеног судију коме је одлука укинута?

“Нема законским разлога предвиђених чланом 37. ст. 1. тач. 4. ЗКП за изузеће судије који је одлучивао у доношењу решења којим је први пут укинута пресуда, па исти судија може поново да поступа у истом предмету када тај предмет поново дође у другостепени суд. Исто важи и за судију који је одлучивао у првом степену, осим у случају из члана 458. став 2. ЗКП када другостепени суд нареди да се нови главни претрес пред првостепеним судом одржи пред потпуно измењеним већем.”

Ниш- 30.09.2016. године

**Жалба против другостепене пресуде
Јавни тужилац овлашћен за изјављивање**

1. Који јавни тужилац је овлашћен да изјави жалбу на другостепену пресуду у смислу одредби члана 463. ЗКП- јавни тужилац који је присуствовао претресу пред другостепеним судом (апелациони ЈТ пред Апелационим судом односно виши ЈТ пред Вишим судом) или пак јавни тужилац који је првостепеном суду поднео оптужни акт, заступао тај оптужни акт на претресу пред првостепеним судом и изјавио жалбу на првостепену пресуду чијим усвајањем је првостепена пресуда и преиначена на пресуду којом се окривљени оглашава кривим?

“Против другостепене пресуде донете по одржаном претресу пред другостепеним судом, овлашћен је да изјави жалбу у смислу одредби члана 463. ЗКП јавни тужилац који је првостепеном суду поднео оптужни акт на главном претресу и изјавио жалбу на првостепену пресуду, а непосредно виши јавни тужилац то право има само под условом да примени деволуцију у смислу члана 19. Закона о јавно тужилаштву и о томе обавести суд трећег степене”.

**Дозвољеност жалбе (у смислу члана 463.ЗКП)
против другостепене пресуде**

2. Да ли је дозвољена жалба у смислу одредбе члана 463.ЗКП против другостепене одлуке којом је преиначена првостепена пресуда о одбијању оптужбе и изречена пресуда којом се оптужени оглашава кривим?

“Против другостепене пресуде којом је преиначена првостепена пресуда о одбијању оптужбе и изречена пресуда којом се оптужени оглашава кривим, дозвољена је жалба, у смислу одредбе члана 463. ЗКП, суду трећег степена.”

Право на накнаду трошкова поступка наследницима покојног окривљеног (против кога је обустављен поступак услед смрти)

3. Да ли наследници покојног окривљеног према коме је кривични поступак обустављен услед његове смрти, имају право на накнаду трошкова кривичног поступка на име награде за ангажовање браниоца током поступка?

“Наследници покојног окривљеног према коме је кривични поступак обустављен услед смрти, имају право на накнаду трошкова кривичног поступка како на име награде за ангажовање браниоца током поступка тако и осталих трошкова који се наводе у одредби члана 265. став 1. ЗКП уколико их је окривљени платио.”

Крагујевац - 02.12.2016. године

Исказ сведока (који сведочи о ономе што му је привилеговани сведок рекао) - као доказ

1. Да ли се може користити као доказ и на њему засновати пресуда, исказ сведока који на суду сведочи о ономе што му је привилеговани сведок рекао о кривичноправном догађају који је предмет кривичног поступка, при чему привилеговани сведок у поступку сходно одредби члана 94. став 1. ЗКП користи своје право да не сведочи?

“Исказ сведока може се као доказ користити у описаној процесној ситуацији јер сведок на овај начин сведочи о чињеницама које је својим чулима опазио и коришћење тог исказа као доказа у кривичном поступку нити у супротности са било којом одредбом ЗКП, па се не ради о незаконитом доказу у смислу одредбе члана 84. став 1. у вези са чланом 16. став 1. ЗКП.”

СТАВОВИ

**Кривичног одељења Врховног касационог суда
око спорних правних питања у вези којих није
постигнута сагласност представника апелационих судова
(Нови Сад - 31.03.2017. године)**

Расписивање потернице и могућност наступања релативне застарелости кривичног гоњења

1. Да ли након расписивања потернице за лицем према коме се води кривични поступак може наступити релативна застарелост кривичног гоњења?

Даном расписивања потернице прекида се релативна застарелост кривичног гоњења и од тог дана застарелост кривичног гоњења почиње поново да тече у складу са одредбом члана 104. став 3. и став 5. КЗ па самим тим почиње и рачунање новог рока релативне застарелости гоњења.

Приватна кривична тужба и противтужба - међусобни однос

2. Питање је везано за однос приватне кривичне тужбе и противтужбе код кривичног дела увреда под околностима како је то образложено у конкретном случају са питањем каква је судбина противтужбе уколико је приватна к. тужба неблаговремена а противтужба благовремена, као и каква ће бити одлука суда уколико једна или обе странке прецизирају на главном претресу свог оптужни акт у погледу времена извршења кривичног дела?

Противтужба је везана за п.к.т само у тренутку подношења, а након тога противтужба има сопствену самосталност до правноснажног окончања поступка и на исход поступка по противтужби је без утицаја исход поступка по п.к.т.

Мера забране напуштања стана - и могућности дозволе свакодневног напуштања стана (ради боравка на свежем ваздуху)

3. Да ли се окривљеном коме је изречена мера забране напуштања стана, сходно одредбама ЗКП са или без електронског надзора, може дозволити свакодневно напуштање стана ради боравка на свежем ваздуху у току трајања ове мере?

Окривљеном коме је изречена мера забране напуштања стана не може се одлуком суда дозволити свакодневно напуштање стана ради боравка у одређеном времену на свежем ваздуху у току трајања ове мере јер ниједном законском одредбом ЗКП или Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера није предвиђено овлашћење суда да о томе одлучује, док су одредбом члана 208. ЗКП дата овлашћења суду да одреди услове самог боравка у стану и таксативно побројане ситуације када окривљени може изузетно а без одобрења суда напустити стан.

Судска рехабилитација и законска рехабилитација

4. Уколико су испуњени услови за законску рехабилитацију по две (или више) осуда којима је осуђени раније осуђиван у смислу одредбе члана 98. став 2. тач.4) КЗ, да ли се у смислу одредбе члана 100. КЗ може дати судска рехабилитација том лицу, будући да је у време друге (односно свих осталих) осуда био осуђиван у смислу одредбе члана 98. став 1. КЗ?

Уколико су у моменту одлучивања о судској рехабилитацији, у смислу члана 100. КЗ, у погледу прве осуде испуњени услови за законску рехабилитацију из члана 98. став 1. и став 2. тач. 4) КЗ, суд ће истовремено дати судску рехабилитацију за прву и остале осуде за које су испуњени услови из члана 98. став 2. тач. 4) КЗ, с обзиром да се давањем рехабилитације за прву осуду осуђени има сматрати неосуђиваним лицем у смислу одредбе члана 98. став 1. КЗ.

СТАВОВИ

**Кривичног одељења Врховног касационог суда
око спорних правних питања у вези којих није постигнута
сагласност представника апелационих судова
(Петроварадин - 25.03.2016. године, Београд- 30.06.2016. године,
Ниш- 30.09.2016. године и Топола, Оплењак -02.12.2016. године)
Петроварадин - 25.03.2016. године**

**Изрицање кривичне санкције (нпр. затвора) преиначењем
првостепеног решења (којим је млађем пунолетном
извршиоцу изречена васпитна мера)- могућност**

1. Да ли су другостепени суд може у седници већа, усвајањем жалбе јавног тужиоца, да преиначи првостепено решење којим је млађем пунолетном учиниоцу кривичног дела изречена васпитна мера, тако што би му била изречена одговарајућа кривична санкција која је законом прописана за пунолетне учиниоце кривичних дела (нпр. казна затвора)?

Другостепени суд не може у седници већа, усвајањем жалбе јавног тужиоца, да преиначи првостепено решење тако да млађем пунолетном учиниоцу кривичног дела уместо васпитне мере изрекне одговарајућу кривичну санкцију која је законом прописана за пунолетне учиниоце кривичних дела (нпр. казну затвора). Ово из разлога што је одредбом члана 81. ст. 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично - правној заштити малолетних лица (“Службени гласник РС”, бр. 85/2005) која се у смислу одредбе члана 1. став 1. истог Закона има применити у описаној процесној ситуацији, предвиђено да ако првостепеном одлуком није изречена казна малолетничког затвора или заводска мера, другостепено веће може ту казну, односно меру изрећи само ако одржи претрес.

Овлашћење суда трећег степена - могућност укидања другостепене пресуде (у предмету у ком је већ била укинута првостепена пресуда)

2. Да ли суд трећег степена може укинути другостепену пресуду у ситуацији када је у истом предмету већ једно била укидана првостепена (а не и другостепена) пресуда?

Суд трећег степена је, независно од тога да ли је у истом предмету првостепена пресуда већ једном укидана, овлашћен да једном укине другостепену одлуку и предмет врати другостепеном суду на поновно одлучивање будући да се у овом поступку не одлучује, поново, о првостепеној пресуди него, по први пут, о пресуди суда другог степена и о против ње изјављеној жалби.

Однос пресуде и оптужбе - везаност суда за чињенични опис дела

3. Да ли првостепени суд може да окривљеног огласи кривим за теже кривично дело (које је описано у диспозитиву оптуженог акта) у ситуацији када је овлашћени тужилац у диспозитиву оптуженог акта описао све елементе лакшег али и тежег кривичног дела (по правилу је то случај код кривичних дела квалификованих тежом последицом или истородних кривичних дела), а правно квалификовао описано дело као лакше кривично дело?

Одредбом члана 420. ЗКП одређен је однос пресуде и оптужбе и у складу са тим одредбама суд је везан чињеничним описом дела у оптужби, а не и његовом правном оценом. У складу са тиме суд је овлашћен да окривљеног огласи кривим и за теже кривично дело, у односу на правну оцену дела од стране тужиоца, уколико су његови битни законски елементи садржани у чињеничном опису дела из оптужбе.

**Утврђивање на главном претресу да није извршено кривично дело квалификовано тежом последицом (из оптужбе)
већ основни облик дела- поступање суда**

4. Када се на главном претресу утврди да окривљени није извршио кривично дело квалификовано тежом последицом или тежи облик кривичног дела из оптужбе, већ основни облик тог кривичног дела, а тужилац не мења оптужбу, да ли ће се донети ослобађајућа пресуда за дело из

оптужбе или ће се донети осуђујућа пресуда за дело у основном облику које је доказано, односно донети одбијајућа пресуда ако је дело у основном облику застарело?

У ситуацији да се на главном претресу утврди да окривљени није извршио кривично дело квалификовано тежом последицом или тежи облике кривичног дела из оптужбе већ основни облик тог кривичног дела, а тужилац не мења оптужбу, суд неће донети ослобађајућу пресуду за дело из оптужбе него пресуду којом окривљеног оглашава кривим за основни облик дела које је доказано изостављајући из описе дела у изреци квалификаторне елементе који нису доказани и у образложењу пресуде о томе изнети разлоге.

У истој ситуацији уколико је за основни облик кривичног дела наступила застарелост кривичног гоњења, суд неће донети одбијајућу пресуду за то дело него пресуду којом ће окривљеног ослободити од оптужбе за дело које је предмет оптужбе (квалификовано тежом последицом или тежи облик кривичног дела) јер је то и повољније по окривљеног и у супротном не би у потпуности био решен предмет оптужбе.

Београд - 28.06.2016. године

Одрицање од права на жалбу у скраћеном кривичном поступку

1. Да ли се у скраћеном кривичном поступку окривљени може одрећи права на жалбу пре достављања пресуде којом му је изречена казна затвора (чл. 510. у вези чл. 434. ЗКП)?

Окривљени се у скраћеном поступку, на основу члана 510. ЗКП, може одрећи права на жалбу пре достављања пресуде којом му је изречена казна затвора. У том случају се не примењује одредба члана 434. ЗКП.

Оштећени као тужилац- право (након завршене истраге) на подношење оптужног акта

2. Да ли оштећени као тужилац, након завршене истраге која је довршена по његовом захтеву за спровођење истраге, у смислу чл. 603. ЗКП, може поднети суду оптужни акт?

Оштећени као тужилац, након завршене истраге која је вођена по његовом захтеву за спровођење истраге, у смислу чл. 603. ЗКП, овлашћен је да након тога суду поднесе оптужни акт. У образложењу овог става Врховни касациони суд указује своју одлуку у предмету К33 559/2015 и упућује на у њој изнете разлоге.

Чињенични опис радње из члана 350. став 3. у вези са ставом 2. КЗ - обавезе навођења објективних и субјективних обележја кривичног дела

3. Да ли је за чињенични опис радње омогућавања транзита код кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарења људи, из члана 350. став 2. КЗ довољно да се, уз опис осталих битних елемената кривичног дела, само уз употребу термина “омогућио транзит” наведе да је учинилац својим возилом преузео илегалне прелазнике у месту А (које се налази на територији Републике Србије) и започео њихов транзит до места Б (које је такође на територији Републике Србије) али га је у близини места Б зауставила патрола полиције и лишила слободе?

За чињенични опис радње омогућавања транзита, код кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350. став 3. у вези са ставом 2. КЗ, потребно је навести објективна и субјективна обележја кривичног дела, што значи у релацију транзита уз описан психички однос учиниоца у смислу да зна да врши кријумчарење људи у транзиту.

Гранична количина опојне дроге (у смислу кривичних дела из члана 246. став 1. и 246а КЗ)

4. Да ли у пракси осталих апелационих судова постоји заузет став о приближној или стриктној граничној количини опојне дроге коју је окривљени неовлашћено држао и при томе је утврђено да је зависник од опојне дроге те преко које количине би морао проистећи закључак да да је та количина сама по себи намењена неовлашћеном стављању у промет те да ли је то количина од 10 гр хероина, 50 гр марихуане, 10 таблета спаида и др. или то нека друга количина?

Врховни касациони суд нема изражен став о граничној количини опојне дроге у смислу обележја кривичних дела из члана 246. став 1. и 246а КЗ будући да ова чињеница зависи од оцене суда у сваком конкретном случају.

Ниш - 30.09.2016. године

**Претресање стана (у смислу судске наредбе из чл. 156. став 7. ЗКП)
у присуству једног сведока - законитост прибављеног доказа**

1. Да ли је законито прибављен доказ и да ли се може користити као доказ записник о претресању стана или просторија када је радња извршена на основу судске наредбе у смислу чл. 156. став 7. ЗКП, али у присуству једног сведока или без сведока, а не два сведока што је законска обавеза и када се на пример као разлог што није обезбеђено присуство сведока претресању наводи да нису могли бити обезбеђени сведоци или један сведок или поједина лица одбијају да буду сведоци и слично?

Радња претресања стана и просторија уз издату наредбу суда и када је по закону обавезно присуство сведока у смислу чл. 156. став 7. ЗКП, изузетно се може извршити у присуству једног сведока или без сведока, само у процесним ситуацијама из чл. 156. став 3. ЗКП, а у другим случајевима, суд ће законитост те радње ценити у смислу чл. 348. став 2. тач. 1) ЗКП, односно да ли се ради о апсолутној или релативној повреди поступка.

**Овлашћење суда да утврди испуњеност услова за законску
рехабилитацију у току кривичног поступка**

2. Да ли је у кривичном предмету првостепени или другостепени суд овлашћен да након извршене провере података у вези рехабилитације и података везаних за њу, а који су засновани на валидним доказима, утврди да су испуњени услови за законску рехабилитацију и то узме у обзир при избору и одмеравању кривичне санкције, а све у смислу одредбе чл. 98. КЗ и чл. 569. и 572. ЗКП?

У току кривичног поступка поступајући суд није овлашћен да утврди да су испуњени услови за законску рехабилитацију и да то узме у обзир при избору и одмеравању кривичне санкције, а у смислу чл. 98, 569. и 572. ЗКП, јер поступање суда у вези законске рехабилитације у смислу чл. 572. ст. 2. ЗКП, подразумева посебну врсту поступка уз учешће претходног изјашњења јавног тужиоца у смислу чл. 572. ст. 3. ЗКП.

Топола (Опленац) - 02.12.2016. године

**Кување сувих чаура мака и постојање кривичног дела
производња опојне дроге (члан 246. став 1. КЗ)**

1. Да ли се ради о производњи опојне дроге у смислу чл. 246. став 1. КЗ када се врши кување сувих чаура мака, што представља макову сламу, и предвиђено је редним бројем 55. Правилника о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци, на начин да окривљени производи концентрат опијумског мака кувањем чаура мака, који у себи садржи морфин који се налази под редним бројем 71. Правилника о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци?

Кување сувих чаура мака, што преставља макову сламу, искључује постојање кривичног дела једино у ситуацији уколико се та макова слама кува за сопствене потребе, односно уколико наведени материјал није предмет трговине, а у осталим случајевима представља производњу опојне дроге у смислу одредбе чл. 246. став 1. КЗ.

**Расписивање потернице и могућност наступања
релативне застарелости извршења казне**

2. Да ли након расписивања потернице за лицем које је правноснажно осуђено на казну затвора може наступити релативна застарелост извршења те казне?

Издавањем потернице од стране надлежног органа, ради извршења казне, прекида се застарелост извршења те казне све док се осуђени не пронађе и не приведе на издржавање казне, с једним изузетком да у међувремену није наступила апсолутна застарелост извршења те казне.

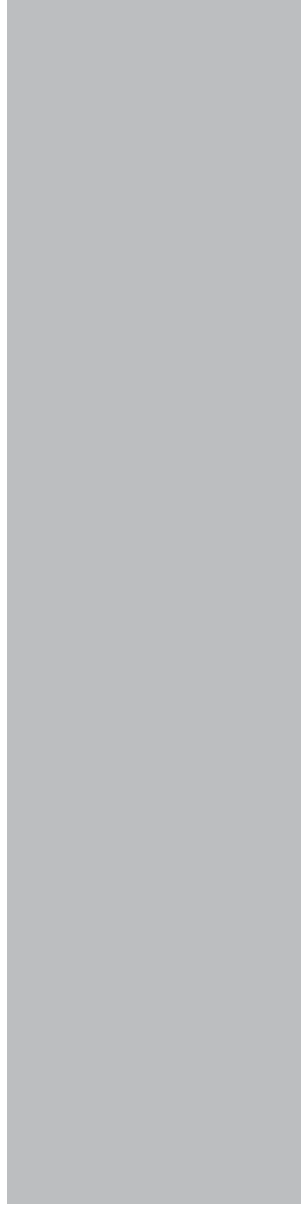
**Измена правне квалификације кривичног дела и кривичне
санкције обухват забране из одредбе члана 453. ЗКП.**

3. Да ли забрана из одредбе члана 453. ЗКП обухвата само правну квалификацију кривичног дела и кривичну санкцију или се односи и на неповољније чињенично стање по оптуженог, без обзира што би се радило о истој правној квалификацији и кривичној санкцији?

У смислу одредбе чл. 453. ЗКП у поновљеном поступку не само што се не може изменити правна квалификација и кривична санкција већ се ова забрана односи и на неповољније чињенично стање и чињенични опис радњи извршења кривичног дела по оптуженог.

КРИВИЧНО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА



ПРАВО НА ОДБРАНУ
(чл. 68. ст. 1. тач. 10. ЗКП)

Оптуженом није повређено право на одбрану тиме што сведок није испитан на главном претресу већ је, уместо тога (на основу чл. 406. ст. 1. тач. 2. Законика о кривичном поступку), извршен увид у записник о његовом саслушању пред истражним судијом, јер су се оптужени и његов бранилац сагласили да се на главном претресу изврши упознавање са садржином записника о саслушању овог сведока.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Неготину 1К.бр.382/13 од 11.09.2014. године, оптужени А.А. из Б. Оглашен је кривим због кривичног дела тешка крађа у саизвршилаштву из чл. 204 ст. 1 тач. 1 у вези чл. 33 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и два месеца у коју му се урачунава време које је провео у притвору од 13.08.2014. године до 11.09.2014. године.

По налажењу Апелационог суда, неосновано се жалбом указује да је оптуженом А.А. из Б. повређено право на одбрану тиме што сведок није испитан на главном претресу већ је, уместо тога (на основу чл. 406 ст. 1 тач.2 Законика о кривичном поступку), извршен увид у записник о његовом саслушању пред истражним судијом, јер су се оптужени и његов бранилац сагласили да се на главном претресу изврши упознавање са садржином записника о саслушању овог сведока.

***(Пресудом Основног суда у Неготину 1К.бр. 382/13
од 11.09.2014. године, пресуда Апелационог суда
у Нишу 16Кж1. бр. 1287/14 од 05.12.2014. године)***

Милица Алексић,
виши судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

УРУЧЕЊЕ ОПТУЖНИЦЕ БРАНИОЦУ (чл. 333 до 337 ЗКП)

Председник већа је у обавези да прописно састављену оптужницу достави не само оптуженом већ и његовом браниоцу.

Из образложења:

Основано се жалбом окривљеног М.Ц. указује да његовом браниоцу није достављена оптужница а суд је одлучио о њеном потврђивању. Одредбом чл. 333. ст.1. ЗКП прописано је да се оптужница подноси већу надлежног суда у онолико примерака колико има окривљених и **њихових бранилаца** и један примерак за суд. Одредба чл. 336. ст. 2. прописује да одговор на оптужницу може поднети и бранилац. Када се ове две одредбе тумаче у међусобној повезаности са општим правима браниоца која су предвиђена у чл. 71. ЗКП произилази да је првостепени суд у обавези да оптужницу достави и браниоцу окривљеног. У конкретном случају првостепени суд је оптужницу доставио само окривљеном али не и његовом браниоцу, чиме је по налажењу Апелационог суда оптуженом ускратио право које има у једној фази поступка-у поступку потврђивања оптужнице. Дужност је браниоца да окривљеном пружи помоћ у одбрани стручно савесно и благовремено а да би ту дужност могао да обави мора бити упознат са свим писменима који се упућују окривљеном. У конкретном случају достављањем оптужнице само окривљеном онемогућено је његовом браниоцу да се упозна са садржином исте и да евентуално поднесе одговор на оптужницу.

(Решење Вишег суда у Пироту Кж.2. бр 233/18 од 31.3.2016. године и решење Апелационог суда у Нишу 12 Кж.2. бр. 233/16 од 20.4.2016. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА ПРЕСУДУ ДОНЕТУ ПО СПОРАЗУМУ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ ОПТУЖЕНОГ И ЊЕГОВОГ БРАНИОЦА, СА ЈЕДНЕ И ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, СА ДРУГЕ СТРАНЕ

Жалба која је изјављена због одлуке о казни на пресуду која је донета по споразуму о признању кривичног дела чији је саставни део изјава о одрицању странака и браниоца од права на жалбу против одлуке којом је суд у потпуности прихватио споразум, осим у случају из чл. 319. ст. 3. истог законика, је недозвољена, због чега је треба одбацити.

Из образложења:

Побијаном пресудом прихваћен је споразум о признању кривичног дела закључен између заменика ОЈТ Ниш и оптуженог А.А. и његовог браниоца, чији је саставни део оптужница ОЈТ у Нишу, па је оптужени оглашен кривим због три кривична дела разбојништва у саизвршилаштву из чл. 206. ст. 1, у вези чл. 33. КЗ, за која су му утврђене казне затвора у трајању од по 2 године, а затим осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5 година, коју да издржи по правноснажности пресуде.

Како се ради о пресуди којом је прихваћен споразум о признању кривичног дела који у чл. 4 садржи изјаву јавног тужиоца, оптуженог и његовог браниоца о одрицању права на жалбу против одлуке суда којом се у потпуности прихвата такав споразум, осим права на изјављивање жалбе у случају из чл. 319. ст. 3. ЗКП, а из садржине изјављене жалбе оптуженог А.А. произилази да оптужени не побија првостепену пресуду због разлога прописаних овом законском одредбом, односно због постојања разлога који, у смислу чл. 338 ст. 1 ЗКП доводе до обуставе кривичног поступка (ако дело које је предмет оптужбе није кривично дело, а нема услова за примену мере безбедности, ако је кривично гоњење застарело или је дело обухваћено амнестијом или помиловањем или да постоје друге околности које трајно искључују кривично гоњење или ако нема довољно доказа за оправдану сумњу да је окривљени учинио дело које је предмет оптужбе) или ако се пресуда не односи на предмет споразума, Апелациони суд је без упуштања у оцену основаности жалбених навода, исту применом чл. 455. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 456. ст. 2. ЗКП одбацио као недозвољену.

*(Решење Апелационог суда у Нишу 1Кж1. бр. 418/16 од 05.04.2016. године
- пресуда Основног суда у Нишу 2Спк.бр. 31/16 од 03.03.2016. године)*

*Аутор сентентце: Ивана Лазовић,
виши судијски помоћник Апелационог суда у Нишу*

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(члан 438. став 2. тачка 2. Законик о кривичном поступку)

Првостепени суд је погрешно ценио тежину и начин извршења кривичног дела, као околност од које зависи оцена да ли су се стекли услови да се оптужени условно отпусти са издржавања казне.

Из образложења:

Апелациони суд налази да се основано жалбом осуђеног указује да је првостепени суд погрешно ценио тежину и начин извршења кривичног дела као околност од које зависи оцена да ли су се стекли услови да се оптужени условно отпусти са издржавања казне, јер ова околност није сходно чл. 46. ст. 1. КЗ и чл. 567. ЗКП од значаја за оцену да ли се осуђени тако поправио да се са основом може очекивати да ће се на слободи добро владати, јер су тежина и начин извршења кривичног дела околности које се могу ценити, приликом изрицања казне, док врста кривичног дела за које осуђени на издржавању казне-примање мита из чл. 367. ст. 1. КЗ, може бити од утицаја на одлуку суда да ли је у случају испуњености услова из чл. 46. ст. 1. КЗ условни отпуст оправдан сходно чл. 46. ст. 2. КЗ.

(Решење Вишег суда у Нишу 1Куо.бр.24/16 од 31.03.2016. године и Решење Апелационог суда у Нишу 16Кж2 бр.230/16 од 19.04.2016. године)

Сентенцу обрадио: судијски саветник Горан Димитријевић

УТИЦАЈ ПРИВРЕМЕНЕ СМЕТЊЕ ИЗВРШИОЦА ИЗ ЧЛ. 416 СТ. 1 ТАЧ. 3 ЗКП НА ТОК КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА КОЈИ СЕ ВОДИ ПРОТИВ ПОМАГАЧА У ИЗВРШЕЊУ ИСТОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Привремена сметња која се састоји у душевном обољењу, душевној поремећености или другој тешкој болести је околност која, у смислу чл. 416. ст. 1. тач. 3. ЗКП погађа искључиво лице код којег је иста наступила и као таква има дејство на ток кривичног поступка у односу на то лице али иста није од утицаја на ток кривичног поступка у односу на лице које је оптужено за радњу помагања из чл. 36. ст. 1. КЗ у извршењу кривичног дела лицу код кога је таква сметња наступила.

Из образложења:

Првостепени суд је према оптуженој одбацио оптужни предлог на основу одредбе чл. 416. ст. 1. тач. 3. ЗКП налазећи да су због немогућности да се поступак води против оптуженог А.А. због кривичног дела пореска утаја из чл. 229. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ настале околности које спречавају вођење кривичног поступка према оптуженој Б.Б. због помагања у извршењу тог кривичног дела, јер радње помагања не представљају кривично дело, већ је за кривицу помагача предуслов осуда извршиоца кривичног дела, што по ставу првостепеног суда значи да се прво мора утврдити постојање кривичног дела које је извршио конкретни учинилац да би се потом могло утврдити да ли су радње помагања допринеле извршењу тог кривичног дела.

Међутим, по оцени Апелационог суда изнети разлози првостепене пресуде су потпуно нејасни, што основано жалбом указује јавни тужилац. Наиме, из одредбе чл. 416. ст. 1. тач. 3. ЗКП да ће у току или по завршетку главног претреса веће решењем одбацили оптужницу ако утврди да је код окривљеног наступило душевно обољење или душевна поремећеност или друга тешка болест због које трајно не може учествовати у поступку, јасно произилази да наведене околности погађају искључиво лице код којег су исте наступиле и као такве су од утицаја на ток кривичног поступка у односу на то лице. Конкретно, обољење оптуженог А.А. према коме је правноснажним решењем одбачен оптужни предлог због кривичног дела пореска утаја из чл. 229. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ, у смислу цитиране законске одредбе није од утицаја на ток кривичног поступка које се због кривичног дела помагања у

извршењу овог кривичног дела води против оптужене Б.Б. а која у смислу чл. 36. ст. 1. КЗ одговара у границама свог умишљаја чија садржина се у сваком конкретном случају утврђује.

Због наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, побијана пресуда је у побијаном делу укинута и предмет враћен на поновно суђење првостепеном суду који ће у поновном поступку извести све потребне доказе, које ће, у смислу чл. 419. ст. 2. Законика о кривичном поступку ценити појединачно и у њиховој међусобној повезаности и најпре утврдити постојање објективних обележја кривичног дела пореске утаје из чл. 229. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ, а затим и да ли је од стране оптужене Б.Б. дошло до помагања у његовом извршењу, што значи утврђење свих чињеница и околности које представљају обележје кривичног дела које се састоји у помагању у његовом извршењу, с тим што ће умишљај оптужене утврђивати у смислу чл. 36. ст. 1. КЗ, након чега ће моћи да донесе правилну и закониту одлуку у којој ће дати јасне и довољне разлоге о свим чињеницама које су предмет доказивања.

*(Решење Апелационог суда у Нишу 2Кж1.бр.450/16 од 07.04.2016. године
-пресуда Основног суда у Нишу 17К.бр.986/15 од 27.10.2015. године)*

*Аутор сентенце: Ивана Лазовић,
виши судијски помоћник Апелационог суда у Нишу*

ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ОСУЂЕНОМ У ОДСУСТВУ

У новом поступку, спроведеном на основу решења којим је дозвољено понављање кривичног поступка, суд може, обуставити поступак до почетка главног претреса и ставити ван снаге ранију пресуду или донети пресуду којом се ранија пресуда делимично или у целини ставља ван снаге или да се оставља на снази (чл. 478. Законика о кривичном поступку).

Из образложења:

Жалбом оптуженог АА се основано побија првостепена пресуда због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач.3 ЗКП, јер је првостепени суд неправилно применио одредбу чл. 478. ст. 3. ЗКП, што је било од одлучног утицаја на доношење законите и правилне пресуде.

Наиме, из списка предмета произилази да је у овој кривичној ствари оптуженом АА суђено у одсуству и да је донета пресуда 1К.бр. 1701/10 од 24.08.2011. године. По захтеву осуђеног, решењем Основног суда у Лесковцу Кв.бр. 875/13 од 31.10.2013. године дозвољено је понављање кривичног поступка у коме је оптужени осуђен у одсуству и окончаног правноснажном пресудом К.бр. 1701/10 од 24.08.2011. године, применом чл. 479. ЗКП.

У поновљеном поступку, суђење је спроведено у присуству оптуженог АА, те је, по завршетку главног претреса, донета побијана пресуда К.бр.1970/13 бд 19.02.2015. године којом је оптужени оглашен кривим за кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 33. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године.

У конкретном случају се ради о понављању кривичног поступка осуђеном коме је суђено у одсуству, те се приликом доношења нове пресуде примењује одредба чл. 478. ст. 3. ЗКП, којом је прописано да када суд у новом поступку донесе пресуду, изрећи ће да се ранија пресуда делимично или у целини ставља ван снаге или оставља на снази.

Како првостепени суд побијаном пресудом уопште није одлучио о судбини раније донете правноснажне пресуде против оптуженог у истој кривичној ствари, већ је одлучивао о кривици оптуженог за радње које му се оптужницом стављају на терет, то је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 3 ЗКП, јер је неправилно применио одредбу чл. 478. ст. 3. ЗКП, којом је прописано поступање суда при одлучивању у поновљеном кривичном поступку.

Наиме, предмет поновљеног кривичног поступка је раније донета пресуда, која је још увек на снази и у поновљеном поступку се налази у фази преиспитивања, који се завршава или њеним остављањем на снази или њеним у целини или делимичним стављањем ван снаге. Самим тим се и идентитет кривичног дела у новом поступку не изводи из оптужнице, како је то учинио првостепени суд одлучујући о кривици оптуженог за радње које му се оптужницом стављају на терет, већ из раније донете пресуде. Поступајући на овај начин и тиме што у поновљеном поступку није одлучио о судбини раније донете правноснажне пресуде, првостепени суд је оставио да у правном промету егзистирају две пресуде против истог оптуженог којима је оглашен кривим за исте радње.

Како је првостепена пресуда донета уз наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, то се за сада ни правилност утврђеног чињеничног стања, ни примена закона не може испитати, те се њено укидање показује обавезним.

У поновљеном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, тако што ће у новом поступку, који се води на основу решења којим је дозвољено понављање кривичног поступка, донети пресуду у свему у складу са чл. 478. ст. 3. ЗКП, те ће након што поново изведе доказе по предлозима странака у складу са одредбама ЗКП и чињенично стање потпуно и правилно утврди, у образложењу пресуде дати довољне и јасне разлоге о оцени доказа и утврђењу одлучних чињеница у погледу радњи за које је ранијом пресудом оптужени оглашен кривим, одређено и потпуно изнети које чињенице и из којих разлога узима као доказане или недоказане, потом којим разлозима се руководио при решавању правних питања и примењивању одређених одредаба закона на оптуженог и његово дело, када ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку.

*(Пресуда Основног суда у Лебану К.бр.1970/13 од 19.02.2015. године
Решење Апелационог суда у Нишу 8Кж.1.бр.184/15 од 29.04.2015. године)*

Обрадила: судија Снежана Милошевић

ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРЕСУДЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ У ПОГЛЕДУ ОДЛУКЕ О КАЗНИ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДОМ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА (чл. 439. тач. 3 и чл. 451. ст. 2. ЗКП)

Другостепени суд је у обавези да испитујући првостепену пресуду у делу одлуке о казни преиначи исту у корист оптуженог када је првостепени суд примењујући одредбе о изрицању јединствене казне за дела у стипцају окривљеног осудио на казну затвора изнад шест месеци на дане.

Из образложења:

Испитујући по службеној дужности првостепену пресуду у делу одлуке о казни (на основу чл. 451. ст. 2. тач. 1. ЗКП), Апелациони суд налази да је

у конкретном случају одлука о казни првостепеног суда неправилна а таквом одлуком је уједно повређен кривични закон. Наиме, првостепени суд је оптуженом за кривично дело из чл. 348. ст. 4. у вези ст. 1. КЗ утврдио казну затвора у трајању од 6 месеци а за кривично дело из. 138. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ казну затвора у трајању од 30 дана, па је оптуженог осудио на јединствену казну затвора у трајању од 6 месеци и 15 дана.

Према одредби чл. 45. ст. 2. КЗ **казна затвора се изриче на пуне године и месеце а до шест месеци и на дане**. Првостепени суд је изрекао казну затвора изнад шест месеци на дане, што је у супротности са одредбом чл. 45. ст. 2. КЗ. Обзиром на утврђене појединачне казне као и на одсуство жалбе овлашћеног тужиоца у погледу казне или повреде кривичног закона, није било могуће одмерити казну затвора оптуженом изнад шест месеци на дане, јер тако прописује одредба чл. 45. ст. 2. ЗКП нити је пак било могуће осудити оптуженог на јединствену казну затвора дужу од 6 месеци на пуне месеце (обзиром на утврђене појединачне казне), због чега је Апелациони суд преиначио побијану пресуду у делу одлуке о казни тако што је оптуженог осудио на јединствену казну затвора у трајању од 6 месеци. У оваквој ситуацији долази практично до тога да оптуженом за једно кривично дело за које је оглашен кривим није изречена казна, али таква ситуација је резултат пропуста првостепеног суда који је уз једну већ утврђену казну затвора у трајању од 6 месеци утврдио за друго кривично дело казну затвора у трајању од 30 дана због чега је немогуће оптуженог осудити на казну затвора дужу од 6 месеци због разлога који су напред наведени.

(Пресуда Основног суда у Лебану К.бр. 775/13 од 26.11.2015. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 12. Кж. 245/16 од 14.3.2016. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

ПРЕКОРАЧЕЊЕ НУЖНЕ ОДБРАНЕ

(члан 19. став 3. КЗ)

Прекорачење нужне одбране се утврђује на основу свеукупних радњи нападнутог и нападача, тако да број удараца нанетих нападачу у нужној одбрани, у конкретном случају, није одлучујући.

Из образложења:

“Основни и први услов за постојање нужне одбране у смислу чл. 19. ст. 2. КЗ је да ли је одбрана била нужна што произилази из фактичке ситуације и утврђеног чињеничног стања. У овом случају нужност одбране је проузрокована поступањем оптуженог, нападача АА, који је са пиштољем у руци пришао оптуженом, нападнутом ББ, репетирао пиштољ и из непосредне близине пуцао у његово тело, из чега произилази да је нападнути ББ, одбијајући истовремени противправни напад имао право и није био дужан да на други начин врши одбрану осим повредом нападачевог добра, односно наношењем повреда нападачу и одбијањем напада. У тренутку напада нападнути ББ у рукама није имао оружје док је напад на њега вршен ватреним оружјем које само по себи поседује велику разорну силу, могућност прецизног погађања и наношења тешких и смртоносних повреда, чиме је нападнути ББ, доведен у ситуацију да није био у могућности да одбије напад пасивним, искључиво одбрамбеним радњама, померањем тела или неким другим начином заштите. При даљој оцени постојања услова одбране неопходно је утврдити границе нужне одбране и то да ли је одбрана коју је предузео нападнути ББ, била неопходно потребна и у том смислу да ли је постојала сразмера између озбиљности и јачине напада и приближно еквивалентног степена одбијања напада. У датој ситуацији из утврђеног чињеничног стања произилази да је нападнуто најзначајније и највредније правно добро нападнутог ББ, и то његово тело и живот и зато је реално и прихватљиво да је он у одбрани од таквог напада могао да изврши повреду исто тако вредног односно највреднијег правног

добра нападача, тела и живота нападача АА. Апелациони суд закључује да су испуњени сви услови за постојање нужне одбране, јер је одбрана била нужна и неопходно потребна, а сразмера између нападнутог и нападачевог добра је потпуна и идентична а са друге стране постојала је несразмера средстава напада и средстава којим се напад у одбрани одбија у корист нападнутог, с обзиром да је нападнути ББ, нападнут ватреним оружјем а бранио се ножем, тако да је из свих наведених разлога погрешан закључак првостепеног суда о постојању прекорачења нужне одбране у поступању нападнутог ББ.

По налажењу Апелационог суда, чињеница да је нападнути ББ задао два убода ножем, а другим нанео тешку телесну повреду опасну по живот нападачу, не ремети постигнуту сразмеру између интензитета напада и степена еквиваленције у одбијању напада. Основ ове. сразмерности проистиче из одговора на питање потребне мере и интензитета одбране. Имајући у виду средства напада и одбране која су употребљена, значај правних добара која су нападнута и која су у одбрани повређена и околност коју је првостепени суд правилно утврдио, да је поред напада нападача АА на нападнутог ББ, истовремено уследио и напад оптужених нападач, ВВ, ГГ и ДД, да је њихов напад био усмерен на тело и живот нападнутог и да је напад био неочекиван и ничим изазван, без обзира на постојање ранијих сукоба између њих, а да је отпочео тиме што је нападач АА пришао нападнутом ББ и без упозорења испалио метак у његово тело, да стицајем околности тим пројектилом није изазвао код нападнутог тешку телесну повреду опасну по живот или тежу последицу и без обзира што је пуцао у доњи део тела односно у бутину ноге нападнутог, имајући у виду близину виталних крвних судова тела, по ставу Апелационог суда нису испуњени услови који произилазе из чл. 19. ст. 3. Кривичног законика о постојању прекорачења нужне одбране.

Не стоји закључак првостепеног суда да је другом убодном раном која је нападачког типа а не одбрамбена, што је утврђено обављеним медицинским вештачењем, прекорачена одбрана нападнутог ББ. Основна карактеристика нужне одбране је заштита права од неправда, односно заштита од противправног и нескривеног напада при чему нападнути није дужан да се заштити бежањем нити искључиво одбрамбеним покретима и радњама, тим пре што су и нападнути и нападач по задобијању повреда могли да предузимају физичке покрете и радње напада, што значи да је опасност од напада и по извршеном пуцњу била извесна и предстојећа од нападача АА, који је био присутан на месту догађаја код су други оптужени који су га пратили наставили са вршењем радње напада ударањем и шутирањем нападнутог ББ.

Из утврђеног чињеничног стања није било могуће утврдити, нити за испуњење услова нужне одбране захтевати да се нападнути брани искључиво одбрамбеним радњама, што би значило да се штити рукама или ножем који се налазио код њега али на други начин, махањем или да бежањем напусти место сукоба, што нису услови који искључују постојање нужне одбране а с обзиром да је нападнут ватреним оружјем и рукама и ногама од осталих лица, није реално и могуће да би на тај начин осујетио напад. Несразмера у тежини повреде коју је задобио нападнути ББ и повреде коју је нанео нападачу АА, по степену тежине и угрожености здравља није услов који детерминише нужну одбрану односно њено прекорачење, јер ова разлика не указује да се ради о одбрани незнатног правног добра повредом неупоредиво вреднијег добра, с обзиром да је нападнути ББ задобио тешку телесну повреду, а нападач АА, тешку телесну повреду опасну по живот.

Закључке Апелационог суда потврђује и афективно стање у коме се налазио нападнути ББ, а по налазу вештака неуропсихијатра код њега је у датој ситуацији постојао афект гнева и страха средњег интензитета са предоминацијом афекта страха и зато није било могуће очекивати да као нападнути изабере делотворније средство, начин одбране и да одмери нижи степен јачине одбране, нити да благовремено и ефикасно процени у ком тренутку је неопходно да прекине предузимање радњи одбране.”

*(Сентенца из пресуде Апелационог суда у Нишу
4Кж.1.бр.754/15 од 27.11.2015. године)*

Судија: Братислав Крстић

ПОКУШАЈ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

(члан 30 КЗ)

Не може постојати покушај извршења кривичног дела у ситуацији када окривљени није започео предузимање нити једне радње која је прописана као радња извршења предметног кривичног дела.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у К. оптужени Д. М. ослобођен је оптужбе да је извршио кривично дело тешка крађа у покушају из чл. 204. ст. 1. тач.1. у вези чл. 30. КЗ.

Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавио Основни јавни тужилац.

Жалба је неоснована.

Одредба чл. 30. КЗ прописује постојање покушаја извршења кривичног дела у ситуацији када неко са умишљајем започне извршење кривичног дела али га не доврши. Према томе, за постојање кривичног дела неопходни су субјективни елементи а то су свест и воља да се изврши предметно кривично дело чега је у конкретном случају било, а и објективни елементи који се огледају у предузимању конкретних радњи извршења кривичног дела који за циљ имају проузроковање забрањене последице, чега у конкретном случају није било. Првостепени суд је правилно закључио да је окривљени конкретном приликом само дошао до подрума оштећеног те да је био поред вратима подрума али да није започео ни једну радњу извршења истог. По налажењу Апелационог суда долазак до места где је обијање требало да се изврши уз евентуално ношење алата којим је обијање требало да се изврши (мада то током поступка није доказано) представљају припремне радње за извршење кривичног дела које нису кажњиве у конкретном случају. Припремне радње су оне делатности које су ван радњи извршења прописаних за конкретно кривично дело и које треба само да створе неопходне услове за извршење дела а покушај извршења кривичног дела је предузимање оне делатности која је прописана као радња извршења конкретног кривичног дела. У конкретном случају радња извршења кривичног дела које се оптуженом ставља на терет је обијање или проваљивање затворених зграда. Оптужени није предузео нити једну радњу усмерену на обијање или проваљивање, тако да он заправо није ни започео радњу извршења предметног кривичног дела, те не може бити кажњен за покушај извршења истог.

(Пресуда Основног суда у Књажевицу 6К бр. 5/15 од 24.02.2016. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 12Кж.1.бр. 521/16 од 25.4.2016. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

УСЛОВНИ ОТПУСТ

(чл. 46. КЗ)

При чињеници да је осуђени издржао две трећине казне, дужина неиздржаног дела казне није од утицаја на одлуку суда о условном отпуштању осуђеног.

Из образложења:

Решењем Вишег суда у Л. одбијена је као неоснована молба осуђеног Ђ. Н. за пуштање на условни отпуст са издржавања казне затвора на коју је осуђен пресудом Вишег суда у Лесковцу.

Против наведеног решења жалбу је благовремено изјавио осуђени због повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да се побијано решење преиначи, и усвоји његова молба за условни отпуст.

Жалба је основана.

Управо разлози које наводи првостепени суд у прилог одбијања молбе за условно отпуштање, а то су низак степен ризика, напредовање по одељењима и групама, успешност у извршавању програма поступања, владање за време извршавања казне, извршење радних обавеза, ранија неосуђиваност и очекивано деловање условног отпуста, указују на неопходност примене института условног отпуста, а не на одбијање молбе у том правцу, због чега је првостепено решење преиначено као у изреци.

Однос издржаног и неиздржаног дела казне на који се позива првостепени суд на страни трећој у пасусу шестом као разлог за одбијање молбе за условно отпуштање је апсолутно неприхватљив обзиром да законодавац у том делу прописује као услов да је осуђени издржао 2/3 казне затвора. Обзиром да је осуђени Ђ. Н. тај услов испунио то је однос издржаног и неиздржаног дела казне потпуно ирелевантан за одлучивање о примени условног отпуста.

(Решење Вишег суда у Лесковцу Куо.бр.74/15 од 21.10.2015. године, и решење Апелационог суда у Нишу 12Кж.2.бр. 814/15 од 02.11.2015. године)

Припремио: судија Зоран Поповић

МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ АЛКОХОЛИЧАРА

(чл. 84. ст. 1. Кривичног законика)

Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе алкохола, суд ће изрећи обавезно лечење уколико су испуњени кумулативни услови из чл. 84. ст. 1. Кривичног законика, за изрицање мере безбедности обавезног лечења алкохоличара, односно да је окривљени кривично дело учинио услед стања зависности од употребе алкохола и да постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље вршити кривична дела. Чињеницу да окривљени болује од зависности од алкохола, суд утврђује на адекватан начин и то на основу налаза и мишљења вештака неуропсихијатра, а у вези са тим прикупља и друге податке и исте цени приликом комплетног сагледавања личности окривљеног, након чега закључује да ли између зависности од алкохола и извршеног кривичног дела постоји узрочно -каузални однос. Тек, након тога, суд опредељује да ли услед болести зависности постоји опасност да ће извршилац и даље вршити кривична дела, што је показатељ потребе да се изрицањем ове мере медицинског карактера, дакле одговарајућим лечењем отклони болесно, опасно стање код учиниоца и тиме предупреди поновно, вршење кривичних дела.

Из образложења:

“Првостепена пресуда нема уопште разлоге о испуњености кумулативних услова из чл. 84. ст. 1. КЗ за изрицање мере безбедности обавезног лечења алкохоличара у стационарним условима, односно да је окривљени кривично дело учинио услед стања зависности од употребе алкохола и да постоји опасност да ће и даље вршити кривична дела. Наведени пропуст првостепеног суда је последица непотпуно и погрешно утврђеног чињеничног стања на шта се основано указује у жалби браниоца окривљеног АА. Наиме, првостепени суд, психичко стање окривљеног у време извршења кривичног дела утврђује на основу налаза и мишљења вештака и то дословним преписивањем истог без икакве квалитетне и квантитативне анализе уз крајњу паушалну констатацију, да је неуропсихијатријско вештачење окривљеног прихваћено, цитат “...јер је сачињено од стручног и квалификованог лица... и да окривљени није тражио додатно изјашњење вештака или друго вештачење”. Да је првостепени суд ценио неуропсихијатријско вештачење, на шта га обавезује одредба

чл. 419. ст. 2. ЗКП, свакако би утврдио знатну противречност између објективног налаза и датог мишљења. Наиме, вештак констатује да је окривљени у време извршења кривичног дела био у акутно алкохолисаном стању, што противречи предлогу да се окривљеном изрекне мера безбедности обавезног лечења од зависности од алкохола у стационарним условима. Првостепени суд је независно од изјашњења окривљеног био дужан да затражи од вештака разјашњење овако суштинске противречности обзиром да је суду, а пре свега вештаку морало бити познато да се ова мера безбедности изриче само уколико је кривично дело извршено услед сталне или перманентне употребе алкохола и када се код извршиоца утврди болест зависности, због којих није способан да контролише своје нагоне, поступке и вољу. Другим речима, алкохолизам, често или периодично опијање не значи истовремено постојање зависности као једног од предуслова за изрицање ове мере безбедности.

У конкретном случају остало је неутврђено да ли окривљени болује од зависности од алкохола, при чему није довољно казивање члана породице, тј. оштећеног, већ је потребно ту чињеницу утврдити на други адекватан начин, прикупити друге податке и исте ценити приликом комплетног сагледавања личности окривљеног, његовог ранијег живота, да ли је лечен од алкохола (амбулантно или стационарно) и томе слично и у вези са тим да ли између зависности од алкохола и извршеног кривичног дела постоји узрочно каузални однос. Тек, након тога, суд опредељују да ли услед болести зависности постоји опасност да ће извршилац и даље вршити кривична дела што је показатељ потребе да се изрицањем ове мере медицинског карактера, дакле одговарајућим лечењем отклони болесно, опасно стање код учиниоца и тиме предупреди поновно вршење кривичних дела.”

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 7К.бр. 126/13 од 18.02.2013. године и решење Апелационог суда у Нишу 11Кж.1. бр.1069/12 од 01.04.2013. године)

Приредила: Јелена Додић,
судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗНУДА ИЗ ЧЛ 214. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА И КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПРИНУДА ИЗ ЧЛ. 135. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Принуда је, по правилу, само средство за остваривање изнуде, а то је прибављање противправне имовинске користи, по ком битном елементу се наведена кривична дела у основи разликују.

Из образложења:

Наиме, првостепени суд је оптужене АА, ББ и ВВ, као саизвршиоце, огласио кривим за кривично дело изнуда из чл. 214. ст. 1. у вези чл. 33. КЗ, а оптуженог АА и за кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. КЗ, за радње детаљно описане у изреци побијане пресуде.

Битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач.2. ЗКП се огледа у томе што у пресуди нису наведени разлози о чињеницама које су предмет доказивања, при чему су дати разлози потпуно нејасни и у неким деловима међусобно противречни. Наиме, првостепени суд је у образложењу пресуде изнео садржину одбрана оптужених, саслушаних сведока и садржину писаних доказа, након чега је утврдио чињенично стање као у изреци осуђујуће пресуде. При том, првостепени суд није поуздано утврдио све чињенице које чине обележја наведених кривичних дела, а што је од значаја за правилно пресуђење ове кривичне ствари.

У вези кривичног дела изнуда из чл. 214. Кривичног законика није утврђена природа, ни висина потраживања оптуженог АА према оштећеном ББ, ради утврђивања одлучне чињенице о постојању субјективног елемента и то намере оптужених да се себи или другом прибаве противправну имовинску корист, на који битан елемент овог кривичног дела жалбе основано указују.

Разлика између овог и кривичног дела принуда из чл. 135. КЗ се састоји управо у овом елементу, јер се кривично дело принуда из чл. 135. КЗ састоји у принуђивању другог лица да нешто учини, не учини или трпи, употребом силе или озбиљне претње, док кривично дело изнуда из чл. 214. КЗ чини онај ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, силом или претњом принуди другог да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине. Дакле, принуда је, по правилу, само средство за остваривање основног циља изнуде, а то је прибављање противправне имовинске користи.

У том смислу се указује првостепеном суду да није поуздано утврдио постојање и суштину облигационог односа између оптужених и оштећеног, конкретно о каквом дугу оштећеног према оптуженом АА се ради, да ли исти постоји, у ком износу и да ли исти потиче из законитог или незаконитог правног посла. Зависно од врсте тог правног посла и чињенице да ли ужива правну заштиту, зависиће и чињенично утврђење о постојању или непостојању намере за прибављање противправне имовинске користи, што управо разликује наведена кривична дела и што је од значаја за закључак да ли се ради о намери оптужених да од оштећеног изнуде противправну имовинску корист или о принуди која је предузета да би се издејствовао повраћај неког износа новца из законитог правног посла.

Поред наведеног, битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач. 2. ЗКП се огледа и у томе што побијана пресуда нема јасне разлоге о примени силе и претње и оцени њихове озбиљности у смислу битних обележја кривичног дела изнуда из чл. 214. КЗ, за које су оптужени оглашени кривим. Разлози за овај битан елемент кривичног дела морају обухватити закључак да ли је употребљена сила била апсолутна односно по јачини дејства неодољива тако да се оштећени томе није могао супротставити и слободно одлучивати или је сила била релативна односно да није искључила слободу одлучивања, али је изнудила одлуку оштећеног да учини радње које су оптужени захтевали. У погледу претњи, пресуда не садржи разлоге о степену тежине изречених претњи као психичког насиља над оштећеним у циљу изнуде одређене одлуке односно чињења, те да ли је тежина зла којим се прети створила код оштећеног уверење да ће претње бити остварене.

***(Пресуда Основног суда у Лесковцу 2К.бр.590/11 од 08.09.2015. године
Решење Апелационог суда у Нишу 8Кж.1.бр.1144/15 од 16.12.2015. године)***

Обрадила: судија Снежана Милошевић

КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Бивши супружници који не живе у заједничком домаћинству, али имају заједничко дете, сматрају се члановима породице.

Из образложења:

Наиме, првостепени суд је оптуженог огласио кривим за кривично дело угрожавање сигурности: из чл. 138. ст. 1. КЗ, док му се оптужним предлогом ставља на терет кривично дело насиље у породици из чл. 194. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ. У образложењу пресуде, првостепени суд закључује да оптужени није извршио кривично дело које му се ставља на терет, јер у време извршења дела он и оштећена нису живели у заједничком домаћинству, због чега сматра да се у његовим радњама стичу обележја кривичног дела угрожавање сигурности за које је оглашен кривим.

Основано се жалбом Основног јавног тужиоца оспорава овакав закључак. првостепеног суда и истиче да је у изреци пресуде садржан опис дела из оптужног предлога, који садржи елементе кривичног дела насиље у породици, те да није правилно тумачена одредба чл. 112. тач. 28. КЗ о томе да ли се оптужени и оштећена. као бивши супружници сматрају члановима породице.

По налажењу Апелационог суда, дати разлози су нејасни и за сада се не могу прихватити. Ово због тога што из изреке пресуде произилази да је првостепени суд у изреци пресуде изнео исти чињенични опис радњи оптуженог, како је то наведено у оптужном предлогу. При томе, сматра да се ради о бившим супружницима који не живе у заједничком домаћинству у време извршења дела и да се због тога не ради о кривичном делу насиље у породици. Међутим, из одредбе чл. 112. тач. 28. КЗ произилази да се члановима породице сматрају бивши супружници, ако живе у заједничком домаћинству, али и лица која имају заједничко дете, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

Стога је нејасно због чега није прихваћена правна квалификација кривичног дела из оптужног предлога, као и разлози наведени у образложењу пресуде да је суд уредио чињенични опис дела, с обзиром да произилази да се ради о истом чињеничном опису.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 6К.бр. 1025/12 од 27.06.2012.године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.657/13 од 13.06.2014. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПАСИВНИ СУБЈЕКТ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ОБЉУБА НАД НЕМОЋНИМ ЛИЦЕМ ИЗ ЧЛ.179. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Немоћно лице, односно пасивни субјект кривичног дела обљуба над немоћним лицем из чл. 179. Кривичног законика, може бити како женско тако и мушко лице код којег постоји душевно обољење, заостали душевни развој или друга душевна поремећеност, немоћ или неко друго стање услед којег то лице није способно за отпор.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 2. тач.2. ЗКП, на коју се основано указује изјављеном жалбом браниоца оптуженог, јер у образложењу пресуде нису наведени јасни разлози о свим чињеница које су предмет доказивања, због чега није могуће испитати законитост и правилност пресуде.

Првостепени суд је оптуженог АА огласио кривим за продужено кривично дело обљуба над немоћним лицем из чл. 179. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ у вези чл. 61. КЗ, при чему је свој чињенични закључак да је оптужени у критичним приликама извршио обљубу над мал. оштећеном ВВ искористивши њен заостали душевни развој услед којег она није била способна за отпор, засновао на оцени одбране оптуженог, исказа мал. оштећене ВВ, исказа испитаних сведока ГГ и ДД, налаза и мишљења Комисије вештака Клинике за ментално здравље КЦ Ниш, Одељење за дечију и адолесцентну психијатрију бр.14310/2 од 03.06.2014. године, те исказа вештака др ЂЂ, члана наведене Комисије вештака. До оваквих чињеничних закључака првостепени суд је дошао анализом не само напред наведених доказа, већ и исказа испитаних сведока ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ и ИИ, као и налаза и мишљења вештака медицинске струке - специјалисте гинекологије и акушерства др ЈЈ од 19.05.2014. године.

Међутим, дати разлози првостепеног суда су за сада неприхватљиви. Ово стога што се основано жалбом браниоца оптуженог АА указује да у пресуди нису наведени јасни разлози о чињеници која је предмет доказивања и то да ли је код мал. оштећене ВВ у критичним приликама постојала психичка немоћ услед које није била способна за отпор, односно да ли је оштећена услед степена заосталог душевног развоја трајног карактера, које је утврђе-

но вештачењем, могла да схвати значај сексуалног акта и његових последица и да ли је због наведеног стања психичког здравља била способна за отпор. Ово стога што је првостепени суд на основу налаза и мишљења Комисије вештака Клинике за ментално здравље КЦ Ниш, Одељење за дечију и адолесцентну психијатрију бр. 14310/2 од 03.06.2014. године утврдио да је мал. оштећена ВВ лице са умереном металном заосталошћу трајног карактера, која у критичним приликама није била способна да схвати значај дела у потпуности, била је делимично способна да управља поступцима и делимично способна да пружи отпор активан и пасиван. Имајући у виду овакав налаз и мишљење Комисије вештака нејасни су разлози првостепеног суда и закључак да мал. оштећена у критичним приликама, услед заосталог душевног развоја, дакле психичке немоћи, није била способна да пружи отпор, јер то не произилази из наведеног вештачења.

Како првостепени суд није поуздано утврдио чињеницу која је предмет доказивања и то да ли је мал. оштећена немоћно лице, које услед свог душевног стања - умереног заосталог душевног развоја трајног карактера, у описаним приликама, није била способна да пружи отпор, односно да ли се може сматрати пасивним субјектом овог кривичног дела, то се због учињене битне повреде одредаба кривичног поступка, за сада ни чињенично стање не може узети као правилно и потпуно утврђено, ни испитати примена кривичног закона, те се укидање побијане пресуде показује нужним.

Радња извршења кривичног дела обљуба над немоћним лицем из чл. 179. ст. 1. Кривичног законика подразумева извршену обљубу искоришћавањем неког од стања неспособности за пружање отпора, које се састоји у томе да је неко од стања немоћи оштећене омогућило учиниоцу да изврши обљубу, али и свест учиниоца да искоришћава неко од тих стања пасивног субјекта, те се може извршити само са умишљајем, који поред наведених околности за постојање квалификованог облика из ст. 2. наведеног кривичног дела мора обухватити и свест о својству пасивног субјекта - у конкретном случају да је малолетно лице.

У поновљеном поступку првостепени суд ће извести доказе које предложи странке, али ће поступити и у оквиру овлашћења из чл. 15. ст. 4. ЗКП, у вези противречних или нејасних доказа, што је неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио, те ће након поновне оцене доказа који се тичу утврђивања чињеница које су предмет доказивања, имајући у виду примедбе

овог суда, у образложењу пресуде дати јасне разлоге о свим тим чињеницама, што је за сада изостало, те ће у смислу одредбе чл. 428. ст. 8. ЗКП у пресуди одређено и потпуно изнети које чињенице и из којих разлога узима као доказане или недоказане, као и разлоге којима се руководио при решавању правних питања и примењивању одређених одредаба закона на оптуженог и његово дело, када ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку.

*(Пресуда Вишег суда у Врању 3 К.бр.65/14 од 04.06.2015. године
Решење Апелационог суда у Нишу 8 Кж.1бр.770/15 од 16.09.2015. године)
Обрадила: судија Снежана Милошевић*

**ОМЕТАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ**
(чл. 23 ст. 1. ЗЈРМ)

Уколико окривљени не поступи по наредби овлашћеног службеног лица да стане, већ настави да бежи и притом не предузима радње активног отпора којим би отежао извршење конкретне службене радње, тада је у питању непослушност која се у кривично правном смислу не може сматрати ометањем овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности.

Из образложења

Према чињеничном опису дела у изреци првостепене пресуде, окривљени су свако понаособ, ометали овлашћена службена лица у обављању послова безбедности (трагање и проналазак лица осумњичених за извршење крив. дела разбојништво) тако што су се оглушили о наредбе полицијских службеника да стану и наставили су да беже, па је тако опт. М. А. приликом покушаја прескакања зида пао, те је од стране полицијских службеника доведен у позицију за везивање службеним лисицама; опт. Г. С је прескочио ограду и ушао у кућу Ј.С и одбио да изађе на позив полицијских службеника а када су га исти пронашли у једној од соба, испод кревета, одбио је наредбу да одатле изађе а опт. Д. К је успео да побегне.

Описано поступање оптужених не може се сматрати ометањем овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности, јер радња извршења у

смислу инкриминације из чл. 23 ст. 1 ЗЈРМ представља активно отежавање извршења конкретне службене радње овлашћених службених лица, другим речима, службена радња се и поред активног отпора извршиоца (увреде, ударање, претње, отимање приликом задржавања...) иако отежано, ипак извршава. Када се извршилац пасивно понаша, као у конкретном случају, и не предузима активан отпор у смислу употребе силе или претње, већ пасивно спречава извршење службене радње, обзиром да одбија да стане и наставља да бежи (опт. Д. К) или неће да изађе испод кревета (опт. Г.С) или након пада приликом покушаја да прескочи зид, не предузме нити једну радњу, (опт. М.А) ради се о непослушности која нема кривичноправни карактер и не може се изједначавати са ометањем службеног лица у смислу извршења крив. дела из чл. 23 ст. 1 ЗЈРМ.

Како чињенични опис дела не садржи радњу извршења као објективно обележје крив. дела које је предмет пресуђења, суд другог степена је применом чл. 359 ст. 1 ЗКП преиначио првостепену пресуду у том делу, тако што је оптужене усвајањем жалби које су изјављене у њихову корист, на основу чл. 423 тач.1 ЗКП ослободио од оптужбе јер дело за које су оптужени по закону није крив. дело ометање овлашћених службених лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира из чл. 23 ст. 1 ЗЈРМ.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу II Кж.1 бр. 1186/15 од 20.01.2016 год. и пресуда Вишег суда у Лесковцу К.бр. 44/14 од 11.09.2015 год)

*Приредила: Мирјана Ђорђевић,
судија Апелационог суда у Нишу*

ПРОВОКАЦИЈА НА ВРШЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ДОКАЗНИ ЗНАЧАЈ ТАКО ПРИКУПЉЕНИХ ДОКАЗА

Када учинилац кривичног дела, пре него предузме конкретну радњу извршења нема вољу за забрањеним поступањем већ је полицијска активност код њега створила или конкретизовала одлуку о извршењу кривичног дела, тако прикупљени доказни материјал је супротан стандардима правичног суђења, због чега не би могао да буде основ утврђеног чињеничног стања и доношења осуђујуће пресуде.

Из образложења:

Првостепени суд је правилно имајући у виду целину конкретног случаја, утврдио провокативну природу полицијске активности и њен утицај на опт. Л.Ф да изврши крив. дело из чл. 246 ст. 1 КЗ, аргументовано образложио зашто пре извршења није постојала воља оптуженог као извршиоца да прода опојну дрогу у наведеној количини и по наведеној цени и сагласно томе га правилно ослободио од оптужбе применом чл. 423 тач. 2 ЗКП.

Кривични законик не познаје институт “провоцираног кривичног дела” а постојање кривичног дела није искључено тиме што је окривљени провоциран да изврши радњу конкретног кривичног дела, јер то није један од законом прописаних основа за искључење противправности дела. Такође, свака провокација на вршење кривичног дела није противна стандардима правичног суђења прокламована у чл. 6 ст. 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (право на правично суђење) односно чл. 16 Устава Републике Србије којим се прихватају општа правила и потврђени међународни уговори који су тиме саставни део правног поретка Републике Србије са непосредном применом. Тако, Европски суд за људска права у случају- представци Teixeira de Castro против Португала од 09.06.1998. год. изнео је правни став да када полицајци врше утицај који је по природи такав да може да подстрекне окривљеног да учини кривично дело уместо да се ограниче на пасивно испитивање криминалне активности они не поштују начело правичног процеса које се примењује на поступке за сва кривична дела од најједноставнијих до најсложенијих.

Дакле, провокације на вршење крив. дела неће бити а тако прикупљени доказни материјал може се користити приликом пресуђења по поднетој оптужби, само уколико полиција предузетим “оперативним радом” односно “постављањем оперативне клопке” пружи прилику извршиоцу да учини кривично дело а исти је спреман тј. вољан да исто учини. У свим осталим случајевима када пре предузете забрањене радње, извршилац нема вољни елемент а полицијска активност је створила или конкретизовала код окривљеног одлуку о извршењу кривичног дела, сав прикупљени доказни материјал би био противан стандардима правичног суђења односно исти не би могао да буде основ утврђеног чињеничног стања и доношења осуђујуће пресуде.

***(Пресуда Апелационог суда у Нишу 11 Кж.1 бр. 423/14 од 29.05.2014. год.
и пресуда Вишег суда у Врању 2 К.бр.111/12 од 18.11.2013 год.)***

***Приредила: Мирјана Ђорђевић,
судија Апелационог суда у Нишу***

ПОВРЕДА ЗАКОНА НА ШТЕТУ МАЛОЛЕТНИКА

(чл. 40. ст. 2.3 М и чл. 462. ст. 4. у вези чл. 453. ЗКП)

У ситуацији када жалбом тужиоца није била побијана одлука о кривичној санкцији изречена према малолетнику, у поновљеном поступку се не може изрежи тежа васпитна мера.

Из образложења:

Претходним решењем донетим у истој кривично правној ствари према малолетном сада пунолетном И.А. била је изречена васпитна мера појачан надзор од стране органа старатељства. Против тог решења је Виши јавни тужилац у Нишу изјавио жалбу само због битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде закона али не и због одлуке о кривичној санкцији, при чему одлука о кривичној санкцији у жалби није наведена ни као основ побијања нити је жалбом предложено изрицање теже мере, па у конкретном случају из тих разлога, изрицањем васпитне мере упућивање у васпитну установу малолетном сада пунолетном И.А. првостепени суд је повредио закон на штету малолетника, поступањем супротно одредби чл. 462. ст. 4. у вези чл. 453 ЗКП, јер тежа мера од раније изречене, а без жалбе јавног тужиоца у том правцу и по том законском основу, није могла бити изречена.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кжм.1бр.64/13 од 21.11.2013. године, решење Вишег суда у Пироту Км.бр.1/13 од 12.09.2013. године)

***Приредила: Мирјана Ђорђевић,
судија Апелационог суда у Нишу***

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

**УРАЧУНАВАЊЕ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ У ИЗВРШЕЊУ
РАНИЈИХ БЛАЖИХ ВАСПИТНИХ МЕРА ПРИ ИЗРИЦАЊУ
ВАСПИТНЕ МЕРЕ ПОЈАЧАНИ НАДЗОР ОД СТРАНЕ ОРГАНА
СТАРАТЕЉСТВА НЕ МОЖЕ СЕ ОДРЕДИТИ ДА СЕ У ТУ МЕРУ
УРАЧУНА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У ИЗВРШЕЊУ РАНИЈИХ БЛАЖИХ
ВАСПИТНИХ МЕРА ИЗРЕЧЕНИХ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИКУ**
(чл. 19. и чл. 26. ЗМ и чл. 63 КЗ)

Малолетном С.Ђ. изречена је васпитна мера појачан надзор од стране органа старатељства, а у ранијим поступцима су му биле изречене блаже васпитне мере и то две васпитне мере појачани надзор од стране родитеља и једна васпитна мера судски укор, то се с обзиром на специфичност ове групе кривичних санкција, када се малолетнику у новом поступку изрекне тежа мера, у њено трајање не може се урачунати време проведено на извршењу раније, блаже мере. Чак и када је малолетнику изречена иста васпитна мера у односу на раније изречену, она почиње да се спроводи из почетка, јер се са малолетником поступа по новом плану и програму који се поново сачињава за период за који је изречена нова васпитна мера, с тим што је суд дужан да води рачуна о најдужем трајању те васпитне мере у смислу материјалних одредаба и одредаба о извршењу.

*(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кж.1.бр.26/15 од 02.06.2015. године,
решење Вишег суда у Пироту Км.бр.28/14 од 24.03.2015. године)*

*Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу*

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Тијана Митровић,
судијски сарадник Апелационог суда у Нишу
и докторанд Правног факултета у Нишу

ЗАЈЕДНИЧКА ИМОВИНА СУПРУЖНИКА

О појму и настанку заједничке имовине супружника

Укупну имовину физичког лица које је у браку, чине заједничка и посебна имовина, као две имовинскоправне целине. Заједничка својина је, дакле, један од фондова у оквиру укупне имовине супружника. Специфичан правни режим који овај део имовине издваја у посебну целину огледа се у постојању два титулара. Имаоци брачне тековине су муж и жена са неопредељеним уделима.¹³ Док постоји заједница, имовина им припада заједнички, они треба заједнички да користе предмете те имовине и да заједнички располажу њима. Према томе, када ангажују заједничку имовину супружници се у правном промету појављују као једна целина. Овде дакле, постоји разлика у односу на сусвојину, у ком случају би оба брачна друга били самостални, међусобно независни титулари одређених предмета са самосталним овлашћењима коришћења и располагања. Код заједничке својине, нагласак је управо на томе што они могу да користе и располажу предметима заједничке имовине само заједно, као брачни другови.¹⁴ Сваки заједничар има право на целину неподељених добара и може да користи заједничка добра у мери у којој му је то потребно, док реализација коришћења према величини удела долази у обзир тек кад дође до деобе кад се право заједничке својине на ствари претвори у право сусвојине. Објекат права заједничке имовине је маса добара, покретне и непокретне ствари које улазе у заједничку имовину, а поред њих ту спадају и облигациона права.¹⁵

Имовина коју су брачни другови стекли радом у току трајања њихове заједнице живота представља њихову заједничку имовину.¹⁶ Примена ове

13 Н. Тешић, *О заједничкој имовини супружника*, Правни живот, бр. 10/2006, стр.260.

14 А. Гамс, *Брачно и породично имовинско право*, Научна књига, Београд, 1966, стр. 35.

15 М. Босиљчић, *Право заједничке својине*, Правни живот, бр. 11/1980, стр. 33.

16 Чл. 171. ст. 1. Породичног закона ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015); у даљем тексту ПЗС.

одредбе у пракси је веома сложена, а најчешће је спорно који се све рад мора валоризовати приликом утврђивања удела супружника у заједничкој имовини и од каквог је значаја била употреба посебне имовине супружника при стицању заједничке имовине.¹⁷

Активности, односно послови који се цене приликом утврђивања удела супружника у стицању заједничке имовине су веома разноврсни, па је потребно да суд валоризује сваки користан рад који су супружници обављали заједнички или посебно у току трајања заједнице живота.¹⁸ Тако је део тих активности везан за професију (занимање), други за вођење заједничког домаћинства, трећи искључиво за децу итд. Неки од послова супружника за резултат имају одређену материјалну корист или накнаду, најчешће новчану. Међутим, бројни су, али и важни они послови супружника чије предузимање није мотивисано остваривањем прихода, нити се исти награђују материјалним вредностима.¹⁹ Иако се таквим радом супружника не ствара нова економска вредност, то се омогућава другом супружнику да то чини. Имовина која се на овај начин стиче резултат је њихове координисане активности са циљем стицања имовинске вредности ради обезбеђења материјалног положаја супружника и породице у целини.²⁰ Уколико су супружници били запослени онда се тај њихов рад цени у односу на висину зараде коју су остваривали.²¹

17 С. Сворцан, *Имовински односи супружника према Породичном закону Републике Србије*, Зборник радова - Новине у породичном законодавству, Правни факултет у Нишу, стр. 158.

18 “За остваривање права на удео у заједничкој имовини брачних другова - стамбеној згради, неопходан је услов да су брачни другови ту имовину стекли радом у току брачне заједнице, а није довољно само да је спорна имовина стечена за време трајања брачне заједнице. Није, дакле, довољно само то што је спорна стамбена зграда стечена за време трајања брачне заједнице, будући да није прибављена њиховим заједничким радом и средствима, већ из других извора, и то из посебне имовине тужиљине мајке”. Пресуда Окружног суда у Зрењанину Гж. 263/97 од 30.12.1997. године; Наведено према: С. Вуковић, *Коментар Породичног закона*, “Пословни биро” ДОО, Београд, 2005, стр. 143.

19 Д. Радић, *Имовински односи у браку*, Правни факултет Универзитета у Бања Луци, 2016, стр. 109.

20 “Код утврђивања доприноса брачних другова у стицању заједничке имовине и с тим у вези одмеравању њихових удела, цене се сви облици рада, а не само они који непосредно остварују нове новчане вредности” - Пресуда Врховног суда Србије Рев. 2326/03; Наведено према: З. Поњавић, нав. дело, стр. 355.

21 “Према схватању Врховног суда, другостепени суд је, код утврђивања удела супружника у смислу одредбе члана 180. Породичног закона, правилно поступио када је као критеријум узео у обзир њихова лична примања-зараде, с обзиром на то да се тај критеријум у конкретном случају појављује као основни критеријум за утврђивање доприноса у стицању наведене уштеђевине. Тако је на основу потврда које је тужени приложио утврђено да је у периоду од 1994. године до раскида брачне заједнице средином лета 2002. године, тужени остварио укупну зараду у нето износу од 1.354.563 динара, док је тужиља за исти период остварила зараду у износу од 512.595 динара. На тај начин утврђен је већи удео

Дакле, заједничка имовина брачних другова је она имовина која је добијена радом у току трајања брачне заједнице, а не она имовина коју су брачни другови добили након што су њихови односи захладнели и дошло до престанка економске заједнице.²² Заједничка имовина може настати и пре брака, ако су брачни другови пре склапања брака имали такву животну заједницу која је по садржини иста или слична брачној заједници, и то од почетка ванбрачне заједнице ако се та ванбрачна заједница претвори у брак.²³

Заједничка имовина настаје само ако супружници остварују заједницу живота, а када заједница живота престане, у том моменту заједничка имовина престаје да се ствара. Иако заснивање заједничке имовине почиње након ступања супружника у брак, оно може престати и пре развода брака или смрти брачног друга, ако дође до престанка заједнице живота.

За режим заједничке имовине се може рећи да је компонента и темељни део законске регулативе имовинских односа у браку у већини модерних законодавстава. За разлику од режима посебне имовине, који је базиран на општим принципима имовинског права и који подразумева примену правила стварног и облигационог права, режим заједничке имовине се састоји од посебних правила која у значајној мери одступају од општих правила имовинског права. У том смислу, важно питање се односи на састав заједничке имовине, за који и поред прописивања одређених критеријума постоје дилеме око појединих категорија ствари и права у смислу њиховог одређивања као предмета заједничке односно посебне имовине.²⁴

једног супружника - туженог - у свему у складу са одредбама чл. 180. Став 3. Породичног закона, и то у сразмери са његовим уделом у настанку уштеђевине од 72,5%, уз допринос тужиље од 27,5%. Тачан је навод ревизије тужиље да се у складу са чланом 180. став 2. Породичног закона претпоставља да су удели супружника у заједничкој имовини једнаки. Међутим, у складу са наведеним, а у ситуацији када је допринос супружника мерљив једино на основу критеријума њихове остварене зараде - прихода, ова претпоставка је оборива, што даље значи да ће се допринос у оваквој ситуацији ценити према критеријуму оствареног прихода” - Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 3044/09 од 13.10.2009. године.

22 “За стицање заједничке имовине, сходно одредби чл. 171. Породичног закона, поред заједничког рада супружника, неопходно је и постојање и остваривање заједнице живота међу њима, односно није довољно само формално постојање брака, већ је нужно да та брачна заједница фактички постоји односно да се остварује заједница живота међу њима. Уколико између брачних другова није постојала заједница живота, односно ако су они на несумњив начин изразили вољу да се та заједница живота прекине при чему су живели самостално, онда имовина стечена у таквим условима има карактер посебне имовине оног супружника који је ту имовину стекао као посебну имовину”. Пресуда Апелационог суда у Нишу, 26Гж. 2516/2016 од 15.03.2017. године.

23 А. Гамс, нав. дело, стр. 43.

24 Д. Радић, *Природа ствари за личну употребу - посебна или заједничка имовина супружника*, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бања Луци, бр. 36/2014, стр. 31.

Увећање вредности и приходи од посебне имовине супружника

Према одредби чл. 168. Породичног закона, посебну имовину супружника чини имовина коју је супружник стекао пре склапања брака, као и имовина коју је стекао у току трајања брака, деобом заједничке имовине односно наслеђем, поклоном или другим правним послом којим се прибављају искључиво права.²⁵

Чести су случајеви у пракси да један од супружника има посебну имовину, на пример, земљишне парцеле, па да те парцеле редовно обрађују супружници и тако стичу одређени доходак, а тај доходак користе заједнички за стицање заједничке имовине. Пошто се у оваквим случајевима земљиште јавља као основно средство у стицању дохотка, неопходно је да се утврди колики је допринос овог супружника у стицању заједничке својине по основу учешћа његовог основног средства у стицању дохотка.²⁶

Иако питање правне природе прихода од имовине није посебно регулисано у ПЗС, може се рећи да приходи од заједничке имовине улазе у заједничку имовину без обзира да ли су настали радом, или из саме имовине. Међутим, да би приходи од посебне имовине супружника били квалификовани као заједничка имовина, неопходно је да буду остварени радом супружника за време трајања заједнице живота.²⁷ Дакле, потребно је кумулативно постојање оба ова услова, што не сме представљати сметњу да се утврђује постојање увећаног доприноса једног од супружника, те да фаворизовање заједничке имовине у овом случају не сме угрозити правну позицију титулару имовине која се користи. Правично решење подразумевало би да се титулару посебне имовине исплати накнада за коришћење његове имовине, или

25 “Будући да имовина на којој су тужилац и тужилка саградили заједнички стамбени објекат представља имовину коју је тужилац стекао наслеђем, то он има искључиво право на ту имовину након развода брака, осим ако је дошло до увећања вредности имовине, када се цени степен учешћа тужилке у увећању имовине и према томе одређује њен удео у деоби”. Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 1572/2012 од 31.01.2013. године.

26 С. Сворцан, нав. дело, стр. 158, 159.

27 “Принос за земљишта, остварен радом, заједничка је имовина. Ако земљиште није заједничка имовине, већ је власништво једног брачног друга (посебна имовина), онда ваља из приноса претходно издвојити ренту која припада власнику земљишта као његова посебна имовина. Висина ренте се утврђује слободном оценом. При томе се узима у обзир износ закупнине који се у време пресуђења могао постићи у постојећим условима производње и промета”; С. Вуковић, нав. дело, стр. 153.

да му се ангажовање сопствене имовине призна као његов посебан, увећан допринос у заједничкој имовини по том питању.²⁸

Квантум увећања вредности посебне имовине једног супружника доприносом другог супружника – невластника, одређује облигациони (мањи допринос) или стварноправни (већи допринос) другог супружника, сходно одредби чл. 170. Породичног закона.²⁹ Ако је, на пример, један супружник власник породичне стамбене зграде, а други супружник је својим доприносом учествовао у незнатном увећању вредности посебне имовине, тада он има право на новчано потраживање сразмерно свом доприносу. Другачија је, међутим, ситуација ако је током трајања заједнице живота наступило знатно увећање вредности посебне имовине (сазидан је још један спрат куће или је кућа потпуно реновирана) у ком случају други супружник има право на стварноправни захтев односно на удео у тој имовини сразмерно свом доприносу.³⁰

Ствари и права која чине садржину заједничке имовине

Сходно нашој судској пракси и правној теорији може се рећи да садржину, односно предмет заједничке имовине чине: својина на покретним и непокретним стварима, стварна права (право залоге, службености), тражбена

28 Д. Радић, *Имовински односи у браку*, стр. 128; С. Сворцан, нав. дело, стр. 158.

29 Од обима и висине улагања и вредности имовине пре и после извршених улагања зависи да ли је реч о незнатном или знатном увећању посебне имовине једног супружника”. Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. бр. 13376/2010 од 07.12.2012. године.

30 Одредбом чл. 170. ст. 1. Породичног закона је прописано да ако је током трајања заједничког живота у браку дошло до незнатног увећања вредности посебне имовине једног супружника, други супружник има право на потраживање у новцу сразмерно свом доприносу, а у ставу 2. да ако је током трајања заједничког живота у браку дошло до знатног увећања вредности посебне имовине једног супружника, други супружник има право на удео у тој имовини сразмерно свом доприносу. Тако је у одлуци Апелационог суда у Београду Гж. бр. 274/13 закључено да “првостепени суд није имао у виду напред наведене одредбе материјалног права, те је пропустио да цени чињеницу да су парничне странке супружници, да је у време адаптације стана између њих постојала заједница живота и да је тужилац радове на стану изводио уз сагласност тужене. Адаптацијом, реконструкцијом или доградњом туђег објекта се не стиче право својине, изузев ако законом или уговором није другачије одређено. У ситуацији када је један супружник улагао средства у посебну имовину другог супружника и ако је о томе постојао споразум између њих, као изузетак од правила да се адаптацијом туђег објекта не стиче право својине, за стицање права својине није нужно да је адаптацијом створена нова ствар. Имајући у виду напред наведено, првостепени суд је пропустио да утврди вредност изведених радова, како би у смислу напред наведеног законског прописа извео закључак да ли је радом тужиоца имовина тужене незнатно увећана (у ком случају може према туженој остварити облигационоправни захтев) или знатно увећана (у ком случају може остварити стварноправни захтев)”

(облигациона) права, потраживања која имају супружници према трећим лицима која су везана за њихов рад, приходи од заједничке имовине, приходи од посебне имовине стечене радом брачних другова, накнада за ствари из заједничке имовине (штета, експропријација, осигурање), уштеде у новцу које потичу од рада брачних другова, ствари за личну употребу које су несразмерне вредности према осталој имовини, предмети који служе за вршење заната и занимања који су стечени радом брачних другова током трајања брачне заједнице.³¹ Уколико нема сагласности супружника у погледу састава заједничке имовине, односно шта све улази у заједничку имовину, потребно је утврдити шта је све радом стечено у току трајања брачне заједнице, што није нимало лак задатак када су у питању брачне заједнице које су трајале дуже време.

Имовина стечена радом и коришћењем права интелектуалне својине

Зараде (плате) и други облици накнаде за рад супружника део су заједничке имовине, при чему се ови приходи остварени радом у највећој мери троше за вођење заједничког домаћинства и остале потребе брачне, односно породичне заједнице. У том случају део остварених зарада излази из заједничке имовине, али у заједничку имовину улазе ствари и права која су том приликом прибављена. Зарада по правилу улази у заједничку имовину оног тренутка када супружник стекне право на зараду, уколико је тада постојала заједница живота, што значи да је релевантан тренутак стицање право на зараду, а не њена исплата. Међутим, ако је право на зараду стечено пре брака, а њена реализација уследи у току трајања брака или након престанка брака, онда тренутак извршења обавезе, односно време обављања рада представља важан критеријум. И у ситуацији када је правни посао закључен и накнада за рад исплаћена пре закључења брака, односно исплата зараде је извршена унапред, предност треба дати моменту извршења посла.³²

У заједничку имовину, дакле, улази зарада, али и накнада зараде и друга примања која послодавац исплаћује запосленом у вези са радом и то: накнада запосленом током плаћеног одсуства, накнада зараде за време привремене

31 В. Стаменковић, Г. Пантић, *Заједничка имовина и њена искушења*, Избор судске праксе - Стручно-информативни часопис, бр. 9/2000, стр. 12, 13.

32 Д. Радић, *Имовински односи у браку*, стр. 122-124.

спречености за рад (боловања, породилског одсуства),³³ отпремнина због одласка у пензију, накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења,³⁴ и друга примања, као што је јубиларна награда.³⁵

У заједничку имовину улази и отпремнина коју је један брачни друг примио приликом превођења у пензију, која се не може третирати као посебна имовина брачног друга коме је отпремнина дата, ако је отпремнина исплаћена по основу рада који је тај брачни друг обављао за време трајања брака,³⁶ као и отпремнина која се запосленом исплаћује због престанка потребе за његовим радом, пре отказа уговора о раду, а на основу програма решавања вишка запослених.³⁷

Зараде, накнаде зараде и друга примања улазе у заједничку имовину, без обзира на то да ли је до њихове исплате дошло пре или по престанку брачне заједнице, под условом да је њихово потраживање, макар посредно, последица ефективног рада код послодавца, оствареног за време брака.³⁸

За разлику од зарада, пензије остварене током заједнице живота улазе у заједничку имовину, без обзира што је рад по основу кога је стечено право на пензију евентуално био предузет и пре настанка заједнице живота. Ово из разлога што ови приходи деривирају из рада, односно посредан су резултат рада супружника-осигураника. Међутим, уколико један од супружника врши уплату премије добровољног осигурања из своје посебне имовине, онда остварени приходи представљају његову имовину, али уколико је премија уплаћивана из заједничких средстава супружника онда би супружнику који није осигураник добровољног пензијског фонда требало признати облига-

33 Видети чл. 115. и 116. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)

34 Видети чл. 119. Закона о раду. Потраживање накнаде штете која је настала услед наношења телесне повреде или нарушавања здравља неког лица се може поделити на два дела. Потраживање накнаде штете за трошкове лечења и изгубљене зараде током опоравка улази у заједничку имовину. С друге стране, накнада за претрпљени физички бол, за трпљење душевних болова због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части слободе или права личности, смрти блиског лица, као и за страх не могу улазити у заједничку имовину (чл. 200. ЗОО). Повређено добро је овде нераскидиво повезано са телесним и духовним интегритетом личности оштећеног, стога је деоба овог потраживања са супружником противна циљу коме служи ова накнада, Н. Тешић, нав. дело, стр. 264, 265.

35 Видети чл. 120. Закона о раду.

36 Видети чл. 119. Закона о раду.

37 Видети чл. 158. Закона о раду.

38 Н. Тешић, нав. дело, стр. 265.

ционоправни захтев за исплаћену накнаду по основу добровољног пензијског осигурања, сразмерно његовом уделу у заједничкој имовини.³⁹

У Породичном закону се посебно регулише питање имовине стечене игром на срећу и коришћењем интелектуалне својине. Имовина стечена игром на срећу у току трајања заједнице живота у браку представља заједничку имовину, осим ако супружник који је остварио добитак не докаже да је у игру уложио посебну имовину (чл. 172. ПЗС). Имовина стечена коришћењем права интелектуалне својине у току трајања заједнице живота у браку представља заједничку имовину (чл. 173. ПЗС). Дела интелектуалне својине јесу настала као резултат посебних склоности и вештина једног супружника, али и као резултат рада, због чега је и имовина стечена по основу ових права заједничка.⁴⁰ Иако ауторско право као лично право ствараоца не може бити предмет заједничке имовине супружника, другачија је ситуација у погледу његовог материјалног искоришћавања, те ауторски хонорар који је прибављен радом за време трајања брачне заједнице улази у заједничку имовину супружника.

Ствари купљене на кредит

Приликом утврђивања садржине заједничке имовине, једно од питања које се поставља јесте и припадност ствари које су купљене на кредит. Чести су случајеви да уговор о кредиту буде закључен пре закључења брака супружника, а да отплата рата по узетом кредиту уследи делимично или у целини током трајања брака.⁴¹

Ако један супружник, на пример, купи стан и изврши његов упис у јавне регистре пре закључења брака, а током трајања брака из средстава из своје посебне имовине отплати рате по кредиту, он ће представљати његову посебну имовину, али уколико у отплати кредита учествује и други супружник у незнатном обиму, онда ће тај супружник имати право на облигационоправни

39 Д. Радић, *Имовински односи у браку*, стр. 124, 125.

40 З. Поњавић, нав. дело, стр. 357. Дакле, уколико је ауторски хонорар остварен као резултат рада обављеног у брачној заједници, исти улази у састав заједничке имовине. М. Шемић, *Заједничка имовина у брачној, ванбрачној и широкој породичној заједници*, Право - Теорија и пракса, бр. 10-12/1994, стр. 93.

41 „Када је стан купљен годину дана пре закључења брака са туженим-противтужиоцем делом сопственим средствима, а делом од кредита који је почела да отплаћује још пре него што је купила предметни стан, који је отплаћиван током трајања брака од средстава остварених издавањем тог стана, па није стечен радом у току трајања заједнице живота у браку, не представља заједничку имовину“. Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 6964/2013 од 17.12.2014.године.

захтев за повраћај тог новчаног износа. Међутим, ако је други супружник учествовао у отплати кредита у знатном обиму, онда ће он имати право на стварноправни захтев, односно право на аликвотни удео у својини на тој непокретности.

У ситуацији када је непокретност купљена и његов упис и предаја извршена у току трајања брака, иста улази у режим заједничке својине, без обзира да ли је отплата кредита окончана по престанку заједнице. У том случају, отплата кредита је још један од трошкова који терети домаћинство брачних другова, па га у том смислу треба и посматрати.

Отплата кредита по престанку брака од стране једног брачног друга, за ствари које чине заједничку имовину, није од утицаја на величину његовог удела у стицању.⁴² Ипак, супружник који је из своје посебне имовине подмирио заједничку обавезу има право на накнаду од другог супружника сразмерно његовом уделу у заједничкој имовини.⁴³

Стицање својине на откупљеном стану

“Када је у току брака, до правноснажности пресуде о разводу брака брачни друг који је уговорни носилац станарског права, закључио уговор о откупљеном стану, право на стан улази у режим заједничке имовине брачних другова. Други брачни друг нема овлашћења да тражи поништај уговора али може да тражи како у току, тако и после развода брака утврђење свог удела у стицању”.⁴⁴ Разлози који иду у прилог чињеници да тако откупљен стан улази у режим заједничке имовине супружника су ти да је приликом доделе стана на коришћење, давалац стана, по правилу, узимао у обзир бројне околности на страни сауговорача (потенцијалног носиоца станарског права), посебно

42 С. Вуковић, нав. дело, стр. 146. На сличном становишту је и одлука Врховног суда Србије у случају престанка брака смрћу једног од супружника: “Када су странке подизањем кредита у току трајања брака купиле стан, онда он представља њихову заједничку имовину. Отплатом преосталог кредита након смрти супруга, тужила не може стећи већи својински удео на купљеном стану од удела који је већ утврђен правноснажном судском одлуком, јер се отплата остатка кредита не може узети као посебан допринос тужиље који би водио повећању њеног својинског удела, већ она само стиче тражено право према осталим законским наследницима супруга”. Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2514/2003; Наведено према: Н. Тешић, нав. дело, стр. 271.

43 Н. Тешић, нав. дело, стр. 271.

44 Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије од 17.05.1993. године, Билтен Врховног Касационог суда бр. 1/2014, стр. 155.

оне које су везане за чланове његове породице, којом приликом су нарочито цењене чињенице да ли је потенцијални корисник стана у браку, да ли има деце, да ли супружник има решено стамбено питање.⁴⁵ Са друге стране, лице које се налази у браку са носиоцем станарског права, није могло стећи исто право на другом стану, чак и када би конкурисало за стан код различитог даваоца стана, па имајући у виду наведено јасно је да је и други супружник имао значајну улогу, тј. одређене заслуге за доделу стана.⁴⁶ Чињеница да је откуп стана извршен средствима из посебне имовине не мења његову правну судбину, јер откупна цена стана није заснована на тржишним критеријумима, већ се утврђује на основу посебних мерила која су у релацији са оба супружника.⁴⁷ Могућа је и ситуација да је један супружник добио стан као дефицитарни или изузетан кадар, и да у процесу добијања стана његово брачно стање није пресудно или није нимало утицало на додељивање стана (мали број бодова на основу брачног статуса и других породичних околности). У таквим случајевима може да се обори претпоставка да је откупљени стан у саставу заједничке имовине.⁴⁸

Одступање од наведеног општег правила да својина на откупљеном стану током брака улази у режим заједничке имовине у судској пракси постоје:

- када порекло откупљеног стана води из експропријације посебне имовине супружника или његовог претходника и
- када је својина откупом стана супружника током брака стечена уступањем права на откуп, сагласношћу трећег лица као носиоца станарског права, односно закупца (чл. 16. ст. 2. Закона о становању).

45 “Ванбрачни супруг нема право сувојине на стану откупљеном у току ванбрачне заједнице. Изузетно стан додељен ванбрачном супругу у току трајања ванбрачне заједнице улази у режим заједничке имовине када је ванбрачни супруг у молби за доделу стана пријавио ванбрачну супругу као члана свог породичног домаћинства и по том основу стекао бодове који су утицали на доделу стана”. Допуна Правног схватања од 22.05.2001. године утврђена на седници Грађанског одељења Врховног суда Србије од 01.04.2002. године, Билтен врховног Касационог суда, бр. 1/2014, стр. 243.

46 И. Бабић, нав. дело, стр. 132, 133.

47 “Чињеница да је у току трајања заједнице стан отплаћен новцем који представља посебну имовину једног супружника није од значаја за измену режима заједничке имовине, јер се тиме не искључује допринос другог супружника у стицању имовине, већ супружник који је уложио сопствена средства стиче тражено право” - Врховни суд Србије, Рев. 269/00; наведено према: С. Панов, *Породично право*, Правни факултет Универзитета у Београду, 2010.

48 С. Панов, нав. дело, стр. 334.

У овим ситуацијама својина на откупљеном стану не улази у режим заједничке имовине. Други супружник не може имати својинско већ евентуално облигационо право поводом учешћа у исплати откупне цене.⁴⁹

Такође, када је откупна цена стана додељеног на коришћење пре закључења брака једном супружнику исплаћена само стамбеним доприносом носиоца станарског права, откупљен стан не постаје заједничка својина супружника.⁵⁰

У ситуацији када брачни друг, као уговорни носилац станарског права, после развода брака (пре или у току ванпарничног поступка за одређивање носиоца станарског права односно закупца) закључи уговор о откупу стана, то није сметња за вођење и окончање ванпарничног поступка за који је ирелевантна чињеница откупа. Уколико одлуком суда у ванпарничном поступку, за носиоца станарског права односно закупца буде одређен други брачни друг, који није извршио откуп, он може тужбом да тражи поништај закљученог уговора о откупу стана, да би реализовао своје право на откуп.⁵¹

Акције и удели у привредним друштвима

Супружници могу средства из заједничке имовине, осим за подмиривање текућих потреба, уложити у оснивање привредних друштава или куповину акција, односно удела у истима. Ово питање је од значаја на пословање привредних друштава због евентуалног уплива трећег лица у статусне и имовинске односе привредних друштава. Привредна друштва уписом у ре-

49 Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 4270/01, 2779/05; наведено према : С. Накић - Момировић, *Имовински односи супружника и ванбрачних партнера - вануговорни режим*, Зборник радова Ново научно законодавство, Правни факултет у Крагујевцу, 2006, стр. 438.

50 Тако је Врховни суд Србије у пресуди Рев. 182/05 од 19.04.2005. године закључио да се “у конкретном случају тужила не сматра суносноцем станарског права зато што у моменту добијања стана није била брачни друг носиоца станарског права. Но и под условом да је тужила била суносилац станарског права, нису испуњени услови из чл. 321. Закона о браку и породичним односима за примену правила о заједничком стицању у брачној заједници. Наиме, по тој одредби основни услов за стицање заједничке својине је да је ствар стечена радом у брачној заједници. У конкретном случају, откупна цена није исплаћена радом брачних другова већ само стамбеним доприносом носиоца станарског права. Како тужила није својим радом или приходима од своје посебне имовине суделовала у исплати откупне цене, то ствар није постала заједничка својина, па се нису стекли услови за деобу у смислу чл. 328. Закона о браку и породичним односима”.

51 Правно схватање Грађанског одељења Врховног суда Србије од 21.06.1993. године, Билтен Врховног Касационог суда бр. 1/2014, стр. 155.

гистар постају одвојени правни субјекти са посебном имовином, независни од правног субјективитета оснивача. Другачија је ситуација када се ради о предузетнику, односно о физичком лицу које обавља делатност ради стицања добити, и нема одвојени субјективитет од свог власника.

Дакле, радња нема статус посебног правног субјекта а делатност се обавља средствима и опремом власника услед чега имовина предузетника, која често потиче из улагања и рада супружника, може бити, као и приходи предузетника, предмет заједничке имовине супружника, уз посебан, привилеговани режим ствари за вршење заната или занимања при деоби.⁵² Ове ствари увек припадају предузетнику при деоби у искључиву својину са урачунавањем у његов део (чл. 184. ПЗС). Када се тражи утврђивање удела у заједнички стеченој имовини са предузетником, тужба се подноси против предузетника као физичког лица, у ком спору се примењују сва правила која важе за имовинске спорове између физичких лица, па се и удео у стицању заједничке имовине стечене радом приватног предузетника утврђује преко удела на конкретним стварима.

Другачија је ситуација када се ради о имовини привредних друштава, основаних средствима физичких лица, која често воде порекло из заједничке имовине супружника и ванбрачних партнера. Приликом утврђивања удела у стицању заједничке имовине код привредног друштва не може се утврђивати својина на конкретној имовини друштва, већ предмет деобе представља оснивачки удео једног од супружника. Наиме, оснивачким актом односно уговором оснивача, се регулише шта је имовина односно удео конкретног члана приликом оснивања друштва односно које су ствари и у којој вредности унете као удео у друштву, што може представљати доказно средство приликом утврђивања доприноса у стицању. Дакле, за утврђивање доприноса у стицању потребно је прибавити извештај из регистра привредних субјеката како би се утврдио облик привредног друштва, као и оснивачки акт (одлуку о оснивању или уговор о оснивању) да би се утврдило која имовина је унета на име оснивачког улога и колико је износила њена новчана вредност, као и друге околности од значаја за утврђивање доприноса у стицању. Предмет тужбеног захтева може бити утврђивање удела у стицању оснивачких права што значи удео у целом привредном друштву или удео у уделу конкретног члана друштва ако је исто основало више физичких лица.

52 С. Накић - Момировић, нав. дело, стр. 438.

У овом случају треба применити иста правила као кад се ради о другим добрима, стеченим средствима из заједничке имовине. Сваки од супружника има право на акције и права која из њих произилазе сразмерно свом уделу у заједничкој имовини. Чак и када се ради о једноперсоналном акционарском друштву, основаном од стране једног супружника, други супружник ће имати право на број акција сразмеран свом уделу у заједничкој имовини.⁵³

Има и другачијих мишљења по којима се искључује могућност стицања удела привредног субјекта а тиме и права управљања и права стицања добити по правилима о заједничкој имовини, полазећи од правног значаја одвојености правног субјективитета привредних друштава од физичких лица, која их оснивају, норми које регулишу положај привредних субјеката и правне природе заједничке имовине супружника. У том случају, супружнику треба признати облигационо потраживање за учешће посебном и заједничком имовином у оснивању и функционисању привредног субјекта.⁵⁴

Међутим, нема дилеме да привредно друштво има правни субјективитет и своју имовину којом одговара за обавезе што не спречава супружнике као осниваче, власнике капитала, да ризикујући оснивачки улог управљају привредним друштвом и остварују добит. Супружници могу бити заједнички власници основног капитала, док је привредно друштво титулар имовине која му припада, па је оправдано становиште да капитал у привредном друштву буде заједничка имовина супружника, чак и када је у јавне регистре уписан само један од њих, што се односи на све облике привредних друштава, без обзира на облик њихове организације, уколико је порекло оснивачких улога из заједничке имовине.⁵⁵

Поклони учињени супружницима као пару

Поклон који је учињен неком од супружника у току трајања заједнице живота улази у посебну имовину поклонопримца. Наравно, поклон може бити дарован и супружницима као пару па се поставља питање ко је од

53 Ово становиште заузето је на саветовању привредних судова, а објављено у Билтену судске праксе привредних судова бр. 3/98, стр. 29; наведено према: Ј. Митровић, *Права разведеног брачног друга на акције друштва које је основао други брачни друг*, Правни живот, бр. 11/98, стр. 243, 244.

54 С. Накић - Момировић, нав. дело, стр. 439.

55 Д. Радић, *Имовински односи у браку*, стр. 146, 147.

супружника власник поклона, уколико нема изричите воље поклонодавца, приликом чињења поклона, што је чест случај у пракси, посебно на прославама венчања.

У одсуству поменуте чињенице, власништво поклона одређује се према врсти поклона (по некад по природи ствари, на пример женска козметика, новац за плаћање школарине или куповине уџбеника) недвосмислено говоре о вољи поклонодавца. Понекад се намера поклонодавца може јасно одредити и сходно поводу за поклон, као што су на пример поклони учињени поводом запослења супруге, а ако се ради о полно неутралним поклонима као што су књига, стан, слика, примениће се критеријум припадности поклонодавца, тј. субјективне релације поклонодавца и поклонопримца (на пример, ако је поклон учинио невестин рођак или мужевљев пријатељ, онда би у првом случају поклон представљао посебну имовину супруге, а у другом случају посебну имовину мужа). Трошкови организације свечаности где је поклон учињен, представља следећи критеријум за утврђивање власништва поклона, обзиром да би било неправично да једна страна сноси трошкове свечаности, а друга страна се “истиче” скупocenим поклоном који припада члану те породице.⁵⁶ Ако у конкретном случају није могуће применити неки од наведених критеријума, супружници стичу право својине на поклон, са једнаким уделитема.

Изгледа да су намера поклонодавца, природа дароване ствари и пригода поводом које је поклон учињен, примерени критеријуми за одлучивање о судбини поклона учињених супружницима као пару. Ипак, ови поклони, по правилу, подразумевају узвратне (ренумерационе) поклоне, у сличним приликама, који се прибављају из средстава заједничке имовине, те често “обавеза благодарности” према поклонодавцу терети оба супружника, па се чини примереним поћи од претпоставке да поклони учињени супружницима као пару улазе у заједничку имовину, осим ако један од супружника докаже супротно.⁵⁷

Управљање и располагање заједничком имовином као израз сагласности воља супружника

Садржину права заједничке имовине чине овлашћења држања, коришћења и располагања и сва та својинска овлашћења врше њихови но-

⁵⁶ С. Панов, нав. дело, стр. 321.

⁵⁷ Н. Тешћ, нав. дело, стр. 274.

сиоци заједнички и споразумно. Постоји законска претпоставка да послове редовног управљања супружник увек предузима уз сагласност другог супружника (члан 174. ст. 2. ПЗС), док је за послове ванредног управљања и располагања увек потребна сагласност другог супружника. Супружник не може располагати својим уделом у заједничкој имовини нити га може оптеретити правним послом међу живима (члан 174. ст. 3. ПЗС). Брачни или ванбрачни партнер може отуђити само свој удео у ствари стеченој у брачној или ванбрачној заједници.⁵⁸

Ако супружник отуђи ствар из заједничке имовине, без сагласности другог супружника, такав уговор је противан принудном пропису и због тога је ништав.⁵⁹ Супружници, дакле, могу пуноважно располагати заједничком имовином само уколико су се претходно споразумели о томе.

Доследна примена општег правила о управљању и располагању заједничком имовином често доводи до повреде интереса трећих лица, али и до компромитовања принципа правне сигурности.

Међутим, у теорији срећемо мишљења да природа правила, по коме је за располагање стварима из заједничке имовине неопходна сагласност супружника, не упућује на санкцију ништавости. У супротном, такав уговор не би могао конвалидирати, чак и ако разлог ништавости касније отпадне. На пример, ако се други супружник накнадно сагласи са располагањем или супружници закључе споразум о деоби заједничке имовине, по коме предмет спorne продаје улази у посебну имовину супружника траденса.⁶⁰ Дакле, уколико је изостала сагласност једног од супружника за располагање стварима из заједничке имовине, други супружник се може успротивити таквом располагању и тражити поништење, а судбина таквог правног посла зависиће од тога да ли је треће лице, саговорач било савесно.⁶¹ Потребно је дакле, да треће лице,

58 “Имајући ово у виду правилно су обавезане тужене да тужиљи исплате $\frac{1}{2}$ противвредности имовине која се налази у државини тужених-покретне ствари, кућа на којој су изведени радови, као и једно моторно возило (у државини тужене...), док су преостала два возила тужене продале и средства задржале за себе. При том, без утицаја је околност да ли је једно од возила покојни З. С. поклонно тужиљама или не, с обзиром да је удео тужиље у стицању овог возила $\frac{1}{2}$, па је покојни...могао поклонити само део на коме је он био сувласник, што тужене обавезује на исплату тужиљи њеног удела у стицању ових возила”. Пресуда Врховног Касационог суда Рев. 986/2010 од 02.03.2011. године.

59 С. Вуковић, нав. дело, стр. 147.

60 Н. Тешић, нав. дело, стр. 261.

61 З. Поњавић, нав. дело, стр. 359.

није знало или према редовном току ствари, није морало знати да други брачни друг није дао свој пристанак и то једино уколико би се радило о теретном правном послу, јер за бестеретни правни посао долази у обзир само изричит пристанак и другог брачног друга.⁶² Ако је у питању располагање покретним стварима из заједничке имовине без сагласности другог супружника уговор се неће поништити уколико је стицалац био савестан и ако је ствар прибављена уз накнаду. За располагање покретним стварима уобичајено се претпоставља да је супружник био овлашћен од другог брачног друга и савестан стицалац би по правилима о одржају или стицању својине од невластника могао одржати уговор пуноважним.⁶³ У погледу располагањем непокретностима, правни посао се неће поништити ако је стицалац био савестан, што подразумева да је у јавне регистре непокретности као једини власник био уписан супружник који је отуђио непокретност и да стицалац није знао нити је могао знати да се ради о непокретностима из заједничке имовине супружника.⁶⁴

Дакле, правило по коме је ништав правни посао којим се располаже заједничком својином од стране једног супружника без сагласности другог, доводи у колизију два важна начела имовинског права: *начела nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* и *начела поверења у земљишне књиге*.⁶⁵ Према првом начелу супружник који располаже заједничком ствари не би могао на другога пренети више права него што има сам, чиме се штити интерес другог супружника. Међутим, према другом начелу, лице које ступа у правни однос са једним супружником, који је уписан у земљишне књиге као власник ствари, поклања поверење земљишним књигама и, између осталог на основу земљишно-књижног стања закључује правни посао. Применом овог начела обезбеђује се заштита савесном (поштенем) стицаоцу, али и преко потребна правна сигурност, односно поверење у правни поредак.⁶⁶

62 М. Шемић, нав. дело, стр. 94.

63 С. Накић-Момировић, нав. дело, стр. 440.

64 З. Поњавић, нав. дело, стр. 359.

65 Одредбом чл. 241. Нацрта законика прописано је да савестан стицалац стиче право својине или друго стварно право у односу на целу ствар: 1) на покретној ствари, коју је пуноважним правним послом прибавио уз накнаду и коју му је заједничар предао у државину; 2) на непокретној ствари, коју је пуноважним правним послом прибавио уз накнаду од једног или више заједничара који су били уписани као власници у јавном регистру.

66 Д. Радић, нав. дело, стр. 166. Одредбом чл. 147. ст. 2. Закона о стварним правима Републике Српске ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/08, 58/98 и 95/11) је прописано да заједничком ствари заједничари располажу заједнички. Поједини заједничар може располагати са ствари само на основу овлашћења, које су му за то дали сви остали заједничари. Изузетно, ради заштите поверења у правном промету, треће лице може на основу правног посла који није закључен са свим заједничарима стећи

Дакле, ради заштите правног промета, уколико је треће лице било савесно, такав правни посао треба сматрати пуноважним, с тим што оштећени заједничар има право да тражи накнаду од заједничара који је имовином неовлашћено располагао.⁶⁷

Имајући у виду да се сада уговор о управљању и располагању заједничком имовином која се односи на непокретност сачињава у писаној форми у облику јавнобележнички потврђене исправе и уписује у регистар права на непокретностима, мишљења смо да ће убудуће бити мање спорова по овом питању, зато што ће нотар у поступку састављања нотарског записа упозорити уговорну страну ако сматра да нема право да склопи одређени правни посао.

Систем једнаких удела у поступку деобе заједничке имовине

Имајући у виду претходно изложене карактеристике заједничке имовине, јасно је да се ради о врло софистицираном правном институту, конструисаном профилисањем пажљиво одабраних посебних правила, која су уграђена у шири нормативни оквир утемељен на основним принципима имовинског права. Тиме је обезбеђена потребна компатибилност овог правног института са општим правилима имовинског права, са једне стране, и уважене све посебности имовинских односа између лица која су везана браком и који су креатори породице, са друге стране.⁶⁸ Законодавац је, прихватајући мешовити систем једнаких удела у поступку деобе заједничке имовине, дефинисао претпоставку да су удели супружника у заједничкој имовини једнаки (чл. 180. ПЗС), остављајући при том могућност тужиоцу да докаже да је његов допринос у стицању заједничке имовине очигледно већи од доприноса другог супружника. Већи удео у стицању заједничке имовине једног од супружника, сходно одредби чл. 180. ст. 3. ПЗС, зависи од његових остварених прихода, вођења послова у домаћинству, старања о деци, старања о имовини и других околности од значаја за одржавање или увећање вредности заједничке имовине. Да би суд могао да изврши деобу заједничке имовине, најпре је потребно да утврди имовинску масу која чини заједничку имовину. Затим је

право својине: на покретној ствари, ако је ствар прибавио на основу наплативог правног посла и ако је поступало у доброј вери, на непокретностима, ако својина није била уписана у земљишним књигама као заједничка и ако је поступало у доброј вери.

67 М. Босиљчић, нав. дело, стр. 33.

68 Д. Радић, *Имовински односи у браку*, стр. 119

потребно да суд из те имовинске масе издвоји стварна и тражбена права, као и обавезе које чине њихову посебну имовину. Сва она имовина која преостане након издвајања посебне имовине, чини заједничку имовину супружника. У случају спора, да ли нека ствар улази у посебну или заједничку имовину, важи претпоставка да улази у заједничку имовину, а странка која тврди другачије треба то и да докаже. Посебну имовину чини сва она имовина коју су супружници имали у време заснивања брачне заједнице, као и она која је стечена за време брачне заједнице, али не радом, већ на неки други начин, на пример поклоном или наслеђем, под условом да у тренутку деобе таква имовина и даље постоји, било по природи било по реалној супституцији односно суброгацији.

Дакле, утврђивање удела у заједничкој имовини супружника одређује се према његовом доприносу, проценом свих околности.⁶⁹ При томе се води рачуна не само о зарадама и другим примањима сваког од супружника него и о раду којима се не стварају нове економске вредности, већ се пружа помоћ другом супружнику да то чини, кроз вођење послова у домаћинству и старању о деци, о одржавању имовине и о сваком другом облику рада и сарадње у управљању, одржавању и повећању вредности заједничке имовине.

Већи удео у стицању заједничке имовине утврђује се у истој сразмери за сва права и обавезе у тренутку престанка заједнице живота у браку. Већи удео једног супружника у стицању појединог права из заједничке имовине може се утврдити само ако је то право економски самостално у односу на остала права из заједничке имовине, а супружник је у стицању тог права учествовао и приходима од своје посебне имовине (чл. 180. ст. 4-5. ПЗС). При томе се не мисли на приходе од посебне имовине брачних другова који су остварени њиховим заједничким радом, будући да они улазе у садржину заједничке имовине, већ на приходе који су остварени отуђењем те имовине или њеним коришћењем без улагања рада, на пример: издавањем у закуп, улагањем новца на штедњу и слично.⁷⁰ Након утврђивања удела сваког од супружника у заједничкој имовини, они се могу споразумети које ће ствари

69 “Оно што један брачни друг дугује маси заједничке имовине, урачунава се приликом деобе у његов део. На пример, оно што је исплатио на име алиментације свог детета из ранијег брака један брачни друг, прирачунаће се заједничкој имовини, а потом и уделу брачног друга о чијем се дугу и ради”; С. Вуковић, нав. дело. стр. 152.

70 М. Јанковић, *Имовински режим у браку и породичној заједници*, Правни живот - Часопис за правну теорију и праксу, стр. 72.

припасти у својину и државину једном а које другом супружнику, а уколико такав споразум изостане физичку деобу ће извршити суд (чл. 180. ст. 1. ПЗС).

Закључна разматрања

Анализом законских решења закључује се да систем једнаких удела представља конкретизацију принципа равноправности супружника на пољу имовинских односа. Наиме, супружници као учесници имовинских односа имају преко потребну сигурност у смислу ефикасне правне заштите њихових постигнућа, а истовремено им се пружа гаранција да ће се исплатити сваки облик рада и уважити напори које они улажу у материјално обезбеђење брачне, односно породичне заједнице.⁷¹

Међутим, законска решења нису лишена одређених непрецизности и правних празнина у погледу прописивања јаснијих критеријума код утврђивања доприноса супружника у стицању заједничке имовине, као и у погледу утврђивања предмета заједничке имовине, обзиром да је одредбама Породичног закона регулисан лимитиран корпус имовинских права која улазе у састав заједничке имовине, па су кроз праксу судова утврђивани критеријуми у погледу ствари купљених на кредит, станова стечених откупом, учињених поклона, као и акција и удела у привредним субјектима, а што је потребно детаљније регулисати прописима из стварно-правне области.

Позитивно-правни прописи из стварноправне области не дају јасна решења у погледу заштите трећих савесних лица код стицања права својине на непокретностима као предмету заједничке својине, ако је преносилац један од супружника, који је у јавним регистрима уписан као власник, што у практичној примени одредаба Породичног закона које се односе на располагање предметом заједничке имовине без сагласности другог супружника доводи до сукоба начела *neto plus iuris* и начела поуздања јавне књиге односно начела правне сигурности у промету.

Следеће измене закона могле би ићи у правцу њиховог унапређења, чиме би се повећала правна сигурност и отклониле недоумице у практичној примени овог института.

71 Д. Радић, *Имовински односи у браку*, стр. 218.

Ивана Рађеновић

Судија Апелационог суда у Нишу

ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА

Апстракт: Закон о изменама и допунама Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 75/14) који је ступио на снагу 29.07.2014. године, одредбом чл. 86, у значајној мери, суштински мења одредбу чл. 191. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13), систематизовану у одељку под насловом - Правне последице незаконитог престанка радног односа. Новелирана одредба чл. 191. Закона о раду прави разлику између престанка радног односа за који се у поступку пред судом утврди да није постојао законски основ за престанак радног односа, садржани у чл. 175. Закона о раду (истек рока за који је заснован, кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, споразумом између запосленог и послодавца, отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог, на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година, смрћу запосленог и у другим случајевима утврђеним законом) и престанка радног односа уколико суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног односа. У зависности од утврђеног чињеничног основа у току судског поступка у погледу постојања разлога за престанак радног односа, различите су и последице по запосленог у остваривању права на враћање на рад и других права и с тим у вези обавеза послодавца садржаних у одредби чл. 191. Закона о раду.

Кључне речи: основ престанка радног односа, последице, враћање на рад, накнада штете, умањење накнаде штете, застарелост.

1. Уводне напомене

У примени одредбе чл. 191. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13), у парницама ради оцене законитости одлуке о престанку радног односа, у случају да послодавац није поступио у складу са одредбом чл. 180. истог закона, која прописује дужност послодавца да

пре отказа уговора о раду запосленог упозори на постојање разлога за отказ и у случају да је отказ дат по протеку рокова застарелости отказних разлога, сходно чл. 184. истог закона, уједначена судска пракса заснована је на становишту да је тако утврђен чињенични основ релевантан, али и довољан да се утврди да је незаконита одлука послодавца о престанку радног односа.

Постојање правноснажне одлуке суда којом је одлука послодавца поништена као незаконита, засноване на повреди поступка у смислу чл. 180. Закона о раду, а тиме и повреди права запосленог на одбрану, према чл. 7. ратификоване међународне Конвенције о престанку радног односа на иницијативу послодавца бр.158, као и одредби чл. 184. истог закона, којом је прописан рок застарелости, био је (по аутоматизму) основ за враћање на рад запосленог, када то запослени захтева, дакле без обзира на постојање чињеница и околности да ли је постојао основ за престанак радног односа.⁷²

Измењена одредба чл. 191. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), даје ново законско решење у погледу правних последица незаконитог престанка радног односа, у зависности од утврђеног чињеничног основа у току судског поступка у погледу постојања основа за престанак радног односа.

2. Последице незаконитог престанка радног односа када се у поступку пред судом утврди да није постојао основ за престанак радног односа

2.1. Право запосленог на враћање на рад (чл. 191. ст. 1., 5. и 6. Закона о раду)

Суд у току поступка ради поништаја одлуке послодавца о престанку радног односа, треба да цени законитост одлуке, како са процесно правног, тако и са материјално правног становишта и утврђује да ли је радни однос престао без правног основа или је постојао правни основ, те да ли је послодавац провео законом прописани поступак за престанка радног односа, што је све по новелираној одредби релевантан чињенични основ од кога не зависи само законитост одлуке послодавца, већ и отклањање последице незаконитог

⁷² Пресуда Врховног касационог суда Рев2 1423/10 од 27.10.2011. године,
Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1 3133/2012 од 26.04.2013. године,
Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 2230/2012 од 22.02.2013. године,
Пресуда Окружног суда у Нишу Гж1 729/2009 од 08.07.2009. године

престанка радног односа у погледу поновног укључивања запосленог у процес рада, као и одлука суда о захтеву запосленог да се врати на рад и другим правима садржаним у чл. 191. Закона.

Уколико суд утврди да је радни однос престао у законом прописаном поступку или супротно одредбама закона којима је прописан поступак, али без правног основа, који подразумева да нису постојали разлози за престанак радног односа предвиђени у чл. 175. Закона о раду (на пример, у случају отказа уговора о раду од стране послодавца, запослени није учинио повреду радне обавезе или акт недисциплине или није доказано да понашање које је стављено на терет запосленом представља повреду радне обавезе), сходно чл. 191. ст. 1. Закона, одлучиће да запосленог врати на рад када то запослени захтева.

Такав захтев треба - мора бити истакнут у поступку ради оцене законитости одлуке о престанку радног односа.

2.2. Право запосленог на накнаду штете као замена за повратак на рад

У истој правној и чињеничној ситуацији када је у току поступка утврђено да је радни однос престао без правног основа, према чл. 191. ст. 5. и 8. Закона, уместо захтева за враћање на рад, запослени има право да захтева од послодавца исплату накнаде штете у висини од највише 18 зарада запосленог коју је остварио у месецу који претходи месецу у коме му је престао радни однос.

Дакле, Закон даје могућност запосленом да бира да ли ће поставити захтев за враћање на рад или ће захтевати накнаду штете као замену за повратак на рад, у ком случају висина накнаде штете зависи од времена радаведеног код послодавца (што је новина у односу на раније законско решење), година живота запосленог и броја издржаваних чланова породице што је релевантан чињенични основ, јер та накнада треба да буде одговарајућа и правична одустанку запосленог од враћања на рад.

2.3. Право запосленог када наставак радног односа није могућ

Према чл. 191. ст. 6. и 8. Закона о раду, када је у поступку утврђено да је радни однос престао без правног основа и уколико послодавац докаже да постоје околности које оправдано указују да наставак радног односа уз уважавање свих околности и интереса обе стране у спору није могућ, суд одбија

захтев запосленог да се врати на рад и досуђује накнаду штете у двоструком износу од износа утврђеног у складу са ставом пет исте одредбе.

Питање да ли у таквој чињеничној ситуацији, запослени треба у току поступка да искаже сагласност или истакне евентуални захтев за накнаду штете, имајући у виду одредбу чл. 3. Закона о парничном поступку (“Службени гласник РС” бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС и 55/2014), којом је прописано да суд одлучује у границама постављеног тужбеног захтева, одговор би био негативан, обзиром да законска норма даје овлашћење суду да донесе одлуку којом одбија захтев за враћање на рад и то право супституише накнадом штете у висини највише до 36 зарада.

Одлука суда не треба да садржи исказ да је захтев неоснован, јер у случају незаконитог престанка радног односа, послодавац мора да отклони последице, примарно успостављањем прекинутог радног односа - враћањем на рад, с тим што се то право запосленог под специфичним условима и околностима, супституише на основу закона, другим правом, када чињенични основ у погледу постојања оправданих околности и интереса обе стране, намеће пуну извесност да наставак радног односа није могућ.

2.4. Право запосленог на накнаду штете због изостале зараде

Према чл. 191. ст. 1, 2, 3. и 4. Закона о раду, у случају незаконитог престанка радног односа запослени има право на накнаду штете у висини изгубљене зараде која у смислу чл. 105. Закона о раду, садржи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се издвајају и уплаћују надлежним фондовима и службама у корист запосленог, на утврђен месечни износ изгубљене зараде, у складу са императивним прописима у тој области, обзиром да запослени порезима и доприносима не може да располаже, услед чега се запосленом исплаћује накнада штете у висини тзв. нето зараде. У садржај накнаде штете, по закону, не улази накнада за исхрану и току рада, регрес за годишњи одмор, бонуси, награде и друга примања по основу доприноса пословном успеху послодавца, чиме су на јасан и прецизан начин отклоњена питања у погледу обима накнаде штете по наведеним основима.

Треба напоменути да право на накнаду штете због изостале зараде сходно чл. 191. ст. 1. Закона, у вези става 5. и 6. исте одредбе, остварује запослени коме је радни однос престао без правног основа, независно од реализованог

права на враћање на рад, права запосленог на накнаду штете као замене за повратак на рад или права запосленог када наставак радног односа није могућ, којим се право на враћање на рад замењује другим правом, јер се ради о независним видовима штете који се не искључују међусобно.⁷³

Уколико се у поступку пред судом утврди да је постојао основ за престанак радног односа, те да је послодавац поступио супротно одредбама закона којима је прописан поступак за престанак радног односа, у случају незаконитог престанка радног односа, запослени нема право на накнаду штете због изостале зараде, обзиром да чл. 191. ст. 7. Закона не садржи упућујућу норму, а с друге стране став један исте одредбе, прописује то право искључиво запосленом коме је радни однос престао без правног основа.

Према новелираној одредби чл. 191. ст. 9. Закона о раду, накнада штете из ст. 1., 5., 6. и 7. исте одредбе, умањује се за износ прихода које је запослени остварио по основу рада по престанку радног односа, чиме је задржано исто нормативно решење, које је садржала законска норма пре измене и допуне одредбе чл. 191. ст. 3. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09).

Како је отклањање правних последица регулисано посебном нормом управо за случај незаконитог престанка радног односа, која предвиђа основ, висину и ограничења у погледу обима накнаде штете због изостале зараде, у примени чл. 191. ст. 2. и 3. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09), у судским одлукама био је изражен јединствен став по питању оцене основаности захтева за накнаду штете применом правила о деликтној одговорности и подељеној одговорности у смислу чл. 154. ст. 1. и чл. 192. Закона о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља), до доношења Одлуке Уставног суда Републике Србије Уж-776/2012 од 11.04.2013. године, којом је утврђено да је подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, поништена је другостепена судска одлука и одређено је да исти суд поново одлучи о жалби изјављеној против првостепене одлуке. Наиме, правноснажна одлука суда којом је поништена одлука послодавца као незаконита, заснована на повреди поступка у смислу чл. 180. Закона о раду - повреди права запосленог на одбрану и

73 Одлука Уставног суда Републике Србије Уж-841/2012 од 26.11.2015. године,
Одлука Уставног суда Републике Србије Уж-7398/2014 од 17.11.2016. године

одредби чл. 184. истог закона, којом је прописан рок застарелости, био је основ за враћање на рад запосленог, када то запослени захтева, без обзира на постојање чињеница и околности да ли је или није постојао основ за престанак радног односа.

У таквој правној и чињеничној ситуацији питање да ли је понашање које је запосленом стављено на терет одлуком послодавца која је правноснажном судском одлуком поништена, представљало повреду радне обавезе или акт недисциплине за коју би био одговоран запослени, расправљано је у поступку права на накнаду штете због незаконитог отказа и висине накнаде, утврђујући основ одговорности послодавца за штету коју је запослени претрпео, искључење одговорности послодавца за накнаду штете, допринос запосленог настанку штете, а све применом правила о деликтној одговорности која су садржана у Закону о облигационим односима.⁷⁴

Међутим, у одлукама Уставног суда Републике Србије Уж-776/2012 од 11.04.2013. године и Уж-3450/2012 од 26.02.2015. године, изнето је становиште да приликом одлучивања о захтеву запосленог за накнаду штете због незаконитог отказа, треба имати у виду да је Закон о раду у том погледу *lex specialis* у односу на Закон о облигационим односима и да у својим одредбама које регулишу права запосленог поводом незаконитог отказа, не садржи одредницу о сходној примени Закона о облигационим односима, односно његових правила о деликтној одговорности, да је интенција законодавца приликом прописивања права запосленог на накнаду штете због незаконитог отказа (чл. 191), била да само постојање правноснажне судске одлуке, којом је утврђено да је запосленом незаконито престао радни однос, аутоматски даје право на накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања, те да изричито закон прописује услове под којима се висина накнаде штете може умањити, а то су само приходи остварени након престанка радног односа, без навођења других изузетака.

Уважавајући изнето становиште у наведеним одлукама и у већем броју других поступака по уставној жалби, у истој чињеничној и правној ситуацији, у судским одлукама изнет је став да је одредба чл. 191. Закона о раду,

⁷⁴ Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 1575/13 од 9.07.2013. године, Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 2766/13 од 06.11.2013. године, Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1 6885/12 од 13.06.2013. године, Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1 1923/14 од 19.01.2015. године

посебна норма, која регулише отклањање правних последица управо за случај незаконитог престанка радног односа, услед чега нема услова да се цени основаност захтева за исплату накнаде штете применом правила о деликтној одговорности која су садржана у Закону о облигационим односима.⁷⁵

Примена чл. 191. ст. 2. и 3. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09) и новелирана одредба чл. 191. ст. 9. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 75/14), од значаја је на висину накнада штете, јер се иста умањује за износ прихода које је запослени остварио по основу рада по престанку радног односа. Спорна питања у примени наведених одредаба, односила су се на евентуалну могућност запосленог да радом умањи штету по престанку радног односа, урачунавање исплаћене новчане накнаде у случају незапослености од стране Националне службе за запошљавање, као и терет доказивања тих релевантних чињеница и околности који могу бити од утицаја на обим штете.

Према Закону о запошљавању и осигурању у случају незапослености (“Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10), право на новчану накнаду у случају незапослености је једно од права из обавезног социјалног осигурања и накнада коју незапослени прима по том основу, не може се сматрати приходом који је запослени остварио по основу рада по престанку радног односа. Стога, накнада штете због незаконитог отказа о којој се одлучује у судском поступку, не може да буде умањена за износ који корисник новчане накнаде прима од Националне службе за запошљавање, јер за то не постоји правни основ. За одлучивање о праву запосленог на исплату накнаде штете у судском спору, без значаја је околност да ли ће Национална служба за запошљавање провести поступак и тражити од корисника да врати примљену накнаду, јер је то однос који ће се између њих расправити по правилима Закона о запошљавању и осигурању у случају незапослености.⁷⁶

Такође, питање да ли постоји допринос сопственој штети и основ за снижење накнаде штете, када се утврди пасивно држање запосленог у периоду када је ван радног односа и када постоји могућност да он за то време ради и остварује зараду, у Одлуци Уставног суда Републике Србије Уж-4058/2014

75 Одлука Уставног суда Србије Уж-7296/2013 од 25.02.2016. године, Одлука Уставног суда Србије Уж-2346/2014 од 3.03.2016. године, Одлука Уставног суда Србије Уж-6252/2013 од 14.04.2016. године, Одлука Уставног суда Србије Уж-7754/2014 од 14.07.2016. године, Одлука Уставног суда Србије Уж-3644/2014 од 15.09.2016. године

76 Пресуда Врховног касационог суда Рев2 2001/2015 од 28.09.2016. године,

од 01.12.2016. године изнето је следеће становиште: “Наиме, само постојање правноснажне судске одлуке, којом је утврђено да је запосленом незаконито престао радни однос, подразумевало је право тог запосленог на накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уговору о раду, уз уплату припадајућих доприноса за обавезно социјално осигурање. То значи да у таквој правној ситуацији постоји фикција о непрекидном радном односу од момента доношења незаконитог решења о отказу уговора о раду до дана враћања на рад. Исплата накнаде штете у висини изгубљене зараде и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање, представља материјализацију те правне фикције, која запосленог доводи у исти правни положај са другим запосленима који су све време радили код туженог послодавца и уредно остваривали права из радног односа (видети Одлуку Уставног суда Уж-3544/2014 од 15.9.2016. године). Из напред изнетог се, по мишљењу Уставног суда, може извести закључак да је запослени који је у одговарајућем (судском) поступку, на законом прописан начин, оспорио одлуку послодавца о отказу уговора о раду, створио легитимно очекивање да ће, за случај успеха у таквом спору, он бити доведен у идентичан правни положај са осталим запосленима, пре свега, исплатом зарада из радног односа које би остварио да је у периоду незаконитог отказа радио код туженог послодавца. Према томе, умањење накаде штете за износ прихода које је запослени остварио по основу рада представљало је само неку врсту заштитне клаузуле у корист послодавца - да није у обавези да накнади штету или део штете који је запослени својим активним држањем (евентуално) анулирао, не и дужност таквог држања запосленог, као услова за остварење права на накнаду штете због незаконитог отказа”.

3. Последице незаконитог престанка радног односа када постоји основ за престанак радног односа

Према чл. 191. ст. 7. Закона о раду, ако суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног односа и да је послодавац поступио супротно одредбама закона којима је прописан поступак за престанак радног односа, суд ће одбити захтев запосленог за враћање на рад и на име накнаде штете досудиће износ до шест зарада запосленом.

Разлози (основи) за престанак радног односа изричито су предвиђени Законом у одредби чл. 175. Отказ уговора о раду од стране послодавца је

један од основа за престанак радног односа и у односу на поједине разлоге за отказ, закон предвиђа посебну процедуру коју послодавац мора поштовати.

Уколико послодавац има намеру да откаже уговор због неостваривања резултата рада и одсуства потребних знања и способности за обављање послова на којима ради (чл. 179. ст. 1. тач. 1.) или због повреде радне обавезе (чл. 179. ст. 2.) и нарушавања радне дисциплине (чл. 179. ст. 3.), у обавези је да се придржава правила која су садржана у одредбама чл. 180. до 182. Закона, систематизована у пододељку под насловом - Поступак пре престанка радног односа или изрицања друге мере, која су дефинисана као дужност послодавца да писаним путем упозори запосленог на настали отказни разлог у случају из чл. 179. ст. 2. и 3. закона, да достави писано обавештење у вези са недостацима у раду запосленог, упутствима и роком за побољшање рада сходно чл. 180а Закона и размотри приложено мишљење синдиката.

Непридржавање тих правила је разлог да се утврди ништавост одлуке послодавца о престанку радног односа, али уколико се у истом поступку утврди да је постојао основ, као оправдан разлог за отказ који се односи на радну способност запосленог и његово понашање, ново законско решење даје овлашћење суду и налаже да се захтев запосленог за враћање на рад одбије и досуди накнада штете у износу до шест зарада коју је запослени остварио у месецу у коме му је престао радни однос (став 8.).

У изнетој правној и чињеничној ситуацији запослени не би имао право на накнаду штете због изостале зараде и других примања, обзиром да одредба чл. 191. ст. 2. закона, која упућује на став један истог члана, прописује право на накнаду штете као последицу незаконитог отказа, коју остварује запослени коме је радни однос престао без основа.

Када је у питању отказни разлог предвиђен у одредби чл. 179. ст. 1. тач. 1. Закона о раду - ако запослени не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради, и примена одредбе чл. 191. ст. 7, у вези чл. 180а истог закона, која прописује да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, ако му је претходно дао писано обавештење у вези са недостацима у његовом раду, упутствима и примереним роком за побољшање рада, а запослени не побољша рад у остављеном року, у одсуству судске праксе по новелираним одредбама закона захтева посебну пажњу. Наиме, када послодавац утврди да запослени не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности, у обавези је да о томе на било који начин укаже или обавести запосленог у вези са недоста-

цима у његовом раду, те да запосленом да упутства и инструкције о пословима на којима ради, па уколико запослени и даље обавља своје дужности на незадовољавајући начин, настаје разлог за отказ уговора о раду, јер задира у суштину радно правног односа, а недостављање обавештења у писменој форми, са садржајем који предвиђа одредба чл. 180а закона, представља повреду поступка и поступање које је супротно одредбама закона, услед чега има услова за примену одредбе чл. 191. ст. 7. закона, уколико се у судском поступку утврди да је постојао основ за отказ.

Међутим, да ли се такво тумачење може прихватити без сагледавања суштине обавезе послодавца и циља давања упутства запосленом са примерним роком за побољшање рада, јер уколико послодавац није доставио запосленом писано обавештење у вези са недостацима у његовом раду, са упутствима и инструкцијама о пословима на којима ради, што је део поступка за примену отказног разлога, али истовремено је и услов за примену отказног разлога из чл. 179. ст. 1. тач. 1. Закона о раду, сматраће се да је запосленом престао радни однос без правног основа и нема места примени одредбе чл. 191. ст. 7. Закона о раду.⁷⁷

Одељак под насловом - Поступак у случају отказа, у одредбама чл. 184., 185. и 186. закона регулише рок застарелости, достављање акта о отказу уговора о раду и обавезу исплате зараде и накнаде зараде.

Рокови застарелости из чл. 184. Закона, који се односе на могућност давања отказа уговора о раду у случају наступања отказног разлога из чл. 179. ст. 1. тач. 1. и ст. 2. и 3. истог закона, су продужени и то субјективни у року од шест месеци од дана сазнања за чињенице које су основ за давање отказа и објективни у року од годину дана од дана наступања чињеница које су основ за давање отказа, услед чега се не може приговорити да се не ради о разумним роковима у којима послодавац може употребити настали разлог за отказ уговора.

Рокови се сматрају преклузивним, па се поједини отказни разлози могу применити (употребити) само у одређеном временском периоду након што су настали и по протеклу тог периода примена отказног разлога није могућа.

У таквој ситуацији, послодавац губи правну моћ да због насталог отказног разлога откаже уговор о раду и сматра се да је одустао од употребе разлога за отказ уговора, обзиром да послодавац може, али и не мора да разлог за отказ

⁷⁷ Пресуда Врховног касационог суда Рев2 148/2013 од 16.5.2013. године, Препорука бр. 166 Конвенције МОП-а бр. 158 ("Службени лист СФРЈ" - Међународни уговори бр. 4/84 и 7/91)

употреби, при том имајући у виду и да се ради о уговорном односу. Пасивност послодавца или други разлози (оправдавајући мотиви, одустанак, опрост и слично), уз протек времена, стављају до знања запосленом да у складу са законом послодавац не може или неће да употреби разлог за отказ, што је све од значаја на стабилност раднофункционалне везе између запосленог и послодавца и треба да подразумева коначно решење спорног односа, што доприноси правној сигурности, услед чега наступањем застарелости отказног разлога, послодавац у суштини нема основ за престанак радног односа.

Међутим, одредба чл. 184. Закона, систематизована у одељку под насловом - Поступак у случају отказа, поставља питање да ли употреба отказног разлога (који је факултативан), по протеку рокова прописаних у наведеној одредби, представља поступање послодавца супротно закону у процедури давања отказа, без обзира на време када ће послодавац донети одлуку којом отказује уговор о о раду и да ли су тиме испуњени услови за примену чл. 191. ст. 7. закона, о чему се судска пракса за сада, у складу са новелираним одредбама, није изјаснила, а неопходно би било јединствено поступање по овом питању у циљу предвидивости решавања евентуалних спорова, што је од значаја и за послодавца и за запосленог.

С тим у вези, непоступање послодавца у смислу чл. 186. Закона о раду, којом је прописана дужност да у року од 30 дана од дана престанка радног односа запосленом исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примана која је запослени остварио до престанка радног односа, није имала делотворну санкцију, јер тако утврђен основ није био релевантан у оцени законитости одлуке послодавца о престанку радног односа. Међутим, како одредба чл. 191. ст. 7. закона не прави разлику између поступка пре престанка радног односа и поступка у случају отказа, произилази да би непоступање по напред наведеној императивној норми стварало услов за отклањање правних последица, сходно овој законској одредби.

Литература и извори

Закон о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

Закон о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља)

Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10)

Закон о парничном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС и 55/2014)

Закон о ратификацији Конвенције Међународне организације рада број 158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца (Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори бр. 4/84, 7/91) и Препорука бр. 166 о престанку радног односа на иницијативу послодавца

Пресуде Врховног касационог суда Рев2 1423/10 од 27.10.2011. године, Рев2 2001/2015 од 28.09.2016. године и Рев2 148/2013 од 16.5.2013. године

Одлуке Уставног суда Републике Србије: Уж-841/2012 од 26.11.2015. године, Уж-7398/2014 од 17.11.2016. године, Уж-7296/2013 од 25.02.2016. године, Уж-2346/2014 од 03.03.2016. године, Уж-6252/2013 од 14.04.2016. године, Уж-7754/2014 од 14.07.2016. године и Уж-3644/2014 од 15.09.2016. године

Судске пресуде:

Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1 3133/2012 од 26.04.2013. године,
Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 2230/2012 од 22.02.2013. године,

Пресуда Окружног суда у Нишу Гж1 729/2009 од 08.07.2009. године,
Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 1575713 од 9.07.2013. године,
Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 2766/13 од 06.11.2013. године,
Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1 6885/12 од 13.06.2013. године,
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1 1923/14 од 19.01.2015. године.

NAŠ TIM

Za uspešno poslovanje potrebna je kvalitetna pravno-ekonomska baza.

Za kvalitetnu bazu potreban je profesionalan tim.

Naš tim broji preko:

- ♦ 180 zaposlenih koji se svakodnevno brinu o tome da dobijete blagovremenu i tačnu informaciju
- ♦ 200 stalnih autora iz oblasti pravnih, ekonomskih i ostalih nauka
- ♦ 15.000 višegodišnjih korisnika koji svojim sugestijama doprinose kvalitetu baze "Paragraf Lex"

POSTANITE I VI DEO USPEŠNOG TIMA!

PRAVNO-
EKONOMSKE
VESTI

SUDSKA
PRAKSA

SLUŽBENA
MIŠLENJA

OBRASCI

CARINSKA
TARIFA

STRANA
SUDSKA
PRAKSA

PROPISI

MODELI

EVROPSKO
ZAKONODAVSTVO

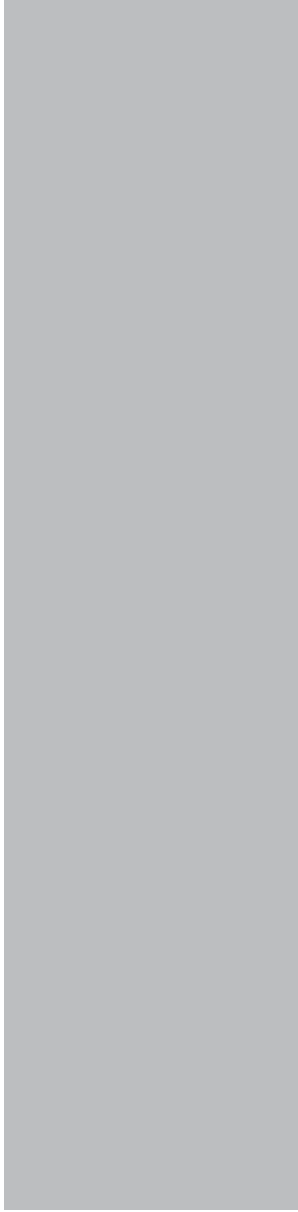
Želite pouzdanu pravno-ekonomsku bazu na koju možete da se oslonite i koja će Vam ponuditi stručne tekstove, pronaći odgovore i biti Vaš virtuelni saradnik?

IMAMO REŠENJE ZA VAS!



www.paragraf.rs

ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА



ПРАВНИ СТАВОВИ

ИЗВОД из записника са заједничке седнице Грађанских одељења и Одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Нишу са представницима Врховног касационог суда одржане 24.03.2017. године.

Констатује се да су на састанку од стране свих апелационих судова **једногласно** усвојени правни ставови:

1. Корисник кредита по уговору о стамбеном кредиту закљученим са банком у валути швајцарски франак има правни интерес за подношење тужбе ради утврђења ништавости тог уговора због неодређености одредбе уговора које се односе на начин и висину обрачуна камате у ситуацији када је претходно са банком потписао вансудско поравнање а све у вези са препоруком НБС од 31.05.2013. године.
2. У споровима у којима тужиоци са подручја Косова и Метохије траже исплату пензије која је обустављена решењима Републичког фонда ПИО (“косовске пензије”), основ спора представља накнада штете настала незаконитим и неправилним радом државног органа, у смислу члана 172. Закона о облигационим односима, за коју је прописан рок застарелости из члана 376. истог Закона.

Износи који су тужиоцима у овим споровима исплаћивани по основу Уредбе УНМИК-а на Косову и Метохији, представљају пензију.

Висина штете се обрачунава тако што се износ пензије, коју је требало да исплати Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, умањује за износ који су тужиоци примили по Уредби УНМИК-а број 2001/35 од 22.12.2001. године са изменама и допунама по Уредби број 2005/20, која је ступила на снагу 29.04.2005. године и Закону о изменама и допунама Уредбе број 2005/20 од 13.06.2008. године.

3. Осигуравач не може да тражи исплаћену накнаду штете оштећеном лицу од штетника у случају када је оштећени са штетником у сродству у правој линији и са њим живи у истом домаћинству изузев ако је штетник штету проузроковао намерно или када је штетник осигуран од одговорности код другог осигуравача (чл. 939 став 4. у вези чл. 1 и чл. 939 став 5 ЗОО).

4. Решење Директора Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 01 бр.181-630/11 од 26.01.2011. године којим је најнижи износ пензије утврђен на износ од 11.447,81 динара почев од 01.01.2011. године, не односи се на категорију пољопривредних пензионера.

5. По тужбама Републичког фонда за здравствено осигурање против тужених домова здравља, болница, клиничког центра и директора ових установа, ради накнаде штете, постоји надлежност суда (чл. 1. ЗПП), а правни основ је накнада штете (чл. 262. ст. 1 и 2. ЗОО).

Констатује се да су на састанку од стране **већине** апелационих судова усвојени правни ставови

1. О приговору као правном леку против одлуке о одређивању привремене мере из чл. 104. ЗЈИМ, одлучује виши суд.

На привремене мере као средство обезбеђења новчаног потраживања, конкретно накнаду штете, примењују се општа правила Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о парничном поступку.

2. У изреци решења којим се одређује привремена мера, а којом се забрањује поновно објављивање информација, морају бити наведени сви наслови текстова у којима су наведене информације објављене, односно морају бити тачно наведене све информације чија се забрана поновног објављивања тражи, имајући у виду одредбе чл. 101. и 104. ст. 1. ЗЈИМ, из којих произилази да се привременом мером може захтевати забрана поновног објављивања само исте информације, односно записа, дакле, одређене али већ објављене информације. Стога је потребно да се у изреци решења тачно наведу све информације чије се поновно објављивање забрањује.

3. За објављивање информација у публикацији, које су способне да због своје садржине проузрокују материјалну и нематеријалну штету лицу на које се односе, одговора аутор те информације, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

4. Могу бити одговорни и један и други (са посебним освртом на то да је чл. 115. ЗЈИМ, прописано да одговорни уредник солидарно са новинаром и издавачем медија одговара за информацију чије објављивање није дозвољено у смислу ЗЈИМ.

5. По захтеву за накнаду штете пасивно легитимисан, као штетник, одговорни уредник који је то својство имао у време када је штетна радња настала, а по тужбеном захтеву за објављивање информације уредник који треба да објави ту информацију, односно онај који то својство има у време пресуђења.

6. Пасивно легитимисани могу бити главни уредни, одговорни уредник и уредник сваке поједине рубрике, а њихова одговорност зависи од кривице.

7. Ако је вансудским поравнањем регулисано да је каматна стопа фиксна и да убудуће нема променљиве каматне стопе, онда не би постојао правни интерес корисника кредита да поднесе тужбу којом би тражио утврђење ништавости одредбе уговора у делу који се односи на променљиву каматну стопу, јер је поравнањем измењен уговор у том делу.

Констатује се да на састанку од старне свих апелационих судова **не постоји јединствен став** по питањима :

1. Како поступати у другостепеном парничном поступку када је тужбеним захтевом на главни износ валуте - евро тражено да тужени тужиоцу плати и камату коју прописује Централна Европска банка, па првостепени суд такав захтев усвоји?

2. Ако првостепени суд тужбу није одбацио по претходном испитивању тужбе сходно члану 294 ЗПП, на припремном рочишту или на рочишту за главну расправу иста се може одбацили због недостатка правног интереса или као неуредна током целог првостепеног поступка, као и у поступку по жалби.

3. Да ли је након доношења аутентичног тумачења одредаба чл. 1, чл. 5. ст. 1. и чл. 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији (“Службени гласник РС” бр. 53/95, 23/01-СУС, 20/09 и 55/13-УС), објављеног у “Службеном гласнику РС” број 106 од 28.12.2016. године дошло до промене досадашњег правног става и постојеће судске праксе да се одредба чл. 42. Закона о експропријацији примењује и на случајеве одређивања накнаде када оду-

зимање или ограничење права на непокретностима није извршено у поступку и на начин предвиђен тим Законом (тзв. “фактичка експропријација”) и уколико јесте, које материјално право убудуће примењивати?

4. Да ли је у односу на оне војне резервисте - учеснике рата 1999. године који су након ратних дејстава водили спор пред судом за исплату ратних дневница и одбијени због застарелости потраживања, извршена дискриминација на основу пребивалишта Закључком Владе Републике Србије 05 бр.401-161/2008 од 17.01.2008. године, којим су обезбеђена средства ради исплате новчане помоћи ратним војним резервистима са пребивалиштем на територији 7 неразвијених општина (Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане, Житорађа, Дољевац и Прокупље)?
5. Да ли записник надзорника осигурања РФЗО представља јавну исправу?
6. Да ли возач теретног возила и аутобуса који по уговору о раду имају уговорено радно време 40 часова недељно, а који су према подацима из путних налога, време поласка на пут и време доласка са пута у периоду пре ступања на снагу Закона о радном времену поседе возила у друмском превозу и тахографима остајали на путу дуже од 8 часова, имају право на увећању зараду за прековремени рад у складу са чл. 108. ст. 1. тач. 3. Закона о раду. Ако имају право на увећању зараду на који начин се утврђује дужина рада дужа од пуног радног времена, да ли само на основу ефективног рада са паузама у складу са законом по подацима из тахографа или као разлика између укупноведеног времена на путу по путним налозима и ефективне вожње по подацима из тахограф траке, као и да ли се у ту разлику урачунава време дневног одмора?

ИЗВОД из записника са заједничке седнице Грађанских одељења и Одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Нишу са представницима Врховног касационог суда одржане 23.06.2017. године са почетком у 11, 00 часова.

Констатује се да су на састанку од стране свих апелационих судова **једногласно** усвојени закључци

1. У парницама у којима је тужбени захтев заснован на тврдњи о постојању дискриминисаног поступања примењује се посебна процес-

ноправна правила за заштиту од дискриминације, садржана у одредбама Закона о забрани дискриминације (“Службени гласник Републике Србије”, број 22/09 од 30.03.2009. године), без обзира када је дискриминација извршена. У парницама у којима је тужбени захтев заснован на тврдњи о постојању дискриминацијског поступања које је извршено пре ступања на снагу Закона о забрани дискриминације не примењује се посебна материјална правна правила за заштиту дискриминације садржана у наведеном закону Норма из чл. 120 Закона о јавном информисању и медијима није процесна норма, већ материјално правна норма која говори о обиму заштите, односно врсти заштите коју овај Закон прописује, па зато нема места примени принципа непосредног, односно тренутног дејства процесних правила, већ се примењује принцип забране ретроактивности.

2. Правни следбеник (супружник, дете или родитељ) преминулог лица има право на накнаду нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа, због објављивања недопуштене информације о покојном, којим се вређа право на пијетет.
3. Суд није овлашћен да уместо родитеља доноси одлуке које замењују сагласност родитеља за одвођење малолетног детета у иностранство, да суд дозволи да малолетно дете отпутује са тужиоцем у иностранство и промени пребивалиште, односно које замењује заједничке одлуке родитеља о битним питањима вршења родитељског права, већ у таквој ситуацији руководећи се најбољим интересом малолетног детета, по чл. 3. Конвенције о правима детета и чл. 266. ст. 1. Породичног закона, овлашћен је да наложи тужиоцу да уреди тужбу у погледу захтева који треба да буде усмерен на делимично лишење родитељског права родитеља који не даје сагласност за промену места пребивалишта детета, у складу са одредбом чл. 82. Породичног закона.
4. За одговор на питања на чији терет падају трошкови налаза и стручног мишљења другог органа старатељства, породичног саветовалишта или друге установе специјализоване за посредовање у породичним споровима за лишење родитељског права, покренутим тужбама Центра за социјални рад против тужених родитеља, а у вези поступања суда у смислу чл. 270 Породичног закона и правног закључка Врховног касационог суда, усвојеног на седници Грађанског одељења одржаној 14.07.2017. године, морају се разликовати две ситуације.

У ситуацији када мишљење треба да да други Центар за социјални рад, онда он то ради у оквиру својих редовних овлашћења, па се тиме није изложио посебним трошковима и нема право на накнаду трошкова.

Друга ситуација је када налаз и мишљење треба да да нема друга установа специјализована за посредовање у породичним односима, која своје услуге наплаћује, па уколико тужилац не предујми трошкове израде налаза и мишљења по налогу суда тада ће се трошкови исплатити из средстава суда, с тим што ће након окончања поступка суд те трошкове наплатити од Центра за социјални рад који је покренуо поступак.

5. Јавни градски превоз представља комуналну делатност, па се једногодишњи рок застарелости комуналних услуга у смислу чл. 378 ст. 1 тач.1 Закона о облигационим односима аналогно може применити и на потраживање наплате доплатне карте за коришћење услова у градском јавном превозу.
6. Након престанка радног односа запослених са којима је закључен споразум о престанку радног односа уз исплату новчане накнаде у смислу чл. 21. наведеног закона, послодавац је у обавези да утврди преостали број запослених за чијим радом престаје потреба од кога зависи обавеза доношења програма решавања вишка запослених сходно чл. 22. Закона, у вези чл. 153. Закона о раду.
7. Послодавац (организациони облик) у коме постоји потреба рационализације броја запослених на одређеним пословима дужан је да у складу чл. 21. ст. 1. наведеног закона спроведе анкету међу запосленима који раде на пословима за које више не постоји потреба или постоји потреба смањења броја извршилаца, јер запосленом треба омогућити изјашњење о намери спремности да му радни однос престане споразумно уз исплату новчане накнаде и у зависности од исхода тог поступка, спроводи се поступак престанка радног односа уз исплату отпремнине у смислу чл. 22. Закона. Послодавац нема овлашћење да бира у поступку рационализације броја запослених да ли ће применити поступак престанка радног односа уз исплату отпремнине користећи се привилегованим роком за исплату отпремнине из чл. 22. ст. 5. Закона.
8. Изјашњење запосленог анкетирањем, да прихвата престанак радног односа уз исплату новчане накнаде је од утицаја на сам поступак споразумног престанка радног односа уз исплату новчане накнаде (чл. 21. закона), али се не може сматрати прихватам понуде пре него што посло-

давац запосленом достави споразум сачињен у писаном облику који садржи све битне елементе у погледу радноправног статуса запосленог и висине новчане накнаде, јер се ради о престанку радног односа на иницијативу послодавца. Уколико изјашњење није резултирало споразумним престанком радног односа, дата изјава у поступку анкетирања не може бити основ, нити један од критеријума за престанак радног односа уз исплату отпремнине.

Констатује се да на састанку од стране свих апелација **не постоји јединствен став** по питањима:

1. Да ли је за суђење по тужби у поступку правне заштите на основу чл. 83, 84, 85. и 101, чл. 107. ст. 2. чл. 112. и чл. 119. Закона о јавном информисању и медијима месно надлежан Виши суд на чијем подручју се налази седиште издавача, како је прописано одредбом чл. 121. Закона о јавном информисању и медијима, који је ступио на снагу 13.08.2014. године или је месно надлежан само Виши суд у Београду, за целу територију Републике Србије, како је прописано одредбом чл. 4. ст. 2. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, који је ступио на снагу 21.11.2013. године, а почео да се примењује од 01.01.2014. године?
2. Да ли је постојање правноснажног решења руководиоца органа о признању права полицијском службенику на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, материјална претпоставка која мора бити испуњења да би у парници полицијски службеник остварио право на исплату новчаног потраживања по том основу?
3. Да ли осигураник губи права у случају када је осигураник лице које је проузроковало саобраћајну несрећу, напустило лице места саобраћајне незгоде, након што је оставило податке оштећеном, те на основу тих података то лице у року од 30 минута буде пронађено од стране полиције, извршено је алко тестирање које је показало да код осигураника нема алкохола у крви, а у току поступка буде утврђено да је осигураник лице места напустио због озбиљних претњи оштећеног да ће напасти живот и тело осигураника?
4. Како тумачити и применити рок доспелости из чл. 71. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица који гласи: Лична породична и увећана породична инвалиднина, додатак за негу и по-

моћ, ортопедски додатак и накнада за време незапослености исплаћују се по истеку месеца за који се врши исплата?

ИЗВОД из записника са заједничке седнице Грађанских одељења и Одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Новом Саду и Апелационог суда у Нишу са представницима Врховног касационог суда одржане 28.09.2017. године у Крагујевцу

Констатује се да су на овом састанку од стране свих апелационих судова **једногласно** усвојени следећи

ЗАКЉУЧЦИ

1. Конвенција о извођењу доказа у иностранству и грађанским и трговачким стварима, у чл. 2. ст. 1. прописује да ће свака држава уговорница именовати централни орган који ће бити задужен да прима замолнице које потичу од судског органа друге државе уговорнице и да их доставља надлежном органу ради извршења и да ће свака држава организовати централни орган у складу са својим законодавством ст. 2. наведеног члана је прописано да се замолница доставља централном органу замољене државе, без посредовања других органа те државе. Чланом 3. је предвиђено шта замолница треба да садржи, тј., какве податке. Наиме, у ситуацији када Центар за социјални рад не може да прибави потребне податке, суд свакако мора. Из напред наведеног потребно је применити чл. 2. и чл. 3. Хашке конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима, односно јесте обавеза суда да прибави доказе, извештај установе специјализоване за породичне односе, односно надлежног органа земље пребивалишта, односно боравишта родитеља детета.
2. Законски заступник странке која нема парничну способност (малолетна лица, лица лишена пословне способности) не може да изда пуномоћје за заступање те странке у парници у којој се штите њени интереси, свом крвном сроднику у правној линији брату, сестри, или брачном другу у смислу чл. 85. ст. 2. ЗКП. Изузетак од овог правила је ситуација када лица, ангажована од стране законског заступника, спадају у круг

лица из чл. 85. ст. 2. ЗКП, у односу на заступано лице, односно ако се ради о крвном сроднику у правој линији, брату, сестри или брачном другу лица које нема парничну способност.

Питања о којем се апелациони судови **нису усагласили**

1. Према Општим условима за обављање поштанских услуга прописаних у чл. 20. ст. 1. препоручена пошиљка је регистрована писмоносна пошиљка, без означене вредности, за коју се пошиљаоцу издаје потврда о пријему пошиљке, а примаоцу се уручује уз потврђење пријема, ст. 5. Наведене одредбе је приписано да све препоручене пошиљке морају у левом горњем углу адресне стране имати бар код налепницу са назнаком “Р” и број пошиљке. Пошиљка која у горњем левом углу адресне стране садржи ознаку “А” према чл. 21. Наведених Општих услова за обављање поштанских услуга је пошиљка са потврђеним уручењем, а не препоручена пошиљка. То значи да у том случају поднесак није послат препорученом пошиљком, па се као дан подношења поднеска има сматрати дан предаје суду, како је прописано чл. 104. ст. 1. ЗПП.
2. Када је усвојен тужбени захтев и утврђена ништавост одредбе уговора о кредиту на основу које је тужена банка наплаћивала тужиоцима више износе на име анuitета, а по основу променљивих каматних стопа, банка је на захтев тужилаца - корисника кредита, дужна да врати више наплаћени новчани износ и то у готовом новцу, са припадајућом каматом.

На овакву обавезу банке не утиче чињеница да је банка доставила доказ или је неспорно да је поступајући по одлуци Народне банке Србије од 25.02.2015. године тужиоцима вратила више наплаћени износ по основу примене променљивих каматних стопа, тако што је те износе урачунала у превремену отплату дела кредита и смањила главницу, јер је банка то учинила без претходне сагласности тужиоца, поступајући са позиције економски јаче стране, што је потребно основима начелима облигационог права.

Уколико је банка доставила клијенту обавештење да му је смањила главницу и доставила нови анuitетни план са смањеном месечном ратом и клијент започео са плаћањем по новом анuitетном плану без приговора, клијент нема право да тражи враћање више плаћеног у готовом новцу, јер се сматра да је прихватио начин враћања урачунавањем више плаћеног износа у превремену отплату кредита и смањењем главнице.

ОДГОВОРИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА НА ПИТАЊА ПОДРУЧНИХ СУДОВА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

Су II -17-3/17

18.04.2017. године

Н И Ш

ОСНОВНОМ СУДУ У СУРДУЛИЦИ

Председнику Грађанског одељења

Одговори на спорно правно питање Основног суда у Сурдулици који је усвојен на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу дана 09.03.2017. године

Да ли се у предметима по тужбама ЕПС Дистрибуција - Огранак Врање, где постоји споразум о признању дуга са тужен им, у ситуацији да је након последње уплате по споразуму протекао рок дужи од 1 године, примењује одредба чл. 378. ЗОО или општи рок према чл. 371. ЗОО, јер је дуг признат споразумом.

Једногласно се прихвата понуђени одговор:

Примењује се одредба чл. 378. ст. 1. ЗОО, јер се ради о потраживању накнаде за испоручену електричну енергију. Због неизмирења рата по споразуму, исти се сматра раскинутим, а обзиром да је тужени закључењем споразума признао застарели дуг, рок застарелости почиње поново да тече од дана закључења споразума, уколико није било уплата по споразуму, а уколико јесте од дана последње уплате. Међутим, треба разликовати ситуације када закључењу споразума претходи закључење уговора о приступању дугу, сходно чл. 451. ЗОО, када према приступиоцу треба применити општи рок застарелости из чл. 371. ЗОО, јер иако је споразум раскинут, уговорни однос по уговору о приступању дугу и даље постоји, а на потраживања из таквог односа примењује се општи рок застарелости.

*Председник Грађанског одељења,
судија Данијела Николић*

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

Су II -17-3/17

18.04.2017. године

Н И Ш

ОСНОВНОМ СУДУ У НИШУ

Одговори на спорна правна питања Основног суда у Нишу, који је усвојен на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу дана 09.03.2017. године и на заједничкој седници Грађанског одељења и Одељења за радне спорове од 20.03.2017. године

1. Како тумачити и применити рок доспелости из одредбе чл. 71. Закона о правима-бораца. Војних инвалида и чланова њихових породица која гласи “лична, породична и увећана породична инвалиднина, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак и накнада за време незапослености исплаћују се по истеку месеца за који се врши исплата”.

Већином гласова прихваћена је друга група мишљења да време испуњења обавезе није одређено одредбом чл. 71. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, па би тужени доспевао у доцњу у смислу чл. 324. ст. 2. ЗОО.

2. Да ли се једногодишњи рок застарелости комуналних услуга, у смислу чл. 378. ст. 1. тач.1. ЗОО по коме је рок застарелости једна година, аналогно може применити и на остале комуналне услуге предвиђене Законом о комуналним делатностима, на пример услуге ради плаћања доплатне карте, за коришћење услуге превоза у градском аутобусу, који су покренути по истеку рока од годину дана од доспелости обавезе?

Већином гласова прихваћен је први понуђени одговор да је у питању комунална услуга и иста застарева у року прописаном чл. 378. ст. 1. тач. 1. ЗОО.

3. Каква је правна природа потраживања тужилаца - физичких лица против пословних - банака, у којима се тужбени захтев заснива на Одлуци НБС о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система (“Службени гласник РС” бр.21/2015 и 51/2015).

У вези са тим поставља се питање правне природе потраживања тужилаца, да ли је у питању накнада штете, умањење имовине, или је реч о стицању

без основа, или се ради о новчаном потраживању односно дугу банака према тужиоцима - корисницима кредита?

Једногласно је констатовано да се судије Апелационог суда неће изјашњавати о овом питању, јер се ради о поступцима који су тек покренути и у којим ајош увек нису донете првостепене пресуде, нити су на постављена питања понуђени одговори са израженим правним ставовима.

4. Да ли је чл. 76. ст. 1. ЗОППО предвиђен исти начин обрачуна пензије у смислу утврђивања најнижег износа пензије, односно да ли је одредба ст. 2. о ванредном усклађивању пензија најнижег износа у осигурању запослених и у осигурању самосталних делатности почев од 01.01.2011. године треба применити и приликом обрачуна пензије за осигуранике пољопривреднике и да ли се у овом случају на ову категорију треба примењивати решење директора РФ ППО о утврђивању најнижег износа пензије.

Једногласно је прихваћен одговор:

Решење директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 01 бр.181-630/11 од 26.01.2011. године, којим је најнижи износ пензије утврђен на износ од 11.447,81 динара, почев од 01.01.2011. године не односи на категорију пољопривредних пензионера. Ово из разлога што је за категорију пољопривредних пензионера најнижи износ пензије већ утврђен Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању на износ од 9.000,00 динара, почев од 01.01.2011. године. Уколико би се прихватило да је решењем директора Фонда измењен износ најниже пензије и за категорију пољопривредних пензионера дошло би до ситуације да се решењем директора Фонда мења законски текст. Сем тога, ове две категорије пензионера би се изједначиле, а сам Закон прави разлику између категорије пензионера који право на пензију остварују из радног односа и категорије пензионера који право на пензију остварују по основу пољопривредне делатности.

Наведено спorno правно питање било је кандидовано од стране Апелационог суд ау Нишу за заједнички састанак Грађанских одељења, Одељења за радне спорове и Одељења судске праксе апелационих судова Републике Србије који је одржан 24.03.2017. године у Новом Саду, на ком састанку је, такође једногласно, од стране свих апелационих судова прихваћен понуђени одговор.

5. Питање везано је за тужбе које се подносе за исплату пореза и доприноса на износ разлике накнаде за случај незапослености, кад је предмет тужбеног захтева само уплата или исплата доприноса на разлике накнаде за случај незапослености, као самостално потраживање.

Овде се поставља питање да ли одлучивање о оваквим тужбеним захтевима спада у судску надлежност, те уколико се о њима одлучује у парничном поступку, који је суд стварно надлежан у првом степену - Основни или Виши, као и питање функционалне надлежности унутар суда, односно да ли о овим тужбеним захтевима одлучивати применом правила ЗПП или посебних правила која важе за поступак у радним споровима.

Једногласно је прихваћен одговор да је то судска надлежност, да се ради о спору из опште парнице и да је надлежан основни суд.

6. Питање тиче се примене одредаба ЗПП о личном достављању писмена, сходно чл. 141. и 143. ЗПП.

Апелацини суд у Нишу једногласно је констатовао да неће одговарати на ово питање јер већ постоје усаглашени правни ставови са заједничких седница представника Грађанских одељења и Одељења за радне спорове апелационих судова одржаних дана 11.12.2015. године у Београду, а у вези питања шта значи “тачна адреса” из чл. 141. ст. 2. ЗПП и дана 10.06.2016. године у Нишу, у вези одбацивања тужбе када је немогуће исту доставити туженом на адресу из тужбе, на који се и сам Основни суд у Нишу позвао у свом питању.

У вези питања шта значи “тачна адреса” из чл. 141. ст. 2. ЗПП указујемо Вам да се тачном адресом сматра адреса на којој је тужени пријављен код надлежног органа, што подразумева пријаву пребивалишта и боравишта, а која може да буде различита. Међутим, адреса на којој странка фактички станује је њена тачна адреса. У случају сазнања суда добијеним од судских достављача, а проведених од стране суда преко државних органа, ПУ, Центра за социјални рад, сазнања суда из другог суда, да на адреси на којој је странка пријављена са пребивалиштем фактички не станује, односно не борава на адреси пребивалишта, достављање писмена које се лично доставља није могуће извршити преко огласне табле суда. Ово из разлога јер странка не мора увек обавезно боравити на адреси пребивалишта, с обзиром на то да, поред пребивалишта, странка може имати и привремено боравиште на другом месту, нпр. Због студија или посла или у другом граду и иностран-

ству или се може догодити да странка нову адресу становања у истом месту није пријавила раније из оправданих разлога, нпр. Подстанарски однос без пријављивања од стране станодавца у саграђеном објекту, у току је процедура пријављивања и слично. С обзиром на то да суд не утврђује разлог непријављивања нове адресе пребивалишта и да то представља питање релевантно за прекршајно право суд није овлашћен да странци ускрати право сазнања да је против ње покренут судски спор где је обавезно лично достављање тужбе, а тиме и право да расправља пред судом.

Поводом постављеног питања:

“Како разумети и примењивати аутентично тумачење одредаба чл. 53. ст. 1. и 2. закона о експропријацији објављеном у (“Службеном гласнику РС” бр. 76 од 27.12.2016. године) указујемо да у случајевима када одузимање права својине на непокретностима није извршено у поступку и на начин предвиђен Законом о експропријацији, нема места примени одредаба овог закона. Међутим, како се ради о одузимању права својине које се гарантује како чл. 58. Устава РС и чл. 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију о људским правима, власници одузетих непокретности имају право на исплату одговарајуће накнаде која не може бити нижа од тржишне вредности непокретности у моменту њеног одређивања, према стању непокретности у то време и то право не застарева.

У вези правне природе накнаде због проласка кабла електричне енергије ваздушним путем и питања застарелости ове накнаде упућујемо на правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 23.01.2017. године.

*Председник Грађанског одељења,
судија Данијела Николић*

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

Су I-7-29/17

08.09.2017. године

Н и ш

ВИШЕМ СУДУ У ВРАЊУ

Председнику Грађанског одељења

Одговори на спорна правна питања Вишег суда у Врању који су усвојени на седницама Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу одржаним дана 24.05.2017. године, 09.06.2017. године и 08.09.2017. године

На седницама Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу одржаним дана 24.05.2017. године, 09.06.2017. године и 08.09.2017. године разматрана су спорна правна питања у вези дискриминације ратних војних резервиста, постављена дана 19.05.2017. године, па Вам дајемо следеће одговоре на исте:

1. Застарелост накнаде нематеријалне штете, односно да ли рок застарелости почиње да тече од дана утврђења дискриминације или од доношења закључка Владе РС од 17.01.2008. године.

Једногласно је прихваћено мишљење да објективни рок застарелости почиње да тече од дана доношења закључка Владе РС.

2. Да ли има дискриминације за припаднике који су били у активном радном односу код Полицијских управа, а признато им је учествовање у рату и уписано у војној књижици?

Једногласно је прихваћено Ваше мишљење да у том случају нема дискриминације.

3. Да ли има дискриминације за лица која су била на одслужењу редовног војног рока у периоду ратног стања?

Једногласно је прихваћено Ваше мишљење да тада нема дискриминације.

4. Да ли има дискриминације тужилаца који се нису одазвали позиву суда ради провођења доказа саслушањем у својству сведока, а тужени није доставио доказе да су исти остварили одређену накнаду?

Једногласно је заузет став да уколико се тужиоци нису одазвали позиву за саслушање у својству странке суд ће ценити да ли има дискриминације,

применом правила о терету доказивања, што значи да у тим случајевима тужиоци нису доказали дискриминацију, па тужбени захтев треба одбити.

5. Да ли има дискриминације када је одбијен тужбени захтев тужилаца у спору који је водио 2002. године, због застарелости.

Ово питање је било на усаглашавању апелационих судова и није било једногласног мишљења. Већинско је мишљење овог суда да у том случају нема дискриминације.

6. Да ли има дискриминације уколико странка није боровила на Косову и Метохији имајући у виду да су боровили на подручју Пчињског округа, који се граничи са Републиком Македонијом и са КиМ, на коме је погинуо велики број резервиста (нпр. Село Рељан)?

Једногласно је прихваћено Ваше мишљење да има дискриминације, односно да не треба правити разлику у зависности од тога да ли је неко био на Косову или не.

7. Да ли има дискриминације када се ратни резервисти, као тужиоци, изјашњавају да су примили минималне износе за личну хигијену или ратне дневнице за осмочасовни боравак на терену (када се из списка утврђује висина накнаде од 60,00 динара или 67,50 динара, које спискове доставља тужена, а према предложеним доказима од стране тужилаца висина накнаде је 350,00 динара по дану, која накнада је исплаћена војним резервистима из Топличког округа)?

Већином гласова прихваћено мишљење да у том случају није доказана дискриминација.

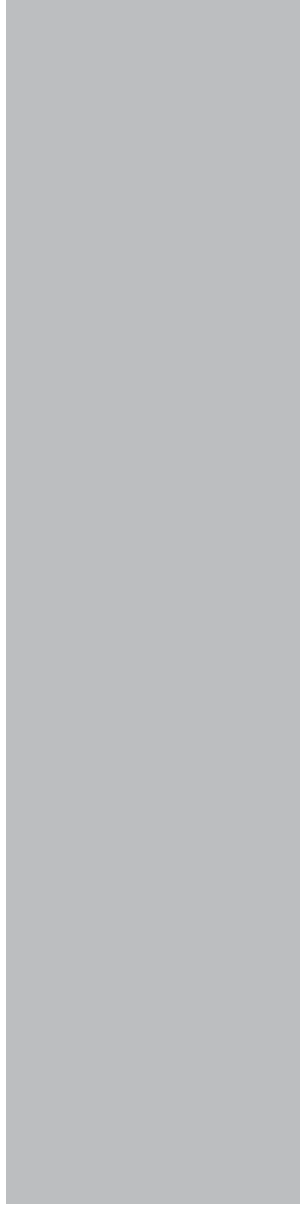
8. Да ли има дискриминације у ситуацији када се тужиоци изјашњавају приликом саслушања у својству сведока да се не сећају да ли су водили спор по завршетку рата, а тужени не нуди доказе да је исти остварио одређену накнаду?

Једногласно је прихваћено мишљење да нема дискриминације, односно да тужилац није доказао дискриминацију.

Истовремено Вас обавештавамо да су одређена питања везана за дискриминацију ратних резервиста разматрана на заједничкој седници свих апелационих судова и Врховног касационог суда одржаној у Малчи дана 23.06.2017. године, на којој су усаглашени и одређени ставови у вези примене Закона о забрани дискриминације. Са садржином записника са те седнице можете се упознати преко званичног сајта Апелационог суда у Нишу.

*Председник Грађанског одељења,
Данијела Николић*

ГРАЂАНСКО ПРАВО СУДСКА ПРАКСА



ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

РАСКИД УГОВОРА

(чл. 124 и 131. ЗОО)

Нису испуњени услови за раскид уговора о купопродаји непокретности, у ситуацији, када до прекорачења рокова за окончање радова дође из објективних разлога, предвиђених самим уговором, међу којима се један односи и на дужину трајања поступка за добијање решења пред управним органом.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд одбио тужбени захтев тужиље за раскид уговора о купопродаји непокретности, закључујући да за то нису испуњени услови предвиђени чл. 5 истог, где продавац задржава право раскида ако купац у року од 180 дана, од овере уговора, не прибави решење о одобрењу за изградњу пословно-стамбеног објекта, с тим да се овај рок може продужити ако купац из објективних разлога не добије решење (застој у раду неког од инспекцијских органа, катастра, Управе за планирање и изградњу, Дирекције за изградњу, чекање на рокове правноснажности). Ово из разлога, јер је тужени, од момента закључења уговора, до подношења тужбе, активно и у континуитету предузимао све неопходне радње у циљу добијања наведеног решења и улагао средства, како би испунио своју уговорну обавезу, а чињеница да је предметна кућа под заштитом Завода за заштиту споменика, није му била позната приликом закључења, јер га о томе тужиља није обавестила. То је додатно довело до продужења рока потребног за прибављање решења, који он није могао предвидети приликом закључења уговора, да би за то тражио дужи рок, при чему није био неодговоран, пасиван и несавестан уговарач.

Неосновани су жалбени наводи да није поштован рок од 18 месеци за изградњу објекта, а који се према уговорним одредбама може продужити у случају више силе, а ово из разлога што овај рок може почети да тече тек по добијању решења и пријави радова. Неосновано се тужиља позива на чл. 125. ЗОО, у смислу основаности њеног захтева, с обзиром да закључени уговор, по својој природи, није такав да испуњење уговорних обавеза у одређеном року представља битан састојак, већ је предвиђена могућност продужења рока за испуњење уговорних обавеза, која је у конкретном случају несумњиво постојала.

*(Пресуда Основног суда у Нишу 17П9399/15 од 21.12.2016. године
Пресуда Апелационог суда у Нишу 27Гж2635/17 од 11.05.2017. године)*

Припремила: судија Добрила Здравковић

РЕНТА ЗБОГ ИЗГУБЉЕНОГ ИЗДРЖАВАЊА

(чл.194. ЗОО)

Накнада за изгубљено издржавање састоји се у износу издржавања које би погинули био дужан и могао обезбедити тужиоца, као издржаваном лицу, у складу са одредбама породичног закона, према потребама повериоца и могућностима дужника, при чему она не може бити већа од оног што би он, као оштећени, добијао од покојног да је овај остао у животу, тј. да штетног догађаја није било.

Из образложења:

Првостепени суд погрешно своју одлуку заснива на налазу вештака економско финансијске струке, који је ренту због изгубљеног издржавања обрачунавао полазећи од износа издржавања по пресуди од 11.03.2003. године, када је тужилац био малолетан, а обвезник издржавања жив и којом је одређено издржавање у висини од 22% од минималне зараде у РС, као и од просечно датих трошкова становања, исхране и набавке уџбеника у актуелном тренутку, а који начин обрачуна није у складу са законским прописима, тј. са одредбама чл. 194. и 196. ЗОО, које регулишу овај институт.

Да би донео правилну и закониту одлуку првостепени суд је био у обавези да најпре утврди да ли су се, од доношења претходне пресуде 23.05.2012. године, а о накнади ове материјалне штете тужиоцу, до подношења конкретне тужбе, што је око годину дана, промениле околности и на који начин, а које условљавају измену те одлуке, па да, уколико утврди да је до њих дошло, висину ренте одреди уз узимање у обзир свих конкретних околности, водећи рачуна о томе да она не може бити већа од оног што би тужилац, као оштећени, добио од покојног оца да је овај остао у животу, тј. да штетног догађаја није било.

Наиме, накнада за изгубљено издржавање састоји се у износу издржавања које би погинули био дужан и могао обезбедити издржаваном лицу, у складу са одредбама породичног законодавства, тј. у складу са одредбама чл. 161., 162. и 163. Породичног закона, према потребама повериоца и могућностима дужника, што суд уопште није утврђивао. Није утврђено да ли би покојни отац тужиоца, да је остао у животу, а према својој стручној спреми и радној способности у моменту подношења конкретне тужбе, могао да се радно ангажује, на којим пословима, колико би могао да остварује месечну зараду и са којим би износом могао да доприноси издржавању тужиоца, а сходно његовим потребама за исхрану, гардеробу, хигијену, уџбенике за факултет и остале активности. При томе је првостепени суд пропустио да цени и обавезу мајке, као другог родитеља, да такође доприноси његовом издржавању, према својим могућностима, као и то, да ли је, у ком периоду и у ком износу тужилац остваривао приходе и од каквог је значаја новчани износ који остварује код РК Б....., у износу од по 5.000,00 динара месечно, тј. да ли се ради о редовним приходима или стипендији и с обзиром на то да ли се та примања могу узети у обзир приликом досуђења ренте.

***(Пресуда Основног суда у Нишу 18П 8470/13 од 15.01.2016. године
Решење Апелационог суда 27Гж2652/17 од 11.05.2017. године)***

Припремила: судија Добрила Здравковић)

ПОСЛОВОДСТВО БЕЗ НАЛОГА

(чл. 221 ст. 1 Закона о облигационим односима)

Пословођа без налога дужан је обавестити о свом поступку што је могуће пре оног чији је посао и наставити започети посао уколико му је то разумно могуће, док овај не буде могао преузети бригу о њему а по свршеном послу он је дужан положити рачун и уступити ономе чији је посао, све што је прибавио вршећи његов посао.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, против тужиоца Г.Ђ. је вођен кривични поступак пред Окружним судом, због кривичног дела из чл. 47. ст. 1. КЗ РС, у коме је ослобођен кривичне одговорности. У притвору је 4 године, 8 месеци и 5 дана. Тужени, који је по струци био адвокат, је без знања и одобрења и без датог пуномоћја, у име тужиоца, покренуо парнични поступак за накнаду штете због неоснованог лишења слободе, па је одлучујући по овој тужби суд пресудом делимично усвојио тужбени захтев и обавезао тужену у том поступку, Републику Србију, да тужиоцу исплати износ од 1.680.000,00 динара са законском затезном каматом као и трошкове овог поступка. Ова пресуда преиначена је пресудом Окружног суда у погледу дана од када тече законска затезна камата. Након добијања ове пресуде, тужени је покренуо извршни поступак па је суд решењем усвојио предлог и тужени је преко благајне ЗОБС-а извршио наплату. Пресудом Основног суда, преиначеном пресудом Апелационог суда, утврђено је да је тужени, као окривљени, крив што је, у намери да себи прибави противправну имовинску корист, лажно приказао чињеницу да је пуномоћник Г.Ђ., давањем генералног пуномоћја, наводно овереног пред судом, којим је био овлашћен да преузме досуђени новац и довео у заблуду извршног судију и навео га да на штету имовине Републике Србије нешто учини, тако што је поднео предлог за извршење ради наплате накнаде штете досуђене наведеном правноснажном пресудом, због чега је осуђен за кривично дело фалсификовања исправе из чл. 233. ст. 3. у вези са ст. 1. КЗ РС на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци а оштећени, овде тужилац Г.Ђ., је упућен на парницу ради остваривања имовинско правног захтева. Тужилац је у свом исказу навео да није овластио туженог да га заступа у поступку накнаде штете нити да исту наплати, да је о постојању парничног и извршног поступка сазнао 2007. или 2008. године

и да му није било познато да има право на накнаду штете због неосновано притвора те да због тога може да тужи Републику Србију.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања усвојен је тужбени захтев тужиоца и обавезан тужени да му на име неоснованог обogaћења исплати износ од 1.680.000,00 динара са законском затезном каматом а применом одредбе чл. 221. ст. 1. и 2. и чл. 222. ст. 1. Закона о облигационим односима према којој је пословођа без налога дужан обавестити о свом поступку што је могуће пре оног чији је посао и наставити започети посао уколико му је то разумно могуће, док овај не буде могао преузети бригу о њему а по свршеном послу он је дужан положити рачун и уступити ономе чији је посао, све што је прибавио вршећи његов посао, при чему је, при вршењу туђег посла, пословођа без налога дужан руководити се стварним или вероватним намерама и потребама онога чији је посао и дужан је поступити са пажњом доброг привредника, односно доброг домаћина а суд може, с обзиром на околности у којима се неко незвано прихватио туђег посла, смањити његову одговорност или га сасвим ослободити одговорности за непажњу.

У конкретном случају стекли су се сви елементи из цитиране законске одредбе осим елемента обавезног полагања рачуна и уступања прибављеног тужиоцу јер је тужени поступао као да је имао налог тужиоца и посао завршио али о томе није обавестио тужиоца нити му дао новац који му је исплаћен у извршном поступку. Имајући наведено у виду, оцењени су као неосновани жалбени наводи да је исплата коју је примио тужени у извршном поступку извршена по редовној судској процедури којој је претходила правноснажна судска пресуда и да није отпао основ наплате иако је у кривичном поступку утврђено да је тужени користио фалсификовано овлашћење да би исходовао правноснажну судску одлуку на основу које је покренут поступак извршења.

Тужени је правноснажно осуђен због кривичног дела из чл. 208. ст. 4. КЗ због кривичног дела преваре па је правилно првостепени суд применио одредбу чл. 13. ЗПП према којој је, у парничном поступку, суд у погледу постојања кривичног дела и кривичне одговорности учиниоца везан за правноснажну пресуду кривичног суда којом се оптужени оглашава кривим. Изузетак од овога би постојао само у случају да тужени није имао могућности или права да учествује у кривичном поступку у коме је та одлука. Међутим, у конкретном случају тужени је био активни учесник кривичног поступка у коме је предлагао доказе и износио своју одбрану и у оквиру кога није успео да

докаже да је овлашћење по којем је водио најпре парнични а затим и извршни потпис заиста добио од тужиоца. Стога су као неосновани оцењени и жалбени наводи да се тужени није могао неосновано обогатити на рачун тужиоца када је и сам тужилац тврдио да није знао да има право на накнаду штете јер је тужени, без обзира што тужилац није био упознат са својим правима ипак, користећи се фалсификованим овлашћењем, водио спор у његово име а по свршеном послу није му положио рачун и уступио све што је прибавио вршећи његов посао. У току кривичног поступка тужени није предлагао сведока на околност да је извршио исплату подигнутог новца тужиоцу тако да је донета осуђујућа кривична пресуда па је по налажењу суда сада неосновано истицање, по први пут у току трајања читавог поступка, укључујући и цео кривични поступак, да је тужени исплатио тужиоцу накнаду која му припада. Неоснованим је оцењено и позивање у жалби на сведока, кога је првостепени суд одбио да саслуша, са образложењем да је након увида у комплетан спис кривичног предмета утврђено да предложено лице нема никаквих додирних тачака са предметом расправљања и да ни тужени ни тужилац никада нису спомињали овог сведока, те да је ово лице извучено из контекста изведених доказа у кривичном предмету.

*(Пресуда Основног суда у Лесковцу 22П.бр.1375/16 од 13.10.2016. године
Пресуда Апелационог суда у Нишу 29Гж.бр.1548/17 од 28.02.2017. године)*

Аутор сентенце: судија Соња Симоновић Стојановић

ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ПРИЗНАЊЕМ ДУГА

Изјава туженог дата на записнику пред судом у парници која се водила између туженог и трећег лица не може се сматрати признањем дуга повериоцу-тужиоцу, у смислу чл. 387. ст. 1. ЗОО

Из образложења:

Првостепени суд је погрешно применио материјално право приликом оцене приговора застарелости потраживања тужиоца, које је тужени истицао током целог поступка, а основано истиче и у жалби. Првостепени суд

погрешно сматра да изјава туженог на записнику од 08.11.2000. године у парници пред Општинским судом у Лесковцу П.1910/96 представља признање дуга у смислу чл. 387. ЗОО, те да је том изјавом прекинуто застаревање.

Према одредби чл. 387. ст. 1. ЗОО застаревање се прекида када дужник призна дуг, а признање дуга може се учинити не само изјавом повериоцу него и на посредан начин, као што су давање отплате, плаћање камате, давање обезбеђења. Изјава туженог Р. дата на записнику пред судом дана 08.11.2000. године није дата повериоцу, овде тужиоцу МП, већ је дата у парници која се водила између трећег лица, НП и овде туженог РД, па се наведена изјава не може сматрати признањем дуга повериоцу, тужиоцу МП. Неспорно је да тужени РД није дао отплате, није плаћао камате, нити давао обезбеђење, односно да није признао дуг ни на посредан начин. Како је тужилац МП износ од 7.000 ДМ дао туженом РМ 1993. или 1994.године, а тужба је поднета дана 05.11.2010.године, то је протекао општи рок застарелости од 10 година у смислу чл. 371. ЗОО, па је потраживање тужиоца застарело.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 24П. 4963/12 од 10.03.2015. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 14Гж.1089/15 од 13.11.2015. године)

*Аутор сентенеце: Мирјана Милутиновић,
виши судијски сарадник Апелационог суда у Нишу.*

ПОЧЕТАК РОКА ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПОВРАЋАЈ ДАТОГ ПО ОСНОВУ НИШТАВОГ УГОВОРА

Право на утврђење ништавости уговора није временски ограничено, оно не застарева, али од момента када се утврди ништавост уговора почиње да тече рок застарелости потраживања из чл. 371. ЗОО за повраћај датог по основу ништавости уговора.

Из образложења:

Првостепени суд је нашао да тужиочево потраживање није застарело, сматрајући да тужиоци имају право на повраћај датог по основу уговора о купопродаји - откупу непокретности Ов.бр.225/92 од 14.02.1992.године, који

је оглашен неважећим правноснажном пресудом Општинског суда у Урошевцу П.769/96 од 04.04.1997. године, јер се право на истицање ништавости не гаси, сходно чл. 110. ЗОО, па првостепени суд закључује да се ни право на реституцију датог по основу ништавог уговора не гаси и да нема места примени рока застарелости из чл. 371. ЗОО.

Првостепени суд је погрешно применио материјално право. Тачно је да се према чл. 110. ЗОО право на истицање ништавости не гаси, као и да је у случају ништавости уговора свака уговорна страна дужна да врати другој све оно што је примила по основу таквог уговора, сходно чл. 104. истог закона. Међутим, ове одредбе не искључују примену чл. 371. ЗОО, већ значе да рок застарелости из чл. 371. ЗОО почиње да тече од момента када се утврди ништавост уговора и истиче протеком рока од десет година. Право на утврђење ништавости уговора није временски ограничено, оно не застарева, али од момента када се утврди ништавост уговора почиње да тече рок застарелости према одредбама Закона о облигационим односима. Како је пресуда Општинског суда у Урошевцу П.769/96 од 04.04.1997. године истог дана постала правноснажна, а којом је оглашен неважећим уговор о купопродаји - откупу непокретности Ов.бр.225/92 од 14.02.1992. године, то је од 05.04.2007. године почео да тече рок застарелости за повраћај датог по основу ништавог уговора, што значи да је исти истекао дана 05.04.2007. године, односно да је у време подношења тужбе, 10.12.2012. године, потраживање тужилаца било застарело.

(Пресуда Основног суда у Нишу 21П.6454/12 од 09.09.2014. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 14.Гж 28/15 од 03.09.2015. године)

***Аутор сентенце: Мирјана Милутиновић,
виши судијски сарадник Апелационог суда у Нишу.***

СТВАРНО ПРАВО

Исељење из непокретности-предмет плодуюживања (чл.37. ЗОСПО)

Када тужена, као ванбрачна супруга, живи у кући тужиље, са њеним оцем, који има право доживотног плодуюживања на тој непокретности, тада тужиља нема право да тражи њено исељење.

Из образложења:

Првостепени суд закључује да тужиља, као власник непокретности из тужбеног захтева, има право заштите у односу на тужену, која без основа живи у тој непокретности, те да је ова у обавези да се из ње исели.

Међутим, због погрешне примене материјалног права побијана пресуда је преиначена и одбијен је тужбени захтев тужиље.

Наиме, институт плодуюживања регулисан је Српским грађанским законом, који у параграфу 374. прописује да коме припада право на уживање туђе ствари, онај може туђу ствар, само суштину њену не нарушавајући, без сваког ограничења уживати. Плодуюживалац употребљава ствар лично или преко другог лица, на исти начин као и власник, с ограничењем да не сме да мења послужно добро, ни његову намену. Плодуюживаочево право обухвата и овлашћење да сам одреди како ће ствар користити, а у складу са природом послужног добра и на уобичајени начин. Под редовном употребом се може разумевати како вршење правних аката (на пример: издавање ствари у закуп), тако и вршење материјалних аката према ствари (на пр. становање у кући).

С обзиром на наведене законске одредбе, право плодуюживаоца је да користи предмет плодуюживања становањем у њему, на начин како њему одговара, па је у овлашћењу тужилиног оца, као поклонодавца и плодуюживаоца,

да у предметној непокретности, а у смислу остварења свог приватног живота, живи са брачним или ванбрачним партнером или лицем које му помаже у свакодневним потребама. Тужена у непокретности, чији је власник тужиља, не живи без основа, већ по одобрењу и уз сагласност плодоуживаоца, због чега су основани жалбени наводи тужене, да се тужиља не може позивати на чл. 37. Закона о основама својинско правних односа тражећи њено иселење.

*(Пресуда Основног суда у Бору П 715/16 од 08.02.2017. године.
Пресуда Апелационог суда у Нишу 27Гж 2662/17 од 18.05.2017. године)*

Припремила судија: Добрила Здравковић

ХИПОТЕКА НА ЗАЈЕДНИЧКОЈ СВОЈИНИ

Хипотека на непокретној ствари у заједничкој својини заснива се само на целој непокретној ствари и уз сагласност свих заједничара.

Из образложења:

Како је и одредбом чл. 18. ст. 2. Закона о основама својинскоправних односа прописано да када се ради о заједничкој својини, заједничари споразумно управљају заједничком ствари и заједно је користе, али не могу отуђити свој удео, јер није познат, што значи да се ствар не може продати или на било који други начин отуђити, па сходно и наведеној законској одредби првотужени није могао нити изјавом, нити споразумом закљученим са друготуженом да на предметној непокретности заснује хипотеку без сагласности тужиље.

Како је хипотека на предметним непокретностима у заједничкој својини заснована без сагласности тужиље, као заједничара, супротно одредби чл. 6. ст. 2. Закона о хипотеци, то је по оцени овог суда без утицаја на другачије одлучивање у овој правној ствари моменат сазнања тужиље о успостављању хипотеке.

Такође и друготужена је била у обавези да пре закључења споразума о обезбеђењу потраживања, утврди да ли је првотужени једини и искључиви власник предметне непокретности, с обзиром да је првотужени био у браку са тужиљом и да важи законска претпоставка да имовина стечена у браку

представља заједничку имовину супружника, па да пре заснивања хипотеке затражи сагласност тужиље у смислу чл. 6. ст. 2. Закона о хипотеци којим је прописано да се хипотека на непокретној ствари у заједничкој својини заснива само на целој непокретној ствари и уз сагласност свих заједничара.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж. 1744/15 од 02.12.2015. године)

Аутор сентенце: Судија Марина Милановић

ПРАВО НА ДРЖАВИНУ

(чл. 72. Закона о основама својинскоправних односа)

Усмено закључени уговор о купопродаји непокретности не представља законити основ за стицање права својине, па не може бити ни ваљани правни основ за стицање права на државину, као уже својинско овлашћење, јер се ради о апсолутно ништавом уговору који се не може конвילадирати, а на основу ништавог правног посла не може се стећи ни савесна државина.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је фактички држалац спорне парцеле по основу правног посла, усменог уговора о купопродаји закљученог 2002. године. Из записника мировног већа од 25.04.2010. године, утврђено је да је тужилац изјавио да је купио предметну парцелу у 2002. години, да је платио купопродајну цену у целости али да о томе не поседује никакав уговор, а тужени је признао да је продао парцелу и примио цену, међутим, не жели да је тужиоцу пренесе. Спорна парцела као пољопривредно земљиште експроприсана је од туженог као ранијег сопственика, односно тужиоца као држаоца, у корист предузећа “Електромонтаже Србије” Београд ради изградње трафо станице и наложено је садашњем сопственику односно држаоцу да експроприсану непокретност уступи кориснику експропријације након закључења споразума о накнади, а накнада за експроприсану непокретност ће бити одређена у посебном поступку и исплаћена туженом као ранијем сопственику односно тужиоцу као држаоцу по окончању ове парнице. Решењем првостепеног суда донетим у овом поступку одређена је привремена мера забране туженом да наплати накнаду за експроприсано

земљиште, а кориснику експропријације наложено да новчана средства за исплату накнаде депонује у судски депозит док управни орган не одлучи у посебном поступку коме ће се накнада исплатити.

Полазећи од утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је усвојио тужбени захтев тужиоца и утврдио да је исти савесни држалац предметне парцеле по основу куповине од туженог 02.09.2002. године, примењујући одредбу чл. 70. ст. 1. Закона о основама својинско правних односа по којој државину ствари има свако лице које непосредно врши фактичку власт на ствари (непосредна државина). Ово стога што сматра да тужилац није знао нити је могао знати да парцела није његова, нити је иста стечена силом, преваром или злоупотребом поверења јер је тужилац на основу усменог уговора о купопродаји исплатио у целости купопродајну цену и ушао у посед парцеле. Истовремено је утврдио да тужиоцу припада накнада за експроприсане делове ове парцеле као замена за повраћај купопродајне цене и да је тужени дужан да трпи да корисник експропријације исту исплати тужиоцу.

Основано се жалбом туженог указује да је првостепени суд на утврђено чињенично стање погрешно применио материјално право, због чега је побијана пресуда морала бити преиначена.

Према чл. 72. ст. 1. Закона о основама својинскоправних односа, државина је законита ако се заснива на пуноважном правном основу који је потребан за стицање права својине и ако није прибављена силом, преваром или злоупотребом поверења. У смислу ове законске одредбе, ради утврђивања права државине није довољно само утврдити постојање фактичке власти на ствари, како је то утврдио првостепени суд сходно чл. 70. истог закона, већ право државине, које се као уже својинско овлашћење може стећи под истим условима као и право својине. Тужилац је тврдио да је државину стекао по основу правног посла-усменог уговора о купопродаји па је првостепени суд био дужан да утврди правну ваљаност таквог уговора. Према чл. 4. ст. 2. Закона о промету непокретности, уговор о промету непокретности закључује се у писменој форми а потписи уговарача оверавају од стране суда. Уговори који нису закључени на овај начин не производе правно дејство односно апсолутно су ништави. Због недостатка писмене форме искључена је могућност касније конвалидације односно накнадног признавања таквог уговора па нису испуњени услови из чл. 3 истог Закона за конвалидацију.

Обзиром на напред наведено, произилази да је између странака закључен ништав уговор који се не може конвалидирати а на основу ништавог правног посла не може се стећи ни савесна државина. Код таквог стања ствари, без значаја за основаност тог дела тужбеног захтева чињеница да је тужилац у фактичкој државини спорне парцеле, па му стога не припада ни накнада за експроприсане делове те парцеле као замена за повраћај купопродајне цене.

*(Из пресуде Апелационог суда у Нишу
16Гж. 1529/14 од 24.07.2014. године.)*

*Приредила: Данијела Николић,
судија Апелационог суда у Нишу*

ДИСКРИМИНАЦИЈА

Постоји разлика у поступању органа јавне власти исплатом ратних дневница војним резервистима у седам неразвијених општина Топличког округа у односу на остале војне резервисте, па и у односу на тужиоца и таква разлика у поступању је дискриминаторска, јер не постоји објективно и разумно оправдање за различито третирање резервиста само по основу пребивалишта.

Из образложења:

Првостепени суд је на основу утврђеног чињеничног стања правилно закључио да у конкретном случају постоји разлика у поступању органа јавне власти исплатом ратних дневница војним резервистима у седам наведених неразвијених општина Топличког округа, у односу на остале војне резервисте, па и у односу на тужиоца, обзиром да су сви били на истом задатку; да је таква разлика у поступању дискриминаторска јер за исту не постоји објективно и разумно оправдање, односно ако она не тежи легитимном циљу или ако не постоји разуман однос пропорционалности између употребљених средстава и циља који се настоји остварити; да исплата која је извршена према Закључку Владе РС од 17.01.2008. године представља исплату ратних дневница а не исплату социјалне помоћи, обзиром да војни резервисти нису били у обавези да доставе доказе о имовном стању или социјалној угрожености, па није било објективног и разумног оправдања за различито трети-

рање резервиста само по основу пребивалишта, па је правилном применом чл. 21. Устава РС, чл. 14. Европске конвенције о људским правима, одлучио као у ставу првом изреке побијане пресуде, правилно налазећи и да су неосновани истакнути приговори стварне ненадлежности Вишег суда у Нишу и недостатка пасивне легитимације на страни тужене, а за своју одлуку дао је довољне и јасне разлоге које прихвата и овај суд.

Устав забрањује ретроактивност (чл. 197), па се на решење конкретног случаја у материјалном смислу не може применити Закон о забрани дискриминације зато што је Закључак донет, а Споразум закључен у току 2008. године, а Закон о забрани дискриминације донет је 2009. године (“Сл. гл. РС”, бр. 22/09) и у прелазним завршним одредбама не садржи правило о делимичној ретроактивној примени. Због тога се овај правни однос може расправљати непосредно на основу чл. 21. Устава и чл. 14. Европске конвенције о људским правима. Ни Европски суд за људска права у предмету “Вучковић против Србије”, као релевантно право за примену не спомиње Закон о забрани дискриминације.

Оцењујући испуњеност услова за примену чл. 21. Устава РС и чл. 14. Европске конвенције о људским правима првостепени суд је правилно закључио (као и Европски суд за људска права у пресуди “Вучковић и др. против Србије” бр.17153/11 од 28.08.2012. године) да исплате на које се односи Споразум по Закључку Владе РС из 2008. године представљају ратне дневнице, а не социјалну помоћ угроженима (обзиром да су резервисти Топличког округа морали да се одрекну тужби у вези са ратним дневницама и да нису имали обавезу да доказују имовинско стање и социјалну угроженост), што потврђује и мишљење Поверенице за заштиту равноправности од 26.07.2011. године, које суд не обавезује, али је за суд прихватљив наведени правни став исте.

Неосновани су жалбени наводи тужене да првостепени суд није утврдио ни дао разлоге зашто је дошло до неједнаке исплате. Ово са разлога што за утврђење постојања дискриминације није релевантна намера или мотив, па се тужена не може ослободити од одговорности тврдећи да није крива, јер је за утврђење постојања дискриминације довољно да се утврди да је дискриминациона радња извршена и да је произвела последице.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж. 1961/16 од 31.08.2016. год.)

Аутор сентенце: Судија Марина Милановић

ПОРОДИЧНО ПРАВО

ПРОМЕНА ВИСИНЕ ИЗДРЖАВАЊА

(чл. 164. Породичног закона)

За правилну примену чл. 164. Породичног закона потребно је утврдити какве су биле околности у време доношења раније одлуке, и то како на страни повериоца издржавања, мал. детета, тако и на страни родитеља као дужника издржавања, сходно чл. 154. ст. 1. Породичног закона, а какве су околности сада када се тражи измена одлуке, како би суд могао да одлучи јесу ли се околности на основу којих је донета ранија одлука промениле, што би био основ за смањење или повећање висине издржавања.

Из образложења:

Одредбом чл. 164. ПЗ прописано је да се висина издржавања може смањити или повећати ако се промене околности на основу којих је донета претходна одлука. Одредбом чл. 160. ст. 1. ПЗ прописано је да се издржавање одређује према потребама повериоца и могућностима дужника издржавања, при чему се води рачуна о минималној суми издржавања. Ставом 3. истог члана прописано је да могућности дужника издржавања зависе од његових прихода, могућности за запослење и стицање зараде, његове имовине, његових личних потреба, обавезе да издржава друга лица те других околности од значаја за одређивање издржавања.

За правилну примену чл. 164. ПЗ потребно је утврдити какве су биле околности у време доношења раније одлуке, и то како на страни повериоца издржавања, мал. детета, тако и на страни родитеља, као дужника издржавања, сходно чл. 154. ст. 1. ПЗ, а какве су околности сада када се тражи измена одлуке, како би суд могао да одлучи јесу ли се околности на основу којих је донета ранија одлука промениле, што би био основ за смањење или повећање висине издржавања.

У конкретном случају првостепени суд није утврдио какве су биле околности на страни тужиоца, као дужника издржавања, колику зараду је остваривао, нити је утврђено колики су били месечни приходи законске заступнице мал. М у време доношења раније одлуке. Такође није утврђено колике су биле основне месечне потребе мал. М у време доношења одлуке чија се измена тражи и које потребе је суд имао у виду приликом одлучивања, а што је од значаја ради оцене да ли је сада утврђени износ од 21.000,00 динара, на име задовољења основних месечних потреба, већи од претходно утврђеног износа.

(Пресуда Основног суда у Нишу П.194/2016 од 22.05.2017. године и решење Апелационог суда у Нишу Гж2.439/17 од 24.10.2017. године)

Аутор сентенце: Мирјана Милутиновић,
виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу.

УКИДАЊЕ СУПРУЖНИЧКОГ ИЗДРЖАВАЊА (чл. 167. Породичног закона)

Нема места доношењу одлуке о укидању издржавања када у првостепеном поступку није утврђено из којих разлога је продужено издржавање тужене од стране тужиоца, као бившег супружника, и по протеку 5 година од развода брака и који су то били нарочито оправдани разлози за обавезивање тужиоца.

Из образложења:

Према чињеничном стању, брак парничних странака је разведен а тужилац је обавезан да на име издржавања туженој као бившој супрузи плаћа износ од 60 евра месечно у динарској противвредности. Тужилац је затражио укидање издржавања налазећи да су се стекли услови за то. Првостепени суд је закључио да је тужбени захтев тужиоца за укидање издржавања тужене, као бивше супруге, основан сходно чл. 163. ст. 2. Породичног закона, јер је увидом у медицинску документацију тужене утврдио да је иста способна да обавља једноставније послове који не захтевају већу физичку снагу, као и

да је од престанка брака протекло више од 5 година, тачније 33 године, па је обавеза тужиоца престала.

Овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити као правилан и законит имајући у виду одредбу чл. 167. ст. 1. Породичног закона којом је прописано да издржавање престаје када истекне време трајања издржавања (тач. 1), или смрћу повериоца или дужника издржавања (тач. 2). Ставом 2 истог члана прописано је да издржавање може да престане када поверилац издржавања стекне довољно средстава за издржавање, осим ако поверилац издржавања није малолетно дете (тач. 1); када дужник издржавања изгуби могућност за давање издржавања или давање издржавања постане за њега очигледно неправично, осим ако поверилац издржавања није малолетно дете (тач. 2); издржавање супружника престаје и када поверилац издржавања склопи нови брак, односно ванбрачну заједницу (тач. 3). Одредбом чл. 63. ст. 1. ПЗ прописано је да издржавање може трајати одређено или неодређено време.

Брак парничних странака разведен је правноснажном пресудом којом је одређено издржавање тужене, а исто је продужено у новом поступку који је вођен накнадно и након истека рока из чл. 63. ст. 2. Породичног закона, од 5 година по разводу брака, што упућује на закључак да је обавеза тужиоца на издржавање тужене утврђена сходно чл. 63. ст. 3. Породичног закона, којом је прописано да изузетно издржавање супружника по престанку брака може се продужити и после истека рока од 5 године ако нарочито оправдани разлози спречавају супружника, повериоца издржавања, да ради. Међутим, у првостепеном поступку није утврђено из којих разлога је пресудом продужено издржавање тужене од стране тужиоца, као бившег супружника, и по протеку 5 година од развода брака, односно који су то били нарочито оправдани разлози за обавезивање тужиоца.

Сходно наведеном, битна чињеница за одлуку о тужбеном захтеву за престанак издржавања супружника је да ли и даље постоје разлози из чл. 63. ст. 3. Породичног закона, који спречавају супружника повериоца издржавања да ради, с тим што суд није стручан да увидом у медицинску документацију тужене закључује да ли је иста у стању да обавља једноставније послове или не, већ о тим чињеницама треба да се изјасне стручна лица-вештаци. Такође је потребно утврдити испуњеност услова из чл. 167. ст. 2. тач. 1 Породичног закона, односно да ли је поверилац издржавања стекао довољно средстава за издржавање, као и из тац.2 истог члана и у вези са тим да ли је дужник

издржавања-овде тужилац, изгубио могућност за давање издржавања или су наступиле нове околности па је давање издржавања постало за њега очигледно неправично.

*(Пресуда Основног суда у суда у Прокупљу 9П2.493/16 од 22.03.2017. године
Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2.бр.265/17 од 05.07.2017. године)*

Аутор сентенце: судија Соња Симоновић Стојановић

УТВРЂЕЊЕ НИШТАВОСТИ БРАКА

(чл. 31. до 36. Породичног закона)

Неоснован је захтев да се утврди ништавост брака када је, у току поступка, утврђено да је брачна заједница трајала непрекидно до смрти тужиоцевог оца, да је задњих неколико месеци живота постојала и заједница живота, да су односи били складни и да ни један од супружника није покретао спор за развод или поништај брака

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужилац је син сада пок. М.М. који је са туженом С.Г. закључио брак дана 31.01.2008. године. Пок. М.М. са овде тужиоцем, својим сином С.М. имао закључен уговор о доживотном издржавању и у вези овог уговора покренуо је судски поступак, којим је затражио раскид предметног уговора, који је прекинут до правноснажног окончања поступка у предмету лишења пословне способности сада пок. М.М. Вештачењем од стране Комисије вештака, утврђено је да је сада пок. М.М. боловао од трајне душевне болести хроничног, можданог психосиндрома са доминацијом интерпретативне симптоматологије васкуларне генезе и да је у време закључења брачне заједнице 31.01.2008. године био умањене пословне способности до нивоа делимичне али да је био способан да закључи брачну заједницу.

У жалби тужиоца наводи се да је пок. М.М. у време закључења брака имао 82 године а тужена више од 30 година мање од њега, те да већ ова разлика у годинама указује да мотив тужене није био заједнички живот и да је

осим тога, заједница живота успостављена тек 2 до 3 месеца пред смрт М.М. јер он више није био у стању да се сам о себи стара, али да ни овим непрекидним боравањем тужене у кући пок. М.М. није успостављена заједница живота и није се остварила сврха брака пошто је тужена долазила у кућу пок. М.М. да му да храну и обави неки кућни посао па се то не може третирати као заједница живота у смислу Породичног закона, па у том смислу тужена има својство пружаоца услуга и неговатељице а не брачног друга, а мотив пок. Милорада је био да закључењем брака изигра свог сина и осталу родбину у погледу њиховог права на наслеђе и имовину.

У одговору на жалбу тужиоца, тужена је потврдила да је формална заједница живота успостављена неколико месеци пред смрт пок. Милорада али да је она константно бринула о Милораду и живела одвојено од њега у складу са заједничким договором, при чему је 6 и више сати проводила у његовој кући а некада је остајала и до 22,00 часова увече да би пред крај његовог живота њему помагала тако што му је стављала памперс пелене, прала га и пресвлачила често да би на крају и формално успоставила заједницу живота са њим и неговала га 24 часова дневно скоро 5 месеци пред смрт.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно применио материјално право када је одбио тужбени захтев тужиоца и одлучио као у изреци пресуде јер је утврдио да је заједница живота заиста успостављена неколико месеци пред смрт Милорада али је путем сведока утврђено да се тужена старала о њему и то на начин којим је остварена сврха брака, те да је то била заједница у којој су задовољене и законске обавезе супружника кроз међусобно поштовање и уважавање, вођење домаћинства, те задовољавање не само физичких, већ и емотивних потреба сада пок. М.М. али и економских потреба тужене кроз увећање заједничког буџета. Првостепени суд је, правилним тумачењем одредбе чл. 32. ст. 2. ПЗ, која каже да се брак неће поништити ако је заједница живота супружника накнадно успостављена, нашао да не стоји разлог ништавости предвиђен истом одредбом ст. 1. ПЗ. По налажењу Апелационог суда, а имајући у виду одредбе чл. 31. до 36. ПЗ, неоснован је захтев да се утврди ништавост брака а због чињеница које наводи тужилац, да је после закључења брака сачињен и оверен уговор о доживотном издржавању и да је превелика разлика у годинама супружника, те да није постојала стварна заједница живота, када је утврђено да је брачна заједница трајала непрекидно до смрти тужиоцевог оца, да је задњих неколико месеци живота постојала и заједница живота, да су односи

били складни и да ни један од супружника није покретао спор за развод или поништај брака.

*(Пресуда Основног суда у Зајечару 16П2 бр.681/10 од 07.10.2015. године
Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2.бр.408/15 од 29.12.2015. године)*

Аутор сентенце: судија Соња Симоновић Стојановић

ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА И НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА (чл. 77. ст. 3., чл. 226. ст. 1 и чл. 270. Породичног закона)

У ситуацији када је у бракоразводној парници Центар за социјални рад дао налаз и стручно мишљење коме од родитеља поверити вршење родитељског права према мал. детету, сходно чл. 270. Породичног закона, околност да је комисија вештака коју су чинили неуропсихијатар, клинички психолог и дипломирани социјални радник, оценила да је личност оца складнија и уравнотеженија не може бити од пресудног значаја за одлучивање.

Из образложења:

У конкретном случају, странке као родитељи мал. детета нису могли да постигну договор око вршења родитељског права након развода брака, па је првостепени суд у складу са својом обавезом да у брачном спору одлучи о вршењу родитељског права (чл. 226. ст. 1. Породичног закона) сходно чл. 270. Породичног закона затражио налаз и стручно мишљење надлежног органа старатељства, Центра за социјални рад у Нишу. Центар је у току поступка доставио више извештаја и у свима је дао мишљење да је у најбољем интересу мал. детета да буде поверено мајци која се о њему успешно брине и стара од прекида брачне заједнице. Као орган старатељства био је све време укључен у поступак, обављао разговоре са родитељима и дететом, пратио њихово понашање и одрастање детета, изражавајући мишљење да је непотребно вештачење родитељске подобности о психичком статуса детета, јер сви неспоразуми и несугласице до којих је долазило потичу од неадекватне

родитељске сарадње, која је у току трајања овог поступка побољшана јер су се родитељи укључили у породичну терапију. При томе је констатовано да је дете без упадљивих реакција, весело, комуникативно, да је блиско са оба родитеља, да по привременој мери редовно одржава контакте са оцем.

Првостепени суд је и поред оваквог мишљења органа старатељства одредио вештачење преко комисије вештака састављене од неуропсихијатра, клиничког психолога и дипломираног социјалног радника, која је дала мишљење да су обе странке подобни и компетентни родитељи за вршење родитељског права, дајући предност туженом са бољим обележјима личности. По мишљењу првостепеног суда, одлучујући разлог за дато мишљење Центра за социјални рад је чињеница да дете од раскида брачне заједнице живи са мајком, а да је у вештачењу комисије лекара предност дата оцу због његове структуре личности која је складнија и уравнотеженија јер су то околности од значаја за даљи правилан психосоцијални развој детета и најбољи интерес детета.

Међутим, основано се у жалби тужиље указује да се одлука суда о вршењу родитељског права и процена најбољег интереса детета не може заснивати искључиво на обављеном медицинском вештачењу које је вршило сагледавање родитељске фигуре странака и детета само са психолошког и психијатријског становишта. У самом налазу вештака се истиче да се интерес детета треба сагледавати и у контексту других чињеница које се утврђују при одлучивању којем родитељу треба поверити дете, те да је потребно да и Центар за социјални рад да своје мишљење.

Сходно томе, Апелациони суд је становишта да је Центар за социјални рад у Нишу компетентни орган старатељства чији стручни тим може свеобухватно да сагледа све релевантне околности за одлуку о вршењу родитељског права и процену најбољег интереса детета по свим његовим елементима. Како је Центар за социјални рад све време био мишљења да дете треба поверити мајци на самостално вршење родитељског права а при таквом мишљењу је остао и након обављеног вештачења које му је достављено, то овај суд налази да је најбољи интерес детета да буде поверено мајци.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 16Гж2-360/15 од 26.11.2015. године)

Приредила: Данијела Николић, судија Апелационог суда у Нишу

ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНИХ ОДНОСА И НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА

(чл. 61. и чл. 270. Породичног закона)

Када је због злоупотребе алкохола, понашање туженог непредвидиво и агресивно, у најбољем је интересу детета да се одржавање личних односа са оцем одвија на јавном месту и у присуству других људи, као и у објектима где не конзумира алкохол.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, странке су биле у брачној заједници која је фактички престала средином 2014. године а брак је разведен делимичном пресудом у овом спору. Из брачне заједнице странке имају мал. дете рођено 14.10.2008. године о коме се након њеног престанка стара тужиља која се вратила својој примарној породици и живи у заједници са родитељима и сестром у двособном стану. Из налаза и мишљења Центра за социјални рад утврђено је да је у најбољем интересу мал. детета да се вршење родитељског права повери тужиљи као мајци, а да отац треба да виђа дете у терминима који су наведени у изреци првостепене пресуде. По мишљењу Центра, контакти треба да се одвијају на неутралном терену односно на јавном месту где има људи због чињенице да је тужени склон насилничком понашању и да је лечен од алкохолизма па је предложено где отац и дете могу да бораве док су заједно. Из правноснажних кривичних пресуда утврђено је да је тужени оглашен кривим за кривична дела насиље у породици и недозвољени прелазак државне границе и кријумчарења људи и условно осуђен на затворске казне, те да је стављен под заштитни надзор који се састоји да се у року од једне године од правноснажности пресуде уздржава од злоупотребе алкохолних пића и да се лечи у здравственом центру због злоупотребе алкохола, као и да му изречена мера безбедности одузимања возила.

Одредбом чл. 61. ст. 1. Породичног закона прописано је да дете има право да одржава личне односе са родитељима са којим не живи, док је ставом два овог члана прописана могућност ограничења овог права само када је то у најбољем интересу детета.

У конкретном случају, првостепени суд је у смислу чл. 270. Породичног закона затражио налаз и стручно мишљење надлежног органа старатељства који је дао предлог начина одржавања личних односа са мал. дететом у

терминима које је првостепени суд прихватио, с тим што је препоручио да се контакти између оца и детета одвијају на неутралном терену односно на јавном месту где има људи, с обзиром да је атмосфера у процени туженог у ризику за мал. дете. У том смислу Центар за социјални рад је навео нека од места где та виђења могу да се реализују, те је препоручио пилерију, послас-тичару, пијачу где родитељи туженог продају пољопривредне производе.

Стога је по становишту овог суда првостепени суд правилно прихватио налаз и мишљење Центра за социјални рад као стручан и у најбољем инте-ресу детета.

Цењени су жалбени наводи туженог којима се оспорава првостепена пре-суда у овом делу али су исти неосновани јер су у супротности са правилно утврђеним битним чињеницама за оцену најбољег интереса детета. Чињени-ца да је првостепени суд у изреци навео нека од места на којима се по пре-поруци органа старатељства виђења могу одвијати не утиче на правилност и законитост донете одлуке, јер је поред ових места навео да се виђења могу одвијати и на другим местима, изузев места где се служи алкохол, што је у складу са предлогом Центра за социјални рад.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 16Гж2-47/16)

Приредила: Данијела Николић, судија Апелационог суда у Нишу

ИСТРАЖНО НАЧЕЛО У ПОСТУПЦИМА У ВЕЗИ СА ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА (чл. 205. Породичног закона)

Одредба чл. 205. Породичног закона прописује примену истражног начела у поступцима у вези са породичним односима, па је суд овлашћен да донесе одлуке и ван граница постављеног тужбеног захтева.

Из образложења:

Првостепеном пресудом, ставом првим изреке, одбијен је тужбени захтев тужиље Е.Т. и мал. тужиоца Б.Т. кога заступа законски заступник мајка Е.Т., против туженог Ј.Т., којим је тражила да се укине ранија пресуда општин-

ског суда у односу на уређење личног односа и виђења између мал. тужиоца и туженог као оца. Ставом другим изреке, уређен је лични однос и виђења мал. тужиоца и туженог на начин како је ближе одређено у овом ставу изреке а тужиља обавезана да омогући овакав начин виђења. Ставом трећим изреке, овом пресудом измењена је ранија правноснажна пресуда у односу на уређење личног односа и виђења између мал. тужиоца и туженог.

Полазећи од утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно применио материјално право када је одлучио као у ставу другом и трећем изреке, изменивши ранију пресуду о начину одржавања личних односа туженог и мал. детета и уредио даља виђења на описани начин у ставу другом изреке побијане пресуде, а за своју одлуку дао је правилне и јасне разлоге које прихвата и овај суд.

Одредбом чл. 62. ст. 1. Породичног закона, прописано је да дете има право да одржава личне односе са родитељем са којим не живи а то право може бити ограничено само судском одлуком када је у интересу детета односно када постоје разлози да се тај родитељ потпуно или делимично лиши родитељског права или у случају насиља у породици како је то предвиђено ставом 2. и 3. наведеног члана.

Према извештају референтне установе (Центра за социјални рад) у најбољем интересу детета је да се измени одлука о начину виђења у односу на раније донету пресуду, узимајући у обзир емотивну дистанцу која постоји између оца и мал. детета али да није потребно оцу ускратити право виђења са дететом из разлога што отац има снажну и позитивну мотивацију да виђа дете, те је показао способност и жељу да у пуној мери заштити интерес детета. Због свеукупне ситуације виђење ће се одвијати у контролисаним условима, у свему према моделу Центра, с тим што се у случају измењених околности, одлука о уређењу личног односа и виђења може изменити.

Неосновани су жалбени наводи да је првостепени суд прекорачио тужбени захтев када је одлучио као у ставу другом и трећем изреке побијане пресуде истичући да је тужиља поднеском од 11.12.2013. године извршила објективно преиначење тужбеног захтева и одустала од захтева који је истекла у поднеску од 13.12.2012. године, а којим је тражила уређење личног односа и начина виђења између мал. тужиоца и туженог а из чега према наводима жалбе произилази да је првостепени суд одлучио о нечему што није предмет тужбеног захтева. Побиијајући првостепену пресуду тужени у жалби не оспорава да дуги низ година није било никаквог контакта између

мал. тужиоца и њега али да предложени модел виђења од стране Центра за социјални рад у суштини кажњава оца потпуним сужавањем модела виђења.

Апелациони суд ове жалбене наводе оцењује као неосноване из разлога што је тужила на рочишту одржаном дана 20.08.2014. године остала при захтеву од 03.12.2012. године којим је тражила обуставу виђења мал. тужиоца и туженог али није одустала од захтева којим је тражила уређење начина виђења од 12.11.2013. године, па је правилна одлука првостепеног суда у ставу првом и другом изреке побијане пресуде.

Осим наведеног, одредба чл. 205. Породичног закона прописује примену истражног начела у вези са породичним односима по ком основу суд може утврђивати чињенице и када оне нису спорне међу странкама а може и самостално истраживати чињенице које ниједна странка није изнела. Предложени модел виђења од стране Центра за социјални рад којим се мења ранија одлука је у најбољем интересу детета, посебно из разлога што мал. тужилац још увек има негативан став према оцу, због протекла времена потпуно је прекинута емотивна веза, па ће се виђење најпре спроводити у контролисаним условима, на начин како је то ближе одређено у ставу другом изреке, чиме ће се туженом омогућити да одржава везу са мал. дететом у циљу неговања осећања, љубави и пажње и омогућити у смислу чл. 78. ст. 3. Породичног закона, да одлучује о питањима које битно утичу на живот мал. тужиоца.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 16Гж2.70/15 од 25.03.2012. године)

Приредила: Данијела Николић, судија Апелационог суда у Нишу

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

(чл. 197. Породичног закона)

Непријављивање насиља кривичним и прекршајним органима и чињеница да члан породице који врши насиље није ни кривично ни прекршајно кажњаван, не искључује аутоматски постојање насиља.

Из образложења:

Првостепени суд је одредио мере заштите од насиља у породици забрањеном туженом приближавања тужили и месту њеног становања на удаље-

ности мањој од 300 метара, као и забраном да на било који начин даље узнемирава тужилу.

У конкретном случају, правилном оценом изведених доказа, у складу са чл. 8 ЗПП, првостепени суд је закључио да је тужени вршио насиље над тужилом, те да је реч о насиљу у породици, у смислу одредбе чл. 197. ст. 2. тач. 1, 2, 4. и 6. Породичног закона. Овакав закључак првостепени суд је пре свега засновао на извештају стручног тима Центра за социјални рад у Врању од 21.12.2015. године, у коме је између осталог, наведено да је насилничко понашање туженог према тужили интензивно и хронично, да је тужени претње упућивао тужили и пред кћерком странака, мал. А., да је тужила овом органу два пута пријављивала извршено насиље, те да је целисходно одредити мере у циљу заштите тужиле од насиља туженог. Из ових разлога, првостепени суд је и одредио мере заштите од насиља у породици наведене у изреци побијане пресуде, у складу са чл. 198 ст. 1. и ст. 2. тач. 3, 4. и 5, као и чл. 199. ПЗ.

Мере заштите од насиља у породици предвиђене законом немају за циљ једино кажњавање насилника, већ превасходно за циљ имају превентивно дејство, спречавање понављања насилничког понашања и пружање жртви насиља извесне правне сигурности и безбедности, из ког разлога није од утицаја околност да тужила живи у домаћинству својих родитеља на удаљености од 12 километара од куће тужиоца. Обзиром на хронично и интензивно понашање тужиоца које има карактер насиља, мерама заштите које су одређене побијаном пресудом тужили се пружа заштита њеног телесног интегритета, душевног здравља и омогућује јој се мир, спокојство и безбедност током њиховог трајања. При том, модел одржавања личних односа странака и мал. деце се тек има уредити, у другом парничном поступку пред судом, пошто најпре буде одлучено о томе који од родитеља ће вршити родитељско право, те је исте могуће уредити у складу са изреченим мерама заштите од насиља у породици.

Жалбени наводи туженог о неверству тужиле, нису од утицаја на другачије одлучивање у овој правној ствари, јер не постоји околност која насиље оправдава и чини допуштеним. Из овог разлога, нису од утицаја ни жалбени наводи туженог да је првостепени суд требало да изведе доказ увидом у фотографије које је доставио, јер се истима утврђују чињенице чије евентуално постојање не би значило да је извршено насиље оправдано и дозвољено. Ни жалбени наводи којима тужени указује да је нејасно зашто суд поклања веру исказима родитеља и брата тужиле, који су као сведоци саслушани током

спроведеног поступка, и на основу истих изводи закључак да је вршено насиље над тужиљом, а да при том не поклања веру исказима сведока које је он предложио, такође нису основани. Ово стога што је закључак о томе да је тужени заиста вршио насиље над тужиљом првостепени суд засновао правилном оценом свих изведених доказа, међу којима је и извештај надлежног органа старатељства - Центра за социјални рад у Врању, као установе која поседује потребна стручна знања у области породичних односа, и резултата целокупног поступка, уважавајући при томе и мишљење тужиље као жртве насиља и њен субјективни осећај угрожености.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 16Гж2-117/16 од 10.03.2016. године)

Приредила: Данијела Николић, судија Апелационог суда у Нишу

ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНИХ ОДНОСА ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА СА КОЈИМ НЕ ЖИВИ (чл. 61. Породичног закона)

Одржавање личних односа детета и родитеља који не врши родитељско право не подразумева само њихово непосредно виђење, већ и одржавање веза и осећања блискости и на друге начине, међу којима и контактирањем путем телефона и других модерних средстава комуникације, ако је то у најбољем интересу детета.

Из образложења:

Основано се жалбом тужиоца указује да првостепени суд није правилно применио материјално право код процене најбољег интереса детета за одржавање личних односа са тужиоцем када је обио његов захтев да му се омогући да се са децом три пута недељно, као и по њиховој жељи, чује путем телефона.

Одржавање личних односа детета и родитеља који не врши родитељско право не подразумева само њихово непосредно виђење, већ и одржавање веза и осећања блискости и на друге начине, па и контактирањем путем телефона и других модерних средстава комуникације, ако је то у најбољем интересу детета. Из изведених доказа, а нарочито извештаја и изјашњења Центра

за социјални рад и исказа самих странака, не произилазе околности из којих би се могло закључити да није у интересу деце да са оцем комуницирају и на наведени начин. Напротив, Центар за социјални рад је након доношења претходне пресуде разрадио план услуга и рад са странкама ради бољег развоја деце којим је поред осталог било предвиђено и да се деца чују два пута недељно са оцем телефоном. Не наводе се разлози да је отац ту могућност на било који начин злоупотребио нити да би било супротно интересу деце да тужилац и на тај начин буде укључен у њихове свакодневне активности и прати њихово одрастање.

Имајући у виду напред изложено, Апелациони суд је у наведеном делу преиначио првостепену пресуду и усвојио тужбени захтев за измену модела виђења омогућавањем тужиоцу да контакте са децом остварује и путем телефонских разговора три пута недељно као и по жељи деце.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 16Гж2.333/16 од 01.09.2016. године)

*Приредила: Данијела Николић,
судија Апелационог суда у Нишу*

ПРАВНА ПРИРОДА ПОКЛОНА ДАТИХ ПРИЛИКОМ ВЕНЧАЊА (члан 168 Породичног закона)

Када поклон по својим својствима може да служи и једном и другом брачном другу, онда поклон припада супружницима у сувојину на једнаке делове, без обзира од чијих сродника или пријатеља је добијен, јер се поклони дати приликом венчања уобичајено дају ради заснивања заједничког домаћинства супружника.

Из образложења:

Применом одредбе чл. 168 став 2 Породичног закона закључује се да је посебна имовина супружника имовина стечена пре брака, имовина стечена током брака деобом заједничке имовине, имовина стечена током брака наслеђем, поклоном или другим правним послом којим се прибављају искључиво права. Посебна имовина је целокупна имовина сваког супружника која није обухваћена правним режимом заједничке имовине.

Осим имовине добијене на поклон, наслеђем или другим правним послом, којим се прибављају искључиво права у корист једног супружника, у посебну имовину спада и имовина која је на име оба супружника заједнички добијена на поклон, или другим облицима бестеретног стицања током брака. Својински удели на овако стеченим стварима су увек познати и супружници стичу на њима сувласничке уделе за разлику од заједничке имовине где су удели неопредељени. Супружници постају сувласници на једнаке делове уколико поклонодавац није на други начин исказао своју вољу или уколико из природе поклона (накит, одећа) и околности под којима је дат (рођендан, диплома, одлазак у војску) не произилази да је учињен само једном супружнику.

У односу на поклоне учињене супружницима поводом склапања брака, треба правити разлику да ли је приликом давања поклона била изричито изражена воља поклонодавца коме се од брачних другова поклон даје, у ком случају поклон као посебна имовина припада том лицу. Ако нема изричито изражене воље, а из природе ствари дате на поклон јасно произилази коме је намењен, узима се да је поклон дат брачном другу чијој је личности према природи поклона, намењен. Када поклон по својим својствима може да служи и једном и другом брачном другу, супружницима припада у сусвојину на једнаке делове, без обзира од чијих сродника или пријатеља је добијен, јер се поклони дати приликом венчања уобичајено дају ради заснивања заједничког домаћинства супружника.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 2413/15 од 14.04.2016. године)

Виши судијски сарадник Оливера Алексић Цветковић

НАСЛЕДНО ПРАВО

Трошкове сахрањивања пунолетног детета, које је било на редовном школовању, сноси родитељ који је по закону био дужан да га издржава и који је оглашен за наследника на дететовој заоставштини након његове смрти, до висине вредности наслеђене имовине, с обзиром да наследник одговара за дугове оставиоца у које дугове спадају трошкови сахране, подизање надгробног споменика и сл.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужила и тужени су бивши супружници. Након развода брака, син и ћерка странака поверени су на самостално вршење родитељског права тужили а тужени је обавезан да доприноси издржавању деце. Син странака преминуо је 13.03.2012. године због тешке болести-леукемије са напуњених 26 година живота, од које болести се разболео када је имао 24 године. У време смрти он је био студент. Преминуо је на Војно медицинској академији у Београду. Тужила је сносила све трошкове транспорта, сахране, трошкове подушја и давања читуља и друго, о чему је доставила доказе-рачунае. Решењем Основног суда у Нишу О.2743/12 од 19.02.2013. године за наследнике пок. сина странака, на заоставштини коју чине новчано потраживање по извршној пресуди Основног суда у Нишу 22П.1253/1 од 13.03.2012. године, новчано потраживање на име рефундације трошкова лечења у износу од 230.000 евра, јавне бесплатне акције и новчано потраживање код Банке Поштанска штедионица ад Београд, оглашене су тужила као мајка и сестра, у делу од по ½. Тужени се одрекао наслеђа у корист своје ћерке.

На основу тако утврђеног чињеничног стања тужени је обавезан да тужили исплати износе ближе описане у изреци, налазећи да трошкови сахрањивања детета подједнако терете оба родитеља, у смислу одредбе чл. 73, 154, и 155. Породичног закона и чл. 15. Закона о сахрањивању и гробљима, без обзира што су родитељи разведени и дете било поверено једном од њих на самостално вршење родитељског права.

Основани су жалбени наводи да је овакав закључак заснован на погрешној примени материјалног права. Сада покојни син странака је, као пунолетно дете у смислу одредбе чл. 155. ст. 1. и 2. Породичног закона, имао право на издржавање од родитеља јер је био на редовном школовању, а у периоду од почетка болести до смрти био неспособан за рад и да према одредби чл. 15. Закона о сахрањивању и гробљима трошкове сахрањивања сnose лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају.

Трошкове сахрањивања јесте сносила мајка, овде тужила, која је по закону била дужна да га издржава и која је иза његове смрти оглашена за законског наследника на половини заоставштине, па је у смислу одредбе чл. 222. Закона о наслеђивању одговорна за дугове оставиоца до висине вредности наслеђене имовине, у које дугове спадају трошкови сахране, подизања надгробног споменика и сл. Трошкови сахране представљају такозвану пасивну

заоставштину, односно право оног који је тај трошак учинио да потражује наплату из заоставштине. Међутим, тужила не може захтев за остваривање тог права поставити према лицу које се одрекло наслеђа, а све у смислу одредбе чл. 223. Закона о наслеђивању којом је прописано да наследник који се одрекао наслеђа не одговара за дугове оставиоца у које спадају трошкови сахране, подизања надгробног споменика и сл.

У конкретном случају, тужени се одрекао наслеђа иза смрти сина па тужила, која је учинила трошкове сахране и која се у оставинском поступку прихватила наслеђа, не може на основу одредбе чл. 218. Закона о облигационим односима захтевати накнаду половине наведених трошкова од туженог, имајући у виду одредбу чл. 223. Закона о наслеђивању јер је она, као законски наследник, на основу одредбе чл. 222. Закона о наслеђивању одговорна за дугове оставиоца до висине вредности наслеђене имовине, у које дугове спадају и трошкови сахране.

*(Пресуда Основног суда у Нишу П.бр.999/14 од 27.05.2015. године
Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. бр. 1837/15 од 18.02.2016. године)*

Аутор сентенце: судијски помоћник Слађана Љубеновић

ПРАВО ПРЕДСТАВЉАЊА

Ако оставиочево дете не може или неће да наследи, његов део на једнаке делове наслеђују његова деца (унуци оставиочеви), а кад неки од оставиочевих унука не може или неће да наследи, његов део на једнаке делове наслеђују његова деца (праунуци оставиочеви) и тако редом све докле има оставиочевих потомака.

Из образложења:

Пресуда парничног суда којим се усваја тужбени захтев има ретроактивно дејство (ex tunc) и успоставља правно стање какво је постојало у моменту смрти оставиље (делације). Због наведеног правилна је одлука првостепеног суда којом је делимично усвојио тужбени захтев тужиле у квоти од $\frac{1}{4}$, јер јој као законском наследнику, (по праву представљања иза смрти своје покојне мајке) и припада толики удео у наслеђу бабе-у моменту смрти оставиље,

обзиром да би друга четвртина припала њеној сестри, која се исте одрекла, али је то могла учинити само у своје име а не и у име малолетне кћери, па њена кћи има право да наследничком тужбом потражује наслеђе по праву представљања на $\frac{1}{4}$ иза смрти своје прабабе Д., од овде тужене М. и тражи предају одговарајућег дела заоставштине. Са изнетих разлога неосновани су жалбени наводи парничних странака, како тужиље тако и тужене у односу на одлуку првостепеног суда у ставу првом изреке побијане пресуде.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж. 1310/15 од 30.09.2015. год.)

Аутор сентенце: Судија Марина Милановић

ТУМАЧЕЊЕ ЗАВЕШТАЊА

Одредбе завештања треба тумачити према правој намери завештаоца.

Из образложења:

На основу утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени суд закључио да је предметно писмено завештање пред сведоцима сада пок. С.Б. сачињено у смислу одредбе чл. 85. Закона о наслеђивању и да је првостепени суд испитивањем праве воље завештаоца у смислу одредбе чл. 135. Закона о наслеђивању правилно закључио да је сачињеним завештањем завешталац имао намеру да туженике именује за једине наследнике на целокупној имовини па и на спорним новчаним средствима депонованим код Alpha bank Srbija АД Београд обзиром да је у истом наведено да им ставља сву своју имовину и покретну и непокретну, па је правилном применом материјалног права одлучио као у изреци пресуде а за своју одлуку о неоснованости тужбеног захтева тужилаца дао је довољне и јасне разлоге које прихвата и Апелациони суд у Нишу.

Неосновани су и жалбени наводи тужилаца којима се истиче да првостепени суд приликом одлучивања о тужбеном захтеву тужилаца није правилно ценио да је за пуноважност писменог завештања пред сведоцима потребно да завешталац прецизно и јасно наведе своју имовину како покретну тако и непокретну, а да покретне ствари треба да буду побројане по роду и броју сходно одредби чл. 194. Закона о наслеђивању, као када је у питању уговор о доживотном издржавању. Ово са разлога што у конкретном случају није

реч о уговору о доживотном издржавању, већ је у питању тестамент као једностран, лична и увек опозива изјава воље, у ком случају се не могу се аналогно применити одредбе Закона о наслеђивању које регулишу уговор о доживотном издржавању.

Неосновани су жалбени наводи тужилаца да је приликом одлучивања о тужбеном захтеву првостепени суд погрешно применио одредбу чл. 135. Закона о наслеђивању. Ово са разлога што је првостепени суд приликом тумачења наведеног завештања размотрио све околности конкретног случаја и правилно утврдио да је права намера и воља завештаоца била да целокупну своју имовину коју је поседовао у тренутку смрти, укључујући и предметна новчана средства остави туженицима, да је покретна имовина наведена у завештању као предмет истог одређива и да исту чине и новчана депонована средства по основу закључених уговора о ороченом новчаном депозиту у динарима код Alpha bank Srbija АД Београд.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж. 1287/16 од 24.08.2016. год.)

Аутор сентенце: Судија Марина Милановић

ПИСМЕНО ЗАВЕШТАЊЕ ПРЕД СВЕДОЦИМА

(чл. 85 Закона о наслеђивању)

Писмено завештање пред сведоцима, као строго формалан акт, мора бити сачињено у законом предвиђеној форми, облик мора бити поштован без одступања како би се осигурала слобода воље, озбиљност и поузданост изјаве воље, као и правна сигурност

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, странке у овом поступку су наследнице првог наследног реда иза смрти пок. Милутина бив. из Козара. Током поступка утврђено је да је пок. Милутин сачинио два завештања, при чему је прво уништио, па је своју имовину поново расподелио другим завештањем, сачињеним 02.11.2008.године. Из самог завештања од 02.11.2008.године се утврђује да је пок. Милутин сачинио писмено завештање тако што је ис-

то издиктирао адвокату, који га је накнадно прекуцао у својој адвокатској канцеларији и потом га предао завештаоцу. Саслушањем парничних странака и сведока, утврђено је да завешталац није потписао завештање у присуству оба сведока, као и да сведоци у тренутку потписивања нису истовремено били у кући завештаоца, нити су завештање заједно потписали. У конкретном случају, тестаментални сведоци се нису могли изјаснити да ли се ради о првом или о другом завештању тестатора и да ли је то уопште његово завештање, нити да ли је завештање већ било раније потписано од стране завештаоца или га је он пред њима потписао.

Из овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је закључио да је предметно завештање сачињено у складу са Законом, не позивајући се при томе на одредбе материјалног права, те је одбио тужбени захтев да се утврди да је без правне важности писмено завештање завештаоца, сада пок. Милутина, сачињено пред сведоцима. Основани су жалбени наводи да у конкретном случају писмено завештање није сачињено у складу са законом, односно да није испоштована његова форма на основу које би исто било пуноважно.

Одредбом чл. 85 Закона о наслеђивању је прописано да завешталац, који зна да чита и пише, може завештање сачинити тако што ће пред два сведока изјавити да је већ сачињено писмено прочитао, да је то његова последња воља и потом се својеручно потписао, а сведоци то истовремено потписују на самом завештању, а пожељно је да се назначи њихово својство сведока. Дакле, процедура састављања завештања из цитиране законске одредбе тече тако да већ готов писмени састав завешталац потписује истовремено изричито и јасно изјављујући пред оба сведока да је то његово завештање, након чега сведоци, којима не мора бити познат садржај завештања, исто потписују, један за другим, чиме потврђују аутентичност завештаоачевог потписа и његову изјаву да признаје то завештање за своју последњу вољу. Завешталац мора да прочита завештање и, да га изричито или прећутно, призна за своје док се улога сведока састоји у потврђивању само две околности, прве да је завешталац признао завештање за своје и друге, да се одмах иза тога на завештању својеручно потписао. Стога, уколико су сведоци завештања приспели у различитим терминима, после потписивања завештања од стране завештаоца и на завештању се накнадно потписали а без претходно остварених услова, није испуњена форма нужна за његову пуноважност.

Како је тестамент строго формалан акт, предвиђено је да та форма, односно облик мора бити поштована без одступања, како би се осигурала слобода воље, озбиљност и поузданост изјаве воље, као и правна сигурност. Имајући напред наведено у виду, Апелациони суд налази да предметно завештање није сачињено у облику и под условима одређеним Законом, тако да недостатак форме не пружа довољно гаранције за обезбеђење аутентичности последње воље завештаоца, услед чега не може производити правно дејство, у смислу чл. 168 Закона о наслеђивању.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 35 П.бр.1896/12 од 27.01.2016. године

Пресуда Апелационог суда у Нишу 29Гж-1194/16 од 24.05.2016. године)

Аутор сентенце: судија Соња Симоновић Стојановић

НАКНАДА ШТЕТЕ

НАКНАДА ШТЕТЕ И ПРЕЗУМЦИЈА НЕВИНОСТИ

(чл. 200. 300)

У току вођења кривичних поступака на снази је претпоставка невиности окривљеног лица, тако да се сматра да окривљени није учинио кривично дело које му се ставља на терет све до доношења правноснажне осуђујуће пресуде на само покретање и вођење судског поступка против неког лица, који је окончан на било који начин осим осуђујућом пресудом, није законом прописано као основ за накнаду овог вида штете.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био запослен код туженог на пословима главног координатора за искључење и прикључење струје и контролу потрошача. Против тужиоца је, по кривичним пријама поднетим од стране туженог, вођено више кривичних поступака за кривична дела која се гоне по службеној дужности од стране надлежног ОЈТ, и то због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 395. ст. 1 КЗ, кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл.

242. ст. 4., у вези ст. 1. КЗ РС, и кривичног дела фалсификовање службене исправе из чл. 248. ст. 3, у вези ст. 1 КЗ РС. Сви поступци су завршени или одбијањем оптужбе због застарелости, или обустављањем кривичног поступка, или доношењем пресуде којом се тужилац, као окривљени, ослобађа оптужбе за извршење кривичног дела.

Код неспорне чињенице да ни у једном поступку није оглашен кривим и кривично осуђен, тужилац нема право на накнаду нематеријалне штете за душевне болове због повреде угледа и части, јер је у току вођења кривичних поступака на снази претпоставка невиности окривљеног лица, тако

да се сматра да окривљени није учинио кривично дело које му се ставља на терет све до доношења правноснажне осуђујуће пресуде. Само покретање и вођење судског поступка против неког лица, који је окончан на било који начин осим осуђујућом пресудом, није законом прописан као основ за накнаду овог вида штете. У конкретном случају, с обзиром да су углед и част тужиоца током трајања кривичних поступка били заштићени презумпцијом невиности, то штета за тужиоца није ни наступила, па нема основа из чл. 200 ЗОО за досуђење тражене накнаде.

Осим наведеног, правилан је закључак да тужени, као правно лице, сходно чл. 223 ст. 1 ЗПК има обавезу пријављивања кривичних дела која се гоне по службеној дужности, па само подношење кривичних пријава не представља противправну радњу која би проузроковала нематеријалну штету код тужиоца и одговорност туженог у смислу одредбе чл. 172 ЗОО. Уколико презумпција невиности у пракси није спроведена, на шта се указује у жалби тужиоца, то тужилац одговорност и евентуалну штету може да потражује од одговорних за непоштовање презумпције невиности, а не и од туженог, који је у односу на тужиоца поступао у складу са својим овлашћењима.

*Пресуда Основног суда у Нишу 17П.10356/13 од 20.02.2017. године,
Пресуда Апелационог суда у Нишу, 29Гж. 3110/17 од 06.06.2017. године)*

Аутор сентенце: судија Соња Симоновић Стојановић

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИМАОЦА ОПАСНЕ СТВАРИ

Противправним држаоцем сматра се лице које је до опасне ствари дошло мимознања и воље њеног имаоца, тј. на правно недопуштен начин. Противправни држалац присваја бесправно положај који је сличан имаоцу и зато он одговора за штету насталу за време док се опасна ствар код њега налазила и то уместо имаоца сходно чл. 175. ЗОО. Услов за то није да одузимање ствари има карактер кривичног дела. Побуде противправног држаоца (стање крајње нужде и сл.) не могу да оправдају његов поступак, јер је одузимање туђе ствари као средство за постизање циља недопуштено. Пошто је ималац опасне ствари мимо своје воље ли-

шен државине и могућности да ствар надгледа и контролише престаје његова одговорност за штету учињену употребом те ствари. У том случају за штету одговара непосредни корисник ствари.

Из образложења:

Првостепени суд је усвојио тужбени захтев у односу на туженог Б.С. применом одредбе чл. 175. и 177. ст. 2. ЗОО, налазећи да је као власник возила којим је проузрокована саобраћајна незгода одговоран по основу кривице, јер је непажљивим остављањем кључева свог моторног возила на лако доступном месту омогућио да се његов аутомобил стави у погон и активирају његова опасна својства, а да исти није доказао да је предметном приликом од њега аутомобил одузет на противправни начин, нити је доказао да је штета настала искључиво радњом оштећеног или трећег лица коју он није могао предвидети и чије последице није могао избећи или отклонити.

Међутим, основано се жалбом туженог Б.С. указује на погрешну примену материјалног права, јер је првостепени суд погрешно закључио да у конкретном случају нема основа за примену чл. 175. и 177. ст. 2. ЗОО и ослобађања власника возила од одговорности за штету причињену возилом у ситуацији када је неко други управљао возилом, до кога је дошао без знања и дозволе власника возила, и који је искључиво одговоран за настану штету.

Наиме, за штету од опасне ствари одговара њен ималац, сходно одредби чл. 174. ЗОО. Ималац опасне ствари, у коју спада и аутомобил, је по правилу њен власник,

али то може бити и друго лице које по знању власника, или без његовог знања држи опасну ствар. Противправним држаоцем сматра се лице које је до опасне ствари дошло мимо знања и воље њеног имаоца, тј. на правно недопуштен начин. Противправни држалац присваја бесправно положај који је сличан имаоцу и зато он одговара за штету насталу за време док се опасна ствар код њега налазила и то уместо имаоца сходно чл. 175. ЗОО. Услов за то није да одузимање ствари има карактер кривичног дела. Побуде противправног држаоца (стање крајње нужде и сл.) не могу да оправдају његов поступак, јер је одузимање туђе ствари као средство за постизање циља недопуштено. Пошто је ималац опасне ствари мимо своје воље лишен државине и могућности да ствар надгледа и контролише престаје његова одговорност за штету учињену употребом те ствари. У том случају за штету одговара непосредни корисник ствари. Међутим, ако је ималац својом кривицом омогућио противправном држаоцу да се домогне опасне ствари

тада одговара солидарно са њим. Сматра се да је ималац крив кад ствар није чувао са просечном пажњом, кад није предузео потребне мере да спречи неовлашћену употребу ствари.

У конкретном случају тужени И.Ђ. је противправни држалац предметног возила, јер је до возила дошао у ресторану користећи непажњу М.С. - брата туженог Б.С., и истим проузроковао саобраћајну незгоду у алкохолисаном стању, због чега је и кривично одговарао. То даље значи да тужени Б.С, који није био присутан критичном приликом на месту дешавања, никако није могао својом кривицом да омогући туженом И.Ђ. да дође до возила, нити је био у могућности да спречи неовлашћену употребу возила од стране истог.

Због наведеног тужени Б.С. није солидарни дужник са туженим И.Ђ, јер су у конкретном случају испуњени услови за ослобађање од одговорности власника возила за штету причињену његовим возилом, сходно одредби чл. 175. и чл. 177. ст. 2. ЗОО, па је Апелациони суд усвајањем жалбе туженог Б.С. преиначио првостепену пресуду у односу на истог и одлучио као у ставу првом изреке ове пресуде.

(Пресуда Основног суда у Зајечару 7П.1242/2014 од 18.11.2015. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 28Гж.307/16 од 28.04.2016. године)

*Аутори сентенце: судија Марина Ђукић и Мирјана Милутиновић,
виши судијски сарадник Апелационог суда у Нишу*

НАКНАДА ШТЕТЕ ПРЕМА ОДРЕДБИ

(чл. 21 ст. 1 тач. 1 Закона о обавезном осигурању)

Власник моторног возила, чијом употребом му је причињена штета на том возилу, нема право на накнаду материјалне штете по основу осигурања од аутоодговорности, нити право на накнаду нематеријалне штете због задобијене телесне повреде у ситуацији када је возилом управљало лице које није имало возачку дозволу.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је власник путничког моторног возила марке “Голф”. Наведено возило је током 2009. године било осигурано полисом осигурања од аутоодговорности код туженог. Дана 17.10.2009.

године догодила се саобраћајна незгода тако што је ово возило, којим је управљало треће лице, а тужилац се налазио на месту сувозача, слетело са пута и ударило у зид зграде, те је настала штета на предметном возилу, а тужилац је задобио бројне повреде. Против трећег лица је вођен прекршајни поступак у вези наведене саобраћајне незгоде те је, правноснажном и извршном пресудом Прекршајног суда - Одељења у Медвеђи IV-13-Пр.бр.12371/10 од 19.10.2010. године, он оглашен кривим за два прекршаја - вожњу без возачке дозволе и непријављивања саобраћајне незгоде. Записником, туженог, У-176/09 од 05.11.2009. године, снимљена је штета на возилу и наведено који делови су за замену, а који за поправку. Дописом од 19.06.2013. године тужилац је од туженог као осигуравача тражио исплату штете, али је његов захтев тужени одбио, услед застарелости потраживања. Медицинским вештачењима утврђено је да је критичном приликом тужилац задобио повреде које се квалификују као лаке телесне повреде, утврђени су интензитет и трајање бола и страха које је тужилац претрпео, као и смањење опште животне активности тужиоца у лакој степену током периода трајања лечења. Вештачењем од стране вештака за област машинства утврђена је укупна вредност штете на тужиоцевом возилу.

Према одредби чл. 21. ст. 1. тач.1 Закона о обавезном осигурању у саобраћају право на накнаду штете по основу осигурања од аутоодговорности нема власник моторног возила чијом му је употребом причињена штета, за штете на стварима а одредбом чл.29. ст. 1. тач. 2. истог Закона прописано је да осигурано лице губи права из осигурања ако возач није имао возачку дозволу за управљање моторним возилом одређене категорије, осим ако је возилом управљало лице које је кандидат за возача за време обуке за управљање возилом, уз поштовање прописа којима је та обука регулисана. У конкретном случају, треће лице, које је критичном приликом управљао тужиоцевим возилом није имало возачку дозволу, из ког разлога је и правноснажно осуђено за прекршај из чл. 226. ст. 1. тач. 29. Закона о основама саобраћаја на путевима јер је управљало путничким моторним возилом пре стицања права на управљање.

Како из важеће законске регулативе произилази да тужилац нема право да од туженог, осигуравајуће куће, захтева накнаду како материјалне, тако и нематеријалне штете а по основу осигурања од аутоодговорности то је побијана пресуда преиначена, а тужбени захтев тужиоца одбијен као неоснован.

*(Пресуда Основног суда у Лесковцу П.бр.3908/13 од 15.09.2014. године
Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.бр.92/15 од 10.09.2015. године)*

Аутор сентенце: судијски помоћник Слађана Љубеновић

ПРАВО НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗА ДУШЕВНЕ БОЛОВЕ ЗБОГ СМРТИ РЕХАБИЛИТОВАНОГ ЛИЦА

(члан 26. Закона о рехабилитацији)

Право на накнаду нематеријалне штете због смрти рехабилитованог лица брачни друг, деца и родитељи, односно браћа, сестре и ванбрачни партнер рехабилитованог лица могу остварити само ако је између њих и рехабилитованог лица постојала трајнија заједница живота.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, решењем Вишег суда у Л. Рех. бр..., пок. АА бив. из Б, је без судске и административне одлуке лишен права на живот дана 17.10.1944 године у П, као жртва прогона и насиља, из политичких и идеолошких разлога, те су без дејства све правне последице таквог поступка. Тужилац В. је најмлађи син рехабилитованог АА, који је рођен 08.03.1945 године, након његове смрти. Оценом изведених доказа, саслушаних сведока, извршеног увида у списе предмета Рех. бр... и понуде Министарства правде за покушај закључења споразума о рехабилитацији, првостепени суд стаје на становиште, да су испуњени услови за накнаду штете, али да је захтев превисоко постављен, па делимично усваја тужбени захтев за износ од 500.000, 00 динара а преко тог износа захтев одбија, применом одредби чл. 172, 200 и 277 ЗОО.

Овакав закључак првостепеног суда у погледу постојања основа за накнаду штете не може се прихватити, јер донета одлука не садржи довољне и јасне разлоге да би се могла испитати са становишта правилне примене материјалног права. Основани су жалбени наводи, да овде тужилац не спада у круг лица која могу остваривати право на рехабилитационо обештећење, обзиром да између тужиоца и пок. Божидача није постојала заједница живота.

Чланом 26. Закона о рехабилитацији (“Службени гласник РС”бр. 92/2011) прописана су права рехабилитованог лица и трећих лица, уколико је захтев за рехабилитацију усвојен, па је у ставу три цитираног члана прописано, да лице из чл. 7. тач. 5. овог Закона има право на накнаду нематеријалне штете за душевне болове због лишења слободе, у складу са законом којим се уређују облигациони облици, а у ставу четири истог члана је прописано, да лица из чл. 21. ст. 2. овог закона, имају право на накнаду нематеријалне штете за душевне болове због смрти рехабилитованог лица, под

условом да је између њих и умрлог рехабилитованог лица постојала трајнија заједница живота, у складу са законом којим се уређују облигациони односи. Према чл. 21. ст. 1. Закона, право на рехабилитационо обештећење имају и брачни друг, деца и родитељи, односно браћа, сестре и ванбрачни партнер рехабилитованог лица у складу са одредбом чл. 26. ст. 4. Закона. Обзиром да је у конкретном случају рехабилитовано лице лишено живота, на конкретан случај се односи одредба чл. 26. ст. 4. у вези са чл.

21. ст. 2. Закона о рехабилитацији. Између овде тужиоца и рехабилитованог лица није постојала заједница живота, обзиром да је тужилац рођен након смрти свога оца, а првостепени суд не даје разлоге, на основу којих налази да тужиоцу припада право на рехабилитационо обештећење, па се основано у жалби тужене указује, да првостепена пресуда у усвајајућем делу не садржи разлоге о одлучним чињеницама, чиме је начињена битна повреда одредаба парничног поступка из чл. 374. ст. 2. тач. 12. ЗПП-а.

(Решење Апелационог суда у Нишу Гж бр. 3595/17 од 18.07.2017. год.)

Аутор сентенце: Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ

Амнестијом се не утврђује да окривљени није извршио кривично дело и да није крив, тако да решење којим се примењује амнестија не може бити основ по коме тужилац може тражити накнаду штете због неоснованог лишења слободе

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је правноснажном пресудом Општинског суда у Н. К. К.бр.87/2009 од 13.10.2009.године, оглашен кривим за кривично дело превара из чл. 208 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ и изречена му је казна затвора у трајању од 8 месеци. Пресудом Апелационог суда у Н. С. Кж.бр.861/10 од 04.03.2010. године, преиначена је првостепена пресуда на тај начин што је тужиоцу изречена казна затвора у трајању од 1 године. На издржавање казне је ступио дана 13.06.2012. године у КПЗ у Ћ. Након захтева тужиоца за амнестију, правноснажним решењем Апелационог

суда у Н. С. Кж.2 1648/13 од 31.05.2013. године, усвојена је жалба тужиоца, те је примењена амнестија, а исти је ослобођен од извршења казне затвора у трајању од 3 месеца и наложено је да се одмах отпусти са издржавања казне, те је исти отпуштен из затвора дана 31.05.2013. године.

Првостепени суд је на основу утврђеног чињеничног стања правилно закључио да је тужбени захтев тужиоца за накнаду штете због неоснованог лишења слободе неоснован, јер у конкретном случају нису испуњени услови прописани одредбом чл. 172. ст. 1 ЗОО.

Тужилац у жалби наводи да је другостепеним решењем Апелационог суда у Н. С. усвојен његов захтев за амнестију те му је изречена кривична санкција од годину дана умањена за 25 %, што би у конкретном случају значило да је требао да буде лишен слободе девет месеци од почетка извршења казне, што значи да је морао бити пуштен на слободу дана 13.03.2013. године. Произилази да је његово лишење слободе било у дужем трајању, односно у периоду од 13.03.2013. године, када је морао бити пуштен на слободу до 31.05.2013. године, када је отпуштен из КПЗ у Ћ. Такође, тужилац наводи да је погрешан закључак првостепеног суда да је у конкретном случају релевантан моменат правноснажности решења о примени амнестије, обзиром да је овај институт у кривичном праву прописан као један од основа за гашење кривичне санкције, а што првостепени суд није уопште ценио и сматра да не може трпети штетне последице услед тога што је Основни суд у К. одбио да примени Закон о амнестији и да се такво поступање има сматрати као незаконит рад државног органа из чега произилази и основ настанка штете.

Апелациони суд налази да су неосновани жалбени наводи тужиоца, обзиром да се амнестијом не утврђује да окривљени није извршио кривично дело и да није крив, тако да решење којим се примењује амнестија не може бити основ по коме тужилац може тражити накнаду штете у овој правној ствари, како је то правилно нашао и првостепени суд. Наиме, тужилац није лице неосновано лишено слободе, нити је основ његовог лишења слободе престао да постоји у смислу одредби Закона о кривичном поступку, тако да је он до доношења правноснажног решења о амнестији издржао казну затвора управо у оном трајању у којем му је она и изречена.

Осим тога, одговорност државе постоји ако је штета настала као последица таквог рада њеног органа који се може сматрати прекорачењем, злоупотребом или погрешном применом датих овлашћења. У конкретном случају наведено решење о амнестији тужиоца постало је правноснажно

дана 31.05.2013. године и исти је одмах након његове правноснажности пуштен на слободу, тако да је државни орган тужене поступао у оквиру својих законских овлашћења, те у том смислу не постоји ни одговорност тужене Републике Србије за штету коју је евентуално претрпео тужилац.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 23Гж.бр.1230/14 од 21.5.2014. године)

Аутор сентенце: судија Сузана Ђурић

ГРАЂАНСКО ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ

Треће оштећено лице по основу накнаде штете причињене моторним возилом остварује правно на накнаду штете од штетника и од осигуравајућег друштва, а осигуравач је у обавези да накнади штету за коју је одговоран осигураник, било да је утврђена његова кривичноправна одговорност, било да је утврђена његова грађанскоправна одговорност.

Из образложења:

Првостепени суд је на основу утврђеног чињеничног стања, полазећи од решења ОЈТ којим је одбачена кривична пријава против овде првотуженика, закључио да је до штете дошло искључивом радњом оштећеника-овде тужиоца, па је нашао да су испуњени услови из чл. 177. ст. 1 и 2. ЗОО, за ослобађање првотуженика од одговорности за штету насталу од опасне ствари, а сходно чл. 940. ЗОО и за ослобађање од одговорности друготуженика, јер ослобађањем његовог осигураника од одговорности за штету причињену трећем лицу не постоји ни одговорност осигуравача за штету од ауто одговорности, па је применом наведеним законских одредби одлучио као у ставу првом изреке побијане пресуде.

Апелациони суд овакав закључак првостепеног суда не прихвата.

Наиме, грађанска одговорност је шира од кривичне одговорности, па парнични суд самостално решава читав низ питања везаних за утврђивање грађанскоправне одговорности, односно у парничном поступку се утврђују чињенице у погледу околности настанка штете, које условљавају степен кривице одговорног лица, а ради евентуалне примене правила о подељеној одговорности (чл. 192. ЗОО, у вези чл. 205. ЗОО). Питање у којој мери је настанку штете допринео штетник, а у којој мери оштећени је питање које решава суд

у парници за накнаду штете и у томе није везан становиштем кривичног суда, нити решењем ОЈТ, како је у конкретном случају првостепени суд погрешно утврдио чињенично стање само на основу образложења из решења ОЈТ Кт.4587/12 од 14.02.2013. године, а којим је одбачена кривична пријава против овде првотуженика.

Правни основ за остваривање захтева за накнаду штете је причињена штета и одговорност штетника за њену накнаду. Треће оштећено лице по основу накнаде штете причињене моторним возилом остварује правно на накнаду штете од штетника и од осигуравајућег друштва, а осигуравач је у обавези да накнади штету за коју је одговоран осигураник, било да је утврђена његова кривичноправна одговорност, било да је утврђена његова грађанскоправна одговорност. У конкретном случају првостепени суд је пропустио да утврди да ли постоји грађанскоправна одговорност првотуженика за насталу штету, па како пресуда нема разлоге о битним чињеницама иста је морала бити укинута.

(Пресуда Основног суда у Нишу 13П.6458/13 од 15.04.2015. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 27Гж.1739/15 од 09.12.2015. године)

***Аутор сентенце: Мирјана Милутиновић,
виши судијски сарадник Апелационог суда у Нишу***

РАДНО ПРАВО

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

(чл. 179. ст. 1. тач. 2. Закона о раду)

Видео запис се може користити као доказ на суду под условом да је прибављен у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), с тим што одлука послодавца која производи правне последице за запосленог и погоршава његов положај, не може бити заснована искључиво на том доказу.

Из образложења:

Тужени је тужиоцу дао отказ уговора о раду применом чл. 179. ст. 1. тач. 2. Закона о раду и чл. 107. Колективног уговора, због несавесног обављања својих радних задатака, јер је тужилац као заменик пословође коме је у опису посла контрола рада пословања и запослених морао да спречи касирку да одштампа рачун док на каси није било купаца и да тако не евидентира промет без куповине робе.

Једини доказ на који се позива послодавац, приликом давања отказа тужиоцу је видео снимак сигурносних камера из тог малопродајног објекта и при том записнички информација није забележена, како би се запосленом омогућила одбрана у поступку давања отказа.

Такође, повреда радне обавезе због које се запосленом може дати отказ уговора о раду прописана општим актом, у одредби чл. 107 тач. 1 Колективног уговора, предвиђа кумулативно испуњење не само у погледу понашања запосленог као неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радних дужности и обавеза, већ и настајање штете или могућност да штета настане. Оспорено решење и претходно дато упозорење, у погледу штете, као кумулативног услова од кога зависи примена отказног разлога, не садржи чињени-

це, нити се указује на доказе и околности које би могле бити од евентуалног значаја за отказ уговора о раду, а суд у поступку оцене законитости одлуке послодавца, нема овлашћења да мења или допуњује изнет чињенични основ и тиме отклања пропуст послодавца.

Закон о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), који регулише прикупљање података о личности (и путем видео надзора) дефинише у чл. 3., да је податак о личности свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медији и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл. односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.) или без обзира на друго својство информације.

Обрада података је свака радња предузета у вези са подацима као што су прикупљање, бележење, преписивање, умножавање, копирање, преношење, претраживање, разврставање, похрањивање, раздвајање, укрштање, обједињавање, мењање, коришћење, стављање на увид, откривање, објављивање, снимање, чување, откривање путем преноса или на други начин чињење доступним или недоступним, као и спровођење радње у вези са наведеним подацима, без обзира да ли се врши аутоматски, полуаутоматски и ли на други начин даље обрађује.

Према одредби чл. 4. наведеног Закона, одредбе тог закона примењују се на сваку аутоматизовану обраду, као и на обраду садржану у збирци података која се не води аутоматизовано.

Стога, у смислу одредбе чл. 8. тог закона, обрада података није дозвољена ако физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења и ако се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског овлашћења за обраду без пристанка, осим ако се врши у сврху прикупљања средстава за хуманитарне потребе из члана 12.

Такође, према члан 9. истог Закона, одлука која производи правне последице за лице или погоршава његов положај, не може бити искључиво заснована на подацима који се обрађују аутоматизовано и који служе оцени неког његовог својства (радне способности, поузданости, кредитне способности и сл.).

На основу наведених законских одредби произилази да се видео записи могу користити као доказ на суду под условом да су прибављени у складу са Законом о заштити података о личности. У том смислу послодавци су у обавези да обавесте запослене да се видео надзор спроводи на одређеном простору, које мора да садржи и одређење у коју сврху се користи. У противном одлука се не може засновати на доказу, који не испуњава услове Законом о заштити података о личности. У конкретном случају тужени у оспореној одлуци и у току поступка пред првостепеним судом нити је истицао чињеницу нити је доставио доказе да су тужилац и остали запослени обавештени о сврси видео надзора које се спроводи у одређеном простору.

Поред тога, из цитираних одредби произилази да видео снимак не може бити једини доказ послодавца против запосленог сходно чл. 9. Закона о заштити права личности.

У конкретном случају како тужени одлуку о престанку радног односа заснива само на видео снимку сигурносних камера, а при том није ни доказао да су запослени обавештени у коју сврху је постављен видео надзор у просторијама малопродајног објекта, те како оспорено решење не садржи чињенични основ у погледу настале штете како кумулативног услова за настајање отказног разлога, то тужени није на несумњив начин утврдио повреду радне обавезе коју ставља на терет тужиоцу, па је правилан закључак првостепеног суда да је оспорено решење незаконито.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18П1.686/16 од 17.03.2016. године)

Сентенцу приредила: Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу

ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ОТКАЗА

(чл. 191. ст. 7. Закона о раду)

Уколико суд у току поступка утврди да је постојао основ, као оправдан разлог за престанак радног односа, а да послодавац није донео одлуку у законом предвиђеном поступку, суд на основу законског овлашћења одбија захтев запосленог за враћање на рад и досуђује накнаду штете у висини до шест зарада коју је запослени остварио у месецу у коме му је

престао радни однос и таква одлука суд није условљена истицањем евен-туалног тужбеног захтева за исплату накнаде штете.

Из образложења:

Законом о изменама и допунама Закона о раду (“Службени гласник РС” бр.75/14) који је донет 21.7.2014. године, а ступио на снагу 29.7.2014. године, одредбом чл. 86., измењена је одредба чл. 191. Закона, тако што је ставом седмим те одредбе, предвиђено да ако суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног односа, али да је послодавац поступио супротно одредбама закона којим је прописан поступак за престанак радног односа, одбиће захтев запосленог за враћање на рад, а на име накнаде штете досудиће запосленом износ до шест зарада.

Измењена одредба чл. 191 Закона о раду, даје ново законско решење у погледу правних последица незаконитог престанка радног односа у зависности од утврђеног чињеничног основа у току судског поступка у погледу постојања основа за престанак радног односа, услед чега за правилно одлучивање о основаности тужбеног захтева којим се тражи враћање на рад, није довољно само утврђење да послодавац није донео одлуку у законом предвиђеном поступку.

Уколико није постојао разлог за отказ у виду повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине и других разлога, о последицама незаконитог отказа, суд расправља применом чл. 191 ст. 1-6. Закона о раду. Међутим, уколико суд у току поступка утврди да је запослени својим понашањем учинио повреду радне обавезе или акт недисциплине, дакле да је постојао основ за престанак радног односа, а да послодавац није донео одлуку у законом предвиђеном поступку у складу са одредбама чл. 180 до 186 Закона, о последицама незаконитог престанка радног односа суд одлучује применом чл. 191 ст. 7. Закона о раду.

У поновном поступку првостепени суд је потребно да утврди на основу чињеница садржаних у оспореном решењу и оценом свих приложених и предложених доказа, у смислу чл. 6. ЗПП, да ли је тужилац учинио повреду радне обавезе или акт недисциплине који му је стављен на терет, дакле да ли је настао основ-разлог за отказ, што је све по новелираним одредбама Закона о раду, релевантан чињенични основ од кога зависи отклањање последице незаконитог престанка радног односа у погледу поновног укључивања за-

посленог у процес рада, као и одлука суда о захтеву запосленог да се врати на рад и другим правима садржаним у чл. 191 Закона. Имајући у виду изнете примедбе, пошто отклони битну повреду поступка и утврди чињенице на које му је указао овај суд, првостепени суд ће поново одлучити о тужбеном захтеву, дајући разлоге за свој закључак.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 18Гж1.2349/16 од 09.08.2016. године)

Сентенцу приредила: Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ТУЖБЕ

(чл. 195. Закона о раду)

Благовременост тужбе за утврђење постојања радног односа, цени се применом правила о року за судску заштиту, који је прописан одредбом чл. 195. Закона о раду, као посебним прописом.

Из образложења:

На основу тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд налази да је основан тужбени захтев тужиле, обзиром да уговор о раду на основу кога је заснован радни однос на одређено време, не садржи одредбу да директору престаје радни однос по истеку рока за који је изабрана, односно даном разрешења, те да је дошло до преображаја радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време, обзиром да је по истеку периода на који је заснован радни однос по уговору од 26.08.2012 године, наставила да ради 23 дана, услед чега применом чл. 14. ст. 1. тач. 6. и 7. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и чл. 37. ст. 4. Закона о раду, усваја тужбени захтев у целини.

Међутим, овакав закључак првостепеног суда за сада се не може прихватити, јер побијана пресуда не садржи разлоге о одлучним чињеницама за правилно пресуђење у овој правној ствари, обзиром да су изостали разлози у погледу благовремености поднете тужбе, о чему суд води рачуна по службеној дужности, у ком правцу је и тужени истицао приговор, услед чега је првостепена пресуда морала бити укинута.

Утврђивање да је запослени засновано радни однос на неодређено време, услед преображаја радног односа заснованог на одређено време, у радни од-

нос на неодређено време, може бити предмет радног спора само када су испуњене процесне претпоставке за судску заштиту права запосленог и када су за то испуњени законом предвиђени услови и тада одлука суда постаје основ којим се декларише заснован радни однос. Првостепени суд је мериторно одлучио о тужбеном захтеву тужиоца, међутим закључак првостепеног суда се за сада не може прихватити, обзиром да су изостали разлози у погледу оцене основаности приговора неблаговремености поднете тужбе. Према чл. 374. ст. 2. тач. 3 ЗПП, битна повреда поступка увек постоји ако је одлучено о захтеву по тужби која је подигнута после рока прописаног законом.

Одредбом чл. 195. Закона о раду, прописано је да се против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени сазнао за повреду права, запослени, односно председник синдиката чији је запослени члан, може да покрене спор пред надлежним судом у року од 90 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.

Поштовање рока за подношење тужбе из напред наведене одредбе је услов за остваривање судске заштите у радном спору по тужби запосленог, јер протеком законом прописаног рока за подношење тужбе наступа преклузија и губитак права на судску заштиту о чему суд води рачуна по службеној дужности и одбацује тужбу уколико утврди да је тужба поднета неблаговремено, обзиром да је посебним прописима одређен рок за подношење тужбе, како је предвиђено одредбом чл. 294. ст. 1. тач.2. и 295. ЗПП.

*(Решење Апелационог суда у Нишу, 18П1.686/15 од 07.05.2015. године)
Сентенцу приредила: Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу*

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ОТКАЗА

(чл. 191. Закона о раду у вези чл. 131. ст. 1. тач.3.

Закона о државним службеницима)

Чињеница да решење о престанку радног односа запосленом државном службенику, који је нераспоређен и није премештен на друго радно место наредног дана од протекла два месеца од када је постао нераспоређен, није донето у складу са законом, није основ за накнаду штете због незаконитог отказа.

Из образложења:

Одредбом чл. 4. ст. 1. Закона о државним службеницима (“Сл. гл. РС” 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) прописано је да се на права и дужности државних службеника која нису уређена овим или посебним законом, примењују општи прописи о раду на све ситуације које нису другачије уређене Законом о државним службеницима или другим посебним законом. Разлози за престанак рада, услови и стицање статуса нераспоређеног државног службеника и доношење решења којим се под законом прописаним условима, утврђује престанак рада, уређени су одредбама чл. 76. до чл. 81. Закона о државним службеницима. Престанак радног односа утврђује се решењем које садржи разлоге због којих је престао радни однос и дан када је престао радни однос. Одредбом чл. 126. истог закона, прописани су начини престанка радног односа државног службеника при чему је у ст. 1. тач.4. као један од начина дефинисан и престанак радног односа по сили закона. У смислу чл. 131. ст. 1. тач. 3. закона, државном службенику престаје радни однос по сили закона, ако је нераспоређен а не буде премештен на друго радно место и то наредног дана од протека два месеца од кад је постао нераспоређен.

Решење о томе да је државном службенику престао радни однос по сили закона је декларативног карактера. Руководилац доноси ово решење искључиво након престанка радног односа државног службеника и њиме утврђује само разлог због кога је радни однос престао и дан када је радни однос престао. На овај начин се радноправни статус запосленог који је остао нераспоређен и који у року од два месеца није премештен на друго радно место или у други државни орган и формалноправно окончава. За случај да решење о престанку радног односа из напред наведеног разлога није донето у складу са законом, овлашћени орган у поновном поступку доноси ново решење са истим датумом нераспоређивања и са датумом престанка радног односа у складу са законом.

Тужиоцу који је остао нераспоређен по основу решења органа туженог од 24.02.2010. године, а није распоређен на друго радно место у истом или другом државном органу у року од два месеца, по истеку овог рока радни однос престаје по сили закона, те је одлука овлашћеног органа, декларативне природе, а не конститутивне. Овим решењем се само констатује настала чињеница за коју закон везује одређену правну последицу, а не конституише нова чињеница.

Тужени је након укидања решења о престанку радног односа од 23.04.2010. године, због тога што исто није било у складу са законом с обзиром да је

овим решењем констатовано да је тужиоцу престао радни однос закључно са 24.04.2010. године, што је противно одредби чл. 90. ст. 2. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да се рок који је одређен по месецима завршава истог оног дана односно месеца који по броју одговара дану у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, донео ново решење дана 05.03.2015. године, којим је тужиоцу престао радни однос са даном 25.04.2010. године.

Запослени коме је незаконито престао радни однос, има право на накнаду штете у смислу става 2. члана 191. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) који прописује да поред враћања на рад, послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уговору о раду. Из тога произилази обавеза послодавца да материјалну ситуацију запосленог доведе у стање у коме би она била да није било штетне радње (чл. 190. ЗОО).

Како тужиоцу радни однос није престао незаконито, то не постоји основ за накнаду тражене штете у висини изгубљене зараде и уплате доприноса, а тиме ни право тужиоца на исту.

*(Из пресуде Апелационог суда у Нишу
25Гж1.бр.1955/15 од 10.05.2016. године)*

*Аутор сентенце: Ружица Јовановић,
судија Апелационог суда у Нишу*

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

(чл. 48. Закона о раду)

Вршилац дужности остварује права и обавезе директора, услед чега се правила која регулишу радно правни статус директора, аналогно примењују и на вршиоца дужности, јер се ради о пословима органа управљања предузећа.

Из образложења:

Према чл. 14. Закона о јавним предузећима у обављају делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", 25/2000... 123/2007), који је био у примени у време закључења уговора о раду од 26.08.2012 године, било је пропи-

сано да вршилац дужности може обављати те послове најдуже једну годину, а према чл. 42 Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС”, бр. 119/12, то право ограничено је на шест месеци, с тим што је ставом 3. исте одредбе, дато овлашћење оснивачу да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. Дакле у складу са прописима који су важили у време доношења одлука оснивача и закључења уговора о раду до њеног разрешења, тужилца је обављала све време послове вршиоца дужности директора у свеукупном трајању не дуже од једне године и шест месеци. Осим тога, из списка произилази да по истеку периода утврђеног уговором о раду од 26.08.2012. године, до закључења другог уговора о раду 03.10.2013. године, није донета одлука о разрешењу тужилце, нити је изабран директор, напротив новим уговор регулисана су права и обавезе странака и то тако што је уговорено да тужилца буде у радном односу све до именовања директора туженог предузећа.

Стога, како вршилац дужности остварује права и обавезе директора, то правила која регулишу радно правни статус директора аналогно се примењују и на вршиоца дужности, јер се ради о пословима органа управљања предузећа. С тим у вези, орочење радног односа директора на одређено време сагласно одредби чл. 48. Закона о раду, врши се на битно другачији начин у односу на радни однос на одређено време у општем радно правном режиму сходно чл. 37. Закона о раду.

Према одредби чл. 48. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05) директор може да заснује радни однос на одређено или неодређено време, да се радни однос заснива уговором о раду, те да радни однос на одређено време може да траје до истека рока на који је изабран директор, односно до његовог разрешења. Међусобна права, обавезе и одговорности директора који није засновао радни однос и послодавца уређују се уговором у ком случају лице које обавља послове директора има право на накнаду за рад која има карактер зараде и друга примања. Уговор из става два и четири наведене одредбе, са директором закључује у име послодавца управни одбор.

Ако је радни однос заснован на неодређено време, трајање радног односа се наставља и по истеку мандата, али на другим пословима и то у случају да је запослени пре именовања већ био у радном односу код послодавца тада остварује право да се врати на раније радно место или уколико је уговорен премештај на друге послове у случају истека мандата или разрешења.

Међутим, уколико је радни однос заснован на одређено време, трајање радног односа и мандата је исто и мандат и радни однос престају истовремено.

У конкретном случају, тужила није била у радном односу код туженог, а одлука о именовању тужиле за вршиоца дужности директора предузећа, била је основ закључења уговора од 26.08.2012. године, па је ступањем на дужност, тужила стекла права и преузела обавезе и одговорности директора, од када јој тече и мандат. Чињеница је да је по истеку рока од једне године, по наведеном уговору, тужила фактички наставила да обавља послове вршиоца дужности директора, 23 дана до закључења уговора о раду 03.10.2013 године, међутим та чињенична и правна ситуација не даје основ за конверзију радног односа из чл. 37. ст. 4. Закона о раду, обзиром да је у питању радно однос на одређено време на пословима који имају специфичну правну природу, који су условљени одлуком оснивача, услед чега се фактичким ступањем на рад и фактичким обављањем тих послова органа управљања предузећа, у смислу чл. 32., у вези чл. 37. ст. 4. Закона о раду, не може засновати радни однос на неодређено време. С друге стране, у том периоду оснивач није донео одлуку о разрешењу, нити је именован директор предузећа, већ напротив закључен је уговор 03.10.2013 године, којим је уговорен радни однос на одређено време до именовања директора по проведеном јавном конкурс, на којој чињеници се и заснива одлука оснивача о разрешењу тужиле, а услед чега је истеком времена на које је именована, вршиоцу дужности директора *ex lege* престаје и радни однос.

Становиште првостепеног суда да је основан тужбени захтев тужиле услед тога што у уговору о раду није изричито наведено да јој по истеку рока, односно разрешења престаје радни однос, не може се прихватити, јер ниједна законска одредба, па ни чл. 33. и 48. Закона о раду, не садржи такав императив. Из изнетих разлога, Апелациони суд налази да није основан тужбени захтев за утврђење да је радни однос заснован на одређено време престао у радни однос на неодређено време због примене специјалног правила које представља одступање и изузетак од правила о престању радног односа из чл. 37. ст. 4. Закона о раду из којих разлога се нису стекли услови за примену правила о конверзији радног односа, нити има основа за враћање на рад, обзиром да странке у поступку нису уговориле премештај на друге послове у случају разрешења, нити на другачији начин регулисале радно- правни статус тужиле.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 18Гж.1.23/16 од 15.01.2016 године)

Сентенцу приредила: Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу

УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАО КАТЕГОРИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈА УЖИВА ПОСЕБНУ ЗАШТИТУ ОД ОТКАЗА ЗБОГ ПРЕСТАНКА ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНОГ (чл. 179. ст. 1. тач. 9. Закона о раду, у вези чл. 34-39. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика)

У поступку оцене да ли запослени као самохрани родитељ ужива заштиту од отказа због престанка потребе за његовим радом, релевантан је стварни статус запосленог који је постојао у време доношења одлуке о престанку радног односа.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је била у радном односу код тужене на неодређено време са 25% радног времена на радном месту наставника физичке културе. Решењем тужене од 01.09.2011. године, тужили је почев од тог датума утврђен статус запосленог за чијим је радом престала потреба за школску 2011/2012 годину. Решењем од 13.12.2011. године, тужили је отказан уговор о раду због престанка потребе у школској 2011-2012 години и радни однос престао је даном исплате отпремнине закључно са даном 30.12.2011. године, јер тужила није могла бити распоређена на друго радно место у установи, распоређена на радно место са непуним радним временом у установи, преузета на основу споразума о преузимању у другу установу, нити упућена на преквалификацију или доквалификацију у складу са чл. 36 ПКУ. Против наведеног решења тужила је изјавила приговор који је одлуком школског одбора од 27.02.2012. године одбијен. Тужена је у поступку доношења решења о отказу уговора о раду извршила бодовање на основу критеријума прописаних колективним уговором. На основу уверења Центра за социјални рад од 04.01.2011. године утврђено је да је 08.11.2005. године, разведен брак тужиле и њеног супруга, као и да није одлучено о вршењу родитељског права, те да тужила самостално врши родитељско право, да се о истима непосредно брине и стара и да са њима живи у заједничком породичном домаћинству.

Код овако утврђеног чињенично стања, правилан је закључак првостепеног суда да у конкретном случају није било услова да се примени отказни разлог из чл. 179. ст. 1. тач. 9. Закона о раду, а у вези одредаба чл. 34. до 39. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим

школама и домовима ученика, које искључују наступање отказног разлога, јер тужила као самохрани родитељ, ужива посебну заштиту запосленог, која је установљена у циљу обезбеђења социјалне сигурности посебне заштите породице.

Жалбени наводи тужене у суштини се свode на указивање да битна чињеница самохраног родитеља није утврђена на основу правно ваљаних доказа износећи тумачење да се ова чињеница, у смислу одредбе чл. 77. Породичног закона, може утврђивати само на основу одлуке суда. Међутим, овај суд наводи да је релевантан стварни, реални статус тужиље који је постојао у време престанка радног односа, а што се утврђује из потврде Центра за социјални рад и других писмених доказа, решења о разводу брака, које је тужена имала још у току поступка давања отказа Уговора о раду, као и исказа сведока. Центар за социјални рад је издао уверење о чињеницама о којима води службену евиденцију, што је назначено и у самом уверењу и такво уверење у смислу одредбе чл. 161. Закона о општем управном поступку има значај јавне исправе. Осим тога, терет доказивања чињеница које образују основ за отказ уговора о раду и оправданост отказа, обавеза је послодавца. С тим у вези, доказивање чињенице да су у уверењу неистинито утврђене чињенице и да су испуњени услови за примену одредбе чл. 38. Посебног колективног уговора и да је одлука о престанку радног односа донета у складу са Законом о раду и посебним колективним уговором, тужена није доставила, нити предложила доказе. С друге стране, тужила је у прилог својих навода не само у поступку код послодавца, него и у поступку пред првостепеним судом, предлагала и достављала доказе које је првостепени суд правилно ценио и прихватио, а ради утврђивања релевантне чињенице у смислу чл. 38. Посебног колективног уговора, у вези чл. 77. Породичног закона, да тужилји као запосленом самохраном родитељу радни однос не може престати.

(Пресуда Основног суда у Нишу 7П1.609/15 од 22.09.2015. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 9Гж1.245/16 од 04.02.2016. године)

***Сентенцу приредила: Тања Ристић,
судија Апелационог суда у Нишу***

**ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У СПОРУ
ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА
НА ОСНОВУ НЕЗАКОНИТЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ
(чл. 164. Закона о раду)**

У спору за накнаду штете директору у виду изгубљене зараде и других права из радног односа због незаконитог разрешења, искључиво је послодавац пасивно легитимисан.

Из образложења:

Првостепеном пресудом, одбијен је тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавезе тужена да тужиоцу на име накнаде материјалне штете због неисплаћене зараде за период од 21.06.2012. године до 06.08.2012. године, услед незаконитог разрешења пре истека мандата са функције ВД директора Апотеке на име неисплаћене зараде за јун, јул и август месец 2012. године исплати месечне износе са законском затезном каматом по месечном доспећу, као и да обрачуна и уплати доприносе на зараде по важећим стопама у тренутку исплате надлежном Фонду ПИО.

Према утврђеном чињеничном стању, решењем СО од 06.02.2012. године, тужилац је именован за в.д. директора Апотеке, са мандатом у трајању до 6 месеци, на основу ког решења је тужилац закључио Уговор о раду од 09.02.2012. године, и засновао радни однос на одређено време најдуже до 6 месеци. Решењем о разрешењу од 20.06.2012. године, СО је тужиоца разрешила дужности в.д. директора због истека мандата, а Решењем о отказу уговора о раду тужиоцу је отказан уговор о раду на одређено време због разрешења са радног места вршиоца дужности директора Апотеке од стране Скупштине општине, услед истека мандата. Пресудом Вишег суда у Врању од 15.11.2012. године, наведено решење о разрешењу тужиоца је поништено као незаконито, а пресуда је потврђена пресудом Апелационог суда у Нишу од 06.03.2013. године. Висина штете због неисплаћене зараде за спорни период утврђена је на основу вештачења вештака економско финансијске струке.

Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени суд применио материјално право када је одбио тужбени захтев тужиоца дајући основане разлоге које у свему прихвата и овај суд.

Наиме, стварну легитимацију у спору представља материјално правни однос странке према предмету спора. Тужилац је активно легитимисан ако

је он носилац права које је предмет спора, а тужени је пасивно легитимисан ако на њему лежи обавеза која одговара том праву. О стварној легитимацији суд води рачуна и по службеној дужности, осим у случају када тужени призна тужбени захтев, јер стварна легитимација зависи од материјалног права које се примењује на одређено чињенично стање.

Одредбом чл. 154. ст. 1. Закона о облигационим односима прописано је ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити уколико не докаже да је штета настала без његове кривице.

Одредбом чл. 164. Закона о раду, прописано је да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом. Порекло штете у смислу наведене одредбе може да се огледа како у повреди здравља самог запосленог тако и у повреди права запосленог, када послодавац донесе одлуку или предузме радњу која није у складу са законом или општим актом, односно ако донесе незаконит акт у вези са радно правним статусом запосленог. Основ одговорности послодавца је тада незаконита одлука која је поништена правноснажном судском одлуком.

У конкретном случају, тужилац потражује накнаду штете у виду изгубљене зараде и других права из радног односа, тако да је у овом спору искључиво послодавац пасивно легитимисан и само он може бити тужен без обзира на узрок и разлог доношења решења о отказу уговора о раду, јер у коначном штета се огледа у губитку права из радног односа због доношења решења о отказу уговора о раду. Осим тога, неспорна је чињеница да тужилац против решења којим је тужиоцу отказан уговор о раду на одређено време због разрешења са радног места вршиоца дужности директора од стране Скупштине општине услед истека мандата, није водио спор и то решење у судском поступку није поништено, а што би био основ одговорности послодавца.

(Пресуда Основног суда у Бујановцу П.115/15 од 09.04.2015. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 9Гж1.2238/15 од 24.09.2015. године)

***Сентенцу приредила: Тања Ристић,
судија Апелационог суда у Нишу***

РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

(чл. 126. ст. 1. Закона о социјалној заштити у вези

чл. 175. ст. 1. тач. 2. Закона о раду)

Нису испуњени услови за разрешење директора установе пре истека мандата због испуњења услова за престанак радног односа у погледу година живота и стажа осигурања прописаних одредбом чл. 175. ст. 1. тач. 2. Закона о раду, уколико је директор са својим послодавцем постигао споразум о продужењу радног века до истека мандата.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, решењем Скупштине Општине од 20.10.2010. године, тужилац је именован на место директора Центра за социјални рад. На основу овог решења, дана 10.01.2011. године, закључен је уговор о раду на неодређено време са тужиоцем на радном месту директора Центра за социјални рад. Тужилац је дана 24.08.2013. године навршио 65 година живота. На седници управног одбора Центра за социјални рад дана 04.07.2013. године, постигнута је сагласност да се са тужиоцем закључи споразум о продужењу радног односа до краја његовог мандата до 20.12.2014. године. Такав споразум је и сачињен дана 10.07.2013. године, који је достављен Скупштини Општине дана 17.09.2013. године. Скупштина Општине је 18.09.2013. године одржала седницу, на чијем дневном реду је био и предлог решења о разрешењу тужиоца са дужности директора Центра за социјални рад. На тој седници је са 26 гласова “за” донета одлука да се донесе решење о разрешењу тужиоца. Решење је донето 18.09.2013. године, а на основу чл. 126. ст. 1. тач. 6. Закона о социјалној заштити и чл. 175. Закона о раду. Седници Скупштине општине претходила је седница Општинског већа која је одржана 13.09.2013. године. На седници је усвојен нацрт решења о разрешењу тужиоца већином гласова и нацрт је упућен Скупштини Општине као предлог одлуке о разрешењу тужиоца са места директора.

Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени суд применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца и поништио оспорено решење, дајући основане разлоге које у свему прихвата и овај суд.

По схватању овог суда, разлози за разрешење тужиоца са функције директора пре истека времена на које је био изабран, могу да буду засновани

искључиво на разлозима за разрешење, предвиђеним одредбама Закона о социјалној заштити и Статута Центра за социјални рад.

Из образложења побијаног решења произилази да је исто донето на основу чл. 126. Закона о социјалној заштити ст. 1. тач.6. и чл. 175. ст. 1. тач. 2. Закона о раду.

Одредбом чл. 126. ст. 1. тач. 6. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС” бр.24/11), прописано је, оснивач центра за социјални рад решиће директора Центра за социјални рад пре истека мандата из других разлога утврђених законом или статутом центра за социјални рад.

Одредбом чл. 175. ст. 1. тач. 2. Закона о раду прописано је, да радни однос престаје кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени другачије не споразумеју. Према наведеној одредби, навршење 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања су позитивни услови за примену овог основа престанка радног односа, али постоји један негативан услов, а то је да радни век не буде продужен. Ако је до продужења радног века дошло, примена овог основа се одлаже до истека продуженог радног века.

У конкретном случају, тужилац је разрешен дужности директора Центра за социјални рад, због тога што је дана 24.08.2013. године навршио 65 година живота и испунио услов у погледу стажа осигурања, што је констатовано у решењу, међутим, с обзиром да су Центар за социјални рад и тужилац закључили Споразум на основу чл. 175. ст. 1. тач. 2. Закона о раду о продужењу радног односа и након навршених 65 година живота, односно до истека мандата директора, произилази да нису били испуњени услови за доношење оспореног решења о разрешењу директора из наведеног разлога.

Тужена у жалби истиче, да је првостепени суд погрешно и непотпуно утврдио чињенично стање, јер није имао у виду да споразум којим је тужиоцу продужен радни однос није пуноважан, с обзиром да на записнику о споразуму не постоји печат Центра за социјални рад, као и да Управни одбор Центра за социјални рад није био прописно састављен јер је бројао 3 члана, а не 5 како то прописује закон у одредби чл. 123. ст. 2. Закона о социјалној заштити, те да је једном члану Управног одбора истекао мандат. Међутим, изнети жалбени наводи су без утицаја на другачију одлуку у овој правној ствари, с обзиром да наведени споразум није стављен ван снаге, оспораван нити

поништаван у законом прописаном поступку, већ је Управни одбор Центра за социјални рад, на седници одржаној дана 27.09.2013. године, након што је Скупштина општине донела решење о разрешењу тужиоца, на основу те одлуке, донео Одлуку о раскиду споразума од 10.07.2013. године, у којој је наведено да се раскида наведени споразум и да престају сва права обавезе из овог споразума, на који начин је призната његова правна важност и дејство до раскида.

(Пресуда Вишег суда у Пироту П.2/15 од 31.03.2015. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 9Гж1.708/15 од 10.09.2015. године)

***Сентенцу приредила: Тања Ристић,
судија Апелационог суда у Нишу***

ПРОЦЕСНО ПРАВО

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

(члан 45. Закона о парничном поступку и чл. 3. и 24.
Закона о пребивалишту и боравишту грађана)

Место пребивалишта, односно боравишта не може одредити сама странка и на истом засновати месну надлежност суда, јер јој највише одговора да тај суд поступа, из разлога економичности, целисходности и сл., већ као пребивалиште, односно боравиште, може бити утврђено само место које је код надлежног орана МУП-а евидентирано као такво.

Из образложења:

Тужилац је поднео тужбу Вишем суду у Н. ради утврђења дискриминације. По приговору тужене, Виши суд у Н. се огласио месно ненадлежним и позвао тужиоца да се у року од 3 дана изјасни, коме од надлежних судова жели да предмет буде уступљен.

Тужилац је уложио жалбу на донето решење, указујући на битну повреду одредба парничног поступка у вези примене чл. 46. и 56. ЗПП-а.

Одредбом чл. 46. ЗПП-а прописано је, да је за суђење у споровима због повреде права личности, поред суда опште месне надлежности, надлежан и суд на чијем подручју је штетна радња извршена или суд на чијем подручју тужилац има пребивалиште, односно боравиште. Чланом 56 ЗПП-а прописано је, да је за суђење у споровима против Републике Србије из односа са војним јединицама, односно војним установама, искључиво надлежан суд на чијем се подручју налази седиште команде војне јединице, односно установе.

Спор који се води за заштиту од дискриминације представља спор због повреде права личности, па је поред суда опште месне надлежности, надлежан и суд на чијем подручју је штетна радња извршена, односно суд на чијем подручју

тужилац има пребивалиште, односно боравиште. Имајући у виду да је суд опште месне надлежности, суд према седишту тужене, тј. Виши суд у Б., а да је пребивалиште тужиоца на подручју Вишег суда у К.М., како то правилно утврђује првостепени суд, то је тужба поднета месно ненадлежном, Вишем суду у Н.

Неосновано тужилац указује на погрешну примену чл. 46. ЗПП-а и да је суд требало да тужиоцу омогући да сам одреди, који је суд “суд његовог места пребивалишта, односно боравишта” и да то буде суд који је тужиоцу најдоступнији, односно најцелисходнији, а да је за тужиоца то суд у Нишу.

Овог стога, што је чл. 3. ст. 1. тач. 2. и 3. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (Службени гласник РС бр. 87/2011) прописано, да је пребивалиште место у коме се грађанин настанио са намером да у њему стално живи, односно место у коме се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност с местом у коме се настанио, а боравиште је место у коме грађанин привремено борави ван места свог пребивалишта дуже од 90 дана. Чланом 24. ст. 1. истог закона је прописано, да се о месту пребивалишта, боравишта и привременог боравка у иностранству, евиденција води код министарства надлежног за унутрашње послове, у електронском облику, из чега произилази да се место пребивалишта, односно боравишта не може одређивати према субјективном ставу тужиоца, шта је за њега повољније, већ према евиденцији надлежног органа.

(Решење Апелационог суда у Нишу Гж бр. 4371/17 од 12.09.2017. год.)

*Приредила: Зорица Стошић,
судија Апелационог суда у Нишу*

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА

Када је тужбени захтев прекорачен тако што је одлучено о другоме, а не о ономе што је тужбом тражено, другостепени суд ће да укине првостепену пресуду и предмет врати на поновно суђење, без обзира на то што је првостепена пресуда већ била укинута.

Из образложења:

Првостепени суд је у ставу другом изреке побијане пресуде прекорачио тужбени захтев, тако што је одлучио о другоме, а не о ономе што је тужбеним

захтевом тражено, јер је тужилац писаним поднеском од 09.04.2015. године прецизирао тужбени захтев у односу на тражену ренту, па је поред основног поставио и евентуални тужбени захтев којим је тражио да му суд досуди укупан износ од 825.000,00 динара на име накнаде штете (на име изгубљене зараде до тренутка доношења пресуде), са законском затезном каматом почев од дана пресуђења до исплате, а од пресуђења па убудуће на име месечне ренте износ од 15.000,00 динара са припадајућом каматом, о чему првостепени суд није одлучио, већ је тужиоцу досудио ренту у траженом износу од 15.000,00 динара месечно са припадајућом каматом, почев од 07.11.2011. године, као дана утужења па убудуће, док је одбио захтев за исплату новчане ренте за период од 01.02.2011. године до 07.11.2011. године као неоснован.

Штета коју оштећени трпи због губитка зараде састоји се из два дела, а то је изгубљена зарада до тренутка доношења пресуде, која је у том тренутку позната и досуђује се у јединственом износу, док други део штете који ће наступити у будућности још није реализован и није извесна његова висина, па се накнада досуђује у облику месечне ренте. Дакле, рента је будућа накнада штете, која се утврђује у висини на дан пресуђења и досуђује за убудуће, док штета која је наступила до пресуђења нема карактер ренте, већ накнаде штете због изгубљене зараде услед неспособности за рад.

Како је првостепени суд досуђивањем месечне ренте ретроактивно, почев од дана подношења тужбе, прекорачио тужбени захтев јер није одлучио о постављеном евентуалном тужбеном захтеву тужиоца за накнаду штете опредељене у јединственом износу, у смислу чл. 197 ст. 2 и 3 ЗПП, то је првостепена пресуда у ставу другом изреке морала бити укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање, сходно чл. 393. ст. 2. и 3. ЗПП.

Наиме, одредбом чл. 393. ст. 2. ЗПП прописано је да ако је првостепеном пресудом прекорачен тужбени захтев тако што је одлучено о другоме, а не о ономе што је тужбом тражено, другостепени суд ће да укине првостепену пресуду и предмет врати на поновно суђење, а ставом 3 истог члана, да се у случају из ст. 2. не примењује одредба чл. 383. ст. 4. истог закона, којим је прописано отварање расправе пред другостепеним судом у ситуацијама када је првостепена пресуда већ једанпут била укидана.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж. 2417/15 од 02.03.2016. год.)

Аутор сентенце: Судија Марина Милановић

ПРЕИНАЧЕЊЕ ТУЖБЕ

Првостепени суд је дужан да, сходно одредби чл. 199. ЗПП, о преиначењу тужбе одлучи решењем којим се допушта или одбија преиначење тужбе, против ког није дозвољена посебна жалба, а које спада у решења којима се управља поступком.

Из образложења:

Побијана пресуда у делу изреке под ставом два захваћена је битном поворедом одредаба парничног поступка из чл. 374. ст. 1. ЗПП, јер првостепени суд није правилно применио одредбу чл. 199. ЗПП.

Ово са разлога што су основани жалбени наводи тужиоца да је првостепени суд пропустио да о преиначењу тужбеног захтева од 05.09.2014. године одлучи благовремено на рочишту, већ је та одлука садржана у изреци пресуде, на који начин је суд погрешно применио правила о поступку на штету тужиоца.

Диспозиција је парничне странке да ли ће поднети тужбу са једним или више захтева, да ли ће тужбени захтев преиначити тако што ће променити истовестност захтева, повећати постојећи или истаћи други уз постојећи, а обавеза првостепеног суда је, сходно одредби чл. 199. ЗПП, да о таквим захтевима одлучи решењем којим се допушта или одбија преиначење тужбе, против ког није дозвољена посебна жалба, а које спада у решења којим се управља поступком, па да након тога мериторно одлучи. Такође, првостепени суд може да дозволи преиначење и када се тужени томе противи, ако сматра да би то било целисходно за коначно решење односа међу странкама и ако оцени да поступак по преиначеној тужби неће знатно да продужи трајање парнице, као у конкретном случају.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 21Гж. 895/15 од 16.09.2015. год.)

Аутор сентенце: Судија Марина Милановић

**СЕОСКИ ВОДОВОД ЈЕ ЈАВНО ВОДНО
ДОБРО ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА**
(члан 5. став 1. и 2. и 138. став 1. Закона о водама)

Не спада у судску надлежност одлучивање о праву тужилаца за прикључење на сеоски водовод јер се не ради о грађанско правном спору проистеклом из личних, породичних, радних, привредних, имовинско-правних и других грађанскоправних односа, већ се ради о управном поступку, односно о појединачном захтеву тужилаца о којима одлуку доноси управни орган, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе

Из образложења:

Према чињеничном стању на коме је одлуку засновао првостепени суд водоводна мрежа за снабдевање мештана села А изграђена је 1979. год. почев од извора “радевачка чесма”, од југа па у правцу севера до базена који је постављен на парцели власника пок. Б.Б., док је на релацији почев од извора до резервоара постављена рачва која посебно служи за довод воде до базена, а које право припада туженој ОШ “В.В.” из Г., истурено одељење у Д. по основу куповине од Ђ.Ђ. као власника парцеле на којој је сопственим средствима изградио приватну шахту преко које се спроводи вода до базе-на (резервоара). Од резервоара за воду по основу природног пада водом се снабдевају ОШ “В.В.” Г., истурено одељење у Д., амбуланта и правни следбеник пок. Ђ.Ђ., Е.Е. Правноснажним и извршним решењем Основног суда у Лебану П бр. 3508/10 од 23.04.2010. год. утврђено је да су овде тужиоци сметали ОШ “В.В.” из Г., тако што су дана 27.07.2009. год. пресекли водоводну цев и на исту прикључили своја домаћинства. У извршном поступку овде тужиоци су искључени са предметне водоводне мреже.

Како је власник спорног водовода Општина Г., те како се истим принципом природног пада у село Д., Општина Г., спроводи вода са планинског изворишта са такозване “радевачке чесме”, а која вода представља добро од општег интереса и у државној је својини, те како су мештани у време изградње водовода 1979. год. одвајали средства у виду општинског са-мо-доприноса и својим радом, неспорно допринели изградњи истог, то Апелациони суд налази да предметни водовод представља јавно водно добро, на коме се сагласно одредби члана 5 став 5 Закона о водама може стећи право коришћења под условима које утврђује Закон о водама.

Тужиоци током поступка нису пружили доказе у смислу одредбе члана 220. и 223 Закона о парничном поступку, да су лично учествовали у изградњи предметног водовода, нити да су уложили одређена материјална средства у изградњи истог, а имајући у виду наводе тужених да су тужиоци помагали искључиво школи као кориснику, то Апелациони суд налази да се у конкретном случају не може применити Закон о основама својинскоправних односа, како то наводи првостепени суд у образложењу побијане одлуке, већ да има места примени Закона о водама као посебног закона којима је регулисан правни статус вода и управљање водама.

Како према одредби члана 138 став 1 Закона о водама одобрење за прикључак издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно надлежни орган општине Г., то се у конкретном случају примењује Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и “Сл. гласник РС”, бр. 30/2010), а према ком закону, сагласно одредби члана 1 поступају државни органи кад у управним стварима, непосредно примењујући прописе, решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке, као и кад обављају друге послове утврђене овим законом. На основу наведеног Апелациони суд налази да одлучивање о праву тужилаца за прикључење на спорни сеоски водовод не спада у судску надлежност јер се не ради о грађанско правном спору проистеклом из личних, породичних, радних, привредних, имовинскоправних и других грађанскоправних односа, већ се ради о управном поступку, односно о појединачном захтеву тужилаца о којима одлуку доноси управни орган, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, у конкретном случају Општине Лебане.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 2361/2016 од 15.12.2016. год.)

Виши судијски сарадник Оливера Алексић Цветковић)

НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИГОВОРУ ИЗЈАВЉЕНОМ ПРОТИВ РЕШЕЊА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

За поступање по приговору извршног дужника изјављеног на решење јавног извршитеља стварно је надлежан основни суд.

Из образложења:

Према стању у списима, основни суд огласио се стварно ненадлежним за поступање по приговору извршног дужника изјављеног против решења јавног извршитеља и спис предмета уступио је вишем суду, као стварно и месно надлежном суду. Виши суд није прихватио стварну надлежност, већ је уз допис спис предмета доставио апелационом суду, ради решавања сукоба надлежности.

Одредбом чл. 148. Закона о извршењу и обезбеђењу (“Сл. гласник РС”, бр. 106/2015 и 106/2016 - аутентично тумачење) прописано је да странка и учесник у поступку могу захтевати да се отклоне неправилности које су настале у току и поводом спровођења извршења. Неправилности могу да се састоје од недоношења одлуке и предузимања или пропуштања радње. Захтев за отклањање неправилности може да се поднесе у року од 15 дана од дана када је одлука требало да буде донета или радња предузета, односно од када је радњу требало предузети. Захтев се подноси суду или јавном извршитељу, зависно од тога ко спроводи извршење, који је дужан да о њему одлучи у року од 5 дана. Овакав захтев нема суспензивно дејство и о њему се одлучује решењем. Уколико о захтеву не буде одлучено у року од 5 дана од дана пријема или захтев буде одбачен или одбијен, дозвољено је изјавити приговор. Тумачењем члана 86. става 2. Закона о извршењу и обезбеђењу закључује се да о приговору одлучује веће суда, а о жалби другостепени суд.

Како је против решења извршитеља којим су одбијени захтеви за отклањање неправилности, сходно наведеном чл. 148. Закона о извршењу и обезбеђењу дозвољен приговор, а за одлучивање по приговору у смислу чл. 24. ст. 3. и чл. 86. ст. 2. Закона о извршењу и обезбеђењу, надлежан је основни суд па је из изнетих разлога, а на основу чл. 22. ст. 1. Закона о парничном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС и 55/2014) одлучено као у изреци решења.

(Решење Апелационог суда у Нишу Р бр. 55/2017 од 25.07.2017. године)

Аутор сентенце: Јадранка Митровски, судија Апелационог суда у Нишу

ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ

О признању стране одлуке као главном предмету одлучује се решењем, којим се одлука може само признати, или се може одбити њено признање. Решење којим се страна одлука признаје деклараторне је природе и сходно томе страна одлука која је призната производи дејство од момента доношења, а не од момента признања. Страна одлука се решењем о признању не може мењати нити допуњавати.

Из образложења:

Првостепеном суду поднет је предлог за признање стране судске одлуке којом је одобрен споразум о повери и издржавању малолетне деце, а о коме је исти одлучио решењем. Предлагач је, преко пуномоћника, благовремено изјавио жалбу, побијајући поменуто решење због битне повреде одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, а за коју је другостепени суд нашао да је допуштена и основана.

Наиме, у конкретној правној ствари првостепени суд је делимично признао страну судску одлуку, налазећи да су се само за део стране судске одлуке стекли услови за признање. Такође, у делу у коме је признао страну одлуку исту је и допунио, без ваљаног правног утемељења.

Консултације релевантног законодавства налажу закључак да Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља не даје могућност да се страна судска одлука делимично призна, а нарочито не да се улази у меритум стране судске одлуке и иста преиначује или допуњује.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж бр. 1371/17 од 28.03.2017. године)

Аутор сентенце: Јадранка Митровски судија Апелационог суда у Нишу



Paragraf Lex iOS aplikacija



Preuzmite na **AppStore**



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

www.paragraf.rs